

DIRITTO PRIVATO

Giurisprudenza a.s. 2021/2022

CAPITOLO I

LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO E L'INTERPRETAZIONE

DIRITTO: strumento di organizzazione di stabili comunità di persone.

Possiamo identificare due punti di vista storici:

- **Giusnaturalismo:** che ha come concezione base il **diritto naturale**, ovvero che la natura della cose esprime le regole cui gli uomini devono attenersi
- **Giuspositivismo:** che ha come concezione base il **diritto positivo**, ovvero il diritto prodotto dal potere costituito, da autorità legittimate a produrlo e a farlo rispettare.
Questo appena citato è il **diritto vigente**, ovvero le normative vigenti negli stati nazionali e il diritto classificato come fenomeno concreto nello spazio e nel tempo.

Accanto al diritto vigente sta il **diritto opzionale**, che è affidato alla libera scelta di applicarlo e consolida modelli di comportamento largamente osservati (come le prassi si commercio internazionale).

Chi si occupa dello studio del diritto vigente è la **dogmatica giuridica**, che appunto studia un concreto diritto attuale, operante in uno spazio e tempo determinati, prodotto da autorità a cui il diritto stesso riconosce il potere normativo (tale è appunto lo studio del diritto privato italiano).

La funzione della dogmatica è quella di rendere logico e coerente l'ordinamento stratificato di cui ci serviamo.

Parametri su cui opera la dogmatica:

- **Inerenza:** capire quale norma prendere in considerazione per ricostruire il profilo del nostro ordinamento (*le norme del codice tedesco non sono inerenti al nostro campo di applicazione*).
- **Ricognizione:** per dare una struttura organica del complesso normativo in quanto non tutte le norme hanno lo stesso valore.

Un ordinamento si occupa di tutti i fatti che hanno rilevanza economica, politica e sociale che si verificano al suo interno, quindi di **fatti giuridici** della più varia natura. Da questa premessa deriva la distinzione tra:

- **DIRITTO PRIVATO:** Sistema artificiale preordinato alla soddisfazione di interessi privati, antecedente al diritto pubblico e comprende diverse materie, come il **diritto civile**, il **diritto commerciale**, il **diritto del lavoro**, il **diritto dei consumatori**...
- **DIRITTO PUBBLICO:** Ha come oggetto interessi di rilevanza pubblica e va per esempio ad individuare i pubblici poteri, la struttura delle pubbliche amministrazioni...

Il processo di contaminazione tra diritto privato e diritto pubblico prende il nome di **diritto comune**, dove il diritto privato ha prestato al diritto pubblico i propri strumenti e viceversa (es. Interesse legittimo).

Fonte del diritto: fatto umano riconosciuto idoneo a produrre diritto.

La parola diritto è qui usata esclusivamente per indicare il **diritto oggettivo**, ovvero l'insieme delle norme giuridiche, ma la parola diritto di può usare anche per indicare il **diritto soggettivo**, ovvero quando una norma oggettiva attribuisce a un soggetto il potere giuridico che gli permette di realizzare un suo interesse.

Le fonti del diritto, ancora prima di produrre diritto, sono prodotte e regolate dal diritto stesso.

Inoltre in ogni ordinamento è rilevante la sua **effettività**, ovvero il fatto che il diritto oggettivo vige finché e se è globalmente osservato.

L'art 117 della nostra costituzione sancisce che l'ordinamento giuridico italiano vigente deriva non solo da fonti statali, ma anche da **fonti esterne o interne allo stato** (come le regioni o le formazioni sociali sancite dall'art 2 Cost, che possono produrre regole di comportamento).

Il criterio fondamentale per determinare i rapporti tra le diverse fonti del diritto è il **criterio gerarchico**.

L'art 1 delle preleggi delinea il sistema delle fonti in questo modo:

1. LE LEGGI
2. I REGOLAMENTI
3. LE NORME CORPORATIVE
4. GLI USI

Sicuramente un sistema poco attuale.

Considerando l'insieme si può tracciare secondo ordine gerarchico il seguente sistema "piramidale" di fonti del diritto:

NORMATIVA PRIMARIA

1. **COSTITUZIONE**: esprime i VALORI FONDAMENTALI dell'ordinamento
TRATTATI UE
2. **NORME COMUNITARIE (direttive, regolamenti)**
3. **LEGGI ORDINARIE** (tra le quali si colloca il CODICE CIVILE), **DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI, LEGGI REGIONALI**

NORMATIVA SECONDARIA

4. **REGOLAMENTI**
5. **USI E CONSUETUDINI**

Per il diritto privato hanno sostanzialmente rilievo: Costituzione, codice civile, Trattati UE, i quali dettano principi fondamentali per molti rapporti privati.

Le fonti di cognizione: documenti che rendono noto e inconvertibile l'esatto testo normativo prodotto dalle diverse fonti (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta ufficiale dell'UE, Raccolta ufficiale degli atti normativi).

Norma giuridica:

- Sono **regole** che prevedono un tipo di **fatto (fattispecie)** e statuiscono quali **poteri o doveri (effetto giuridico)** siano attribuiti in quel caso ai soggetti coinvolti.
- Possono essere **principi** quando esprimono una direttiva senza indicare la fattispecie
- Possono essere **clausole generali** quando esprimono uno standard da utilizzare in concorso con le regole (*correttezza nel rapporto obbligatorio*)

Caratteristiche delle norme:

- **GENERALITA'**: non considerano un caso singolo
- **ASTRATTEZZA**: non considerano rapporti concreti

La norma è ricavata dall'interpretazione di una **disposizione**, che è sostanzialmente una proposizione prescrittiva.

OBBLIGATORIETA' NORME GIURIDICHE:

La norma è obbligatoria in quanto giustifica e rende legittimo in caso di inosservanza l'uso della forza in funzione di **sanzione**-CARATTERE DELLA COERCIBILITA'

Sotto questo aspetto possiamo distinguere:

- Norme imperative: quando non ammettono violazione. L'insieme delle norme imperative in un ordinamento non derogabili costituisce l'**ordine pubblico**.
- Diritto dispositivo: insieme delle norme derogabili, ovvero che ammettono il **patto contrario** (quando la disciplina sia modificabile dalle parti, quindi derogano ad essa)
- Norme suppletive: disposizioni intese a disciplinare certi aspetti del rapporto per l'ipotesi in cui le parti non si siano curate di farlo.

L'OBBLIGATORIETA' DELLA NORME VIVE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, in quanto entrano in vigore con la pubblicazione sulla GU, trascorso il periodo di *vacatio legis*.

Questione dell'**efficacia retroattiva**:

- Proibita dalla Costituzione per le leggi penali
- Le leggi civili possono avere effetto retroattivo solo nei limiti del **principio di ragionevolezza** e tranne per i rapporti giuridici ormai del tutto estinti e sulle sentenze già passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge retroattiva.

LE ANTINOMIE

Antinomia=contrasto tra norme

Una premessa da sottolineare è che è possibile che l'incompatibilità si profili secondo il senso che si dà a una o all'altra disposizione (*sentenze di rigetto della corte costituzionale*).

Abbiamo diversi tipi di criteri di risoluzione delle antinomie:

- **Criterio gerarchico**: la norma superiore prevale su quella inferiore
- **Criterio di competenza**: La norma proveniente dalla fonte specificamente competente prevale sulla normativa di fonti non competenti.
- **Criterio di specialità**: si preferisce la norma speciale su quella avente carattere generale. E' il principio della *deroga*, ovvero che la norma generale deroga a quella speciale.
- **Criterio cronologico**: la norma posteriore prevale su quella anteriore.

IL CODICE CIVILE:

Il codice civile è una legge e ha 2 caratteristiche ben precise:

- Unificazione del diritto privato
- Da grande attenzione ai rapporti di natura patrimoniale

Breve excursus storico:

Negli anni 60 si è visto il fenomeno della **costituzionalizzazione del diritto privato**, quindi ha avuto luogo una reinterpretazione delle disposizioni del Codice Civile per renderle coerenti con i principi costituzionali.

Negli anni 90 due fattori hanno modificato il codice: una imponente produzione di leggi speciali e la penetrazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria.

Struttura: E' composto da 6 libri

- **LIBRO I: delle Persone e della Famiglia**
- **LIBRO II: delle Successioni**
- **LIBRO III: della Proprietà**
- **LIBRO IV: delle Obbligazioni** (all'interno troviamo il contratto)
- **LIBRO V: del Lavoro**
- **LIBRO VI: della Tutela dei diritti**

LE CARTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE:

- **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE**: ha lo stesso valore giuridico dei trattati e lo stesso rango costituzionale
- **CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (CEDU)**: E' invece di rango subordinato rispetto alla costituzione, infatti l'incompatibilità tra norme interne e CEDU giustifica il controllo di legittimità costituzionale per violazione dell'art 117.

Inizialmente i diritti fondamentali garantiti dalle carte dei diritti erano pensati prevalentemente per il diritto pubblico, quindi *come* i diritti fondamentali operano nei rapporti privati?

Abbiamo due tesi al riguardo:

- Una prima tesi è quella dell'**efficacia indiretta dei diritti fondamentali nel diritto privato**, ossia al ricorso delle clausole generali (*buona fede, correttezza*)
- Una seconda tesi riguarda un'**efficacia orizzontale diretta**, che consentirebbe al privato di vantare i suoi diritti fondamentali nei confronti di un altro privato.

Sicuramente l'applicazione concreta dei diritti fondamentali tra privati richiede adattamenti, infatti quando i diritti siano coinvolti da entrambe le parti occorre un bilanciamento.

L'INTERPRETAZIONE:

Come abbiamo già dette le fonti del diritto producono disposizioni, che per applicarle occorre ricavarne il preciso significato, cioè le norme. Questo è il compito dell'interpretazione o **ermeneutica**.

Non tutti gli ordinamenti possiedono regole legali sull'interpretazioni, o solo per alcuni casi; quando tali norme esistono l'interpretazione si dice che è **legalmente guidata** e il suo risultato è corretto solo se il procedimento seguito è legalmente corretto.

Se non sussistono regole legali sull'interpretazione è giusta l'**interpretazione corretta**, ovvero il risultato interpretativo che ha a suo sostegno i migliori argomenti interpretativi.

Nel sistema italiano esistono norme giuridiche sull'interpretazione della legge e dei contratti, non sull'interpretazione di altri atti o fatti.

Art 12 PRELEGGI: parla dell'interpretazione della legge e prescrive di non dare altro senso alla legge se non quello che risulta

- a) Dal significato delle parole, secondo la loro connessione (**interpretazione letterale**)
- b) Dall'intenzione del legislatore, che si può guardare come le ragioni stabili che spiegano e giustificano la funzione della norma, ovvero la sua *ratio legis* (**interpretazione teleologica**)

Abbiamo 4 categorie di interpreti del diritto soggettivo e sono: **la dottrina**, che effettua uno studio scientifico della legislazione e fa proposte interpretative, **la giurisprudenza**, che per applicare la regola al caso i giudici devono individuare il corretto senso delle disposizioni, **il legislatore**, il quale può tornare su precedenti atti normativi e fissare con la propria autorità quale sia il loro corretto significato, e infine la **pubblica amministrazione**.

Non è sempre vero che il legislatore formuli bene la disposizione e con essa impartisca la norma che intendeva produrre, così abbiamo altri tipi di interpretazione:

- **Interpretazione estensiva:** amplia il significato di una parola nella disposizione
- **Interpretazione restrittiva:** lo restringe
- **Interpretazione sistematica:** attribuisce un senso a una disposizione creando collegamenti con le altre disposizioni che regolano quella fattispecie

In ogni ordinamento possono presentarsi delle fattispecie concrete giuridicamente rilevanti, ma che non trovano previsione legale neppure a seguito dell'interpretazione, in questo caso si parla di **LACUNE**.

Il criterio di risoluzione delle lacune fornito dall'art 12 delle preleggi è l'**analogia**, che si può suddividere in:

- **Analogia legis:** cercare la regola nella disposizione che disciplina casi affini o materie analoghe
- **Analogia iuris:** cercare la soluzione nei principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato.

L'EFFICACIA DELLE NORME NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO A CARATTERE TRANSNAZIONALE

I rapporti di diritto privato per loro natura scavalcano le frontiere e si espandono senza limiti nel mondo globalizzato, da qui la necessità di **norme di diritto internazionale privato**.

La normativa in materia è la L. 218/1995, la quale oltre a disporre regole specifiche fa anche salve delle convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia che definiscono la normativa regolatrice di vari tipi di rapporti.

Ovviamente sussiste un **limite all'ordine pubblico**, in quanto le norme italiane di ordine pubblico sono norme di necessaria applicazione, che prevalgono sulle disposizioni di diritto privato internazionale.

La normativa vigente individua caso per caso la legge applicabile ai diversi tipi di rapporti in relazioni a vari criteri di collegamento. Esempi:

- CAPACITA' E DIRITTI PERSONALISSIMI PERSONE FISICHE: rinvio alla legge nazionale
- ENTI COSTITUITI COME PERSONE GIURIDICHE O NON RICONOSCIUTE: rinvio alla legge dello stato di costituzione
- SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTRE: rinvio alla legge nazionale del *de cuius*
- RESPONSABILITA' FATTO ILLECITO: rinvio alla legge dello stato in cui si è verificato l'atto

Particolarmente rilevante è la **Convenzione di Roma** nel campo delle obbligazioni contrattuali e che riguarda il principio per il quale il contratto sia regolato dalla legge eventualmente scelta dalle parti e in mancanza di scelta si applica la legge del Paese con il quale il contratto ha il collegamento più stretto (ad es. la legge del luogo del bene).

Per quanto riguarda la **giurisdizione** la regola basilare è che sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto sia residente o domiciliato in Italia.

CAPITOLO II

L'AUTONOMIA NEGOZIALE E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

L'AUTONOMIA PRIVATA

L'autonomia privata è il potere del singolo e dei gruppi organizzati di autoregolamentare i propri interessi mediante **negozi giuridici** e rappresenta uno dei modi principali di esplicazione della vita di relazione, perché con l'autonomia privata il singolo può intrattenere con gli altri soggetti **forme vincolanti di cooperazione** e di **scambio che si basano sul consenso reciproco**.

L'autonomia deve sottostare al rispetto dei limiti e obblighi stabiliti dall'ordinamento.

Abbiamo due forme di autonomia privata:

- **AUTONOMIA PRIVATA NEGOZIALE:** ha maggiore ampiezza e comprende l'intera gamma dei **negozi giuridici**, ovvero dichiarazioni di volontà che si rivolgono al raggiungimento di uno scopo garantito dalla legge e che abbiano struttura unilaterali, bilaterale o plurilaterale e che abbiano contenuto patrimoniale o non.
L'autonomia privata negoziale ritrova una garanzia costituzionale nell'art 2, il quale tutela i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
- **AUTONOMIA PRIVATA CONTRATTUALE:** E' una specificazione della prima e si realizza solo tramite lo strumento del **contratto**, ovvero l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (**art 1321 c.c.**).
Essa compare nell'**art 1322 c.c.** dove vengono elencate la libertà di scegliere se e con chi concludere il contratto e definire il contenuto del medesimo e la libertà di perseguire i propri interessi ricorrendo a modelli contrattuali anche atipici (unico limite del contratto atipico è che deve essere volto a perseguire scopi leciti).
Inoltre l'autonomia contrattuale trova una garanzia implicita anche nell'**art 41 Cost** (libertà di iniziativa economica) e nell'**art 42 Cost** (tutela proprietà pubblica e privata).

Diversa è l'**autonomia collettiva** che è riconosciuta non solo al soggetto singolo ma anche agli enti e tende a regolare gli interessi della categoria professionale o sociale che essa rappresenta.

L'**art 39 Cost** attribuisce ai sindacati la legittimazione a stipulare **contratti collettivi** vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria a condizione che si sottopongano a controlli pubblici sulla democraticità del loro ordinamento.

I contratti collettivi rimangono comunque governati dal diritto comune per via della loro efficacia vincolante e **inderogabilità in pejus**, su cui si basa il rapporto tra contratti collettivi di lavoro e contratti individuali, ovvero che la fonte inferiore (contratto individuale) può derogare a quella superiore (CCNL) mai in senso sfavorevole (*in pejus*) ma solo in senso favorevole (*in melius*).

L'autonomia privata è collocata al livello più basso della struttura piramidale, ovvero nelle **norme concrete**, cioè quelle norme già applicate al singolo fatto che presuppongono quindi l'esistenza di norme astratte e che possono avere carattere **attuativo** (contratto a effetti istantanei) o **programmatico** (contratti-quadro).

Il rapporto tra autonomia privata e ordinamento giuridico varia a seconda del periodo storico.

Nello stato liberale l'autonomia privata era sottoposta a **limiti negativi di ordine pubblico** per non comprimere la libertà dei cittadini, mentre nello stato sociale troviamo dei **limiti positivi** agli atti negoziali.

L'**autonomia negoziale privata** è espressione di libertà che però incontra limiti nell'ordinamento:

- La libertà di compiere o meno l'atto di autonomia e di scegliere l'interlocutore trova un limite nell'art 2597 c.c., ovvero l'obbligo a contrarre del monopolista, e nell'art 1679 c.c., ovvero nell'obbligo di contrarre per il concessionario dei pubblici servizi di linea
- La libertà di compiere l'atto di autonomia personalmente o tramite un rappresentante volontario incontra un limite negli **atti personalissimi** (testamento).
- La libertà di determinare il contenuto dell'atto di autonomia incontra diversi limiti:
 - Art 1374 c.c.: l'autonomia delle parti incontra un limite nella legge
 - Obbligo di comportarsi secondo buona fede
 - Obbligo posto dalle **condizioni generali di contratto** (art 1341 c.c.): sono le clausole predisposte da un contraente per concludere un numero indefinito di contratti con lo stesso contenuto (contrattazione di massa), ed è richiesto che il predisponente mette l'altra parte nella condizione di poter conoscere queste clausole (es. le **clausole vessatorie** non hanno effetto se non sono approvate per iscritto).
- La libertà di inserire i c.d. **elementi accidentali** è attribuita ai singoli per consentire loro una migliore conformazione del contenuto negoziale ai motivi che li hanno spinti ad adottare l'atto di autonomia.
Il c.c. disciplina 3 figure, ossia la **condizione**, che è un avvenimento futuro e incerto dal quale si fa dipendere l'efficacia del negozio, il **termine**, che limita l'efficacia del negozio nel tempo, e il **modo**, che è un peso imposto ad un beneficiario di un atto gratuito (erede, donatario).
LIMITE: I c.d. **atti legittimi** (come il matrimonio) non tollerano l'apposizione di una condizione o termine.
- La libertà di forma trova un limite nella legge, la quale può prevedere la forma scritta (**ad substantiam**) a pena di nullità per esempio nel testamento, nei negozi astratti (cambiale), nei negozi aventi come oggetto beni immobili.
La legge o la volontà delle parti può prescrivere talora la forma scritta ai soli fini della prova dei fatti giuridici (**forma ad probationem**).

L'atto di autonomia è anche espressione di **autoresponsabilità**, ovvero ha forza di legge per il suo autore e può sciogliersi solo in virtù di **mutuo consenso** o cause ammesse dalla legge (art. 1372 comma 1 in materia di contratto).

FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO

Un **fatto giuridico** è un avvenimento o situazione che va a comporre la fattispecie di una norma, la quale riconduce la produzione di effetti giuridici.

UN FATTO E' GIURIDICO IN QUANTO RILEVANTE PER IL DIRITTO.

I fatti possono distinguersi in:

- **Fatti in senso stretto/naturali**: eventi naturali che non hanno la volontà dell'uomo
- **Fatti umani**: vi è la coscienza e la volontà del comportamento da parte dell'agente.

Sono **atti giuridici** i fatti giuridici umani caratterizzati dalla volontà del comportamento rilevante per l'ordinamento giuridico.

Quindi, TUTTI GLI ATTI GIURIDICI SONO FATTI GIURIDICI, MA NON TUTTI I FATTI GIURIDICI SONO ATTI GIURIDICI.

Gli atti giuridici si classificano così:

- **ATTI ILLECITI:** denominati come **fatti illeciti** dall'art 2043 c.c. e hanno l'effetto giuridico di far sorgere a carico del loro autore l'obbligazione di risarcire il danno causato ad un terzo e richiedono in capo all'autore la volontarietà della condotta, la sussistenza di dolo o colpa e la capacità di intendere e volere al momento dell'atto (art 2046).

ATTI LECITI: che si distinguono a loro volta in:

- **Atti reali:** come la costruzione di un edificio o la presa in possesso di una cosa
- **Atti dovuti:** come l'adempimento a una obbligazione
- **Dichiarazioni di scienza:** confessione
- **Dichiarazioni di volontà:** con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi (negozi giuridici).

- **ATTI RECETTIZI:** sono atti unilaterali che producono effetto solo nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario.

ATTI NON RECETTIZI: non sono indirizzati a una persona determinata quindi producono i loro effetti una volta resi pubblici (la promessa al pubblico).

Una categoria a parte sono i **NEGOZI GIURIDICI**, che sono **dichiarazioni di volontà o atto di autoregolamentazione dei propri interessi, di natura unilaterale, bilaterale o plurilaterale, rivolto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.**

Il prototipo di negozio nel diritto positivo italiano è il **CONTRATTO**, ovvero l'**accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico PATRIMONIALE (art. 1321 c.c.).**

ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO (Art 1325 in materia di contratto):

- **VOLONTÀ':** è il fulcro dell'autonomia privata. E' prevista la nullità dell'atto che non risulti voluto dal suo autore e l'annullabilità dell'atto per incapacità dell'autore o vizi della sua dichiarazione.

La volontà deve essere dichiarata e manifestata all'esterno. Non deve avere una determinata forma almeno che non lo prescriva la legge, quindi la manifestazione di volontà può anche avvenire per linguaggio orale/gesti e per silenzio (privo per regola generale di valore proprio salvo che la legge non preveda diversamente).

- **CAUSA:** nel codice civile se ne parla come **causa dell'obbligazione**, ovvero il titolo da cui l'obbligazione di origina e come **causa del contratto**, la cui mancanza o illiceità ne determina la nullità.

La causa è la **funzione economico-sociale** (questa accezione mette in risalto i limiti posti alla libertà negoziale) o la **funzione economico-individuale** (questa accezione mette in risalto l'agire libero dell'individuo per realizzare i propri interessi) dell'atto di autonomia.

L'**illiceità** della causa è la conseguenza alla contrarietà del negozio giuridico ad una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume.

I negozi sotto il profilo causale possono distinguersi in:

- **Negozi tra vivi/negozi per causa di morte** a seconda che i loro effetti conseguano o meno alla morte dell'autore
- **Negozi a titolo oneroso/negozi a titolo gratuito** a seconda che il vantaggio di acquisire comporti o meno un sacrificio economico corrispondente
- **Negozi a contenuto patrimoniale/non patrimoniale**, i primi danno luogo a spostamenti di ricchezza, i secondi riguardano per lo più aspetti della persona o della famiglia

- **Negozi causali/astratti**, i quali non sono privi di causa, ma gli effetti si producono a prescindere dalla causa
- **Negozi di accertamento** sono rivolti a eliminare l'incertezza di una situazione giuridica pre-esistente

La causa si distingue dal **motivo**, che sono le motivazioni personali dell'agire. Il motivo è irrilevante per l'ordinamento giuridico, ma il motivo illecito nel contratto è causa di nullità qualora sia comune alle parti o sia stato il solo ad indurle a stipulare l'accordo (art 1345).

- **OGGETTO**: è il bene o comportamento assunto dal negozio giuridico che ne costituisce il contenuto dispositivo e che può venire ad esistenza anche successivamente all'atto.

Requisiti oggetto:

- **La possibilità**
- **Liceità**: deve riguardare l'operazione economica e non l'oggetto in sé
- **La determinatezza o determinabilità anche ad opera di un terzo**

Un tipo di negozio giuridico sono i **negozi rappresentativi**, che sono posti in essere da chi è munito di poteri di rappresentanza (**rappresentante**) e compie l'atto in nome e per conto di un altro soggetto (**rappresentato**).

La rappresentanza può essere:

- **Rappresentanza volontaria**: quando il potere è conferito al rappresentante dall'interessato mediante un atto chiamato **procura**.
- **Rappresentanza legale**: quando il rappresentante è autorizzato da una norma giuridica (per esempio madre e padre sono rappresentanti nel minore).

Alcuni negozi giuridici non possono essere conclusi per mezzo di un rappresentante (testamento).

LA SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Le situazioni giuridiche soggettive sono frutto degli **effetti della norma giuridica** e si caratterizzano per il conferimento di prerogative o per l'imposizione di determinati obblighi.

- **Situazioni giuridiche soggettive ATTIVE**: rappresentano il riconoscimento giuridico di un interesse individuale, collettivo o diffuso e si distinguono in: **diritto soggettivo, diritto potestativo, potestà, interesse diffuso, interesse collettivo, interesse legittimo, aspettativa, status**.
- **Situazioni giuridiche soggettive PASSIVE**: Esprimono la posizione di svantaggio di chi:
 - È tenuto a rispettare l'altrui sfera giuridica (**dovere generico di astensione**)
 - È tenuto a porre in essere un certo comportamento volto a soddisfare l'interesse del titolare del corrispondente diritto (**obbligo o obbligazione**)
 - È costretto a subire l'esercizio dell'altrui potere (**soggezione**)
 - È costretto a tenere un comportamento necessario per l'acquisto di una propria posizione di vantaggio (**onere**).

La previsione normativa di un fatto e dei suoi effetti va a comporre la fattispecie giuridica, e le situazioni soggettive concorrono a delineare la fattispecie e indicano quali sono gli strumenti che ha a disposizione il titolare per realizzare il proprio interesse e quindi rappresenta gli effetti che prevede la norma a tal fine.

IL DIRITTO SOGGETTIVO

E' la situazione giuridica soggettiva attiva di maggiore portata.

Il diritto soggettivo consiste nel conferimento al privato di una **sfera di libertà d'azione (agere licere)** al cui interno il titolare può perseguire la **realizzazione del proprio interesse** mediante l'esercizio di **poteri giuridici**, il cui esercizio modifica la realtà del diritto preesistente (disporre della cosa propria) e l'attuazione di specifiche **facoltà** il cui esercizio modifica lo stato di fatto (uso della cosa propria).

Forme diverse:

- **Diritti patrimoniali/non patrimoniali**
- **Diritti assoluti:** che garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti (erga omnes) e che si dividono in **diritti della personalità** (sono tutelati in capo al singolo nei confronti di chiunque) e in **diritti reali** (diritti su una cosa, attribuiscono al titolare una signoria su un bene)
Diritti relativi: che garantiscono al titolare un potere che può far valere nei confronti di una o più persone determinate e sono i **diritti di credito** (contrapposti ai diritti reali, in quanto non hanno come oggetto una res, ma una persona) e i **diritti personali di godimento** (situazione in cui un soggetto si è obbligato a far godere di un proprio bene un altro soggetto come la locazione, il comodato)

Il diritto soggettivo dà l'idea della strumentalità a uno scopo, la realizzazione dell'interesse riconosciuto dall'ordinamento.

E' uno strumento in mano all'arbitrio del titolare e l'unico limite intrinseco al diritto soggettivo è la **figura dogmatica del divieto di ABUSO DEL DIRITTO**, che contrasta quelle forme di esercizio del diritto che si rivelino contrarie alla ragione per la quale esso stesso sia stato conferito.

Il fondamento del divieto di abuso del diritto è il precetto di agire secondo **buona fede oggettiva** (**art 1375**: buona fede durante la fase esecutiva del contratto; **art 1175**: debitore e creditore devono comportarsi con correttezza).

L'atto abusivo non è illecito, ma illegittimo. **Illegittimità:** un tipo di difformità meno secca rispetto all'illiceità. Non poggia sulla violazione di una norma a cui è correlata una sanzione, ma sulla portata non giusta delle conseguenze dell'esercizio della situazione attiva.

Tra i diritti soggettivi è compreso anche lo **status**, che è l'insieme di posizioni giuridiche assunte nell'ambito della società/famiglia e che si rilevano come presupposti necessari per l'attribuzione di diritti e doveri che possono costituire oggetti di veri e propri diritti soggettivi.

Un ulteriore distinguo tra i diritti soggettivi è tra:

- **Diritti disponibili:** il titolare può disporre mediante atti di trasferimento, rinuncia...il diritto soggettivo e hanno carattere patrimoniale (es. diritto di proprietà)
- **Diritti indisponibili:** diritti soggettivi che non possono essere trasmessi a un altro soggetto e sono per lo più non patrimoniali (libertà personale), ma possono essere anche patrimoniali (diritto agli alimenti).

All'interno dei diritti soggettivi fa parte la categoria autonoma del **diritto potestativo**, il quale conferisce al titolare la possibilità di provocare modificazioni non solo nella propria sfera giuridica, ma anche in quella altrui. Ne consegue che il titolare della sfera suscettibile di modificazioni versa in una **situazione soggettiva passiva di soggezione**.

La fattispecie più nota è per esempio il diritto del proprietario del fondo confinante a ottenere la comunione del muro di cinta eretto sul confine del vicino (art 874).

LE ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

POTESTÀ: Ufficio privato nel quale vengono conferiti poteri e facoltà non nell'interesse del titolare, ma al fine di perseguire gli interessi del terzo. La più nota forma di potestà è la **responsabilità genitoriale**.

INTERESSE DIFFUSO: esigenza individuale su larga scala ovvero un interesse per una pluralità indefinita di soggetti.

INTERESSE COLLETTIVO: esigenza sovra-individuale che è identificabile con una categoria umana o con un gruppo sociale definito.

INTERESSE PUBBLICO: abbandona la logica individuale per assumere quella dell'istituzione che si rende interprete dei bisogni di una collettività. E' inevitabile che l'interesse pubblico possa entrare in contrasto con taluni interessi individuali.

INTERESSE LEGITTIMO: Si parla di interesse legittimo nell'ambito dei rapporti tra il privato e i pubblici poteri. E' il potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine a un comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione.

Il tipico strumento di tutela è l'**impugnazione** dell'atto amministrativo illegittimo.

- **Interesse legittimo pretensivo:** ampliamento della sfera giuridica del titolare per il quale è necessario un provvedimento favorevole della pubblica amministrazione
- **Interesse legittimo oppositivo:** perseguimento della conservazione della propria sfera giuridica cui un provvedimento della pubblica amministrazione sfavorevole intende imporre una qualche limitazione o riduzione.

INTERESSE LEGITTIMO DI DIRITTO PRIVATO: oltre che nel diritto amministrativo è rintracciabile anche nel diritto privato. Es. le norme che regolano il funzionamento delle assemblee di una società per azioni sono stabilite nell'interesse della società, ma il socio che si sente leso da una di loro può richiedere al giudice di annullarla.

ASPETTATIVA: interesse individuale tutelato in via provvisoria e strumentale, ossia il mezzo al fine di assicurare la possibilità di svolgere un diritto. (es. acquistare il diritto di eredità solo con il conseguimento di una laurea).

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

Le situazioni giuridiche soggettive esprimono la posizione di svantaggio imposta al soggetto di diritto dall'ordinamento.

Indicano quell'effetto della norma giuridica che comprime la sfera giuridica di tale soggetto in vista del soddisfacimento o di interessi generali o di interessi particolari o dello stesso destinatario.

DOVERE: condotta necessitata e di contenuto generico per la realizzazione di interessi di natura superindividuale.

2 elementi caratterizzanti:

- La natura generale dell'interesse da salvaguardare o da realizzare
- Contenuto generico della condotta

La figura di dovere che necessita maggiore attenzione è il **dovere generale di astensione**, che sorge in capo a ciascun consociato di fronte alle altrui situazioni giuridiche attive ed è il correlato dei **diritti soggettivi assoluti**.

OBBLIGO: condotta necessitata e di contenuto specifico per la realizzazione di interessi di natura particolare a vantaggio di uno o più soggetti determinati.

L'obbligo instaura quella relazione intersoggettiva che prendere il nome di **rapporto giuridico**, ovvero dove abbiamo la correlazione tra una situazione giuridica attiva e una situazione giuridica passiva.

La struttura giuridica più compiuta dell'obbligo è l'**obbligazione**, che è la forma più ampia e perfezionata del rapporto giuridico e vede correlati un obbligo, il **debito** e un diritto soggettivo relativo, il **credito**. E' sinonimo di **rapporto obbligatorio**.

Altre forme di obbligo al di fuori dell'area delle obbligazioni, perché di natura non patrimoniale sono per esempio gli obblighi familiari.

ONERE: comportamento necessitato per la realizzazione di un interesse proprio del soggetto tenuto ad adempierlo.

La conseguenza della violazione dell'onere consiste in uno svantaggio dell'onerato, non dà luogo a responsabilità per danni nei confronti di terzi.

ES. il compratore che intenda avvalersi della garanzia per i vizi della cosa vendutagli ha l'onere di denunciare i vizi entro 8 giorni dal momento in cui li ha scoperti, se no perde il diritto di farlo.

SOGGEZIONE: situazione passiva correlata all'attribuzione di un **diritto potestativo**. La condotta necessitata non consiste in una qualche realizzazione, ma nel tollerare la modificazione della propria sfera giuridica.

IL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è sicuramente una tra le principali categorie del diritto privato e consiste in una relazione giuridicamente rilevante tra due o più soggetti, la quale assume la forma giuridica dell'**interconnessione tra situazioni attive e passive**.

Le parti del rapporto sono:

- **La parte attiva:** colui a cui l'ordinamento attribuisce un potere o diritto soggettivo
- **La parte passiva:** colui a carico del quale sussiste un obbligo, un dovere...

È anche possibile che il rapporto giuridico abbia una fisionomia unisoggettiva, per esempio il **contratto concluso con se stesso**, che è quando il rappresentante acquista per se il bene che il rappresentato ha messo in vendita (art 1395 c.c.).

L'**oggetto del rapporto giuridico** è individuato nell'utilità che esso è preordinato a far conseguire e nel comportamento che è necessario adottare affinché un tale risultato si realizzi.

Un altro profilo cruciale del rapporto giuridico è costituito dal **titolo**, ovvero la **fonte**, cioè l'atto o fatto giuridico per effetto del quale è attribuito ad un soggetto un diritto soggettivo.

Rapporti identici dal punto di vista dell'oggetto sono sottoposti a discipline diverse a seconda del titolo.

Il dominio del rapporto giuridico ha caratterizzato per tempo anche la distinzione tra **diritti relativi** e **diritti assoluti**. I primi sono caratterizzati dall'instaurazione di un rapporto giuridico in quanto è necessaria la cooperazione della controparte, mentre per quanto riguarda i secondi appare più sforzato il tentativo di mettere nella categoria dei rapporti giuridici anche i diritti assoluti, anche se questo non significa che il titolare di un diritto assoluto non entri in un rapporto giuridico con terzi,

per esempio nell'ipotesi della violazione da parte del terzo della sfera di godimento del titolare del diritto assoluto, che rappresenta un illecito seppure eventuale.

Nei diritti assoluti quindi il rapporto non appartiene alla fisiologia dell'esercizio del diritto ma all'eventuale fase patologica della sua violazione.

ES. **diritti reali di godimento su cosa altrui**: tra proprietario e titolare del diritto di godimento si instaura un rapporto funzionale per la costituzione del diritto, non per la realizzazione dell'interesse del proprietario.

Inoltre, le impostazioni tradizionali distinguono i diritti assoluti e relativi anche in questo modo:

- Diritti assoluti: **efficacia erga omnes**
- Diritti relativi: **efficacia inter partes**

Questa distinzione è entrata in crisi con la formula della **TUTELA AQUILIANA DEI DIRITTI DI CREDITO**, che indica l'allargamento dell'area della responsabilità extracontrattuale per soggetti terzi rispetto al rapporto obbligatorio, quindi diversi dal debitore, anche se i diritti di credito sono diritti relativi.

Questo ampliamento è stato possibile grazie alla riconcettualizzazione della nozione di **danno ingiusto** che ha superato due concetti:

- a) La delimitazione della tutela dei diritti di credito nei confronti del solo debitore
- b) La rilevanza soltanto *inter partes* dei diritti relativi

Quindi, i diritti relativi, come quelli assoluti vanno rispettati da tutti i consociati.

La rilevanza verso l'esterno di ogni situazione soggettiva si indica col termine **opponibilità**, che è diverso dal termine **efficacia**, la quale indica la produzione degli effetti specifici della situazione soggettiva.

Ogni situazione soggettiva è opponibile, ma abbiamo delle distinzioni in base all'efficacia:

- Diritti assoluti: **efficacia non determinabile a priori**
- Diritti relativi: **efficacia determinabile a priori**

Non tutte le **relazioni sociali** assumono rilevanza giuridica nell'ordinamento come rapporti giuridici, ma se consacrata in un negozio o nella legge ogni relazione sociale può divenire rapporto giuridico. In alcuni casi però anche delle relazioni non formalizzate in un negozio possono divenire rapporti giuridici, come le **relazioni animate dall'affidamento**.

È il caso della relazione paziente-medico, se il medico commette una violazione deve risarcire il danno e in questo modo la relazione si trasforma in un rapporto giuridico.

LE VICENDE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Le situazioni giuridiche soggettive hanno una sorta di ciclo vitale, che però non trova una precisa disciplina nel codice, ma trova il suo fondamento nella nozione di **titolo**, ovvero ogni fatto idoneo a determinare l'acquisto o il trasferimento di una situazione giuridica soggettiva.

ACQUISTO:

- **A TITOLO ORIGINARIO**: si ha per i diritti della persona in base alla nascita e per i diritti reali in base ad una fattispecie acquisitiva prima di dante causa, come l'usucapione o l'occupazione di cose mobili abbandonate o animali oggetti di caccia e pesca.
- **A TITOLO DERIVATO**: ha luogo tra un **autore/dante causa** e un **avente causa** e determina un fenomeno denominato **successione**, che può essere:
 - **Inter vivos**, per esempio il contratto con effetti traslativi

Mortis causa, per esempio la successione ereditaria

- **A titolo universale**, concerne tutti i rapporti attivi e passivi del dante causa, anche in questo caso poteva essere *inter vivos* o *mortis causa*

A titolo particolare, avente ad oggetto uno o più diritti o rapporti determinati e anche qui poteva essere *inter vivos* o *mortis causa*.

L'acquisto a titolo derivato può avere:

- o **Carattere traslativo**: viene acquisito lo stesso diritto che aveva il precedente titolare (vendita proprietà di un bene)
- o **Carattere costitutivo**: quando il trasferimento riguarda solo una parte del contenuto del diritto (costituzione di un diritto reale di godimento su cosa altrui, tipo usufrutto)

Regole acquisto a titolo derivato: innanzitutto l'avente causa non può vantare un diritto più ampio di quello che competeva al suo dante causa e inoltre, l'avente causa che abbia acquistato la proprietà da chi non è proprietario perde il proprio diritto, ma se ha acquistato in buona fede ciò è escluso dagli errori inescusabili.

ESTINZIONE:

- Piena realizzazione dell'interesse per il quale il diritto era stato attribuito (proprietà beni consumabili)
- Impossibilità della prestazione, come nel caso di **impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore** (art 1256 c.c.)
- Perdita del diritto senza la sua trasmissione (per esempio l'abbandono), si parla in questo caso di **rinuncia abdicativa**, diversa dalla **rinuncia traslativa**, che ha natura contrattuale e determina l'acquisto altrui.

La rinuncia è ammessa solo per i diritti disponibili e non è ammessa per: diritti della personalità, status, potestà, diritti patrimoniali rivolti al soddisfacimento di bisogni essenziali (diritto agli alimenti, diritto alla retribuzione).

CENNI SULLA PUBBLICITA'

Il diritto è un fenomeno di comunicazione umana, quindi ha un rilievo necessariamente esterno.

L'ordinamento non si accontenta solo dell'esternazione di atti volontari, ma pretende forme di **pubblicità legale** adatta per le vicende dei beni immobili o mobili registrati (come la pubblicità di atti negoziali, pubblicità di status come l'iscrizione nei registri dello stato civile) e forme di **pubblicità di fatto**, adatta per i beni mobili, che consente di avvalersi del possesso, ossia del potere di fatto sulla cosa, per far presumere a terzi la corrispondenza tra lo stato di fatto e lo stato di diritto.

La pubblicità è uno degli indici esterni di una modificazione della sfera giuridica di un soggetto o della condizione giuridica di un bene, cioè entra in campo quando la situazione giuridica muta.

L'obiettivo principale della pubblicità è quello di dare certezza alle situazioni giuridiche soggettive. È molto importante nell'ambito della tutela giurisdizionale: la protezione di interessi giuridicamente rilevanti presuppone la loro messa in evidenza.

La pubblicità legale può essere:

- **Pubblicità-notizia**: rende conoscibile l'atto da parte di terzi, che non partecipano al suo compimento, ma sono autorizzati dalla legge a manifestare un'eventuale opposizione, la mancata pubblicazione non invalida né rende inefficace l'atto, ma dà luogo a una sola sanzione amministrativa pecuniaria. (pubblicazione matrimoniale)
- **Pubblicità dichiarativa**: non riguarda la validità o efficacia dell'atto come la pubblicità-notizia, ma serve a renderlo opponibile a terzi. Es. **atti soggetti a trascrizione nei pubblici**

registri immobiliari (artt. 2643 e 2696 c.c.), ed è il fatto giuridico che da luogo al più articolato sistema di pubblicità nel nostro codice.

Altri esempi di pubblicità dichiarativa possono essere:

- **Possesso di buona fede** (art 1155 c.c.): in caso di conflitto tra più acquirenti della stessa cosa mobile prevale il soggetto che abbia ricevuto la cosa in buona fede
- **Detenzione** (art 1380 c.c.): in caso di conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto personale di godimento prevale il contraente il cui contratto ha data anteriore.
- **Pubblicità costitutiva:** rappresenta un elemento interno alla fattispecie giuridica, la mancanza di pubblicità fa sì che l'atto non produca i propri effetti giuridici tra le parti.
Es. le s.p.a. acquistano personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle imprese.

TUTELA SITUAZIONE GIURIDICHE SOGGETTIVE

La titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva comporta anche il potere di reagire, secondo determinate modalità, a quei comportamenti dei terzi che si mostrano idonei a frustare l'attuazione dell'interesse privato.

Abbiamo un duplice significato di tutela:

1. Fenomeno con cui un dato interesse entra a far parte nell'insieme di quelli di cui l'ordinamento promuove la realizzazione
2. Ordinamento che si mobilita a favore del titolare del diritto, ovvero l'insieme degli strumenti di reazione (**mezzi di tutela**), degli organi e delle procedure che hanno lo scopo di salvaguardare l'interesse leso.

L'ordinamento riconosce quindi, al soggetto il cui interesse è stato leso, poteri di immediata reazione, come:

- **Autotutela:** poteri che consentono al privato di cautelarsi personalmente contro un rischio di pregiudizio. Es. **eccezioni dilatorie** (art 1460 c.c.), ovvero il rifiuto di eseguire la prestazione se l'altra parte non esegue la propria.

Un tipo di autotutela è l'**autotutela esecutiva**, che consiste in una forma di esecuzione privata che attribuisce al creditore il diritto potestativo di conseguire da terzi l'oggetto dell'interesse non soddisfatto o il suo equivalente monetario.

- **Tutela stragiudiziale:** mezzi di protezione destinati ad essere attivati al di fuori del processo. Es. le 3 fattispecie di risoluzione automatica (del contratto):

- **Diffida ad adempiere (art 1454)**
- **Clausola risolutiva espressa (art 1456)**
- **Termine essenziale (art 1457)**

La tutela stragiudiziale si può avvalere di:

- **Transazione**
- **Arbitrato:** affidamento a uno o più soggetti terzi (arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione che sarà vincolante per le parti.
- **Mediazione:**
 - **Volontaria:** prevista solo per alcune materie, dove le parti con l'assistenza di un mediatore tentano di raggiungere un accordo.
 - **Obbligatoria:** per alcune materie l'azione giudiziaria deve essere preceduta da un tentativo di mediazione
 - **Delegata:** avviene su ordine del giudice dopo averne valutato l'opportunità

L'accordo raggiunto in sede di mediazione dove vi è l'attestazione degli avvocati delle parti acquista **efficacia a titolo esecutivo**, mentre l'accordo non assistito dagli

avvocati delle parti per acquistare tale efficacia va sottoposto all'omologazione del giudice ordinario.

FORME E TECNICHE DI TUTELA

L'art. 24 Cost. si riferisce al caso in cui la tutela in senso stretto passi attraverso un giudice che ha il compito di rendere effettive le posizioni di vantaggio riconosciute dall'ordinamento ai privati ogni volta che ciò non accada in modo spontaneo.

Si parla qui di **tutela giurisdizionale**, non **stragiudiziale**.

Si ha una pluralità di forme di tutela:

- **Tutela satisfattoria**: tutela di cui godono i **diritti relativi** ed è intesa a far conseguire al titolare del diritto l'utilità che egli avrebbe dovuto ricevere dalla controparte
- **Tutela restitutoria**: tutela di cui godono i **diritti assoluti** ed è intesa a ripristinare lo stato di cose anteriore alla lesione. In questo ambito rientrano:
 - a) Tutela invalidatoria di atti di autonomia privata, che può essere disposta:
 - **Ope legis**: (per forza di legge) ed è quindi oggetto di mero accertamento in sede giudiziale (es. nullità)
 - **Ope iudicis**: è oggetto di accertamento costitutivo in sede giudiziale (innova la realtà giuridica preesistente, produce un nuovo effetto (annullabilità e la rescindibilità)
 - b) Tutela caducatoria di rapporti giuridici di fonte contrattuale: anche questa può essere disposta a volte **ope legis** (es. risoluzione di diritto) o **ope iudicis** (es. risoluzione giudiziale)
- **Tutela risarcitoria**: comune ad entrambe le categorie di diritti e ha lo scopo di risarcire la parte lesa del pregiudizio economico derivante dalla condotta illecita di un terzo, e tale tutela si modella poi a seconda del tipo di lesione.

La possibilità di una sorta di dialogo tra forme e tecniche di tutela si ha nella vicenda del **concorso di responsabilità**: idea che in talune circostanze il danneggiato può scegliere tra la **responsabilità contrattuale**, che deriva dalla violazione di un dovere specifico derivante da un precedente rapporto obbligatorio, e la **responsabilità extracontrattuale**, dove invece si ha la violazione del dovere generico del *neminem laedere*.

Es. la persona trasportata subisce un danno in uno scontro ferroviario: il danneggiato a tutela della propria integrità fisica può agire sia per inadempimento del contratto di trasporto (responsabilità contrattuale) sia per via extracontrattuale ex art. 2043.

La dottrina in questo ambito ritiene inammissibile il concorso di responsabilità perché quando il danneggiato e danneggiante sono legati da un vincolo obbligatorio preesistente si innesca unicamente la tutela contrattuale, mentre la giurisprudenza appare fedele al concorso di responsabilità.

Tutela contrattuale- art. 1218 c.c.: *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento dei danni, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*

Tutela aquiliana/extracontrattuale- art. 2043 c.c.: *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

Ciascuna forma di tutela si può avvalere di **tecniche di tutela differenti**: la tutela risarcitoria per esempio può impiegare lo strumento classico del risarcimento per equivalente oppure certe volte si può utilizzare anche il risarcimento in forma specifica.

La tutela restitutoria può impiegare:

- **Sentenze di mero accertamento**: accertamento esistenza/inesistenza di un rapporto giuridico controverso
- **Sentenze costitutive**: modifica la situazione fino a quel momento vigente
- **Sentenze di condanna**: dove si ha l'emanazione di un comando. In questo caso si parla di **azione inibitoria**, cioè il bisogno di tutela può essere soddisfatto vietando una data condotta.

Uno strumento processuale che è stato introdotto in materia di rapporti di consumo è l'**azione di classe risarcitoria**, che rappresenta un rimedio contro le condotte illecite del professionista idonee a ledere interessi identici in una pluralità di consumatori.

Si tratta di un meccanismo processuale di adesione di tutti coloro che vantano un diritto della medesima specie rispetto al singolo consumatore che ha dato l'iniziativa.

La *ratio* è il rafforzamento della **tutela del consumatore** ottenuta mediante uno **strumento di aggregazione processuale**.

L'iniziativa di un'azione di classe comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

La l.31/2019 ha riformato l'istituto dell'azione di classe estendendo la platea dei soggetti legittimati e inoltre prevedendo che si può aderire all'azione di classe sia nella fase successiva all'ordinanza che ammette l'azione, sia nella fase successiva alla pronuncia della sentenza.

Il fronte della tutela costituisce uno dei profili centrali dell'**interesse legittimo**, che delinea i confini della **giurisdizione amministrativa**, ovvero della giurisdizione affidata ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

La salvaguardia degli interessi legittimi è affidata a una pluralità di forme e tecniche di tutela:

- **Azione di annullamento del provvedimento amministrativo**
- **Azione di accertamento**
- **Azione di adempimento e azione di risarcimento del danno**

I RIMEDI

Forme di tutela: sono gli schemi generali di risposta a un bisogno di protezione

Tecniche di tutela: meccanismi, processuali o meno, di attuazione delle forme

RIMEDI: piano mobile di strumenti preposti al soddisfacimento di un bisogno di tutela del singolo a causa dell'inattuazione di un suo interesse per un ostacolo o per la violazione da parte di un terzo.

La costruzione di un'idea più completa di rimedio segna un passo avanti con i **rimedi contrattuali**, che sono meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto o problema che il contratto presenta, quindi questi rimedi vanno a eliminare i conflitti via via prodottisi nella formazione e nell'esecuzione del rapporto.

LA TUTELA GIUDIZIALE: AZIONE ED ECCEZIONE. IL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA

L'esercizio di un diritto in sede processuale comporta il rispetto di alcune regole che danno vita alla **procedura civile**.

La tutela giurisdizionale dei diritti può attivarsi soltanto su istanza di parte mediante la **proposizione di una domanda**, che risulta ammissibile se vi è un idoneo interesse ad agire.

Nella domanda si concretizza l'**esercizio dell'azione**, cioè il potere di chiedere e ottenere dal giudice un provvedimento a tutela della situazione fatta valere in giudizio.

È necessario fornire la prova delle circostanze e dei fatti rilevanti per la definizione del giudizio, a carico delle parti, e su questo si fonda il **principio dell'onere della prova (art. 2967 c.c.)**.

Un altro principio fondamentale in questo ambito è il **principio del contraddittorio (art. 24 Cost.)**, che impone che al processo deve partecipare a pieno titolo anche colui contro il quale si richiede l'emanazione del provvedimento (convenuto).

L'arma fondamentale del convenuto è l'**eccezione**, cioè si può far valere la circostanza che il diritto fatto valere in giudizio dall'attore non sia mai esistito. Ovviamente anche in questo caso i fatti devono essere provati.

Il regime dell'onere della prova può essere modificato dalla legge e anche dalle parti entro limiti rigidi:

- **Presunzioni legali:** in virtù delle quali un certo fatto si dà per avverato
- **Patti relativi all'onere della prova** (art. 2698 c.c.): è ammessa la validità dei patti con cui i contraenti invertono o modificano l'onere della prova, salvo i casi in cui si controverta su diritti indisponibili o la modifica renda per una delle parti difficile l'esercizio del diritto.

Fondamentale distinzione tra **titolarità del rapporto** e **legittimazione ad agire**

La prima è un elemento costitutivo della domanda ed è in merito alla decisione, in quanto è una prova che incombe sull'attore. La seconda riguarda il diritto d'azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.

Es. crolla una collina su un fabbricato. Il proprietario del fabbricato agisce contro l'impresa che ha scavato sulla collina.

All'attore spetta l'onere di dimostrare il fatto, ovvero la sussistenza di un proprio diritto reale sul fabbricato. FATTO DELLA TITOLARITA' DEL RAPPORTO

Inoltre ha diritto al risarcimento=AZIONE RISARCITORIA (legittimazione ad agire), cioè diritto oggetto della domanda.

I VARI TIPI DI PROVA

La **prova** è lo strumento grazie al quale il giudice può trarre informazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti e emettere la decisione nel modo il più possibile consapevole, in quanto la risoluzione delle controversie deve fondarsi su un **criterio di verità**, quindi su un accertamento dei fatti rilevanti ai fini della causa.

Diversi tipi di prova:

- **Prove documentali:** risultanti da un documento; sono dette anche **prove precostituite**, perché precedono il processo.

Tra le prove documentali si trovano:

- **Atto pubblico:** documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale il quale fa prova della provenienza del documento (es. rogito notarile)
Per contestare l'esistenza dei fatti attestati nell'atto pubblico bisogna mettere in atto la **querela di falso**, che si tratta dell'incriminazione del pubblico ufficiale per falso in atto pubblico.

L'atto pubblico è una **prova legale**, quindi il giudice deve dare per accertati i fatti dell'atto pubblico.

- **Scrittura privata:** a differenza dell'atto pubblico ha un ambito operativo più ridotto, in quanto si basa sulle dichiarazioni affermate da colui che l'ha sottoscritta.

È considerata una prova legale solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce i fatti.

Un problema che rileva la scrittura privata è il problema della data degli atti, quindi in generale la scrittura non ha data certa.

- **Prove semplici:** sono formate durante lo svolgimento del processo.
 - Prove semplici senza efficacia legale:
 - **Prova testimoniale:** la sua ammissibilità è legata alla discrezionalità del giudice, tranne nei casi in cui: il contratto ha valore inferiore a €2,58, se sussiste un principio di prova per iscritto, vi è l'impossibilità di procurarsi una prova scritta o se vi è stata la perdita senza colpa del documento di prova scritta.
 - Prove semplici con efficacia legale:
 - **Confessione:** dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte
 - **Giuramento**, il quale può essere **decisorio**, se una parte chiede al giudice che l'altra parte giuri su determinati fatti; **estimatorio**, se ha lo scopo di stabilire il valore della cosa domandata; **suppletorio**, se è ordinato dal giudice ad una delle parti col fine di decidere la causa.

LA TIPOLOGIA DELLE SENTENZE. LA COSA GIUDICATA

Allorché il giudice reputi fondate le ragioni dell'attore, ne accoglie la domanda emanando un provvedimento che prende il nome di sentenza.

Le sentenze, dal punto di vista del loro contenuto, si dividono in tre categorie:

- **Sentenze di mero accertamento:** questa sentenza appaga l'interesse dell'attore stabilendo in modo inconvertibile quale sia il vero stato giuridico di cose o situazioni.
- **Sentenze di condanna:** contiene l'ordine del giudice al convenuto di consegnare una cosa determinata mobile o non mobile, o di fare o non fare qualcosa. Rivesta un'importanza particolare in quanto costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
- **Sentenze costitutive:** attua il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, ma non si limita a stabilire quale sia lo stato giuridico di una cosa, ma pone a capo effetti innovativi rispetto alla situazione preesistente.

La sentenza può essere **impugnata**, ovvero sottoposta al riesame da un giudice diverso da quello che l'ha emanata.

Vi sono 3 gradi di giudizio e in ultimo appello vi è la Corte di Cassazione che decide in ordine della legittimità (correttezza) e non del merito (ricostruzione dei fatti).

Una sentenza non più impugnabile prende efficacia della **cosa giudicata**, ovvero non può più essere proposta in giudizio.

L'ESECUZIONE FORZATA

L'esecuzione forzata, che come abbiamo detto prima è riconosciuta nella sentenza di condanna, mira a far conseguire al creditore la prestazione dovuta se il debitore non abbia adempiuto.

Per procedere il creditore deve munirsi di un **titolo esecutivo**, riguardante un diritto certo liquido e esigibile, che va inoltrato al debitore insieme al **precetto**, che consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo stesso entro un termine non inferiore a 10 giorni.

L'esecuzione forzata è di due tipi:

- **Esecuzione per espropriazione:** ha come contenuto la tutela di un'obbligazione con oggetto somme di denaro o in seguito liquidate. Trova il suo fondamento *ex art. 2740 c.c.* nella responsabilità patrimoniale del debitore, che è chiamato a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si articola in una pluralità di fasi procedurali:
 - 1) Pignoramento
 - 2) Vendita forzata a terzi con susseguente distribuzione del ricavato ai creditori o Assegnazione forzata ai creditori
- **Esecuzione in forma specifica:** ha come oggetto la tutela di una prestazione specifica che non può essere sostituita con un adempimento alternativo.

L'ESECUZIONE INDIRETTA

Si tratta di una tecnica di rafforzamento dei provvedimenti giudiziari di condanna che impongono un obbligo di prestazione diversa da quella pecuniaria.

Nell'esecuzione indiretta quindi non si fa a meno del comportamento dell'obbligato, ma l'ordinamento continua ad ancorarsi ad esso per la realizzazione della prestazione.

L'esecuzione indiretta è complementare a quella diretta, in quanto l'ambito della prima inizia dove si arresta quello della seconda.

Il ricorso all'esecuzione indiretta si può giustificare per indurre il debitore ad eseguire la prestazione in modo da evitare il ricorso al dispendioso procedimento di esecuzione forzata, tramite **strumenti di coercizione**, ovvero **incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi**, imponendo di fare o non fare qualcosa mediante il condizionamento di volontà.

PRESCRIZIONE E DECADENZA: GLI ELEMENTI DIFFERENZIALI

La **prescrizione** e la **decadenza** sono istituti idonei a regolare l'influenza del tempo nell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive.

PRESCRIZIONE:

- **ESTINTIVA/in senso proprio:** produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'**inerzia** del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non lo usa per un arco di tempo determinato dalla legge.

La *ratio* è l'**esigenza di certezza dei rapporti giuridici**, quindi è stabilita per ragioni d'interesse generale, quindi le norme che la disciplinano sono inderogabili.

La regola generale è che tutti i diritti sono oggetti a prescrizione estintiva, ma sono esclusi:

- Diritti indisponibili
- Status
- Diritto di proprietà

- Le singole facoltà che sono oggetto di un diritto soggettivo

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato e l'impossibilità di esercitare il diritto è quella che deriva solo da cause giuridiche, quindi la prescrizione non opera se sopraggiunge una causa che giustifica l'inerzia stessa.

Durata prescrizione:

- **10 anni: prescrizione ordinaria**, la quale si applica in tutti i casi dove la legge non dispone diversamente
 - **20 anni: estinzione diritti reali su cosa altrui**
 - **5 anni: illecito extracontrattuale**
 - **2 anni: danni derivanti da circolazione di veicoli**
- **PRESUNTIVA:** si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o sia stato estinto per effetto di un'altra causa. Quindi la legge, dopo un breve periodo, presume che si sia verificata una causa estintiva di esso.
La *ratio* è che la prescrizione presuntiva si basa sulla considerazione che nella vita quotidiana ci sono dei rapporti dove l'estinzione del debito avviene contestualmente all'esecuzione della prestazione (es. corrispettivo cena ristorante).
Il debitore è quindi esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito, spetta invece al creditore offrire la prova che la prestazione non è stata eseguita.

DECADENZA: alla base della decadenza sta la fissazione di un termine perentorio (che non ammette dilazione) entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività se no l'esercizio del diritto è definitivamente precluso.

Implica l'**onere di esercitare il diritto entro il termine prescritto**, quindi la decadenza può essere impedita solo tramite il compimento dell'atto.

Es. il diritto alla garanzia per difetti sugli oggetti comprati, decade entro 8 giorni dalla data di acquisto.

La decadenza può essere stabilita:

- **Nell'interesse individuale di una delle parti** (in relazione a **diritti disponibili**): le parti possono o modificare il regime legale della decadenza o possono rinunziarvi. (termine in cui il compratore deve denunciare i vizi della cosa)
- **Nell'interesse generale** (in relazione a **diritti indisponibili**): le parti non possono modificare il regime previste dalla legge né rinunziare alla decadenza. (es. in tema di rapporti familiari)

CAPITOLO III

LA PERSONA FISICA

E I DIRITTI DELLA

PERSONALITA'

IL SOGGETTO DI DIRITTO E LA PERSONA FISICA

Riferimento necessario delle norme giuridiche è il **soggetto di diritto**, titolare delle situazioni giuridiche attive e passive in esse previste e autore degli atti che sono fonte di diritti e obblighi o ne costituiscono rispettivamente esercizio e adempimento.

La nozione di soggetti di diritto è da differenziare dalla nozione di **parte**, che presuppone ma non coincide con il concetto di soggetto di diritto, infatti un atto o un fatto può essere imputato a una pluralità di soggetti che costituiscono un'unica parte.

Ogni ordinamento stabilisce chi può divenire titolare di situazioni giuridiche.

Nell'ordinamento italiano la discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nella garanzia dei **diritti inviolabili dell'art 2 Cost.**, il quali sono riconosciuti ad ogni essere umano in quanto tale.

La qualità di soggetto di diritto è riconosciuta anche agli **enti**, che possono divenire titolari di diritti e obblighi autonomi da quelli dei membri che ne fanno parti, ai quali fa riferimento l'art. 2 allorché menziona le **formazioni sociali** all'interno delle quali si svolge la personalità umana.

LA CAPACITA' GIURIDICA E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

La **persona fisica**, individuo identificato da nome e cognome, è soggetto di diritto in quanto l'ordinamento gli riconosce la **capacità giuridica**, ovvero la capacità di divenire titolari di posizioni giuridiche attive e passive.

La capacità giuridica si acquista al momento della **nascita (art. 1 c.c.)**. L'art. 1 c.c. è espressione di un fondamentale **principio di uguaglianza formale** che riconosce a tutti la possibilità di assumere posizioni giuridiche idonee al soddisfacimento dei propri interessi.

CAPACITA' E INCAPACITA' GIURIDICHE SPECIALI

Non costituisce una violazione del principio di uguaglianza la **capacità giuridica speciale**, ovvero l'ipotesi in cui la legge limita la possibilità di essere titolare di determinate posizioni giuridiche e non si acquista con la nascita. Es. per essere parte di un lavoro subordinato occorre avere una determinata età.

Ci sono invece dei casi in cui la legge esclude la possibilità di divenire parte in alcuni rapporti ad alcuni soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità: **incapacità giuridica speciale**.

Es. i pubblici ufficiali non possono essere acquirenti di beni venduti per mezzo del loro ministero.

IL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

L'art. 16 delle preleggi stabilisce che la capacità riconosciuta allo straniero è condizionata dal fatto che lo stato al quale egli appartenga non discrimini il cittadino italiano, ma gli riconosca la possibilità di acquistare diritti al pari dei propri cittadini.

La legge quindi ammette un differente trattamento allo straniero nell'ipotesi in cui non sussista una **condizione di reciprocità**, che opera solo per lo straniero privo di permesso di soggiorno e non può determinare l'esclusione dei diritti inviolabili.

È escluso invece il riconoscimento dei **diritti politici**.

LA TUTELA GIURIDICA DEL NASCITURO: IL CONCEPITO

Al nascituro già concepito è riconosciuta una **limitata capacità giuridica**, il quale può succedere per *mortis causa* e ricevere per donazione.

Queste attribuzioni a favore del nascituro sono subordinate all'evento della nascita: se si verifica, l'attribuzione diviene definitiva, altrimenti si considera come se non fosse mai avvenuta.

La giurisprudenza desume la **soggettività giuridica del concepito**, in quanto titolare di interessi protetti dall'ordinamento:

- Diritto al risarcimento del danno derivante dalla salute o integrità fisica provocato dalla condotta dei genitori o fatti imputabili ad altri soggetti: **diritti a nascere sano**
- Nell'ordinamento italiano non è riconosciuto un **diritto a non nascere se non sano**
- L'aborto è ammesso solo in casi limitati e si esclude l'ammissibilità di un **aborto eugenetico**, ovvero l'aborto utilizzato come tecnica per controllare le nascite.

NASCITA E MORTE DELLA PERSONA FISICA

L'ordinamento attribuisce rilevanza all'inizio e alla fine della vita della persona fisica.

L'evento della **nascita** si considera verificato al momento del parto, se vivo e autonomo a respirare.

La **morte** è individuata invece nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (morte cerebrale).

Quando vi è incertezza sull'ordine di morte di due persone (per esempio se due fratelli muoiono insieme per stabilire l'eredità) si prevede una **presunzione di commorienza**, ovvero che i soggetti siano morti nello stesso momento.

DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA

DOMICILIO: luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

- **Domicilio volontario:** quando è oggetto di libera scelta del soggetto
 - Generale: se è sede di tutti i principali affari e interessi
 - Speciale: se è sede di determinati atti o affari, e in questo caso deve farsi per iscritto
- **Domicilio legale:** assegnato dalla legge a determinate persone (es. il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia)

DIMORA: non ha una definizione legislativa, ma è comunemente intesa come il luogo in cui il soggetto si trova attualmente anche diverso da quello in cui abitualmente soggiorna, caratterizzato da una minima stabilità.

RESIDENZA: luogo in cui la persona fisica abitualmente dimora.

La residenza presuppone:

- Elemento materiale: effettiva e abituale presenza fisica in un certo luogo
- Elemento formale: iscrizione all'Anagrafe del comune nel cui territorio tale luogo è situato

SCOMPARSA, ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

La **scomparsa** si ha nell'ipotesi in cui la persona fisica non sia più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne abbiano più notizie per un tempo che faccia ragionevolmente dubitare che sia ancora in vita o in condizioni di provvedere ai propri interessi.

In questo caso, il Tribunale dell'ultimo domicilio/residenza, su istanza delle persone che sarebbero chiamate alla successione della persona scomparsa, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati, nomina un **curatore**, che ha il compito di conservare il patrimonio dello scomparso. Può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione serve l'autorizzazione del tribunale.

Dopo 2 anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona il Tribunale ne dichiara l'**assenza**. Il Tribunale immette nel **possesso temporaneo** dei suoi beni coloro che sarebbe stati eredi testamentari o legittimi.

La dichiarazione d'assenza cessa automaticamente di produrre effetti se l'assente ritorna, o ne è provata l'esistenza in vita. In questo caso egli ha diritto alla restituzione dei beni e a 1/3 delle rendite percepite da quei beni.

La **morte presunta** è invece dichiarata con sentenza dal tribunale dopo 10 anni dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia. Produce gli stessi effetti della morte della persona con conseguenze apertura della sua successione.

Se il presunto morto ritorna ha diritto a recuperare i beni nello stesso stato in cui si trovano e il matrimonio è nullo.

LA CAPACITA' DI AGIRE IN RELAZIONE ALL'ETA' DELLA PERSONA

La **capacità di agire (art. 2 c.c.)** è il naturale completamento della capacità giuridica, ovvero consente al soggetto di **compiere validamente atti giuridici**.

L'atto compiuto da una persona senza capacità di agire non è nullo, ma **annullabile**, quindi produce i suoi effetti fino a quando non sia annullato dal giudice.

La mancanza di capacità di agire priva di efficacia anche le dichiarazioni di scienza.

La capacità di agire si acquista al compimento dei **18 anni**, in quanto si presuppone che il soggetto abbia raggiunto un livello adeguato di maturità.

L'ordinamento stabilisce che in alcuni casi possa essere perduta o limitata (**incapacità legale**) e attribuisce rilevanza alla situazione di incapacità di intendere e di volere in cui possa trovarsi un soggetto (**incapacità naturale**).

Alcune eccezioni al fatto che la capacità d'agire si acquista a 18 anni:

- Il minore ultrasedicenne è ammesso a stipulare il proprio contratto di lavoro
- Se autorizzato dal giudice può prestare il consenso alle nozze: **status di minore emancipato**.

I minori possono compiere validamente gli atti della vita quotidiana (es. acquistare il biglietto dell'autobus) in quanto si presume che agiscano in forza di una **procura tacita** da parte dei genitori.

La capacità di agire non è necessaria invece per rispondere dei **fatti illeciti**: in questo caso è richiesta la sola **capacità di intendere e di volere**.

LA RESPONSABILITA' GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI

Il minore è soggetto alla **responsabilità genitoriale**, in quanto:

- I genitori sono chiamati ad adempiere gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione, i quali sono esercitati di comune accordo tra i genitori e in caso di contrasto su questioni rilevanti ogni genitore può ricorrere al giudice

- I genitori hanno il potere/dovere di amministrazione dei beni dei figli minori e il potere di rappresentarli nel compimento di tutti gli atti civili (art. 320 c.c.)

Per quanto riguarda gli **atti di ordinaria amministrazione**, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, mentre per gli **atti di straordinaria amministrazione**, i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

Il codice civile indica espressamente gli atti che non rientrano nella normale gestione del patrimonio amministrato:

- **Atti di disposizione:** i quali comportano un mutamento della consistenza del patrimonio (es. vendita di beni)
- Accettazione/rinuncia eredità o donazioni
- Riscossione capitali

Se sorge un conflitto di interessi patrimoniali:

- Tra i figli ed entrambi i genitori: il giudice nomina un **curatore speciale**
- Tra i figli e uno solo dei genitori: la rappresentanza del compimento dell'atto spetta all'altro genitore.

I genitori hanno in comune l'**usufrutto legale** sui beni del figlio, fino alla maggiore età o emancipazione, ovvero i frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione dei figli.

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale si apre l'**istituto della tutela dei minori**.

Il giudice tutelare nomina un **tutore** che può essere designato per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I compiti del tutore sono:

- Prendersi cura della persona del minore
- Amministrazione dei beni
- Rappresentanza legale

In linea generale gli atti compiuti dal tutore devono essere autorizzati dal giudice tranne nel caso di acquisto di beni mobili necessari per il minore o nel caso di riscossione di capitali per spese necessarie per il mantenimento.

Nel caso di conflitto di interessi tra il minore e il tutore viene nominato un **protutore**.

La rappresentanza legale dei genitori e del tutore non può riguardare gli **atti strettamente personali**, che deve essere una scelta effettuata necessariamente dal minore.

IL MINORE EMANCIPATO

Il **minore emancipato** è il minore che viene autorizzato a contrarre matrimonio e acquista una **limitata capacità d'agire**.

Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti è assistito da un **curatore**, che non si sostituisce a lui, ma insieme a lui esprime il proprio consenso a partecipare all'atto; inoltre per la validità di questi atti è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'INTERDIZIONE GIUDIZIALE E LEGALE

INTERDIZIONE GIUDIZIALE: è un correttivo alla regola secondo la quale alla maggiore età si acquista la piena capacità di agire nel caso in cui la persona si trova in una condizione di **abituale infermità mentale**, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.

È chiamata "giudiziale" perché appunto si presuppone un esame dell'interdicendo da parte del giudice.

Cause: patologia che privi completamente il soggetto di provvedere ai propri interessi (presuppone una certa durata della malattia), valutata non in termini assoluti ma in relazione agli specifici affari e situazioni che il soggetto si trova a gestire.

I soggetti legittimati a chiedere l'interdizione sono:

- Coniuge
- Perenti entro il quarto grado
- Affino entro il secondo grado
- Curatore/pubblico ministero
- Unito civilmente

Effetti interdizione:

- Si producono alla pubblicazione della sentenza di interdizione
- L'interdetto viene a trovarsi in una situazione di **totale incapacità di agire**, ma con la riforma del 2004 si è stabilito che il giudice possa stabilire che l'interdetto possa compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione.
- Nomina di un **tutore**.
Il tutore svolge l'attività preclusa all'interdetto ma non si estende agli atti strettamente personali (l'interdetto però non può fare testamento o matrimonio). Il consenso informato al trattamento sanitario è espresso dal tutore.
Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti solo con **autorizzazione del giudice**.

Proprio in considerazione dell'invalidità che colpisce gli atti compiuti dall'interdetto e a tutela di coloro che stipulano contratti o instaurano rapporto giuridici con l'interdetto, tutti gli atti sono sottoposti a un **doppio regime di pubblicità**: devono essere trascritti nel registro delle tutele presso la cancelleria del Tribunale e trasmessi all'ufficiale dello stato civile che fa l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Quando cessa l'interdizione si ha la **sentenza di revoca**, che produce effetti quando passa in giudicato.

INTERDIZIONE LEGALE: costituisce una **pena accessoria** che grava su chi sia stata condannato o all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Quindi non ha misura protettiva, come nel caso dell'interdizione giudiziale, ma ha misura punitiva.

L'INABILITAZIONE

L'**inabilitazione** si verifica qualora l'infermità mentale in cui versa la persona non sia così grave da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.

Possono fare richiesta gli stessi soggetti dell'interdizione.

Cause:

- Abuso abituale di alcool o stupefacenti che espongono se e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
- Sordomutismo o cecità

Questi casi devono comunque presupporre il fatto di una **parziale incapacità di provvedere ai propri interessi**.

Conseguenze:

- L'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e atti di carattere personale
- Può esprimere autonomamente il proprio consenso informato al trattamento sanitario
- Per gli atti di straordinaria amministrazione l'inabilitato deve essere assistito da un **curatore**

La riforma del 2004 ha garantito una maggiore discrezionalità del giudice, che valutando il caso concreto può disporre che l'inabilitato possa compiere alcuni atti di straordinaria amministrazione.

L'inabilitazione può essere revocata, dove ne siano venuti meno i presupposti, con sentenza che ha efficacia quando passa in giudicato.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'istituto dell'**amministrazione di sostegno** è stato introdotto dalla l. 6/2004 per garantire una **protezione più ampia e flessibile**, in grado di adattarsi in modo diverso ai concreti bisogni di ciascuna persona.

Presupposti: La persona, per effetto di un'infermità o menomazione fisica si trovi nell'**impossibilità di provvedere ai propri interessi** anche in modo temporaneo.

La tutela può coprire sia le situazioni di abituale infermità mentale, per le quali è possibile anche l'interdizione o inabilitazione, sia **incapacità che non dipendono da patologie mentali** (anziani, soggetti fragili).

Il giudice tutelare nomina l'**amministratore di sostegno** e se vi è un'indicazione da parte dell'interessato riguardo la nomina il giudice deve tenerne conto se no il giudice nomina la persona che ritiene più idonea a svolgere l'incarico (coniuge, parenti).

Ad oggi è l'istituto più utilizzato, infatti si utilizzano interdizione e inabilitazione quando non si può utilizzare l'amministrazione di sostegno.

Per quanto riguarda i compiti dell'amministratore, il **decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno** deve indicare:

- Gli atti che l'amministratore deve compiere in nome e per conto del beneficiario
- Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore

Gli atti compiuti dall'amministratore in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico sono **annullabili**. L'amministratore è obbligato a riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

Questo istituto si caratterizza per una **notevole elasticità**, infatti la legge non fa neanche una suddivisione in base agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

GLI ATTI E I CONTRATTI DELL'INCAPACE NATURALE

La legge attribuisce rilevanza alla situazione di **incapacità di intendere e di volere** in cui si trovi una persona nel momento in cui ha compiuto l'atto, che priva il soggetto di esprimere la volontà consapevolmente.

Questo può dipendere sia da causa transitorie (es. abuso di alcool), sia da causa permanenti (abituale infermità mentale priva di una qualsiasi protezione).

In queste ipotesi l'atto compiuto può essere annullato su istanza della persona stessa o dai suoi eredi.

In caso di **contratto** occorre:

- Prova dell'incapacità
- Prova del pregiudizio
- Prova della malafede dell'altro contraente, ovvero che era consapevole della condizione dell'attore.

In alcuni casi stabiliti dalla legge occorre solo la prova dell'incapacità per l'annullamento: la donazione, il matrimonio e il testamento.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA': CARATTERI GENERALI

Art 2 Cost: la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.

Sicuramente ha una radice giusnaturalistica, ovvero l'idea che la persona umana è portatrice di **diritti innati**.

Non solo la costituzione tutela il cittadino contro gli abusi e l'arbitrio dei pubblici poteri, ma i diritti inviolabili sono tali anche nei confronti degli altri consociati.

Inoltre l'art. 2 non fa riferimento solo ai diritti contenuti in norme, ma anche a quelli che la coscienza sociale, in un determinato momento storico, ritiene essenziali per la tutela della persona umana.

Norme di derivazione extrastatuale sui diritti della personalità sono:

- **DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (ONU)**
- **CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (Cedu)**
- **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE**

Caratteri diritti della persona:

- **Necessarietà:** competono a tutte le persone fisiche, che li acquistano con la nascita e li perdono con la morte
- **Imprescrittibilità:** il non uso prolungato non ne determina l'estinzione
- **Absolutezza:** tutelabili *erga omnes*
- **Non patrimonialità:** tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica
- **Indisponibilità:** non sono rinunziabili

IL DIRITTO ALLA VITA

Il **diritto alla vita** è il presupposto di tutti gli altri diritti, anche se manca una espressa garanzia costituzionale, ma lo troviamo menzionato nell'art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI e nell'art. 2 della CEDU.

Nell'ordinamento italiano la tutela di questo diritto opera fin dal concepimento (**diritto a nascere**).

Non riceve tutela per quanto riguarda gli atti lesivi posti in essere dal diretto interessato (suicidio), sono però sanzionate le fattispecie di istigazione e aiuto al suicidio (eutanasia).

La legge riconosce già ad ogni persona capace di agire di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche indispensabile per la sopravvivenza. Per quanto riguarda gli incapaci invece, per i trattamenti indifferibili il medico dovrà comunque praticarli, mentre le altre decisioni relative al trattamento sanitario devono essere assunte da un **rappresentante legale**.

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Nella nostra costituzione, più precisamente nell'**art 32**, il diritto alla salute è visto come un **diritto fondamentale dell'individuo** e come **interesse dell'intera collettività**, infatti è un dovere di solidarietà in quanto ciascuna salute è considerata un valore per l'intera società e inoltre la sanità pubblica è finanziata dalle imposte pagate da tutti i consociati.

Gli **atti di disposizione del proprio corpo** sono vietati quando conducono ad una diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano contrari alla legge. Sono ammessi però la sterilizzazione volontaria e il prelievo di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto.

Secondo l'art 32 nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, cioè la legge può prevedere **terapie obbligatorie** per la salvaguardia dell'interesse collettivo.

Il **consenso informato** è il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e essere informati in modo completo. Ha una funzione di tutelare il malato come **persona** garantendogli la **libertà di autodeterminarsi**.

In caso di incapacità di esprimere il consenso il medico interviene dove vi sia necessità urgente e su autorizzazione del **rappresentante legale**.

DAT: Disposizioni anticipate di trattamento: sono disposizioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprime la propria volontà in materia di trattamenti sanitari: il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente, quindi è esente da responsabilità civile o penale.

DIRITTO ALL'INTEGRITA' MORALE: ONORE, DECORO E REPUTAZIONE

- **Diritto all'onore:** coscienza individuale del valore di una persona in considerazione delle sue doti morali
- **Diritto al decoro:** coscienza individuale del valore di una persona in considerazione delle sue doti fisiche e intellettuali
- **Diritto alla reputazione:** considerazione e stima del soggetto nel proprio ambiente sociale

La lesione di tali diritti consente alla persona offesa di agire per risarcimento danni.

Il diritto all'integrità può entrare in contrasto con altri diritti, come per esempio col diritto di manifestazione del pensiero o diritto alla cronaca: in questo caso ci deve essere un bilanciamento tra i due.

DIRITTO AL NOME

Art. 22 Cost: nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

Il nome comprende:

- **Prenome:** attribuito al momento della dichiarazione di nascita, fatta all'ufficiale dello stato civile da uno dei genitori
- **Cognome:**
 - Il figlio nato all'interno del matrimonio prende il cognome del padre
 - Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo, se lo hanno riconosciuto nello stesso momento acquisisce quello del padre
 - Ai neonati non riconosciuti da entrambi i genitori il nome e cognome sono attribuiti dall'ufficiale dello stato civile.

Il diritto al nome è tutelato a possibili comportamenti lesivi:

- Contestazione uso legittimo del proprio nome (es. in seguito al riconoscimento da parte del padre, esso cerca di impedire al figlio l'uso del suo cognome)
- Usurpazione del terzo che usa indebitamente il nome altrui
- Utilizzo abusivo di nome altrui per es. per un prodotto commerciale

DIRITTO ALL'IMMAGINE

Sussiste il divieto di esporre, pubblicare o diffondere la raffigurazione di un'altra persona salvo che questa non acconsenta.

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Il diritto all'identità personale va a tutelare la persona rispetto a rappresentazioni non veritiere potenzialmente in grado di alterare l'immagine sociale.

L'elemento costitutivo di questo diritto è il **diritto all'identità di genere**, riconosciuto dalla giurisprudenza.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'ordinamento tutela la persona rispetto alle ingiustificate intromissioni nella sua sfera privata e la divulgazione di fatti riservati che la riguardano.

La giurisprudenza ha introdotto in questo ambito il **diritto all'oblio**, cioè la pretesa del soggetto che siano dimenticate proprie vicende personali del passato rese pubbliche, dove non sussista un interesse pubblico.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica.

Particolare tutela hanno i **dati sensibili** (che rilevino la etnia, la religione, l'opinione politica...) che non possono essere trattati senza il consenso esplicito dell'interessato e l'utilizzo deve avere finalità specifiche.

CAPITOLO IV

GLI ENTI

GLI ENTI: I SOGGETTI METAINDIVIDUALI; CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA:

ENTI NON RICONOSCIUTI: AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA E

IMPERFETTA

ENTE: unità organizzative distinte dai promotori e costituenti

Caratteristiche degli enti:

- **Stabilità**
- **Organizzazione**
- **Autonomia patrimoniale**
- **Scopo:** può essere altruistico/non lucrativo (**enti libro I**, quindi **associazioni, fondazioni, comitati**) o egoistico/lucrativo (**enti libro V**, cioè le **società**)

Tutte queste caratteristiche trovano il loro punto di incontro nel perseguire un **interesse**, che rimane distinto dagli interessi degli individui che compongono l'ente e dall'interesse dell'individuo che ha predisposto la massa patrimoniale autonoma.

L'ente può essere:

- **Riconosciuto:** organizzazione metaindividuale dotata di **personalità giuridica** mediante atto o specifico procedimento (**persona giuridica**)
- **Non riconosciuto:** organizzazione metaindividuale priva di personalità giuridica, ma munita di soggettività pari all'ente riconosciuto (**ente di fatto**)

Evoluzione dell'idea di soggettività giuridica:

in passato l'idea di soggettività giuridica veniva riconosciuta solo alle persone giuridiche, quindi enti riconosciuti, mentre gli enti di fatto venivano considerati privi di capacità giuridica, come dei **non soggetti di diritto**.

Oggi invece entrambi sono dotati di soggettività giuridica, la distinzione tra ente riconosciuto e non si riflette solo l'autonomia patrimoniale, la quale è **imperfetta** negli enti non riconosciuti (partiti, sindacati) e **perfetta** negli enti riconosciuti.

La **soggettività giuridica** degli enti non va quindi confusa con la **personalità giuridica**, la quale non è indispensabile per creare un'organizzazione di persone e beni centro di imputazione unitario.

ENTI RICONOSCIUTI:

- **Istituto della rappresentanza organica:** fenomeno di immedesimazione tra l'individuo che compie atti in nome e per conto dell'ente e l'ente stesso che rappresenta
- Il riconoscimento avviene mediante l'**iscrizione a un pubblico registro** (sistema di pubblicità):
 - Enti del libro I: **registro delle persone giuridiche**
 - Enti del libro V: **registro delle imprese**
- **Autonomia patrimoniale perfetta:** si ha l'esposizione del solo patrimonio dell'ente, quindi senza coinvolgimento del patrimonio personale di amministratori e associati, al soddisfacimento delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente stesso. Vi è quindi un'**incomunicabilità bilaterale delle conseguenze patrimoniali**:
 - I creditori dell'ente non possono avanzare pretese sul patrimonio personale di associati e amministratori
 - I creditori personali degli associati e amministratore non possono avanzare pretese sul patrimonio dell'ente

Ciò che collega questi ultimi due punti è il **controllo dell'ordinamento giuridico sull'ente** per verificare la congruità del patrimonio rispetto allo scopo e la separazione tra patrimonio della persona giuridica e quello dei componenti.

ENTI NON RICONOSCIUTI:

- **Autonomia patrimoniale imperfetta: incomunicabilità non bilaterale**

Il patrimonio dell'ente è insensibile alle pretese dei creditori personali dei componenti e amministratori, ma abbiamo una comunicazione tra patrimonio dell'ente e patrimonio di quei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, che sono:

- Gli amministratori, come accade nelle associazioni non riconosciute
- Non solo gli amministratori, ma anche dei componenti, come accade nella società semplice (livello minimo di autonomia imperfetta)

Quindi non vi è quell'assoluta separazione tra patrimonio dell'ente e quelli di amministratori e componenti

La netta ripartizione delle regole di autonomia patrimoniale in funzione della personalità giuridica subisce talune deroghe:

- **Estensione autonomia patrimoniale imperfetta agli enti riconosciuti:** es. le associazioni di promozione sociale, che possono essere identificate sia come non riconosciute, sia come riconosciute, ma anche in quest'ultimo caso al soddisfacimento delle obbligazioni in nome e per conto dell'ente non è vincolato solo il patrimonio dell'ente, ma anche quello dei rappresentanti
- **Estensione autonomia patrimoniale perfetta agli enti di fatto:** es. consorzi, che possono assumere sia la forma di società di capitali, sia la forma di società per persone, ma in ogni caso i creditori che hanno assunto obbligazioni nei confronti del consorzio possono soddisfarsi solo sul patrimonio dell'ente stesso.

DISTINZIONE TRA ENTI DEL LIBRO PRIMO ED ENTI DEL LIBRO QUINTI DEL

CODICE CIVILE: IL PROBLEMA DELLO SCOPO

La distinzione tra **enti del libro I** ed **enti del libro V** si coglie sul piano dello **scopo**, che è il fine o gamma di fini per il cui conseguimento una pluralità di soggetti si sono associati conferendo denaro o altri diritti di natura economica e predisponendo un'organizzazione stabile.

La distinzione tradizionale è la seguente:

- Enti libro I: **scopo altruistico**
- Enti libro V: **scopo lucrativo**, dove si ha quindi la percezione individuale di utili collegata allo svolgimento di un'attività economica.

La differenza quindi si coglie sul piano della destinazione dello scopo.

Fondamento di questa correlazione è l'**art. 2247**, che fornisce la definizione di società, quindi presuppone il fatto che associazioni e fondazioni non erano idonee a svolgere attività economiche. Questo insegnamento tradizionale è entrato in crisi per via della frequenza con la quale gli enti del libro I svolgano attività economiche.

Oggi infatti si ritiene non più che lo scopo degli enti del libro I debba essere solo uno scopo di utilità sociale, ma piuttosto uno **scopo lecito e quantomeno non strettamente egoistico**.

Quindi si vede che vi è piena compatibilità tra lo scopo di carattere non economico degli enti del libro I e lo svolgimento di un'attività economica, in quanto è ammesso il vantaggio economico

dell'ente, ma non quello del componente/fondatore, in quanto questo vantaggio deve essere sempre destinato al conseguimento dello scopo sociale.

Certe volte comunque, la partecipazione a uno di questi enti può generare un vantaggio economico in capo al singolo: **vantaggio indiretto**, che si tratta di un vantaggio personale, delle conquiste che l'ente ha ottenuto per l'intera categoria.

L'**istituto di trasformazione eterogenea** ha reso possibile la modifica causale da ente lucrativo a ente non lucrativo e viceversa (**articoli 2500 c.c.**)

- **Art. 2500-septies**: consente di trasformare le società di capitali in consorzi, fondazioni non riconosciute, associazioni
- **Art. 2500-opties**: prevede l'operazione inversa.

L'ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Effetti riconoscimento personalità giuridica:

- **Beneficio della responsabilità limitata** per rappresentanti, soci o associati
- **Pubblicità costitutiva**, con riferimento all'acquisto della personalità stessa
- **Pubblicità-notizia** relativa alle caratteristiche salienti dell'ente e i più significativi atti

2 schemi di attribuzione diversi della personalità giuridica:

- **Sistema normativo** (riguarda le società del Libro V): il riconoscimento in questo caso è l'effetto automatico dell'iscrizione nel **registro delle imprese**. È previsto un **controllo di legittimità** come condizione indispensabile al conferimento della personalità giuridica, dove si va a verificare l'adozione della struttura organizzativa prescritta dalla legge e l'effettività della consistenza patrimoniale richiesta.
- **Sistema concessorio** (per gli enti del Libro I): il riconoscimento in questo caso è concesso con un procedimento amministrativo ed è previsto un **controllo di merito**, per verificare la meritevolezza dello scopo e l'adeguatezza del patrimonio.
Oggi il sistema concessorio è disciplinato dal dpr 361/2000, che prevede che il riconoscimento consegue all'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le prefetture. L'accoglimento della domanda di riconoscimento è subordinato a:
 - Al soddisfacimento di condizioni prescritte dalla legge
 - Possibilità/liceità dello scopo
 - Adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

La recente **riforma degli enti del Terzo settore**, i quali sono enti privati diversi dalle società, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, ha introdotto un'ulteriore fattispecie di conferimento della personalità giuridica: infatti questi enti acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al **Registro unico nazionale del Terzo settore**.

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

L'**associazione** è un'aggregazione di individui che si uniscono per il raggiungimento di uno scopo non economico comune.

Per raggiungere questo scopo questi individui costituiscono tramite dei conferimenti il patrimonio dell'associazione stessa, patrimonio necessario e strumentale allo svolgimento dell'attività comune.

L'associazione consta di tre elementi sostanzialmente:

- **Elemento patrimoniale**
- **Elemento teleologico (scopo)**
- **Elemento personale**, il quale è l'elemento principale e tipico dell'associazione, in quanto è richiesta una pluralità di individui

L'**atto costitutivo** ha natura giuridica di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, ed è detto **contratto associativo**. Inoltre ha natura aperta, in quanto l'adesione all'associazione è libera e vi può essere un costante rinnovo e mutamento dell'unione associativa.

L'atto costitutivo deve essere concluso mediante **atto pubblico** e deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, il patrimonio, la sede e le regole di funzionamento e amministrazione.

Oltre all'atto costitutivo è necessario predisporre anche uno **statuto**, che può essere parte integrante del primo o assumere la forma di documento autonomo, nel quale è contenuta la disciplina di dettaglio dell'associazione.

L'associazione è dotata di **organi**, i quali sono individui ai quali è affidata una sfera di competenza.

- **Organo gestorio=amministratori**: ha poteri di rappresentanza e legittimazione a stare in giudizio per l'ente. Questa rappresentanza viene detta **rappresentanza organica**, quindi una vera e propria immedesimazione.

Operano sulla base delle **regole del mandato** e sono responsabili dei danni arrecati all'ente solo se:

- Abbiano partecipato all'atto doloso
- Abbiano avuto certezza del suo compimento senza mostrare dissenso

e inoltre, sono responsabili verso i creditori

- **Organo deliberativo=assemblea degli associati**: è un organo collegiale, formato dagli associati (non solo individui, anche enti), la quale sfera di competenza è estesa a tutte le decisioni di rilievo per l'associazione.

È applicato al funzionamento dell'assemblea il **principio maggioritario**, cioè sono necessarie distinte maggioranze per la valida deliberazione a seconda del tipo di decisione.

- Per quanto riguarda le **materie ordinarie**, il quorum deliberativo richiesto è il voto favorevole della maggioranza, il quorum costitutivo richiesto è la metà degli associati
- Per le **materie importanti**, dove si parla di **assemblea straordinaria**, il quorum costitutivo richiesto è dei 2/3, mentre quello deliberativo è la maggioranza assoluta.

La qualità di associato non è trasmissibile né *inter vivo* né *mortis causa*; l'associato ha diritto di **recesso ad nutum** (senza giustificazione e a propria scelta). Alle associazioni sono inoltre riconosciuti poteri di carattere sanzionatorio e rientranti nella figura della **pena privata**, i quali vanno dal richiamo alla censura e esclusione del singolo associato per motivi gravi.

Estinzione associazione: è governata innanzitutto dall'atto costitutivo e dallo statuto, i quali possono prevedere espressa causa di scioglimento, incluso il decorso di un certo lasso di tempo. La regola generale è però che l'associazione si estingue per il raggiungimento dello scopo, per impossibilità sopravvenuta di perseguirlo o per il venir meno di tutti gli associati.

Dal momento della dichiarazione di estinzione:

- Gli amministratori non possono più porre in essere nuove operazioni

- Si avvia il procedimento della **liquidazione**, quindi si dà luogo al pagamento dei debiti dell'ente e se residuano beni o denaro ha luogo la **devoluzione**, cioè il trasferimento di ciò che residua a un altro ente di carattere economico.

Disciplina associazioni non riconosciute:

secondo l'art 36 c.c. l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione non riconosciuta, nonché la disciplina dei rapporti tra associati e ente sono rimessi all'**autonomia degli associati**.

Come si vede è una disciplina molto scarsa, quindi la giurisprudenza e la dottrina hanno rintracciato tre diversi orientamenti per completare la disciplina delle associazioni non riconosciute:

- **Applicazione diretta:** travaso completo della disciplina delle associazioni riconosciute in quella delle non riconosciute
- **Estensione analogica:** cercare la disciplina nelle disposizioni che disciplinano materie affini (società capitalistiche), nei limiti della compatibilità
- Cercare nei **principi generali in materia di persone giuridiche**

LE FONDAZIONI

Le fondazioni consistono in patrimoni vincolati e destinati a uno scopo di carattere non economico, se non addirittura di utilità sociale.

In questo caso prevale l'**elemento patrimoniale** su quello personale che si esaurisce nell'amministratore/amministratori.

Per quanto riguarda la nascita delle fondazioni, nasce dal gesto di un **fondatore** che estrapola dal proprio patrimonio una massa di beni o di diritti destinandoli a uno scopo non economico. Il fondatore non è un organo ma rimane all'esterno dell'ente, dopo aver fondato l'ente infatti l'amministrazione della massa patrimoniale passa agli **amministratori**, che sono l'unico organo dell'ente.

Procedimento di costituzione:

Va innanzitutto distinto l'**atto costitutivo**, che ha natura giuridica di un atto unilaterale del fondatore, il quale può essere *inter vivos*, quindi assoggettato alla disciplina degli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, o *mortis causa*, quindi assume una delle forme testamentarie. Il contenuto necessario dell'atto costitutivo deve contenere: la denominazione dell'ente; l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede.

Anche nelle fondazioni va redatto uno **statuto** il quale specifica la disciplina della fondazione.

Dall'atto costitutivo va distinto l'**atto di donazione**, il quale è l'atto di disposizione del proprio patrimonio con il quale il fondatore appresta i mezzi necessari al conseguimento dello scopo fissato nell'atto costitutivo.

È essenziale il riconoscimento della **personalità giuridica**, in quanto è condizione fondamentale per la trasformazione della massa patrimoniale in un regime di autonomia patrimoniale perfetta.

L'art 15 c.c. ammette la revoca dell'atto di fondazione fino al momento del riconoscimento.

Profilo organizzativo:

Nelle fondazioni vi è l'assenza di un organo deliberativo, quindi vi è solo la presenza di un **organo esecutivo** cioè gli amministratori. Questo si traduce nell'inesistenza di forme di controllo.

L'art. 25 prevede un sistema di **controllo esterno** affidato all'**autorità governativa (controllo di legittimità)**.

Estinzione:

Le cause dell'estinzione possono essere previste espressamente dall'atto di fondazione o dallo statuto oppure la fondazione può essere estinta per il raggiungimento dello scopo o per la sua sopravvenuta impossibilità.

L'art 28 c.c. Prevede che l'autorità governativa possa disporre la **trasformazione della fondazione**, invece che l'estinzione. L'autorità modifica il corpo della fondazione, che va a individuare nuove finalità, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Dopo l'estinzione ha luogo il divieto di nuove operazioni, la liquidazione e la devoluzione, come nelle associazioni.

Con l'evoluzione sociale è nato un ibrido che avvicina la distanza tra associazioni e fondazioni, queste sono le **fondazioni a base assembleare** ovvero munite di un organo deliberativo.

Inoltre ci sono dei casi dove la legge ha imposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato a intere categorie di enti pubblici la (**privatizzazione**), le cosiddette **fondazioni bancarie**. Es. trasformazione ex casse di risparmio.

I COMITATI

I comitati sono **enti collettivi di carattere congiunturale** costituiti al fine di raccogliere presso la popolazione i fondi necessari per lo svolgimento di un'attività di natura non economica e circoscritta nel tempo, quindi hanno **carattere temporaneo (art. 39 c.c.)**.

Vi sono tre figure all'interno del comitato:

- **Promotori:** enunciano lo scopo perseguito e lanciano la raccolta presso il pubblico dei fondi necessari a formare il fondo comune
- **Gestori:** hanno il compito di amministrare il fondo e perseguire lo scopo

Entrambi questi due hanno la **responsabilità patrimoniale, personale e solidale**.

- **Sottoscrittori:** non entrano a far parte del comitato e fungono da soggetti esterni finanziatori.

Il comitato può essere:

- **Riconosciuto:** acquista autonomia patrimoniale perfetta e la forma giuridica dell'associazione o della fondazione
- **Non riconosciuto:** acquista autonomia patrimoniale imperfetta e promotori e gestori rispondono personalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del comitato.

L'autorità governativa può predisporre la **devoluzione del fondo del comitato** quando vi è l'insufficienza dei fondi raccolti, la sopravvenuta impossibilità o la impossibilità di raggiungimento dello scopo.

Il carattere connotativo del comitato è quello personale o patrimoniale? Dipende dai casi

- Nella fase di istituzione è il carattere personale, sicché il comitato si presenterebbe come una sorta di **associazione atipica**
- Nella fase di impiego dei fondi è il carattere patrimoniale, in quanto assume la forma di una **fondazione di fatto**

CENNI SUGLI ENTI PUBBLICI

Secondo l'art. 11 c.c. gli enti pubblici sono necessariamente persone giuridiche e sono assoggettati a una disciplina diversa rispetto agli enti privati, ovvero al diritto amministrativo.

Gli enti pubblici possono essere **territoriali** (regioni, città metropolitane, comuni), e in questo caso si occupano del governo della comunità locale e i loro atti normativi hanno efficacia solo nel proprio territorio, o **non territoriali**.

Inoltre gli enti pubblici possono distinguersi in:

- **Economici**: cioè attuano forme di intervento pubblico nell'economia e si caratterizzano per l'esercizio in via principale di un'impresa, adottando anche strumenti di diritto privato
- **Non economici**: carattere residuale

Gli enti pubblici, in definitiva, godono sia di una capacità giuridica di diritto pubblico, sia capacità giuridica di diritto privato.

CAPITOLO V

I SOGGETTI DI MERCATO

LO STATO E IL MERCATO

Il **mercato** è il complesso degli scambi e delle altre operazioni economiche compiute in un determinato ambito territoriale o comparto merceologico.

Il mercato è preesistente al capitalismo e all'affermarsi degli stati nazionali, e quindi il nascere successivo di un soggetto giuridico sovrano si è ovviamente ripercosso sul mercato.

Lungo la storia di sono stata diverse concezioni del ruolo statale nella regolamentazione dei rapporti economici.

- **Stato liberale:** qui si ha un spontaneismo del mercato; lo stato deve astenersi dal regolamentare il mercato o la redistribuzione della ricchezza, deve avere un solo ruolo fiscale. (mano invisibile)
- **Stato corporativo:** si è affermato in Italia durante lo stato fascista, e i principali scopi erano stabilire relazioni tra stato e forze economiche, ordine nel sistema economico e inglobazione attività economica nella struttura burocratica dello stato.
- **Stato sociale:** nato dall'esigenza di interventi pubblici e privati; si ha un principio di uguaglianza sostanziale, quindi il riconoscimento dei diritti sociali e i doveri di contribuzione. Le conseguenze di questo tipo di stato furono: una segmentazione delle forme protettive (squilibrio prestazioni) e un aumento della spesa pubblica
- Così si passa allo **stato dispensatore di beni**, che nasce dall'insieme delle forme d'intervento dello stato sociale e dello **stato dirigista/imprenditore**. Qui abbiamo degli interventi statali diretti al finanziamento pubblico delle imprese private e delle norme imperative per disciplinare l'iniziativa economica dei soggetti privati.
- Negli anni 70 si è affermato lo **stato programmatore**, dove la legge determina i programmi e controlli più opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali
- Nell'epoca attuale possiamo dire che si è affermato uno **stato regolatore**, che svolge quindi un'attività di regolazione dell'attività economica per il ripristino di condizioni di concorrenza dinamica.

Con la globalizzazione lo stato è incapace di fronteggiare con gli strumenti di diritto interno i rapporti economici oltre i confini e quindi ha dislocato le scelte di economia in sedi più ampie, come l'UE, divenendo uno **stato esecutore**, quindi adegua le proprie politiche e ordinamento alle scelte dell'Ue.

LA CONCORRENZA

La **concorrenza** è la possibilità riconosciuta ad ogni impresa di accedere al mercato e di competere con le altre.

Il **principio della libera concorrenza** è il corollario della **libertà di iniziativa economica (art. 41 cost)**, dove gli unici limiti sono: l'utilità sociale e il rispetto della libertà, sicurezza e dignità della persona umana.

La concorrenza non è una condizione naturale dei mercati, infatti comporta la necessità di un controllo e correzioni costanti del potere pubblico: in questo modo si è costituita un'apposita autorità, cioè l'**Autorità Garante della concorrenza e del mercato**.

L'AGCM ha introdotto diverse normative, come quella antitrust, la quale vieta le intese anticoncorrenziali e l'abuso di posizione dominante, la normativa a tutela del consumatore e la disciplina delle clausole abusive e pratiche commerciali scorrette.

L'ordinamento italiano si è munito di strumenti adeguati per fronteggiare i fenomeni distorsivi del mercato.

Il codice civile al TITOLO X del LIBRO V presenta 4 segmenti normativi fondamentali:

- 1) **Limiti legati alla concorrenza (art. 2595 c.c.):** La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia statale e nei limiti previsti dalla legge. Questa norma è stata poi assorbita dall'art 41 della costituzione, il quale pone limiti all'iniziativa economica.
- 2) **Limiti contrattuali della concorrenza (art. 2596 c.c.):** la norma disciplina il **patto di non concorrenza** (cioè una clausola contrattuale che impedisce al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con l'azienda del suo datore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro), il quale è valido se circoscritto a una determinata zona o attività e non può durare per più di 5 anni.
- 3) **Obbligo di contrarre del monopolista (art. 2597 c.c.):** il quale ha la funzione di tutelare il consumatore rispetto ad abusi provenienti dal monopolista
- 4) **Atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.):** la norma elenca gli atti di concorrenza sleale che integrano l'**illecito concorrenziale**. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con colpa e dolo, l'autore è tenuto al risarcimento del danno (art. 2600 c.c.).

I SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI DEL MERCATO

I **soggetti di mercato** sono persone fisiche e organizzazioni superindividuali pubbliche o private che svolgono un qualche ruolo nel mercato stesso.

Quali sono i soggetti di mercato?

- **Consumatore:** colui che consuma per soddisfare i suoi bisogni
- **Produttore:** il quale può agire come singolo o organizzazione di impresa
- **Intermediario:** soggetto che mette in collegamento consumatore e produttore
- **L'impresa:** che può essere
 - Privata: espressione della libera iniziativa economica
 - Pubblica: costituisce attività economica esercitata da un **ente pubblico economico** per il perseguimento di uno scopo di lucro in regime di concorrenza
- **Professionista:** tutti i soggetti che offrono beni o servizi sul mercato
- **Enti:**
 - No profit: soggetti del terzo settore
 - Imprese sociali: forme organizzative a base democratica che hanno un fine solidaristico
- **Autorità indipendenti:** funzione di regolazione del mercato (AGCM, AGCOM): sono enti pubblici dotati di **personalità giuridica** e titolari di funzioni amministrative, normative e giurisdizionali in ambiti di relazioni economiche. Godono di **autonomia dal governo**, quindi svolgono il loro ruolo con neutralità.
- **Agenzie di rating:** svolgono un **ruolo informativo** nell'ambito dei mercati finanziari internazionali e esprimono giudizi sull'**affidabilità** delle società private e stati nazionali in quanto emittenti di strumenti finanziari.

L'IMPRESA:

L'**art. 2082 c.c.** identifica l'impresa incentrando la nozione sulla figura dell'**imprenditore** e con lo **svolgimento professionale e organizzato dell'attività economica finalizzato alla produzione di beni e allo scambio di beni e servizi**.

L'impresa si compone di tre elementi essenziali:

- 1) **Attività economica:** intesa come pluralità di atti collegati e preordinati a uno scopo. Il connotato dell'economicità è collegato allo **scopo** dell'attività, il quale è la produzione e scambio di beni e servizi.
La nozione di impresa è unitaria quindi viene utilizzata anche per quelle attività economiche volte al perseguimento di finalità senza scopo lucrativo.
- 2) **Organizzazione:** implica l'adozione di un **sistema gerarchico** che vede al suo vertice l'imprenditore.
- 3) **Professionalità:** questo carattere dipende dall'**abitudine**: l'attività deve essere svolta in modo stabile, anche se ciò non implica anche la natura continuativa (es. imprese stagionali)

L'impresa presuppone l'imputazione degli atti che compongono l'attività economica a un soggetto individuale o meta-individuale, quindi è necessaria la **spesa del nome dell'imprenditore**.

L'**imprenditore occulto** è invece chi finanzia e svolge l'attività economica i cui atti sono però imputati a un prestanome.

Lo **statuto generale dell'impresa** permette l'applicazione di norme comuni, ci sono però delle distinzioni di norme di natura speciale:

- In base all'oggetto dell'attività svolta: distinzione tra **imprenditore commerciale** e **imprenditore agricolo**
- In base alle dimensioni dell'impresa: distinzione tra **medio imprenditore, imprenditore medio-grande e macro imprese** (introdotta dal diritto privato europeo)

Lo **statuto dell'impresa commerciale** si affianca a quello generale dell'impresa per ampiezza dell'ambito e riguarda:

- Iscrizione nel registro delle imprese
- Obbligo di tenuta delle scritture di bilancio e contabili
- Assoggettamento al fallimento

La nozione di imprese va completata con quella di **azienda** (art. 2555 c.c.), che è il complesso di beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Questi beni possono essere:

- Materiali, mobili, immobili, mobili registrati
- Immateriali: come le opere di ingegno, che sono coperte dal **diritto d'autore**, e le invenzioni industriali che sono coperte dal **diritto di brevetto** e dal **diritto di proprietà industriale**.
- Diritti di credito e rapporti contrattuali

Il codice civile disciplina vari aspetti dell'azienda: gli oneri formali (art. 2556 c.c.), il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.), le successioni nei debiti/crediti/contratti dell'azienda ceduta (artt. 2558 a 2560 c.c.)...

I **segni distintivi dell'impresa** la identificano agli occhi del pubblico e sono:

- **Ditta:** segno identificativo sotto il quale l'azienda svolge la sua attività. Deve contenere il nome e la sigla dell'imprenditore a cui si possono affiancare parole liberamente scelte.
La ditta può essere:
 - Individuale
 - Collettiva: in questo caso prende il nome di **ragione sociale** nelle società di persone e **denominazione sociale** nelle società di capitali.

- **Insegna:** consiste nelle parole o nel disegno grafico che identificano i locali dove si svolge l'impresa
- **Marchio:** segno che contraddistingue i prodotti e i servizi dell'impresa dalle altre imprese. Possono essere:

- Denominativi: composti da parole
- Figurativi: costituiti da immagini o segni

La **registrazione del marchio** deve essere effettuata nelle forme stabilite dalla legge e comporta l'acquisto da parte dell'impresa del diritto di utilizzarlo e disporne in esclusiva.

I requisiti per la sua registrazione sono: **novità, capacità distintiva e liceità**.

Secondo l'art. **2571 c.c.**: chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuarlo a usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui precedentemente se ne sia avvalso.

Il **marchio collettivo** svolge la funzione di assicurare che i beni/servizi contrassegnati abbiano particolari caratteristiche, l'uso in questo caso è plurimo (es. parmigiano reggiano)

Il marchio si estingue per **decadenza**, quindi per non uso entro 5 anni dalla registrazione, per illiceità sopravvenuta o volgarizzazione.

Intorno alla figura del marchio è nato un contratto atipico, il **merchandising**: è un contratto attraverso il quale il titolare di un segno distintivo cede ad un altro imprenditore il diritto alla sua utilizzazione per contrassegnare i prodotti in un settore diverso rispetto a quello originario, al fine di trarne un tornaconto economico.

Il contratto di *merchandising* ha alcune affinità con il **contratto atipico di licenza d'uso (licensing)**, ovvero il contratto con il quale il titolare del marchio ne concede la facoltà di utilizzo ad un altro soggetto affinché quest'ultimo lo apponga su prodotti identici o simili a quello per cui è stato creato con lo scopo di espandere la presenza del marchio sul mercato.

Un altro contratto atipico è la **sponsorizzazione**: attività di diffusione di un messaggio commerciale attraverso la realizzazione di un evento nei quali partecipa il soggetto che diffonde il messaggio, che è terzo rispetto all'impresa.

Di fianco ai segni distintivi, il codice disciplina anche i **brevetti per invenzioni industriali** e il **diritto d'autore sulle opere d'ingegno**, i quali rientrano nella **proprietà intellettuale**, cioè il complesso di diritti assegnati al titolare di tali beni. Tra questi diritti rientrano:

- **Diritto morale d'autore:** diritto al titolare di essere riconosciuto autore dell'opera ed è trattato come diritto della personalità
- **Diritto esclusivo dell'utilizzazione economica:** diritto esclusivo di sfruttare l'opera economicamente (una sorta di monopolio legale), tranne in alcune eccezioni:
 - **Contratto di edizione:** l'autore concede a un editore il diritto di sfruttamento dell'opera ai fini della sua pubblicazione e commercializzazione
 - **Licenza di brevetto:** con il quale il titolare concede a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione.

Per le opere di ingegno l'acquisto a titolo originario dell'esclusiva avviene con la semplice creazione, mentre per le invenzioni industriali, l'esclusiva è subordinata al conseguimento del brevetto, concesso **dell'ufficio italiano dei brevetti e dei marchi**.

LA SOCIETÀ E LE SUE TIPOLOGIE

L'impresa può essere svolta sia in forma individuale sia in forma collettiva, ora bisogna soffermarsi sulle strutture organizzative dell'impresa collettiva.

La forma più comune è sicuramente quella della **società**, forma giuridica più diffusa, ma non è di certo l'unica perché l'impresa, come già detto, può assumere anche la forma giuridica delle associazioni o delle fondazioni.

Il modello generale di società si può articolare in:

- **Società di persone** (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)
- **Società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione)

ART 2247 c.c.: definisce la società come **il contratto col quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.**

Si tratta dunque di un **contratto associativo**, per lo più plurilaterale con comunione di scopo.

C'è da sottolineare anche il fatto che il diritto europeo ha introdotto la **società unipersonale**, e quindi ora è possibile costituire la società per azioni o a responsabilità limitata tramite un **atto unilaterale**.

Nella società semplice non è richiesta la forma scritta; mentre per la società in nome collettivo e nella società in accomandita semplice la forma scritta non è imposta esplicitamente dalla legge, ma implicitamente a causa dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; per le società di capitali è richiesta invece la forma solenne dell'atto pubblico.

La società può anche presentarsi come un **atto costitutivo** di una stabile organizzazione metaindividuale destinata ad assumere una soggettività distinta da quella dei soci, sia nelle società di persone che hanno l'assenza di personalità giuridica, sia nelle società di capitali, che invece sono muniti di personalità giuridica.

Elementi che caratterizzano la società:

- **CONFERIMENTO DI BENI E SERVIZI**

La società si deve dotare di un **patrimonio sociale**, quindi ciascun socio si obbliga ad effettuare una prestazione economica, detta **conferimento**, che può consistere in:

- Prestazione traslativa: trasferimento della titolarità di beni materiali, immateriali, di diritti di credito. Ciò produce un effetto reale che determina il trasferimento dei diritti ceduti dalla sfera giuridica del socio a quella della società.
- Obbligazione pecuniaria: trasferimento di una somma di denaro; in questo caso l'effetto del trasferimento è di natura obbligatoria.
- Obbligazione di fare: il socio si obbliga a fornire un servizio o prestazione lavorativa a favore della società (**socio d'opera**)

Il patrimonio sociale consiste inizialmente nel complesso dei conferimenti effettuati dai soci, ma esse è destinato a variare in base all'andamento.

Dal patrimonio sociale va distinto il **capitale sociale**, che indica la consistenza patrimoniale minima che la società garantisce ai terzi di essere dotata in modo che sappiamo quale sia l'entità patrimoniale su cui possono fare affidamento per il soddisfacimento dei loro crediti e indica la misura al di sotto del quale il patrimonio sociale non deve scendere.

- **ESERCIZIO COMUNE DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA**

Ciò implica che tutti i soci assumano il rischio d'impresa e una conferma di ciò la si ricava dal **divieto di patto leonino**, il quale colpisce di nullità il patto inserito nel contratto di società col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione alle perdite o agli utili (art 2265 c.c.)

L'attività economica sociale integra l'**oggetto sociale**, che deve essere identificato nell'atto costitutivo della società; sono nulli sia i contratti con oggetto generico sia quelli con oggetto plurimo, ovvero con attività del tutto diverse tra loro.

- **LO SCOPO**

All'oggetto sociale è strettamente correlato lo **scopo**, che è la finalità perseguita dallo svolgimento in comune dell'attività economica.

La definizione posta dall'art 2247 c.c. si presenta restrittiva, perché identifica lo scopo nel mero scopo lucrativo soggettivo, ovvero nell'interesse dei soci a conseguire gli utili ricavati dall'attività di impresa svolta dalla società, quando si è già chiarito che l'attività di impresa può coincidere anche con uno scopo di lucro oggettivo, ossia il conseguimento di proventi anche se non destinati al percepimento individuale, purché sia svolta nel rispetto del **criterio di economicità** (copertura costi con ricavi).

ART 2249 c.c. illustra la distinzione più rilevante tra **società commerciali** (società di persona e società di capitali) e **società non commerciali** (tradizionalmente identificate nella società agricola).

LE SOCIETA' DI PERSONE.

Nelle società di persone i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte dalla società qualora il patrimonio di quest'ultima risulti insufficiente per l'adempimento. La regola della **responsabilità illimitata** può incontrare una deroga qualora l'atto costitutivo la escluda per i soci che non hanno assunto l'obbligazione in nome e per conto della società.

Si tratta di società che non hanno personalità giuridica e hanno un'**autonomia patrimoniale imperfetta**.

- **LA SOCIETA' SEMPLICE**

Individua la società che non presenta elementi ulteriori rispetto a quelli contemplati dall'art 2247 c.c.

E' definita come la società che non ha per oggetto un'attività commerciale e per l'esercizio della quale le parti non hanno preferito un'altra forma di società.

Il socio effettua il conferimento ed è anche amministratore della società. Esistono due modi di gestione della società semplice:

- **Amministrazione disgiuntiva**, dove ogni amministratore può da solo decidere e stipulare atti in nome della società
- **Amministrazione congiuntiva**, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto.

Tutti i soci (ai sensi dell'art 2266 c.c.) hanno funzione rappresentativa.

Il carattere personale della società semplice si riflette anche sulla morte, recesso e esclusione del singolo socio.

- **Morte del socio**: gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi.
- **Recesso del socio**: determina lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio, quindi la facoltà di sciogliere unilateralmente il suo vincolo con la società in ogni momento.

- Esclusione del socio: che può avvenire sia per un grave inadempimento, sia dell'intervenuta limitazione della capacità di agire, sia dalla sopravvenuta impossibilità di effettuare il conferimento.

L'**estinzione** della società semplice può avvenire per: decorso del termine, conseguimento oggetto sociale e sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, altre cause previste dal contratto sociale (art 2272 c.c.).

- LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Può avere ad oggetto ogni attività, quindi anche commerciale e in questo tipo di società tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed è inefficace nei confronti di terzi ogni patto contrario.

Per l'atto costitutivo è richiesta l'iscrizione del registro delle imprese, pena l'**irregolarità** della società.

Si estingue per le medesime ipotesi della società semplice, oltre che per la dichiarazione di fallimento e provvedimento autorità governativa.

- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci che devono essere menzionate nell'atto costitutivo:

- **Soci accomandatari**: risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali e sono i naturali amministratori della società.
- **Soci accomandanti**: risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita e non hanno né l'amministrazione né la rappresentanza della società, almeno che non gli venga attribuita tramite procura speciale dagli accomandatari.

Per tutto ciò non espressamente disciplinato si applicano le norme inerenti alla società in nome collettivo. L'estinzione della società, oltre che per i casi già visti, può avvenire anche nel caso in cui rimangano solo soci accomandanti o accomandatari.

LE SOCIETA' DI CAPITALI

Nelle società di capitali il socio è responsabile per le obbligazioni sociali nei limiti di quanto ha conferito e non è automaticamente amministratore della sua società, in quanto l'amministrazione è attribuita **all'assemblea dei soci**.

Le società di capitali posseggono la cosiddetta **personalità giuridica**, la quale porta con sé il concetto di **autonomia patrimoniale perfetta**.

- SOCIETA' PER AZIONI:

costituisce il prototipo delle società di capitali e l'art 2325 c.c. enuncia la regola dell'autonomia patrimoniale perfetta "per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, salvo il caso in cui tutte le azioni appartengono a un solo socio".

Le **azioni** rappresentano la quota di partecipazione del socio alla società e sono dei **titoli di credito** nominativi.

La **costituzione** della società va scandita nelle seguenti fasi:

1. Stipulazione **atto costitutivo**, che deve essere redatto nella forma di atto pubblico
2. Realizzazioni delle condizioni richieste per la costituzione (es. il capitale sottoscritto deve essere almeno di € 50.000)
3. Iscrizione nel **registro delle imprese**, che determina l'acquisto della personalità giuridica.

Le azioni hanno uguale valore e attribuiscono uguali diritti, come:

- **Diritto patrimoniale:** tra cui il diritto alla parte proporzionale degli utili
 - **Diritto di opzione:** diritto di venire preferiti a terzi nell'emissione di nuove azioni.
 - **Diritto di voto** (salvo per i possessori di **azioni senza diritto di voto**)
- E altri...

Il **capitale sociale** costituisce la garanzia patrimoniale per i terzi con cui la società intreccia rapporti obbligatori. L'aumento di esso avviene di norma tramite l'emissione di nuove azioni o di obbligazioni.

L'**assemblea** è formata dai possessori di azioni con diritto di voto e il potere decisionale è regolato dal **principio maggioritario** e il numero dei voti viene calcolato in proporzione alle azioni possedute da ciascun socio. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda della materia trattata.

Nelle società di capitali vi è una netta separazione tra il complesso dei soci e l'organo amministrativo, a differenza della società di persone.

Gli amministratori hanno la **rappresentanza della società** e sono responsabili dei loro atti nei confronti della società, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi.

Il controllo sulla società viene affidato al **collegio sindacale**, che vigila sulla corretta osservanza della legge e dello statuto, che è diverso dal **revisore legale**, che controlla la correttezza della contabilità sociale e del bilancio.

Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.):

- Decorso del termine
 - Conseguimento oggetto sociale e la sua sopravvenuta impossibilità
 - Riduzione capitale sociale al di sotto del minimo legale
 - Espressa volontà assemblea
- **SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI**
 Coniuga alcune caratteristiche della società di persone (ovvero come nella società in accomandita semplice dove vi è la presenza di due tipologie di soci: **accomandati** e **accomandatari**) e alcune caratteristiche della società per azioni (le quote di partecipazione sono rappresentate da **azioni**).
 - **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
 Coniuga i vantaggi della società per azioni (**autonomia patrimoniale perfetta**) con la facilità di gestione propria delle società di persone.
 L'art 2463 c.c. impone la forma dell'atto pubblico per l'atto costitutivo e il capitale sociale deve essere almeno pari a € 10.000, tranne nel caso in cui i soci non vogliano dare vita ad una **società a responsabilità limitata semplificata**.

SOCIETA' A SCOPO MUTUALISTICO: Ovvero che forniscono direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. (non hanno scopo di lucro)

- **SOCIETA' COOPERATIVE:** costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la **cooperativa** è sorta.
- **MUTUE ASSICURATRICI:** hanno lo scopo di fornire ai soci delle prestazioni tipiche dell'assicurazione contro i danni, quindi si ha la coincidenza della qualità di socio con quella di assicurato.

L'ORGANIZZAZIONE RETICOLARE D'IMPRESA

Le imprese possono ricorrere a forme di collaborazione volte a realizzare un'organizzazione reticolare e gli strumenti giuridici per realizzare una tale organizzazione sono:

- IL CONTRATTO DI CONSORZIO (art 2602 c.c.): con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Se gli imprenditori che partecipano al consorzio vogliono entrare in rapporto con terzi possono dare vita a un *consorzio con attività esterna* e in tal caso un estratto del contratto deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese. Non costituisce una persona giuridica, ma gode di autonomia patrimoniale perfetta.
- RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI: istituto mediante il quale un'impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti necessari per partecipare a una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese in vista della partecipazione alla specifica gara.
- DISTRETTI PRODUTTIVI: non consistono in un contratto, ma in libere aggregazioni di imprese a livello territoriale finalizzate all'accrescimento dello sviluppo delle aree di riferimento o al miglioramento dell'efficienza/organizzazione delle imprese.
- JOINT VENTURE: contratto di collaborazione tra due imprese al fine del raggiungimento di un determinato scopo o progetto.
- CONTRATTO DI RETE: Con il **contratto di rete** due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e può prevedere anche l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

LA CRISI D'IMPRESA

L'attività d'impresa comporta necessariamente un'estesa esposizione debitoria e questa realtà ha indotto il legislatore a dare rilievo alla fattispecie della **crisi d'impresa**, con l'obiettivo principale di tutelare l'interesse dei creditori.

Il fallimento presuppone lo **stato d'insolvenza** dell'imprenditore e non tutte le imprese sono soggette a fallimento, infatti la procedura trova applicazione soltanto nei confronti degli **imprenditori commerciali**.

Nel caso di impresa societaria il fallimento si estende ai soci personalmente e illimitatamente responsabili delle società commerciali, e non soltanto ai soci palesi, ma anche ai soci occulti.

La *ratio* del fallimento consiste nel dissolvimento dell'impresa considerata irrimediabilmente disestata tramite la liquidazione e la ripartizione tra i creditori del suo patrimonio.

Ai fini del fallimento è nominato un **curatore**, che è l'organo che ha il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio dell'imprenditore fallito.

EFFETTI FALLIMENTO:

- **Spossessamento** dei beni, salvo quelli strettamente personali e nella conseguente perdita dell'**amministrazione** e della **disponibilità** degli stessi.
- Il fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul passivo del fallito. Qui si possono distinguere i **creditori privilegiati** (coloro che saranno soddisfatti prima degli altri per avere un diritto di prelazione) e i **creditori chirografari** (che non hanno alcun diritto di prelazione e quindi saranno soddisfatti dopo i privilegiati)

- Il fallimento incide sui rapporti contrattuali in corso, i quali rimangono sospesi fino a quando il curatore non dichiara di subentrarvi al posto del fallito, ma alcune tipologie di contratto (*contratto di conto corrente bancario, di borsa a termine*) si sciolgono di diritto a seguito della dichiarazione di fallimento.

Il curatore può avvalersi del duplice strumento della:

- AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA (art. 2901 c.c.): mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori.
- AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE: mediante la quale tutti gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell'anno o nei sei mesi antecedenti il fallimento, sono dichiarati inefficaci.

Il fallimento si conclude quando si ricorre a una delle seguenti ipotesi:

- nessun creditore ha fatto domanda di ammissione al passivo fallimentare;
- è terminato l'attivo, vale a dire non è rimasto più nulla da distribuire ai creditori del fallito;
- l'attivo è così esiguo che la prosecuzione della procedura di fallimento non consentirebbe di soddisfare alcun creditore;
- nella migliore delle ipotesi, sono stati pagati sia i debiti ammessi nello stato passivo che le spese da rimborsare in prededuzione.

La chiusura del fallimento può avvenire anche per mezzo del **concordato fallimentare**, che consiste in un accordo tra il curatore e il comitato dei creditori volto alla soddisfazione dei crediti in una determinata misura percentuale.

Una procedura concorsuale (che sono le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori) alternativa al fallimento è la **liquidazione coatta amministrativa**, che, da un lato, determina la liquidazione dei beni dell'imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della **par conditio creditorum** (parità di trattamento dei creditori, i quali non possono far valere individualmente le proprie pretese), e, dall'altro, si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, anche prima dell'interesse della classe creditoria, è l'interesse pubblico legato alla natura o all'attività dell'impresa.

Le procedure concorsuali non mirano soltanto alla liquidazione del patrimonio, ma anche al risanamento dell'impresa e da ciò la previsione delle **procedure non liquidatorie**:

- **concordato preventivo**: è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, **per evitare la dichiarazione di fallimento** attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie.

Si chiama "preventivo", appunto, per questa sua principale funzione di prevenire la più grave procedura fallimentare che potrebbe seguire ad uno stato di dissesto finanziario.

- **Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**: è la procedura non liquidatoria riservata alla grande imprese commerciale insolvente e ha una procedura bifasica:
 - FASE GIUDIZIALE: è la fase di dichiarazione dello stato di insolvenza, dove il Tribunale d'ufficio su richiesta dei creditori o del debitore o del PM, emette una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
 - FASE AMMINISTRATIVA: è la fase di apertura dell'amministrazione straordinaria vera e propria, dove il Ministero dello Sviluppo economico nomina i **commissari straordinari**, ai quali è affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni

dell'imprenditore insolvente, e il **comitato di sorveglianza**, che ha funzioni consultive.

L'amministrazione straordinaria può avere esito negativo, e in questo caso il Tribunale converte l'amministrazione straordinaria in fallimento, oppure esito positivo e in questo caso il Tribunale dichiara la chiusura della procedura.

Con l'entrata in vigore del nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (2019) si è andato a sostituire la **legge fallimentare**, e tra le principali novità spiccano:

- a) La sostituzione del termine fallimento con l'espressione "**liquidazione giudiziale**"
- b) L'introduzione di un sistema di allerta della crisi d'impresa, affinché si possa intervenire in tempo per evitare l'insolvenza. L'allerta è una sorta d'avviso che comunica all'imprenditore che sono stati superati gli **indicatori di crisi**.
- c) La previsione di una corsia preferenziale per le procedure che mirano alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
- d) **Composizione assistita della crisi d'impresa**: è un procedimento attivabile su istanza del debitore finalizzato al raggiungimento dell'accordo con i creditori con l'ausilio dell'OCRI (**Organismo di composizione della crisi d'impresa**), a cui è affidato il compito di assistere l'imprenditore nello svolgimento delle trattative al fine del superamento della crisi.

GLI ENTI NO-PROFIT

Gli enti no-profit compongono il c.d. **Terzo settore** ed è una categoria che si connota per:

- La natura privatistica degli enti
- La loro finalità socialmente rilevate, se non addirittura di utilità sociale
- Il divieto di distribuzione degli utili tra i partecipanti all'ente
- L'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività socialmente rilevanti.

Le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** possono assumere la forma giuridica di associazioni, comitato, fondazione o società cooperativa.

La materia del Terzo settore trova la sua regolamentazione nel **Codice del terzo settore**.

Sono enti del Terzo settore per esempio le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni.

Una previsione apposita è dedicata agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sono assoggettati alle norme del codice del Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle sole attività di interesse generale, per le quali devono adottare un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice stesso.

Gli enti del Terzo settore possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che questo sia ammesso nell'atto costitutivo e che comunque siano subordinate o strumentali all'attività di interesse generale.

IL PROFESSIONISTA E IL CONSUMATORE

Professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.

La nozione di consumatore non fornisce indicazioni sufficienti per identificare uno specifico soggetto e assegnargli un rango di classe sociale, perché chiunque è destinato ad assumere i panni di consumatore quando conclude un contratto per soddisfare un proprio bisogno.

Un divario sulla nozione di consumatore c'è stato tra, da un lato la Corte di giustizia europea e dottrina, che hanno riconfermato l'identificazione del consumatore con la persona fisica, e dall'altro il diritto privato europeo che ha ritenuto di estendere le discipline a tutela del consumatore anche alla c.d. **microimpresa**.

CAPITOLO XII

I BENI

I BENI

Nel linguaggio del legislatore italiano il termine “bene” è utilizzato in due diverse accezioni:

- La prima è quella attestata dall'**art 810 c.c.**, ovvero **sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti**. I beni dunque sarebbero un sottoinsieme delle **cose**, in quanto per “cosa” si intende una parte di materia.
- Una seconda accezione di bene è che per bene si può intendere una qualsiasi utilità economica che può formare oggetto di diritti.
Per esempio nell'art 2555 c.c. che definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, utilizza sicuramente questa seconda accezione di bene.

La fotografia di questo articolo del 1942 inquadra una parte sempre minore di mondo, non è una nozione sbagliata, ma viene dato per scontato che i beni siano sottoinsiemi di cose, quindi materiali. Non tutto quello che viene inteso come bene è materiale, oggi ci sono molti **beni immateriali**: crediti, oppure i diritti che tutelano le opere dell'ingegno, le invenzioni industriali, i segni distintivi. Sicuramente il panorama tende ad ampliarsi man mano che lo sviluppo tecnologico genera nuovi beni.

Non tutte le cose possono formare oggetti di diritti, dunque non tutte le cose sono beni.

Alcuni beni non possono formare oggetti di diritti perché il loro godimento non è fonte di conflitto di interessi, per esempio il sottosuolo o lo spazio aereo (art. 340 c.c.).

Allo stesso modo si è ragionato per cosa come l'aria e l'acqua del mare. Si parla per indicare tali beni di **cose comuni a tutti** (*res communes omium*).

Altre cose sono sottratte al novero dei beni per una precisa scelta dell'ordinamento che ha inteso sottrarle a una qualsiasi forma di appropriazione, ciò vale per esempio per le parti del corpo umano (salvo limitate ipotesi per parti che si rigenerano, come i capelli).

(**art.5 c.c.: atti di disposizione del proprio corpo** sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume).

Sono beni anche le cose che in un certo momento non costituiscono oggetti di diritti, ma sono suscettibili a diventarlo, si parla di **cose di nessuno** (*res nullius*). Sono cose di nessuno le cose abbandonate intenzionalmente dal proprietario (*res derelictae*).

I pesci per esempio sono ancora qualificati oggi come *res nullius*.

E' importante sottolineare che una cosa può essere qualificata come bene anche se non può essere oggetto di proprietà privata:

nell'ordinamento italiano sussistono, accanto ai beni privati, anche i **beni pubblici**:

- **Patrimonio disponibile**: sono beni di cui possono essere titolari gli enti pubblici che non sono direttamente e immediatamente destinati a finalità pubbliche, pertanto questi beni possono essere oggetto di alienazione a privati o trasferimento ad altre Amministrazioni.
- **Beni demaniali** (elencati all'**art. 822 c.c.** a cui si aggiungono i beni demaniali degli enti locali di cui all'**art 824 c.c.**): sono inalienabili e possono formare oggetto di diritti di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, inoltre non possono essere acquistati per usucapione.

Si possono distinguere in:

- o **Demanio necessario**: composto da quei beni che non possono che appartenere a un ente pubblico, come il lido del mare, i fiumi, i laghi...

- **Demanio accidentale:** composto da quei beni che per loro natura potrebbero appartenere anche a un privato, ma fanno parte del demanio solo in quanto appartengono a un ente pubblico, come le strade, gli acquedotti... solo per questi è possibile la **sdemanializzazione (art 829)**, cioè il passaggio del bene dal demanio al patrimonio.
- **Patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.):** sono per esempio le miniere, le caserme, gli armamenti, le navi da guerra... e non possono essere sottratti dalla loro destinazione se non nei modi stabili dalla legge.

Diversi dai beni pubblici sono:

- Gli **usi civici:** facoltà di godimento su determinati territori di proprietà pubblica o privata (es. diritto di una certa frazione comunale di raccogliere la legna in un determinato bosco)
- Le **proprietà collettive:** il territorio appartiene alla stessa collettività di beneficiari che ne godono in genere in modo turnario oppure per zone.

Entrambi questi diritti collettivi sono inalienabili e imprescrittibili, ma il legislatore ne ha prescritto l'eliminazione.

CATEGORIE DI BENI MATERIALI

Distinzione tra **beni mobili** e **beni immobili (art. 812 c.c.):**

- Sono **beni immobili** il suolo e tutto ciò che artificialmente o naturalmente è incorporato al suolo (il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici), sono altresì beni immobili anche gli edifici galleggianti che sono stabilmente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Ovviamente gli edifici e gli alberi sono beni immobili fino a quando sono incorporati al suolo.
- Sono **beni mobili** tutti gli altri beni che non ricadono nella definizione di beni immobili.

Avendo i beni immobili un apprezzabile valore economico e non se destinati a una rapidissima circolazione, è stato approntato per essi un apparato amministrativo che provvede ad annotarne in appositi registri (**pubblici registri immobiliari**) le vicende giuridiche: **pubblicità immobiliare**.

Se il bene non viene trascritto nei pubblici registri non è opponibile a terzi.

Il regime della pubblicità è stato esteso anche ad alcuni beni mobili, come le navi, gli aeromobili o gli autoveicoli, si parla in questo caso di **beni mobili registrati (art. 815 c.c.)**.

Distinzione tra **beni consumabili** e **beni inconsumabili:**

- I **beni consumabili** sono quelli in cui l'utilizzo di essi porta a venir meno dello stesso bene, quindi l'utilizzo del bene porta alla sua consumazione (cibo, benzina)
- I **beni inconsumabili** sono quei beni che possono essere utilizzati senza che ci sia un qualsiasi tipo di riflesso sull'esistenza del bene stesso, rimangono uguali anche dopo il nostro utilizzo (un appartamento).

Per quanto riguarda i beni inconsumabili è ipotizzabile la coesistenza di un diritto di proprietà e un diritto minore reale (es. usufrutto).

Per i beni consumabili è pensabile solo il trasferimento di proprietà.

Distinzione tra **beni fungibili (o di genere)** e **beni infungibili (o di specie):**

- I **beni fungibili** sono quelli che consideriamo in virtù della loro appartenenza a un genere (100 litri d'olio)
- I **beni infungibili** sono beni dotati di caratteristiche individualizzanti (la bicicletta utilizzata da Tizio)

Nel momento in cui consideriamo un bene infungibile, quando si raggiunge l'accordo in quel momento si verifica il trasferimento di proprietà (*art 1376 c.c.*)

In caso di beni fungibili la proprietà si trasferisce nel momento in cui SPECIFICO il bene, quando noi poniamo in essere un bene che appartiene a un genere gli effetti reali sono rimandati al momento dell'individuazione/separazione del bene stesso. (es. vendo una penna delle mie 100 penne, si trasferisce la proprietà nel momento in cui viene individuata la penna x)- (*art. 1378 c.c.*)

Distinzione tra **beni divisibili** e **beni indivisibili**:

- I **beni divisibili** possono a loro volta essere suddivisi in parti che mantengono tutte le caratteristiche proprie dell'intero (una torta)
- I **beni indivisibili** non sono suddivisibili e la suddivisione porterebbe alla perdita del bene (quadro, automobile).

I **BENI-FRUTTI** vengono generati a loro volta da **beni produttivi**, e si dividono in:

- **Frutti naturali (art 820)**: beni materiali che provengono direttamente da una cosa produttiva (prodotti agricoli, legna, parti di animali) e finché non avviene la separazione della cosa, i frutti formano parte di essa e solo una volta separati i frutti diventano beni autonomi. Di regola appartengono al proprietario della cosa produttiva.
- **Frutti civili (art 821)**: sono gli introiti che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento (canone che ricevo se concedo in affitto il mio fondo). I frutti civili spettano al proprietario e si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

AGGREGAZIONI DI BENI

Art 816 c.c., considera **universalità di mobili** la **pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria**. (collezione di quadri, una biblioteca, un gregge). Esse possono essere prese in considerazione nel loro insieme anche se è possibile che le singole cose formino oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Le universalità di beni mobili rientrano in un più ampio concetto, ovvero quello di **UNIVERSALITA' PATRIMONIALE**: si ha quando un complesso di beni ed altri rapporti giuridici è unitariamente considerato dal diritto (es. **eredità, azienda**).

Un altro caso in cui i beni pur separati sono considerati unitariamente è il **regime delle pertinenze (art 818 c.c.)**: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa.

Può trattarsi di:

- Due cose mobili (la ruota di scorta è pertinenza dell'automobile)
- Due cose immobili (il box di un'auto è pertinenza dell'appartamento)
- Una cosa mobile può essere pertinenza di una cosa immobile (arredamento è pertinenza di un appartamento)

CAPITOLO XIII

I DIRITTI REALI E LE SITUAZIONI DI FATTO

I DIRITTI REALI

I diritti reali sono i diritti sulle cose (*iura in rem*), ovvero sui beni materiali, e sono la categoria ricompresa nel più ampio settore dei diritti soggettivi di natura patrimoniale.

In essi rientrano la proprietà e i c.d. diritti reali minori.

I beni immateriali invece costituiscono l'oggetto di situazioni di tipo dominicale, compendiabili nella c.d. **proprietà intellettuale** e obbediscono a principi propri tra cui la prescrittibilità.

Caratteristiche diritti reali:

- **Immediatezza:** il titolare di un diritto su una cosa si serve da se e ha il potere di soddisfare il proprio interesse utilizzando direttamente il bene, a differenza di quanto accade per i diritti di credito, in quanto l'utilità a cui mira il creditore gli deve essere procurata dalla prestazione del debitore.
- **Absolutezza:** i diritti reali valgono *erga omnes*, nel senso che il loro titolare può pretendere l'astensione di chiunque da atti che interferiscano con l'esercizio del suo diritto, mentre il titolare di un diritto di credito può rivolgersi solo a un debitore determinato.
Un aspetto dell'assolutezza è il **diritto di seguito**: il diritto reale permane a prescindere dagli spostamenti giuridici che interessino la titolarità della cosa (se ho una servitù di passaggio su un fondo essa permarrà anche se il fondo viene alienato a un altro proprietario)

L'ordinamento italiano ammette che si possono configurare dei **diritti personali di godimento**, cioè diritti che riguardano il godimento di una cosa, ma sono configurati come diritti di credito: il titolare di tali diritti ha un semplice diritto verso un altro determinato soggetto a che questo gli consenta il godimento di una cosa (contratto di comodato).

- **Tipicità:** i diritti reali sono a **numero chiuso**, cioè sono ammissibili solo i diritti reali espressamente previsti e disciplinati dalla legge, quindi non si possono costituire nuove figure di diritti reali o modificarne la disciplina.

I diritti reali comprendono, oltre la **proprietà**: i **diritti reali di godimento**, che conferiscono una più o meno ampia facoltà di godimento di una cosa altrui (**superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali**) e i **diritti reali di garanzia** che servono a rendere più facile il soddisfacimento di un credito, vincolando dati beni a garanzia di esso (**ipoteca, pegno**).

LA PROPRIETÀ

La proprietà è la situazione che indica l'appartenenza di una cosa ad un soggetto nella forma tendenzialmente più ampia ed estesa.

Art. 832 c.c.: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

- La **pienezza** della proprietà sta a significare che al proprietario è attribuita la generalità delle forme di godimento e di disposizione che quel bene consente.
- L'**esclusività** significa che il proprietario può respingere le intromissioni altrui a suo piacimento, senza bisogno di fornire una particolare giustificazione.

In alcuni casi sono previsti dei limiti (art 843 c.c., per esempio il proprietario deve permettere l'accesso al fondo al fine di costruire/riparare un'opera propria del vicino o per recuperare cose o animali altrui che si trovano nel suo fondo)

- **Elasticità della proprietà:** i poteri del proprietario possono essere compressi in virtù dell'esistenza, sullo stesso bene, di altri diritti reali o di vincoli di carattere pubblicistico. I poteri del proprietario sono destinati a riespandersi automaticamente nel momento in cui i diritti reali o vincoli pubblicistici vengano meno.
- L'art 832 parla di un **diritto di godere**, ovvero il potere del proprietario di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire sia direttamente che indirettamente, e di un **diritto di disporre**, ovvero il potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa (il proprietario può vendere un appartamento, donarlo, locarlo)
- L'ordinamento configura **limiti** al godimento e alla disposizione e **obblighi**, che spesso sono diversi per ogni categoria di beni.
Es. **beni culturali:** i privati proprietari di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione e non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti.
Un limite generale all'esercizio del diritto di proprietà privata emerge dall'**art 833 c.c.**, che vieta gli **atti di emulazione**, cioè quei comportamenti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Tale divieto è considerato espressione della teoria dell'**abuso del diritto**, inteso come strumento in ordine all'esercizio dei diritti, laddove il titolare agisca in contrasto con gli scopi per i quali essi sono riconosciuti dall'ordinamento.

LA PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE

Nella nostra costituzione la proprietà non è più, come accadeva nello Statuto Albertino, dichiarata inviolabile, ma non viene neppure disciplinata né fra i principi fondamentali né fra i diritti di libertà, ma è contemplata nel titolo relativo ai "rapporti economici".

Tuttavia, la costituzione dichiara **all'art 42** che **"la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."**

Tale garanzia implica non solo che non è consentito al legislatore ordinario sopprimere l'istituto della proprietà privata, ma che sarebbe anche in contrasto con i principi fondamentali la trasformazione del nostro sistema in un sistema in cui i beni siano prevalentemente collettivizzati.

L'esatto contenuto dell'idea di **funzione sociale**, non è agevole da definire e potrebbe riguardare:

- Limiti e obblighi diretti ad assicurare un più efficiente utilizzo dei beni
- Limiti e obblighi che consentano a tutti l'accesso alle risorse.

Il legislatore può escludere l'ammissibilità della proprietà privata per quanto riguarda **una o più determinate categorie di beni**.

La costituzione prevede poi la possibilità di **espropriazione per pubblico interesse** della proprietà privata, procedimento che conduce a trasferire la proprietà del bene dal privato a un ente pubblico, al fine di utilizzarlo per funzioni socialmente rilevanti.

2 limiti all'espropriazione:

- Può avvenire solo nei casi previsti dalla legge (qui esiste una riserva di legge)
- La costituzione prevede che il proprietario deve ricevere un **indennizzo** (che non deve necessariamente consistere in un *integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall'espropriato*, ma deve rappresentare un *serio ristoro del pregiudizio conseguente all'espropriazione*- Corte costituzionale)

Secondo la giurisprudenza costituzionale nel concetto di espropriazione rientrano:

- **L'espropriazione traslativa:** comporta la perdita della proprietà del bene
- **L'espropriazione anomala:** ovvero gli atti che impongano limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà.

LA PROPRIETA' FONDIARIA

È evidente come i beni immobili siano beni di rilevante importanza economica e che la cui utilizzazione incide facilmente sugli interessi individuali di altri proprietari (specialmente quelli nei fondi vicini) e sugli interessi della collettività.

Con riguardo, ad esempio, all'attività edificatoria, già il codice civile prescrive all'art 869 che i proprietari d'immobili debbano osservare le prescrizioni dei **piani regolatori**, che è lo strumento principale della pianificazione urbanistica comunale. Inoltre, tutti gli interventi di nuova costruzione e i più importanti interventi di ristrutturazione devono avere un **permesso a costruire** da parte dell'autorità comunale.

Venendo alla proprietà fondiaria, l'**art 840 c.c.** stabilisce i c.d. **limiti verticali** delle facoltà del proprietario, ovvero che la proprietà si estende al sottosuolo, con tutto ciò che contiene e allo spazio sovrastante, ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano ad una profondità (metropolitana) o ad una altezza (es. navigazione aerea) tali da non pregiudicare il suo interesse.

L'**art 841 c.c.** stabilisce che il proprietario può chiudere in ogni tempo il fondo, quindi per esempio impedire l'ingresso ad altri recintandolo, anche se vi sono i limiti previsti dall'art 843 prima visti e un ulteriore limite che riguarda il fatto che il proprietario non può impedire l'accesso ai fini dell'esercizio della caccia, tranne in certi casi.

La gran parte della disciplina dedicata alla proprietà fondiaria è finalizzata a pervenire o risolvere i **conflitti di vicinato**: conflitti che possono nascere dall'interferenza nel godimento di fondi vicini.

- LE DISTANZE:

Il codice detta delle regole in materia di distanze qualora si vogliano aprire pozzi o cisterne, scavare fossi o canale o persino piantare alberi.

Per quanto riguardare le **distanza fra le costruzioni** il legislatore non detta distanze minime dal confine, ma le distanze che devono essere mantenute fra gli edifici.

Art 873 c.c. prevede che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, siano distanti fra loro almeno tre metri, salvo che i regolamenti locali prevedano una distanza maggiore.

In concreto la disciplina delle distanze si applica a seconda delle scelte del primo dei due proprietari confinanti che realizza una costruzione.

Il problema delle distanze si pone anche a riguardo delle aperture degli edifici, che si distinguono in:

- **Luci:** aperture che consentono il passaggio di luce e aria, ma non di affacciarsi sul fondo del vicino
- **Vedute:** consentono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente e solo per esse è prevista una distanza minima per la riservatezza e la sicurezza del vicino.

- **LE IMMISSIONI:**

sono tutte le propagazioni, ad esempio: fumo, rumori, esalazioni.

Il legislatore ha fissato una soglia, largamente rimessa alla discrezionalità del giudice, oltre la quale le immissioni diventano illecite e possono essere vietate.

Art 844: le immissioni che non superano la soglia della normale tollerabilità, “avuto anche riguardo della condizione dei luoghi”, devono essere sopportate.

È ovvio come anche le circostanze temporali e la frequenza delle immissioni assumono un importante rilievo e qualora le immissioni siano intollerabili il giudice dovrà vietarle oppure imporre idonei accorgimenti.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ'

Art 922 c.c.: «La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.»

L'articolo in questione contiene un elenco NON tassativo dei modi di acquisto della proprietà, si fa infatti rinvio agli altri modi stabiliti dalla legge.

Tradizionalmente si distingue tra:

- **Modi di acquisto a titolo derivativo**, dove avviene la successione nello stesso diritto che prima faceva capo a un diverso titolare e in questo caso l'acquisto è subordinato all'effettiva esistenza del diritto in capo al dante causa, e in linea generale i difetti e le vicende pregiudizievoli concernenti il titolo del dante causa possono ripercuotersi sulla posizione dell'acquirente.
Essi sono il **contratto** e la **successione a causa di morte**.
- **Modi di acquisto a titolo originario**, dove sorge un nuovo diritto di proprietà del tutto indipendente da qualsiasi rapporto col precedente titolare, che potrebbe addirittura non esistere, è comunque irrilevante.
Essi sono: l'**occupazione**, l'**invenzione**, l'**accessione**, l'**usucapione** e il **possesso in buona fede di beni mobili**. (questi ultimi due li affronteremo successivamente in quanto si tratta di effetti del possesso dei beni)

OCCUPAZIONE (art 923 c.c.): *Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.* L'occupazione consiste nella presa di possesso, con l'intenzione di acquisirle in via permanente e definitiva, di **cose mobili** che non sono in proprietà di alcuno (*res nullis*) o sono abbandonate dall'avente diritto con l'intenzione di disfarsene.

Non sono suscettibili di occupazione i beni immobili, che se non sono in proprietà ad alcuno spettano al patrimonio dello Stato, ex art 827 c.c.

INVENZIONE (art 927 c.c.): *Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.*

L'invenzione riguarda solo le **cose mobili smarrite** dal proprietario. È ovvio che ci trova una cosa smarrita non ne diventa proprietario, ma ha l'obbligo di restituirla al proprietario o di consegnarla al sindaco.

Viene dato in questo modo pubblico avviso del ritrovamento della cosa e se il proprietario richiede la restituzione di essa, al ritrovatore sarà dovuto un **premio** in denaro, se invece trascorre 1 anno senza che si presenti il proprietario, il ritrovatore della cosa ne acquista, a titolo originario, la proprietà.

Delle particolari eccezioni sono:

- *Tesoro*, ovvero mobile di pregio, nascosta e sotterrata e che non è riconducibile a nessuno proprietario, in questo caso esso diventa **immediatamente** di proprietà del titolare del fondo in cui si trova.
- *Beni culturali* ritrovati nel sottosuolo, appartengono allo Stato e viene dato un premio al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento.

ACCESSIONE (art 934 c.c.):

L'accessione opera in caso di **stabile incorporazione** di beni di proprietari diversi. In tale ipotesi di regola il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose che vengono in essa incorporate.

Occorre distinguere fra:

- **Accessione di mobile ad immobile:** di regola qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (art 934). Il proprietario del suolo acquista la proprietà di quanto nello stesso suolo venga da chiunque incorporato. Questa regola è derogabile mediante costituzione di un **diritto di superficie** e la c.d. **accessione invertita** .
L'accessione invertita si ha quando, nel realizzare una costruzione, il proprietario confinante sconfinava su fondo altrui. In questo caso se il proprietario del fondo occupato non fa opposizione entro 3 mesi dal giorno in cui la costruzione sul fondo ha avuto inizio, il proprietario sconfinante può richiedere che il giudice gli trasferisca la proprietà del suolo occupato a fronte del pagamento al confinante di una somma pari al doppio del valore della superficie occupata.
- **Accessione di immobile ad immobile,** si articola nelle seguenti figure:
 - o Alluvione: sussiste nell'accrescimento dei fondi rivieraschi di fiumi e torrenti per l'azione naturale dell'acqua corrente: Questi terreni appartengono al proprietario del fondo incrementato.
 - o Avulsione: un fiume o torrente stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo e la trasporta verso un altro fondo. Il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà, deve però pagare all'altro un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione;
- **Accessione di mobile a mobile:** da luogo alle due figure:
 - o **UNIONE:** si ha quando cose mobili appartenenti a proprietari diversi vengano unite o mescolate in modo da formare un insieme inseparabile, pur senza dar luogo a una

nuova cosa. In questo caso l'insieme risultante diviene di proprietà comune, in proporzione del valore delle cose originariamente spettanti a ciascuno.

- **COMMISTIONE:** Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata.

SPECIFICAZIONE (art 940 c.c.): consiste nella creazione di una cosa del tutto nuova con beni mobili appartenenti ad altri, quindi si ha la trasformazione della materia mediante opera umana.

La proprietà del nuovo bene spetta allo specificatore, salvo l'obbligo di pagare al proprietario il prezzo della materia, tranne nell'ipotesi in cui il valore della materia **sorpassi notevolmente** quello della mano d'opera: in questo caso la proprietà del bene realizzato spetta al proprietario della materia, che deve pagare allo specificatore il prezzo della mano d'opera.

LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Il codice civile disciplina all'art 948 e seguenti l'**azione di rivendicazione**, l'**azione negatoria**, l'**azione di regolamento di confini** e l'**azione di apposizione di termini**.

Tali azioni servono per andare a garantire le prerogative connesse alla titolarità del diritto di proprietà e sono definite **AZIONI PETITORIE**, che si contrappongono alle **azioni possessorie**, quindi alle azioni di difesa del possesso.

AZIONE DI RIVENDICAZIONE (ART 948 c.c.)

Può essere esercitata dal proprietario della cosa nei confronti di chiunque la possieda o la detenga, al fine di ottenerne la restituzione.

Il proprietario deve dimostrare di essere tale e quindi deve effettuare la **prova della proprietà**, che richiede di risalire fino a un acquisto a titolo originario.

Nell'assolvimento di questo onere probatorio l'attore in rivendicazione si può giovare dell'istituto dell'**usucapione**, quindi la prova della proprietà può considerarsi raggiunta quando l'attore possa dimostrare di aver posseduto, in proprio o attraverso i precedenti alienanti, per un tempo sufficiente ai fini dell'usucapione.

In mancanza di tale prova la domanda di rivendicazione deve essere respinta.

Il convenuto è colui che possiede o detiene la cosa. Tuttavia l'azione di rivendicazione può essere proseguita anche quando il convenuto cessa di possedere o detenere la cosa, in questo caso dovrà recuperarla a proprie spese o in mancanza corrispondere il valore al proprietario.

L'azione è **imprescrittibile**, quindi non è soggetta a prescrizione, in quanto anche il non uso del bene rientra tra i poteri del proprietario. L'azione può essere rigettata qualora il convenuto dimostri di aver acquistato la proprietà per usucapione.

AZIONE NEGATORIA (art 949 c.c.)

Con essa il proprietario può agire sia per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa sia per chiedere la cessazione delle turbative o molestie, oltre al risarcimento dei danni.

Nell'azione negatoria non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente che l'attore dimostri un valido titolo di acquisto; sarà il convenuto a dover dimostrare, per ottenere il rigetto dell'azione, l'esistenza del titolo vantato.

AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI (art 950 c.c.)

Azione riconosciuta a ciascun proprietario quando i confini tra i due fondi risultano incerti.

Essa ha ad oggetto l'accertamento della reale estensione dei rispettivi beni non della titolarità dei diritti.

Le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali e ognuno ha l'onere di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.

In mancanza di elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI (art 961 c.c.)

Serve ad ognuno dei proprietari dei fondi confinanti a obbligare il vicino a partecipare alle spese occorrenti per l'apposizione o il ripristino dei segni di ripartizione o divisione tra i fondi, se essi mancano o sono divenuti irriconoscibili.

Un'azione non espressamente prevista dalla legge, ma riconosciuta dalla giurisprudenza è l'**AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ**, che è volta ad ottenere una sentenza che affermi il diritto di proprietà dell'attore sopra un determinato bene, al fine di rimuovere una situazione di incertezza.

Due speciali azioni sono le **AZIONI DI NUNCIAZIONE**, che non spettano solo al proprietario, ma anche al titolare di un altro diritto reale di godimento o al possessore, esse sono:

- **DENUNZIA DI NUOVA OPERA (art 1171 c.c.):** possibile quando da una nuova opera, intrapresa da un terzo, stia per derivare danno al bene oggetto del diritto o del possesso dell'attore, purché questa non sia terminata o non sia trascorso un anno dal suo inizio. L'autorità giudiziaria in questo caso può vietare la continuazione dell'opera o permetterla.
- **DENUNZIA DI DANNO TEMUTO (art 1172 c.c.):** quando il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. Il giudice potrà ad esempio ordinarne la demolizione o l'abbattimento,

Le azioni sono simili, ma si differenziano per il fatto che l'azione di danno temuto non presuppone un'**attività di trasformazione della situazione dei luoghi**, ma qualsiasi situazione dei luoghi di cui si ha ragione di temere un **pericolo**, che deve essere di un **danno grave e prossimo**.

GLI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO: la superficie, l'enfiteusi

IL DIRITTO DI SUPERFICIE (art 952 c.c. e seguenti)

Il diritto di superficie consente al suo titolare di costruire e di mantenere un edificio al di sopra o al di sotto di un fondo altrui. Esso costituisce una deroga al **principio di accessione**, in quanto si ha una scissione della titolarità del fondo e della titolarità dell'edificio costruito sopra o sotto il suolo.

2 ipotesi differenti per la realizzazione del diritto di superficie:

- È possibile la cessione di un edificio già esistente. E quindi abbiamo un proprietario superficiario che sarà proprietario dell'immobile e un proprietario del fondo distinto.
- È possibile consentire ad un soggetto di edificare l'edificio sul suolo altrui. Il proprietario del fondo costituisce il diritto di superficie a favore di un altro soggetto il quale avrà diritto di costruire l'edificio diventando così un proprietario superficiario. Quindi qui vediamo la nascita di uno **ius ad aedificandum**, diritto a costruire.

Quindi quando l'edificio è stato edificato si parla di **proprietà superficiaria**, proprio perché il titolare del diritto di superficie diventa un autentico proprietario dell'immobile che è stato costruito.

Il proprietario del suolo non deve ostacolare l'esercizio del diritto del superficiario, ovvero deve **permettere lo svolgimento dell'attività di costruzione** e, per quanto riguarda le costruzioni già esistenti, deve tollerarne il mantenimento evitando comportamenti che possano danneggiarle. Il diritto di superficie non prevede limiti temporali, ma più frequentemente viene costituito per un tempo determinato.

Può essere costituito per atto tra vivi (contratto) o per testamento, e tra vivi può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito: il corrispettivo può consistere in una somma di denaro oppure in un canone periodico.

Estinzione:

- Decorso eventuale termine
- Rinuncia da parte del titolare
- Prescrizione (per effetto del non uso protratto per venti anni)

Il venir meno della costruzione non comporta l'estinzione del diritto di superficie, il superficiario ha diritto di ricostruire.

Una volta estinto il diritto di superficie, riprende ad operare il principio di accessione, e il proprietario del suolo diventa proprietario delle costruzioni.

ENFITEUSI (art 960 c.c.)

L'enfiteusi attribuisce al soggetto a cui favore è costituita (**enfiteuta**) lo stesso potere di godimento che, su un bene immobile, spetta al proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e pagare al proprietario stesso un canone periodico.

A differenza dell'usufruttuario, l'enfiteuta può anche mutare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori.

L'enfiteusi può essere **perpetua**, oppure **a tempo**, ma non può mai avere durata inferiore a 20 anni.

L'enfiteuta può disporre liberamente del proprio diritto sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*.

Modi di acquisto dell'enfiteusi sono il contratto, il testamento e l'usucapione.

La legge attribuisce:

- All'enfiteuta il c.d. **potere di affrancazione**: acquisto della piena proprietà del fondo mediante il pagamento al concedente di una somma di denaro
- Al concedente il c.d. **potere di devoluzione**: per effetto del quale lo stesso, in caso di inadempimento dell'enfiteuta, libera il fondo enfiteutico.

USUFRUTTO

L'usufrutto è un diritto temporaneo di godere di una cosa e di trarne i frutti, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (**art 981 c.c.**).

L'usufrutto ha necessariamente **durata temporanea**, e:

- Se costituito a favore di una persona fisica, l'usufrutto s'intende per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, tranne nel caso in cui il titolo costitutivo non preveda una durata inferiore, in ogni caso si estingue con la morte dell'usufruttuario.
- Se costituito a favore di **persone giuridiche**, oppure di un ente non riconosciuto, la durata non può essere superiore a 30 anni (art 979 c.c.).

Fino all'estinzione dell'usufrutto il proprietario è privato della possibilità di usare la cosa, il suo diritto prende nome di **nuda proprietà**, che conserva un valore economico, in quanto è destinata con certezza a ridiventare proprietà piena.

Oggetto di usufrutto può essere qualunque specie di bene, con esclusione dei soli **beni consumabili**: non potrebbero infatti essere restituiti al proprietario alla cessazione dell'usufrutto. In caso di beni consumabili si avrà una situazione che non coincide con l'usufrutto, chiamata **quasi usufrutto**, in tal caso la proprietà dei bene passa al quasi-usufruttuario, quindi esso non è un diritto reali su cosa altrui.

Modi di acquisto dell'usufrutto:

contratto a titolo gratuito o oneroso, testamento e usufrutto.

Diritti dell'usufruttuario:

- **potere di godimento sul bene**
- **facoltà di trarre dalla cosa tutte le utilità** che la stessa può dare, fermo l'obbligo di rispettarne la destinazione economica
- **possesso della cosa**
- acquisto dei **frutti naturali separati** durante l'usufrutto e dei **frutti civili maturati** giorno per giorno fino al termine dell'usufrutto.
- **Potere di disposizione del diritto di usufrutto**: L'usufruttuario può di regola cedere ad altri il proprio diritto d'usufrutto e può anche concedere ipoteca sull'usufrutto stesso, in ogni caso la cessione non può danneggiare il nudo proprietario.
- **Potere di disposizione del godimento del bene**: l'usufruttuario può concedere in locazione la cosa che forma l'oggetto del suo diritto e quindi, più in generale, può concederla in godimento a terzi.

Obblighi dell'usufruttuario:

- **Restituzione della cosa al termine del suo diritto**
- **Usare la diligenza del buon padre di famiglia** nel godimento della cosa (art 1001 c.c.)
- **Non modificare la destinazione**

Nell'ipotesi di inadempimento di questi obblighi il nudo proprietario può richiedere all'usufruttuario il risarcimento del danno eventualmente sofferto.

L'usufruttuario è inoltre tenuto alle spese e in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria della cosa, sono invece a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie.

Estinzione usufrutto:

- **Scadenza del termine o morte dell'usufruttuario**
- **Prescrizione estintiva ventennale**
- **Totale perimento della cosa**
- **Abusi compiuti dall'usufruttuario del suo diritto**
- **Rinuncia** (che in caso di beni immobili deve essere fatta per iscritto ed essere trascritta nei pubblici registri immobiliari)

USO E ABITAZIONE

Sono diritti affini all'usufrutto, che prevedono però facoltà di godimento più limitate.

Chi ha il diritto d'**uso** su una cosa può servirsi di essa e è fruttifera può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art 1021 c.c.).

Chi ha il diritto di **abitazione** di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art 1022 c.c.).

Si tratta di **diritti temporanei**, che non possono essere ceduti né dati in locazione.

I diritti d'uso e d'abitazione possono sorgere anche per legge: **art 540 c.c.**, prevede che in caso di morte del coniuge convivente, all'altro siano riservati i diritti di abitazione sulla casa di residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni.

LE SERVITU' PREDIALI

art 1027 c.c.: La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (**fondo servente**) per l'utilità di un altro fondo (**fondo dominante**) appartenente a un diverso proprietario.

Peso: metafora, allude al fatto che il proprietario del fondo dominante può trarre determinate utilità dal fondo servente (es. diritto del proprietario di un fondo a passare sul fondo del vicino per raggiungere la via pubblica).

Possono essere:

- **Affermative:** quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di fare qualche cosa/di svolgere un'attività sul fondo servente e questo scaturisce un obbligo di sopportare un peso sul proprio fondo (obbligo di *pati*) in capo al proprietario del fondo servente.
- **Negative:** quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di vietare al proprietario del fondo servente di fare qualche cosa (servitù *altius non tollendi*: il proprietario del fondo servente è tenuto a non edificare oltre una data altezza)

La **predialità** consiste nel fatto che le servitù siano stabilite a favore di un fondo e non di una persona, quindi recano utilità a una persona solo in quanto questa sia proprietaria del fondo dominante.

Inoltre, non è necessario che i due fondi siano contigui: la **servitù di acquedotto** può gravare su diversi fondi.

La servitù non può avere ad oggetto prestazioni attive da parte del titolare del fondo servente, può solo derivarne un obbligo di non fare oppure sopportare una certa attività del vicino.

Le servitù prediali possono essere costituite:

- **Volontariamente:**

- Per contratto
- Per testamento

E quando sono **apparenti**, ovvero quando esistono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, possono costituirsi per:

- Usucapione
- **Destinazione del padre di famiglia (art 1062 c.c.):** questa modalità opera nel contesto in cui i due fondi (dominante e servente) attualmente divisi, in passato sono appartenuti allo stesso proprietario, quindi prima della divisione l'uno era servente rispetto all'altro.

Quando il fondo cessa di appartenere allo stesso proprietario il codice civile prevede che si costituisca una servitù corrispondente allo stato di fatto preesistente, che appunto consentiva ad una parte del fondo di trarre utilità e vantaggi dall'altra parte del fondo. Non occorre quindi alcuna manifestazione di volontà negoziale per costituire la servitù.

- **Coattivamente:**

Le **servitù coattive** nascono sulla base dell'ipotesi che in alcuni casi, quando un fondo può trovarsi in condizioni che potrebbero pregiudicarne l'adeguata utilizzazione (per esempio quando è intercluso, quindi non ha accesso alla strada pubblica), il proprietario può ottenere che sul fondo vicino si costituisca una servitù.

Per concluderla concretamente occorre:

- Contratto
- Sentenza di un giudice, se il vicino si rifiuta di concludere un contratto, la quale determina un'indennità che dovrà essere pagata al proprietario del fondo servente.

Le servitù coattive previste dal codice sono: **acquedotto e scarico coattivo; appoggio e infissione di chiusa; somministrazione coattiva di acqua; elettrodotto coattivo; passaggio coattivo di teleferiche e passaggio coattivo (art 1051 c.c.)**: quest'ultima è la più rilevante. Si applica nell'ipotesi di un fondo intercluso, il proprietario ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. La regola generale in questo caso è il passaggio si deve stabilire nella parte per cui l'accesso è più breve e reca il minor danno possibile.

Si può applicare anche in fondo non intercluso ma caratterizzato da un accesso alla via pubblica inadeguato e non suscettibile di ampliamento. (art 1052 c.c.)

ESTINZIONE:

- **Rinuncia del titolare**
- **Confusione**, quindi quando in una sola persona si riuniscono la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente
- **Prescrizione estintiva ventennale**, ma il momento dal quale comincia a decorrere il termine per la prescrizione estintiva varia, a seconda del tipo di servitù:
 - o Servitù negative: il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
 - o Servitù continue (un tipo di servitù affermative, quando per l'esercizio di tali servitù non occorre l'attività dell'uomo), stessa cosa delle servitù negative
 - o Servitù discontinue (sempre un tipo di servitù affermative, quando invece il fatto dell'uomo deve essere concomitante con l'esercizio della servitù), in questo caso la prescrizione estintiva inizia a decorrere dall'ultimo atto di esercizio.

A difesa del proprio diritto il titolare della servitù può esercitare l'**azione confessoria**: con essa può farne riconoscere in giudizio l'esistenza e il contenuto se essi siano stati contestati.

COMUNIONE, CONDOMINIO, MULTIPROPRIETA'

Si ha **comunione** quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.

L'origine della situazione di comunione può essere diversa:

- **Comunione volontaria**: quando essa sorge per volontà delle parti (acquisto insieme di una cosa)
- **Comunione incidentale**: quando essa sorge indipendentemente dalla volontà delle parti (comunione ereditaria)
- **Comunione forzosa**: quando è imposta dalla legge e non ne è ammesso lo scioglimento (parti comuni dell'edificio condominiale)

Per regolamentare la partecipazione di ciascuno alla contitolarità del diritto si utilizza il concetto di **quota**: è la misura e il parametro del concorso dei partecipanti sia nei vantaggi quanto nei pesi della

comunione, ex art 1101 c.c., il quale presume anche il **principio di eguaglianza delle quote dei partecipanti**, almeno che il titolo non disponga diversamente.

La quota determinata:

- La misura con cui i partecipanti devono concorrere alle spese della comunione
- La misura con cui i partecipanti hanno diritto a percepire i frutti del bene
- In caso di divisione è in base alle quote che si determinano le parti spettanti ai diversi partecipanti.

Le quote non sono determinanti rispetto all'utilizzo della cosa, infatti ciascun partecipante può servirsi liberamente della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne ugualmente uso secondo il loro diritto (art 1102 c.c.).

Tutti i partecipanti concorrono all'amministrazione della cosa comune:

- Decisioni di ordinaria amministrazione prese dalla maggioranza dei partecipanti, secondo il valore delle loro quote
- Decisioni di straordinaria amministrazione prese è necessaria una maggioranza dei rappresentanti che rappresenti almeno due terzi del valore del bene.

Sotto il profilo della disposizione: da un lato l'art 1103 stabilisce che ogni partecipante può cedere liberamente a terzi la sua quota, dall'altro l'art 1108 annovera tra gli atti di straordinaria amministrazione anche gli atti di disposizione, e che quindi solo con il consenso di tutti è possibile alienare il bene o costituire su di esso diritti reali.

Ai sensi **dell'art 1111 c.c.** ciascun partecipante può sempre domandare lo scioglimento della comunione, almeno che:

- Non sia stato deciso il patto di rimanere in comunione per un dato periodo, che non può eccedere il **decennio**
- Quando la divisione farebbe venire a meno l'utilità che i partecipanti ricevono dall'uso della cosa (art 1112 c.c.)

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI: il **condominio** è caratterizzato dalla coesistenza della proprietà individuale dei singoli piani o porzioni di piani e della comproprietà delle parti comuni dell'edificio. Costituisce una tipologia di **comunione forzata**.

L'**art 1117 c.c.** elenca le parti che sono comuni, se non risulta il contrario dal titolo, e origina una **presunzione di comunione** per tutte le parti dell'edificio o ad esse pertinenti o esterne, ma egualmente destinate all'uso comune.

Quindi il suolo è di norma in comproprietà, mentre le singole unità immobiliari appartengono individualmente ai condomini-questa disciplina rappresenta una parziale deroga al principio di accessione (art 934 c.c.) secondo cui il proprietario della cosa principale acquista a titolo originario la proprietà delle cose che vengono ad essa incorporate stabilmente.

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è **proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene** e determina la misura con cui ciascun condomino concorre sia nelle spese sia nel prendere decisioni relative alle cose comuni (per quanto riguarda le **spese**, non viene tenuto conto solo del valore della proprietà, ma anche dell'uso che ciascuno può fare delle cose).

Assemblea dei condomini: prende le decisioni relative al condominio secondo un articolato sistema di maggioranza. Tutti i condomini devono essere regolarmente convocati e l'assemblea è

regolarmente costituita quando intervengono tanti condomini che rappresentino due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti del condominio.

È poi previsto un **amministratore** che esegue le deliberazioni dell'assemblea, disciplina l'uso delle cose comuni, eroga le spese necessarie...

MULTIPROPRIETA': operazione economica volta ad assicurare al c.d. **multiproprietario** un potere di godimento su di un'unità immobiliare ma solo per un **determinato e normalmente invariabile periodo dell'anno**.

la **multiproprietà immobiliare (o reale)** è stata variamente ricostruita;

Si è fatto per esempio ricorso a una **comunione immobiliare**, ma in questo caso un problema nasce dall'impossibilità di disporre un vincolo di comunione per più di 10 anni ex art 1111 c.c., così si è cercata la soluzione di estendere il campo di applicazione dell'art 1112 c.c., per dichiarare l'indivisibilità del bene oggetto di multiproprietà.

IL POSSESSO E LA SUA TUTELA

Il **possessione** è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (**art 1140 c.c.**).

Si tratta dunque di una **situazione di fatto**, in quanto il possessore può essere o meno proprietario o titolare di un altro diritto reale sul bene, ciò che conta è che, DI FATTO, egli si comporti come tale.

Il possesso può essere:

- **Conforme al diritto** (se il possessore è effettivamente titolare del diritto corrispondente)
- **Non conforme al diritto**
 - o **Possesso in buona fede**: che si ha quando il possessore ignora di ledere l'altrui diritto (**art 1147 c.c.**) perché ritiene di essere effettivamente proprietario o titolare di un altro diritto reale. Essa non giova se l'**ignoranza dipende da colpa grave**, ovvero che il soggetto che ignora di ledere il diritto altrui poteva accorgersene adoperando un minimo di diligenza, in questo caso è **equiparato a un soggetto in mala fede**.
 - o **Possesso in mala fede**: che si ha quando il possessore è consapevole di ledere il diritto altrui.

Il possesso è diverso dalla **detenzione**, che si ha quando un soggetto esercita un potere di fatto sul bene, ma riconosce un altro soggetto come possessore (es. colui che ha preso un libro in prestito).

Il possesso consta di due elementi:

- **Corpus**: la materiale disposizione del bene
- **Animus**: intenzione di tenere la cosa per sé, allo stesso modo di un proprietario.

La detenzione riscontra solo il **corpus**.

Quando la detenzione è separata dal possesso si dice che il **possessore possiede per mezzo del detentore (art 1140 c.c.)** e quindi si parla di **possessione mediato**, contrapposto al **possessione diretto** del bene.

Modi di acquisto del possesso:

- Attraverso la **consegna volontaria** da parte del precedente possessore
- Attraverso l'**occupazione** di una cosa non posseduta da alcuno (una cosa abbandonata)
- Attraverso uno **spoglio**, quindi la sottrazione del bene a un precedente possessore contro la sua volontà

- Il detentore si trasforma in possessore: **interversione del possesso**. A tal fine non è sufficiente che il detentore cambi l'atteggiamento psicologico, ma l'interversione è consentita dall'**art 1141 c.c.** solo in due ipotesi:
 - o **Causa proveniente da un terzo**: in forza di un atto con il quale l'attuale possessore quando anche non è legittimato a disporre del bene attribuisca al detentore il diritto corrispondente la propria posizione possessoria
 - o **Opposizione del detentore contro il possessore**: per esempio l'affittuario di un fondo che non paghi più il canone di affitto, si rifiuti di restituire il bene alla scadenza del contratto e impedisca al proprietario ogni esercizio del proprio diritto.

L'ordinamento giuridico protegge il possesso attraverso le **azioni possessorie**

- **Azione di reintegrazione**: consente al possessore, ma anche al detentore, di recuperare il bene quando ne sia spogliato da parte di un terzo, purché agisca entro un anno dallo spoglio. Il codice parla di spoglio **violento o clandestino**: secondo la giurisprudenza è violenta qualsiasi azione che produca la privazione del possesso contro la volontà del possessore.
- **Azione di manutenzione**: concessa SOLO al possessore di beni immobili e universalità di beni mobili che sia tale da oltre un anno e gli consente, qualora sia turbato o molestato nel suo possesso, di chiedere, entro un anno dalla turbativa, la cessazione delle molestie.

Perché l'ordinamento tutela il possesso in quanto tale? Perché nel conflitto tra due soggetti dove nessuno dei quali è titolare del diritto, l'ordinamento sceglie di far prevalere quello che si trova nel possesso del bene, quest'ultimo poi soccomberà qualora si faccia vivo il vero titolare del diritto.

DIVIETO DI CUMOLO (tra giudizio possessorio e giudizio petitorio):

chi è convenuto con una delle azioni possessorie non può difendersi invocando il suo diritto, quindi per esempio non può dichiarare che aveva diritto a sottrarre il bene al possessore perché è proprietario, ma dovrà restituire il bene al possessore e poi far valere il proprio diritto con un'azione petitoria. Unica deroga: quando dal giudizio possessorio possa derivare un pregiudizio grave alle ragioni del convenuto (quando la cosa rischia di essere alienata a terzi)

Questo denota il fatto che l'ordinamento ha interesse che il proprietario ricorra alle vie legali, non alle vie di fatto.

Per quanto riguarda il detentore di fronte allo spoglio da parte di un terzo può reagire attraverso l'azione di reintegrazione, ma il codice non concede tale azione al **detentore che sia tale per ragioni di servizio o di ospitalità** (es. autista rispetto al mezzo guidato). Il detentore è inoltre difeso anche contro il possessore.

Nell'assenza del proprietario la cosa può: **produrre dei frutti, potrà aver bisogno di riparazioni, potrà essere migliorata ad opera del possessore.**

- **FRUTTI: art 1148 c.c.** il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.
Il possessore in mala fede invece deve restituire sia i frutti naturali sia quelli civili.
- **RIPARAZIONI E SPESE ORDINARIE**: Il possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per **riparazioni straordinarie**, in quanto vanno anche a beneficio del proprietario. Per quanto riguarda le spese ordinarie, considerate come passivo del godimento della cosa e che si compensano con il godimento del bene e acquisto dei frutti, il

possessore di mala fede, che deve restituire i frutti, ha diritto al rimborso di tali, mentre tale diritto non spetta al possesso di buona fede.

- **MIGLIORAMENTI:** Il possessore ha diritto a **indennità** per i miglioramento recati sulla cosa. Se di buona fede, l'indennità è pari all'aumento di valore delle cosa, se di mala fede è pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento del valore. Solo il possessore in buona fede può tenere con sé la cosa fino a quando non riceve le indennità che gli sono dovute.

ACQUISTO DEI DIRITTI REALI MEDIANTE IL POSSESSO

Il possesso del bene è parte di alcune fattispecie che conducono all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale.

L'OCCUPAZIONE: impossessamento di una **cosa mobile che non appartiene a nessuno** conduce all'acquisto della proprietà (**art 923 c.c.**).

Sono cose che non appartengono a nessuno: le cose abbandonate dal proprietario e gli animali che formano oggetto di caccia e pesca. La fauna è attualmente patrimonio indisponibile dello Stato, ma si qualifica come occupazione l'acquisto della fauna selvatica tramite la caccia, dove non sia vietata. L'acquisto di frutti spontanei da parte di soggetti che siano diversi dal proprietario del fondo è ammesso dalla legge in modo eccezionale.

ACQUISTO A NON DOMINIO DI BENI MOBILI (non si applica alle universalità di beni mobili e ai beni mobili registrati) **art 1153 c.c.:** Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in **buona fede** al momento della consegna e sussista un **titolo idoneo** al trasferimento della proprietà. (acquisto a titolo originario)

Non può ovviamente avvalersi dell'art 1153 il soggetto che ignori indizi evidenti che dovrebbero indurlo a sospettare che non sta acquistando dal vero proprietario (colpa grave).

Per via di ciò, nel caso in cui ci fosse un conflitto tra il vero proprietario a cui è stato sottratto il bene e il terzo acquirente in buona fede, si privilegia l'acquirente in buona fede.

In questo modo si vuole facilitare la circolazione dei beni mobili.

USUCAPIONE: Si realizza attraverso il possesso del bene prolungato nel tempo, che deve essere continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto ed è modo di acquisto di tutti i diritti reali di godimento.

Tempi:

- Di regola il lasso di tempo fissato è di **20 anni**

Per alcune ipotesi sono previsti termini di usucapione più brevi:

- **10 anni** per i beni immobili e **3 anni** per i beni mobili registrati, quando concorrono anche cumulativamente i seguenti presupposti:
 - o Che il possessore possa vantare a proprio favore un **titolo idoneo** a trasferire la proprietà (ipotesi di acquisto *a non domino*)
 - o Che l'acquirente acquistato il possesso del bene **in buona fede**

- Che sia stata effettuata la trascrizione del titolo: il termine dell'usucapione decorre dalla data di trascrizione
- **10 anni** per i beni mobili non registrati quando l'acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede
- **15 anni** per i **fondi rustici** situati in comuni classificati come montani o aventi un reddito dominicale molto basso.

L'usucapione è sicuramente un'utilità per l'ordinamento al fine di evitare di dover ricostruire fatti troppo risalenti, un'utilità di facilitare la circolazione dei beni e rendere più trasparenti le situazioni giuridiche.

Abbiamo detto che l'usucapione è un modo di acquisto di tutti i diritti reali di godimento.

L'acquisto per usucapione è abbastanza frequente per le **servitù prediali** (solo per quelle apparenti), mentre per gli altri diritti reale un acquisto per usucapione sarà infrequente.

L'art 1146 c.c. prevede:

- La **accessione del possesso**: chi ha acquisito il possesso a titolo particolare può sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri dante causa.
- La **successione nel possesso**: chi ha acquisito il possesso a titolo universale si avvale anche del possesso del suo autore

LA TRASCRIZIONE

La **trascrizione** è un sistema di **pubblicità dichiarativa**, relativa agli atti che determinano la circolazione, costituzione o estinzione di diritti reali su beni immobili. Essa si realizza mediante i c.d. **registri immobiliari**, tenuti presso appositi uffici (conservatorie immobiliari).

Si utilizza invece il termine **iscrizione** per quanto riguarda gli atti per i quali vige un sistema di **pubblicità costitutiva** (es. l'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei pubblici registri).

L'art 2643 c.c. elenca una serie di atti che si devono rendere pubblici per mezzo di trascrizione:

- **I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili oppure che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono altri diritti reali su beni immobili**: una volta effettuata la trascrizione, nel conflitto tra più persone che abbiano acquistato diritti su un bene immobile, prevale non chi ha acquistato per primo, ma chi per primo ha trascritto il suo acquisto. Essendo la trascrizione una forma di pubblicità dichiarativa, pur in assenza di trascrizione, il contratto tra due soggetti è valido e produce l'effetto tra i due di trasferimento della proprietà, ma in assenza di trascrizione, non è opponibile a terzi.

Questo risolve l'esigenza di sicurezza della circolazione giuridica con riguardo ai beni immobili. I registri fanno **pubblica fede**: chi acquista un bene può conoscerne con certezza la situazione esaminando i registri immobiliari, sapendo che qualunque atto che non risulti dal registro non sarà a lui opponibile.

- **Acquisti a causa di morte riguardanti diritti reali immobiliari**: in questo caso la trascrizione ha la funzione di informare che l'eredità è stata accettata e perciò acquistata, ma anche senza trascrizione tali fatti sono opponibili a terzi, dunque si tratta di pubblicità-notizia.

- **Domande giudiziali con cui si aprono processi relativi a qualcuno degli atti soggetti a trascrizione:** essa serve a rendere la sentenza opponibile anche ai terzi che abbiano acquistato diritti sul bene coinvolto nel processo in base ad un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

La pubblicità non è impostata su base reale, ma su **base personale**, cioè la trascrizione non fa riferimento a un bene, ma con riferimento alle parti dell'atto. In particolare si fa a favore di una persona (es. compratore) e contro un'altra persona (es. il venditore).

L'art 2650 sancisce la c.d. **continuità delle trascrizioni**, cioè le varie vicende non devono subire interruzioni, infatti il codice prevede che, quando un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore d'acquisto.

La trascrizione costituisce un onere, non un obbligo, per la parte interessata, invece è un obbligo per il notaio o altro pubblico ufficiale.

Questo sistema non si applica in alcune zone d'Italia che erano di dominazione austriaca (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e in parte del Veneto) in cui si applica un diverso sistema di pubblicità immobiliare, detto **sistema tavolare**.

CAPITOLO XIV

LA DISCIPLINA

DELL'OBBLIGAZIONE

L'OBLIGAZIONE: CONCETTO E FUNZIONE

Si parla di **rapporto obbligatorio** quando la cooperazione, necessaria per realizzare un proprio obiettivo quando non lo si riesce a soddisfare autonomamente, dà vita a un rapporto espressivo di un vincolo che rende doverosa la prestazione di un soggetto nell'interesse dell'altro: l'avente diritto a detta prestazione è il **creditore**, chi è tenuto a effettuarla è il **debitore**.

Il termine adoperato per indicare il rapporto in questione è **obbligazione**, che consta quindi di due profili:

- Quello **passivo**, ovvero il debitore/obbligato
- Quello **attivo**, ovvero il creditore, titolare di un **diritto soggettivo relativo**.

L'OBLIGAZIONE E LE RELAZIONI NON OBLIGATORIE

Elementi di struttura del rapporto obbligatorio:

- **Natura intersoggettiva del rapporto:** sono infatti estranee all'obbligazione le relazioni che legano un soggetto a un bene.
- **Determinatezza o determinabilità del creditore e debitore** nel momento in cui sorge l'obbligazione, essendo che solo grazie alla cooperazione il creditore può veder realizzato il suo interesse, non è immaginabile che il debitore risulti non individuato o non individuabile.
- **Natura vincolante del rapporto**

Sono estranei dal contesto delle obbligazioni le c.d. **relazioni di cortesia**, che attengono al piano dei rapporti sociali e si instaurano in osservanza del galateo o delle norme di buona educazione, in quanto manca il vincolo a tenere un certo comportamento.

Sta di fatto che nel momento in cui è assunta la decisione di porre in essere la prestazione essa fa nascere tra i soggetti un contatto voluto che può far insorgere affidamenti e aspettative meritevoli di tutela, quindi non del tutto irrilevanti giuridicamente.

Il codice civile all'art 2034 c.c. disciplina le c.d. **obbligazioni naturali**, che hanno ad oggetto prestazioni non dovute, ma spontaneamente eseguite in esecuzione di doveri morali e sociali, e sancisce che esse **non sono ripetibili** (non restituibili), almeno che non compiute da un incapace.

Stesso vale per le **prestazioni in via amichevole**. Una prestazione amichevole è presa in considerazione dall'ordinamento per disciplinare il caso del trasporto a titolo amichevole di persone o bagagli nell'esercizio della navigazione marittima e va appunto ad affermare una responsabilità favorevole nei confronti del vettore, in quanto risponde solo per dolo o colpa grave.

La disposizione è applicabile anche al trasporto terreno.

Differenza tra trasporto amichevole e trasporto gratuito? Quest'ultimo costituisce esecuzione di un contratto di trasporto, quindi prestazione giuridicamente dovuta.

LA PRESTAZIONE

Art 1174 c.c.: *La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.*

L'articolo in questione esplicitamente identifica l'**oggetto dell'obbligazione** nella **prestazione**.

L'**art 1218 c.c.** considera inadempimento l'inesatta esecuzione della prestazione e l'**art 1256 c.c.** connette l'estinzione dell'obbligazione all'impossibilità della prestazione, quindi se ne deduce che la prestazione costituisce imprescindibile elemento di struttura dell'obbligazione.

Spontaneo è il richiamo alla classica tripartizione delle obbligazioni basata proprio sul tipo di prestazione: *dare, facere e prestare*.

La prestazione è il riscontro concreto dell'interesse che l'obbligazione intende soddisfare.

Un tempo aveva distinti due teorie:

- **Teoria patrimoniale:** riteneva che l'oggetto dell'obbligazione fosse il bene dovuto dal debitore, non il comportamento doveroso del soggetto obbligato
- **Teoria personale:** "personale" in quanto per identificare l'oggetto della prestazione al debitore e al comportamento che questo deve porre in essere per realizzare l'interesse del creditore. Teoria che ha prevalso sull'altra.

Inoltre una parte di dottrina dava rilievo alla distinzione tra:

- **Obbligazioni di mezzo o di comportamento:** il diritto del creditore si basa solo sul comportamento debitorio e non sul risultato che esso intende realizzare.
- **Obbligazioni di risultato:** in riferimento ad esse è solo il conseguimento del risultato che interessa al creditore.

È inconcepibile configurare obbligazioni di mero comportamento e di mero risultato, infatti l'art 1174 c.c. rappresenta la coesistenza e la dialettica tra la prestazione, associata al comportamento del debitore, e del risultato che il creditore aspira ad acquisire, quindi il suo interesse.

L'art 1174 c.c. chiarisce che la prestazione deve avere carattere patrimoniale ossia deve *essere suscettibile di valutazione economica*. Es. dare una somma di denaro o altre prestazioni che si prestano naturalmente ad una valutazione in termini economici (riparare un elettrodomestico).

Una prestazione priva di carattere patrimoniale può acquisirlo la dove siano i soggetti interessati ad attribuire ad essa una valenza economica.

L'**interesse del creditore** può anche non essere patrimoniale, quindi può non essere un interesse economico, ma anche un interesse puramente ludico o culturale del creditore.

Es. l'impegno assunto da un insegnante di impartire lezioni di inglese può soddisfare un interesse che sfugge dalla dimensione patrimoniale ed essere solo motivato da ragioni culturali

Il debitore è tenuto, con il suo comportamento, non solo a realizzare l'interesse primario del creditore, ma anche a far sì che non siano danneggiati i suoi beni o la sua persona: **obbligo di protezione**, considerato parte integrante della prestazione e dalla sua violazione ne si fa discendere la responsabilità contrattuale (art 1218 c.c.).

Quando l'obbligo di prestazione è autonomo, quindi esaurisca il rapporto senza presenza di obbligo di prestazione si può parlare di **obbligazione senza prestazione**, disciplinata dall'art 1337 c.c., che impone alle parti in trattativa non di effettuare una prestazione in senso stretto, ma di adottare un comportamento conforme a buona fede, con conseguenza responsabilità contrattuale (non aquiliana).

Si è sviluppata una corrente dottrinale che ha generalizzate le obbligazioni senza prestazione al di là del terreno delle trattative precontrattuali, definendo il concetto di **contatto sociale qualificato**, una relazione giuridica priva di obblighi di prestazione ma con obblighi di protezione. In quest'ottica ogni volta che un affidamento chiama in gioco la buona fede e gli obblighi che essa è in grado di generare e venga a palesarsi un danno correlato alla lesione di detto affidamento, saremo di fronte alla violazione di un'obbligazione senza prestazione.

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Art 1173 c.c.: *Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.*

Quindi da questo articolo si evince due fonti nominate e una genericamente delineata.

La nozione di **contratto** (art 1321 c.c.) poggia sull'accordo delle parti, per cui si tratta di una fonte consensuale di obbligazioni.

Mentre una fonte non consensuale di obbligazioni è il **fatto illecito**.

Art 2043 c.c.: *ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno*=responsabilità extracontrattuale, così definita il danneggiante non è legato al danneggiato da alcun preesistente rapporto o accordo contrattuale.

In questo caso il rapporto obbligatorio tra i due soggetti è occasionato dal danno e l'obbligazione costituisce la reazione predisposta dall'ordinamento al verificarsi di un fatto illecito.

Per quanto riguarda il generico riferimento ad **altri atti o fatti diversi dal contratto o fatto illecito**, sicuramente ciò segna il passaggio a un sistema di fonti delle obbligazioni aperto e elastico, a differenza del codice del 1865 che prevedeva un sistema rigido, dove le fonti erano: la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto e il quasi-delitto.

L'attuale codice non fa più richiamo al quasi-contratto e al quasi-delitto, ma possiamo dedurre che i quasi-delitti sono stati assorbiti nel fatto illecito e i quasi-contratti nella generica categoria degli altri fatti o atti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Sicuramente è complesso individuare la fonte di questa categoria generica, ma come abbiamo detto prima, le obbligazioni possono nascere anche da "contatti sociali".

L'ESATTO ADEMPIMENTO

L'**adempimento** è il modo ordinario (fisiologico) di estinzione dell'obbligazione, giacché rappresenta l'esito naturale della vicenda obbligatoria.

L'adempimento è esecuzione della prestazione da parte del debitore, ma capita nel codice di vederlo indicato con il termine pagamento, quindi più propriamente riferibile alle obbligazioni pecuniarie.

È mediante l'adempimento che trova soddisfazione l'interesse del creditore.

Art 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) sancisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto a risarcire il danno cagionato. "inadempiente" non è solo quando il debitore manchi di effettuare la prestazione, ma anche quando la esegue in modo inesatto.

Questo articolo richiama il principio dell'**esatto adempimento**.

Art 1176 c.c.: richiama la **diligenza del buona padre di famiglia** (osservanza di regole di cura, cautela e perizia tipiche dell'uomo medio) o del "buon professionista", che il debitore deve usare nell'adempiere l'obbligazione.

La diligenza è il criterio di misura qualitativa dell'adempimento, definibile come l'adeguato impiego di energie e mezzi da parte del debitore per conseguire la soddisfazione dell'interesse del creditore.

Art 1775 c.c.: sancisce la regola della **correttezza**, ovvero che entrambe le parti del rapporto obbligatorio si comportino reciprocamente con lealtà e onestà, questa fa anche in modo che il creditore non abusi del suo diritto. La correttezza va a coincidere con la **buona fede in senso**

oggettivo (generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di comportamento nell'esplicazione della vita giuridica dei soggetti).

Un altro indice per valutare l'esattezza della prestazione è l'**identificazione della persona che pone in essere l'adempimento**, che è di norma il debitore, è quindi esatto adempimento quello emanato dal debitore.

L'**art 1180 c.c.** prospetta la possibilità che anche l'**adempimento del terzo** possa estinguere l'obbligazione e configurarsi quindi come esatto. Il terzo di cui si parla è persona estranea al rapporto obbligatorio e alle parti in esso coinvolte.

L'adempimento del debitore può essere sostituito dall'esecuzione a opera di un terzo se la prestazione non ha caratteristiche tali da soddisfare l'interesse del creditore solo quando è eseguita dal debitore, in tale caso il creditore può rifiutarlo.

La liberazione del creditore non si realizza in caso si configurasse un **pagamento con surrogazione**, ovvero quando il terzo che adempie l'obbligazione del creditore, sostituendosi al debitore originario, subentra al creditore nel diritto verso il debitore. In questo caso si dà luogo a una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio.

L'adempimento va effettuato al creditore, ma l'**art 1188 c.c.** definisce esatto anche l'adempimento rivolto ad altri destinatari, come il rappresentante del creditore o la persona da questi indicata o autorizzata dalla legge.

L'**art 1189 c.c.** contempla l'ipotesi di pagamento a soggetto diverso dal creditore, ma non legittimato a riceverlo. In questo caso il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fede, buona fede in questo caso in **senso soggettivo** (intesa come ignoranza di ledere un diritto altrui).

Il vero creditore in questo caso per ottenere ciò che gli spetta deve rivolgersi a chi ha incamerato senza averne titolo la prestazione.

Per quanto riguarda la valutazione della capacità delle parti:

L'**art 1191 c.c.** sancisce che l'esatto adempimento, in quanto **atto dovuto**, estingue l'obbligazione a prescindere dall'eventuale incapacità (naturale o legale) del **debitore**.

L'adempimento del debitore incapace non può essere impugnato perché lo stato di incapacità non influisce sullo scopo dell'atto né sull'idoneità dello stesso a soddisfare l'interesse del creditore.

In virtù di tale norma si **esclude la natura negoziale dell'adempimento**, ma piuttosto si rafforza l'idea che l'adempimento sia un **atto giuridico in senso stretto**, in quanto non rileva la presenza o meno della capacità di agire del debitore, quel che conta è la prestazione.

Per quanto riguarda il creditore, l'**art 1190 c.c.**, afferma che il pagamento fatto a persona incapace di riceverlo non libera il debitore, quindi implica la necessità della sua capacità di agire nel momento in cui riceve il pagamento. È comunque ipotizzabile che creditore della prestazione sia un soggetto incapace di agire (come un minore) e in questo caso può essere data la prova che la prestazione ha effettivamente dato luogo a un **incremento della propria sfera economica** (quella del creditore).

Spostiamo ora l'attenzione verso l'oggetto della prestazione:

L'**art 1181 c.c.** sancisce che il creditore è legittimato a rifiutare l'**adempimento parziale**, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente. Solo eccezionalmente la legge, per venire incontro al debitore che non sia in grado di onorare puntualmente i suoi debiti, consente, mediante l'**esdebitazione**, al debitore di ottenere la liberazione con il solo pagamento di una parte, consentendogli in questo modo di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica.

L'art 1192 parla invece di **adempimento irregolare**, ovvero nel caso in cui il pagamento sia effettuato con cose altrui o con cose di cui il debitore non poteva disporre. In questo caso il debitore non può impugnare il pagamento, salvo se offre di adempiere con cose di cui può disporre (**surrogazione reale**). Qualora il creditore non fosse a conoscenza della mancata disponibilità delle cose ricevute da parte del debitore (buona fede), egli può **impugnare il pagamento** impedendo l'effetto estintivo dell'obbligazione.

L'art 1197 c.c. ammette la prestazione **in luogo di adempimento (*datio in solutum*)**; con essa il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una **prestazione diversa da quella dovuta**, anche se di valore maggiore, sempre che il creditore vi acconsenta.

Si realizza mediante un **contratto solutorio di natura reale**, nel senso che l'obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita.

La *datio in solutum* può compiersi anche a mezzo della **cessione di un credito**; in tal caso l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito (**cessione pro solvendo**), se non risulta una diversa volontà delle parti. In alternativa i soggetti interessati possono stabilire che l'estinzione dell'obbligazione si determini a seguito dell'accordo di cessione, a prescindere cioè della riscossione del credito (**cessione pro soluto**) (art 1198 c.c.).

Va anche considerato il luogo dell'adempimento:

L'art 1182 c.c. dà facoltà alle parti di stabilire il luogo ove la prestazione deve essere eseguita; luogo che può essere individuato dagli usi o desunto dalla natura della prestazione.

Laddove la determinazione non sia avvenuta secondo tali criteri, entra in gioco la regola legale, per cui:

- a) Se l'oggetto è la consegna di una cosa certa e determinata, il luogo dell'adempimento è quello in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta
- b) Se l'oggetto è il pagamento di una somma di denaro liquida, l'obbligazione va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; se l'obbligazione è illiquida e se detto domicilio è diverso da quello che aveva al momento della nascita del vincolo obbligatorio presso il domicilio del debitore.
- c) In tutti gli altri casi il luogo dell'adempimento è il domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Quindi l'adempimento effettuato in un luogo diverso da quelli indicati, non è esatto e non libera il debitore dall'obbligazione, ma resta possibile che il creditore lo accetti come esatto.

Per ciò che riguarda il **tempo dell'adempimento (termine)** rimane ferma la facoltà delle parti di individuarlo a loro discrezione, ma in mancanza di ciò, la legge fissa la regola secondo cui la prestazione può **essere pretesa immediatamente**, se non impongano diversamente gli usi, la natura dell'obbligazione o le modalità/luogo dell'esecuzione.

In assenza di indicazione diversa, il termine previsto è sempre a **favore del debitore**, ciò significa che il debitore non può essere costretto ad adempiere anticipatamente.

Se invece il termine è stato stabilito a favore del creditore, questi può pretendere in ogni momento l'adempimento.

Se il termine è stato stabilito a favore di entrambi, l'adempimento non può essere preteso né eseguito prima del tempo.

I MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.

GENERALITA'.

L'adempimento è il modo ordinario di estinzione dell'obbligazione, ma il codice civile ne riconosce degli altri agli artt. 1230-1259.

Alcuni di essi sono definiti **satisfattori**, poiché implicano la realizzazione dell'interesse creditorio, mentre altri sono definiti **non satisfattori**, in quanto l'estinzione dell'obbligazione si determina senza che detto interesse trovi realizzazione.

1. LA COMPENSAZIONE

La **compensazione** è un modo di estinzione dell'obbligazione satisfattorio.

Essa opera quando tra due soggetti coesistano ragioni debito e credito reciproche in virtù di rapporti diversi, in questo caso i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art 1241 c.c.). Questa ora descritta è la **compensazione propria**.

La **compensazione improprie** è quando i rispettivi crediti e debiti traggono origine da un unico complesso rapporto giuridico, quindi hanno la stessa fonte.

Abbiamo 3 tipologie di compensazione:

- **Compensazione legale (art 1243 comma 1):** si ha quando i crediti reciproci siano **omogenei** (aventi per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere), **liquidi** (devono essere già determinati nel loro ammontare o facilmente determinabili) e **esigibili** (il suo adempimento non è soggetto a un termine o condizionato dal verificarsi di un evento futuro).
Perché la compensazione legale operi è necessario che la parte la faccia valere in giudizio, attraverso la **proposizione dell'eccezione di compensazione**, in opposizione alla richiesta di adempimento dell'altra parte.
I debiti reciproci si estinguono però non dal giorno della sentenza, ma dal momento della loro coesistenza automaticamente (*ex tunc*).
- **Compensazione giudiziale (art 1243 comma 2):** si ha quando, nel corso di un giudizio, venga invocato un credito liquido e esigibile e l'altra parte opponga in compensazione un controcredito **omogeneo** ed **esigibile**, non è richiesta la liquidità. Il giudice in questo caso può dichiarare l'estinzione dei due debiti.
- **Compensazione volontaria (art 1252 c.c.):** si ha quando le parti in forza di uno specifico accordo rinuncino in tutto o in parte ai rispettivi crediti reciproci seppure questi non presentino i requisiti per dar luogo a compensazione legale o giudiziale.

La compensazione non può avere luogo per alcuni crediti, elencati dall'art 1246, come il credito agli alimenti, che si risolverebbe per l'alimentando nell'impossibilità di soddisfare proprie primarie esigenze di vita.

2. LA CONFUSIONE

È un modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio.

Si ha confusione al verificarsi, per effetto di atto *inter vivos* o *mortis causa*, della riunione, in capo alla medesima persona, delle qualità di creditore o debitore (**art 1253 c.c.**).

Per esempio se il debitore divenga erede del proprio creditore, in quanto è inconcepibile che un debitore paghi a sé stesso.

Diverso fenomeno è la **consolidazione**, che si verifica con la riunione, in capo a una stessa persona, del diritto di proprietà con un diritto reale limitato, quest'ultimo verrà assorbito in quello di proprietà, di portata più ampia.

3. LA NOVAZIONE OGGETTIVA

La **novazione oggettiva** comporta l'estinzione dell'originaria obbligazione per via della creazione, in sua sostituzione, di un altro rapporto obbligatorio, diverso da quello precedente quanto all'oggetto (**novazione reale**, es. obbligazione pecuniaria sostituita con l'obbligazione di trasferire un bene immobile) e/o al titolo (**novazione causale**, es. il debitore di una somma a titolo di canone di locazione si accorda col creditore affinché lo stesso importo sia versato a titolo di mutuo).

Art 1230 c.c. sancisce che l'**effetto estintivo** proprio della novazione, che trae origine dall'accordo tra le parti, non si produca se non in presenza di un certa manifestazione di volontà (**animus novandi**), tale volontà può anche desumersi per via dell'interpretazione dell'accordo o risultare implicata in atti o comportamenti concludenti.

Elementi novazione:

- **Elemento oggettivo** (diversità della nuova obbligazione)
- **Elemento soggettivo** (*animus novandi*).

La novazione trova fonte in un **contratto** che determina l'estinzione dell'obbligazione novata e la sostituzione di questa con altra obbligazione.

È un modo non soddisfacente, perché l'interesse del creditore non è soddisfatto quando la vicenda estintiva si realizza.

Qualora l'obbligazione originaria sia inesistente perché invalida o estinta, la novazione è inefficace o addirittura nulla, ma se l'obbligazione originaria deriva da un **titolo viziato da annullabilità** la novazione è valida se il debitore che ha assunto il nuovo debito era a conoscenza del vizio (art 1234 c.c.).

Dall'estinzione del precedente rapporto deriva l'**estinzione dei suoi accessori**, salvo diverso accordo tra le parti (come i privilegi, il pegno e le ipoteche) (art 1232 c.c.).

L'art 1235 c.c. parla di **novazione soggettiva** per esempio nel caso in cui un nuovo debitore si sostituisce a quello originario che viene liberato, in questo caso gli istituti mediante i quali la sostituzione si realizza sono la delegazione, espromissione e l'accollo.

4. LA REMISSIONE DEL DEBITO

È un modo di estinzione dell'obbligazione non soddisfacente e si sostanzia nella dichiarazione unilaterale del creditore recante volontaria e gratuita rinuncia al proprio credito, nella sua interezza (**art 1236 c.c.**). Una **remissione solo parziale** del debito non è causa di estinzione dell'obbligazione, ma di modificazione dell'oggetto di quest'ultima.

Non è necessaria una dichiarazione di accettazione da parte del debitore beneficiario, ma è un **negozio giuridico unilaterale avente natura recettizia**, dal momento che l'obbligazione è da considerare estinta quando la dichiarazione del creditore viene comunicata al debitore.

Questa dichiarazione è di norma espressa, ma può anche essere tacita e implicata in un comportamento concludente (restituzione documento costituente il titolo originale del credito).

Nel caso in cui il debitore non voglia profittare della remissione ha la possibilità di opporre ad essa una dichiarazione dove risulti il suo **rifiuto** al beneficio, purché ciò avvenga in un termine opportuno. Tale rifiuto pone nel nulla *ex tunc* l'effetto estintivo della remissione.

Ogni credito può essere oggetto di remissione, ma alcuni crediti, come il credito alimentare, sono irrinunciabili.

Inoltre con la remissione vengono a meno le garanzie costituite a tutela del credito (art 1239 c.c.).

Diverso è il ***pactum de non petendo***, cioè l'impegno del creditore a non agire in giudizio per la realizzazione della sua pretesa, quindi non ha come effetto l'estinzione dell'obbligazione.

Inoltre quando la rinuncia di un credito integri il contenuto di una transazione non è qualificabile come atto di remissione del credito, in quanto non è caratterizzato da gratuità.

5. L'IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL

DEBITORE

È un modo non soddisfacente di estinzione dell'obbligazione con correlata liberazione del debitore solo se non risulti a costui imputabile; infatti come si evince dall'art 1218 l'impossibilità imputabile al debitore non estingue l'obbligazione.

"Sopravvenuta" nel senso che deve connettersi ad eventi si siano verificati in epoca successiva alla costituzione del rapporto obbligatorio, infatti l'impossibilità originaria preclude *ab initio* la nascita del vincolo.

L'impossibilità è rapportata a situazioni diverse:

- **Impossibilità totale e definitiva:** quando deriva da un impedimento irreversibile per l'esecuzione della prestazione e ovviamente ha effetto estintivo
- **Impossibilità temporanea:** ha invece a che fare con l'adempimento, non con la prestazione, e finché l'impossibilità perdura, il debitore non è responsabile per il ritardo nell'adempimento e l'obbligazione non si estingue.
- **Impossibilità parziale:** il debitore resta tenuto ad eseguire la prestazione per la parte che è rimasta possibile e solo all'esito di questo adempimento parziale è liberato dal vincolo.

L'impossibilità può essere **materiale**, quando vi è il perimento o distruzione della cosa dovuta, ma anche lo smarrimento della cosa determinata (art 1257 c.c.), oppure **giuridica**, per esempio nell'ipotesi di incommerciabilità del bene oggetto della prestazione.

Inoltre, può essere:

- **Oggettiva:** il verificarsi di eventi totalmente estranei alla persona del debitore e non evitabili né prevedibili che precludano l'adempimento. Questi eventi richiamano i concetti di:
 - **Caso fortuito:** avvenimento estraneo al debitore e alla sua sfera di controllo, caso eccezionale che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto.
 - **Forza maggiore:** forza esterna che determina la persona a compiere un'azione cui questa non può opporsi
 - **Factum principis:** decisione imperativa dell'autorità che sia d'ostacolo all'adempimento
- **Soggettiva:** attiene alla persona del debitore che non è in grado, economicamente o fisicamente di eseguire la prestazione. È osservabile per lo più in riferimento a obbligazioni aventi per oggetto un fare non fungibile. (amputazione braccia di un pittore)

Del tutto irrilevante è invece la ***difficultas praestandi***, che è connessa a circostanze che vanno a rendere semplicemente più complicato o disagiata l'adempimento, e quindi non ha nulla a che vedere con l'impossibilità.

LA MORA DEL CREDITORE. LA LIBERAZIONE COATTIVA DEL DEBITORE.

La **mora del creditore** trova spazio quando il creditore, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione offerta dal debitore oppure frappone ostacoli all'adempimento da parte di quest'ultimo (**art 1206 c.c.**).

Non è annoverabile tra i modi di estinzione dell'obbligazione, ma si tratta di una situazione particolare perché la soddisfazione dell'interesse del debitore alla liberazione dal vincolo obbligatorio si attua in **via coattiva**, quindi contro o senza la volontà del creditore.

Si tratta di un *deficit* di cooperazione imputabile al creditore, ma deve essere data al debitore la possibilità di effettuare la prestazione dovuta e per fare ciò la legge prevede un certo *iter*.

Il primo passo è la **costituzione in mora del creditore**, dove occorre una **formale e solenne offerta di adempimento**, i quali requisiti di validità sono elencati nell'art 1208 c.c., dove al punto 7 prevede la necessità che l'offerta sia fatta da un **ufficiale pubblico** (notaio o ufficiale giudiziario).

- Se l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere **reale**: il pubblico ufficiale deve recarsi con la cosa dal creditore e farne formale offerta
- Laddove l'oggetto della prestazione siano cose mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore o beni immobili, l'offerta deve avvenire per **intimazione**, ovvero tramite un atto notificato al creditore da un ufficiale giudiziario, contenente l'ora, il giorno e il luogo in cui il debitore intende consegnare le cose mobili o rilasciare l'immobile a favore del creditore.

Perché gli effetti della mora si producano occorre che l'**offerta sia accettata dal creditore** o che essa sia **dichiarata valida con sentenza passata in giudicato**.

Effetti della mora (decorrono dal giorno dell'offerta):

- Traslazione sul creditore stesso del rischio legato all'impossibilità sopravvenuta.
Ciò merita attenzione nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive. In questo caso, quando una delle prestazioni divenga impossibile operano le regole degli art 1463 e 1464, ma tali non si applicano se il creditore è in mora e che quindi deve eseguire la sua prestazione anche quando la controprestazione sia divenuta impossibile.
- La non spettanza al creditore degli interessi o dei frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore
- Obbligo per il creditore di risarcire i danni derivanti dalla sua mora e rimborsare le spese per la custodia e la conservazione della cosa.

Il debitore, a fronte del rifiuto dell'offerta reale o il creditore non si sia presentato dopo l'intimazione, può eseguire il **deposito liberatorio** (art 1210 c.c.):

- Denaro e titoli di credito vanno depositati presso la **cassa dei depositi e prestiti** o presso un **istituto di credito**
- Le altre cose mobili presso **stabilimenti di pubblico deposito**

Una volta effettuato il deposito e che esso sia stato o accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è finalmente liberato dalla sua obbligazione e non può più ritirare il bene.

In caso di un bene immobile è previsto che il debitore, dopo l'intimazione, possa ottenere dal Presidente del Tribunale la nomina di un **sequestratario** al quale l'immobile è consegnato con contestuale liberazione del debitore. (art 1216)

Un caso eccezionale è quello in cui la prestazione riguarda **cose deperibili o di dispendiosa custodia**. In questo caso il debitore può far sì che il tribunale ne dia **l'autorizzazione a venderle**. (art 1211 c.c.)

L'art 1214 c.c. contempla la possibilità dell'**offerta secondo gli usi**, in alternativa all'offerta reale o intimazione. In questo caso però gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui il debitore esegue il deposito a norma dell'art 1212.

Tutto ciò per quanto riguarda le prestazioni *di dare*, mentre nel caso di obbligazioni *di fare* il legislatore non disciplina il momento in cui il debitore è liberato in quanto l'obbligazione implica un'attività personale, quindi non ci può essere un deposito o la nomina di un sequestratore. Allora in questo caso l'art 1217 conclude il fatto che prima dell'accettazione del credito o della sentenza passata in giudicato il debitore non può considerarsi libero.

LE SPECIE DI OBBLIGAZIONI. GENERALITA'.

Una distinzione generale è quella tra:

- **Obbligazione di dare cosa determinata:** presenta diversi profili peculiari come si vedrà, per esempio il vincolo dell'obbligato di custodire la *res* fino al momento della consegna (art 1177 c.c.)
- **Obbligazione generica:** ha per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, e in questo caso l'esatto adempimento si connette alla prestazione di cose di qualità non inferiori alla media (art 1178 c.c.)

Vediamo ora diverse categorie di obbligazioni.

1. L'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA. IL PRINCIPIO NOMINALISTICO. DEBITO DI VALUTA E DEBITO DI VALORE

Il **debito di denaro** dà luogo a un'**obbligazione pecuniaria**, infatti lo stesso art 1277 c.c. parla di *debito di somma di denaro*.

Il denaro è una *res* singolare, in quanto è sia **mezzo di pagamento**, sia **bene in sé**, sia **unità di misura**.

Distinzione tra:

- **Denaro-valuta:** il valore nominale del denaro
- **Denaro-valore:** valore commisurato al suo potere di acquisto, cioè a ciò che, in un determinato spazio tempo con una certa somma di denaro è possibile acquistare, quindi soggetto a variazioni.

Secondo l'art 1277 i debiti pecuniari si estinguono con **moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale**. Quindi si guarda al denaro-valuta e qui trova espressione il **principio nominalistico**: ai fini dell'identificazione dell'esatto adempimento con valenza estintiva del debito, è solo il valore nominale che conta.

Il termine "moneta" utilizzato dall'art 1277, altrimenti detto "in contanti" deve fare il conto con le **limitazioni imposte dalla legge all'uso del contante**, per esempio per la lotta contro l'evasione fiscale o il tracciamento dei pagamenti.

Sono infatti largamente usati bonifici o assegni, ma in questo caso si parla di prestazioni in luogo dell'adempimento (*datio in solutum*)? La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non ci si trova in presenza di una *datio in solutum* e che è consentito al creditore rifiutare il pagamento solo dove sussista un giustificato motivo secondo la regola della correttezza e buona fede (es. dubbia regolarità dell'assegno).

Sicuramente il principio nominalistico penalizza i creditori, i quali però, sempre che la parte passiva del rapporto sia d'accordo, possono evitarne l'applicazione.

- L'art 1278 c.c. sancisce che l'oggetto dell'obbligazione può essere **una somma riferita a moneta non avente corso legale nello stato**, come la **valuta estera**. Il debitore però può liberarsi pagando in moneta legale secondo il **cambio vigente**.

Il creditore può escludere però l'adempimento tramite una moneta avente corso legale apponendo la **clausola "effettivo"**, che esprime l'idoneità della sola valuta estera a soddisfare l'interesse creditorio. Se però il debitore mostri l'impossibilità di procurarsi la moneta richiesta al tempo del pagamento può adempiere con la moneta avente corso legale nello stato.

- Un altro sistema è quello di **agganciare la determinazione della somma dovuta al valore di un bene**.
 - o Clausola oro: le parti concordano che la quantità dell'importo sia commisurata al valore di una certa quantità di oro al tempo del pagamento
 - o Clausola di indicizzazione (tra le quali è particolarmente diffusa la clausola ISTAT): l'importo monetario dovuto è periodicamente aggiornato in relazione alla variazione dei prezzi di alcuni beni, accertata appunto dall'Istituto di Statistica.

Da ciò si rileva che il prototipo di obbligazione pecuniaria è il **debito di valuta**, ma non è estraneo nemmeno il **debito di valore**, estratto quindi dall'influenza del principio nominalistico. (un esempio di debito pecuniario di valore è il risarcimento danni, in quanto il valore del danno è apprezzato non nel momento in cui il danno è prodotto, ma nel momento in cui il danno viene liquidato).

1.1. GLI INTERESSI

L'art 1282 c.c. sancisce che i crediti pecuniari **liquidi** ed **esigibili** producono alla scadenza interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Quindi il denaro è un **bene fruttifero** e gli interessi dei capitali sono **frutti civili**.

3 tipologie di interessi:

- **Interessi corrispettivi o di pieno diritto**: sono prodotti automaticamente, anche senza una previsione specifica, da ogni debito pecuniario liquido (ammontare precisamente determinato) ed esigibile (non sottoposto a condizioni né termini, oppure quando il termine è scaduto). Essi sono la **contropartita del godimento** di cui il debitore ha beneficiato: il creditore ha diritto a ottenere la somma di denaro, questo vuol dire che fino al momento

dell'adempimento il debitore gode di questa somma che dovrebbe essere versata al credito e questo godimento rappresenta l'interesse corrispettivo.

- **Interessi moratori:** sono da corrispondere in caso di ritardo dell'adempimento e sono calcolati dal giorno in cui il creditore ha messo in mora il debitore.

Entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto.

- **Interessi compensativi** (art 1499 c.c.): sono circoscritti alla disciplina della vendita; se il venditore consegna al compratore un bene produttivo di frutti, prima di ricevere il pagamento, ha diritto a tali interessi, anche se il prezzo non è ancora esigibile,

Gli **interessi corrispettivi** possono essere esclusi o dalla legge o per volontà delle parti (i locatari e gli affittuari non sono tenuti a versare gli interessi sui canoni dovuti).

Il debito di interessi è **autonomo**, quindi rimane distinto (IMPORTANTE perché il debito capitale è fruttifero, ma debito di interessi a sua volta non produce interessi. Cfr anatocismo), rispetto al debito "di capitale" ed è un **debito di valuta** (principio nominalistico). Il debito di interessi trova espressione in una somma di denaro calcolata in una misura percentuale, tramite l'applicazione di un **saggio** (tasso) di interesse rispetto all'importo del capitale.

Il saggio può essere:

- **Saggio legale:** è variabile e determinato con decreto dal Ministro delle Finanze. Trova applicazione in tutti i casi in cui le parti non si siano accordate sugli interessi.
- **Saggio convenzionale:** determinato dalla volontà delle parti. La legge impone però che nel caso in cui la determinazione di interessi superiori alla misura legale sia operata in **forma scritta**, in caso di mancato rispetto di questo onere sarà utilizzato il saggio legale.

1.2. INTERESSI ED USURA

Esiste comunque un limite alla possibilità di stabilire interessi convenzionali più elevati rispetto alla misura di quello legale: tale limite è configurato dall'**usura**.

L'usura è **penalmente sanzionata** e il reato previsto demanda alla legge di stabilire il **tasso di soglia** oltre il quale l'interesse è da considerare usurario.

Quindi le parti non possono fissare un tasso di interesse (sia per gli interessi corrispettivi sia per quelli moratori) che, alla data relativa della stipula, superi di 4 punti percentuali il **tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.)** trimestralmente rilevato dal Ministro delle Finanze.

Sono altresì usurari gli interessi che, avendo avuto riguardo delle condizioni di difficoltà economica del debitore e anche se inferiori a tale limite, risultano comunque **sproporzionati** rispetto alla prestazione di denaro. (usura soggettiva)

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è **nulla** e non sono dovuti interessi (art 1815 c.c.). Questa regola però è prevista solo per gli interessi corrispettivi, non anche quelli di mora, che qualora risultino fissati in maniera superiore al tasso di soglia dovranno pur sempre essere corrisposti.

1.3. L'ANATOCISMO

L'**anatocismo** è il fenomeno della produzione di interessi (definiti **anatocistici** o **composti**) da parte di interessi già scaduti (essendo decorso il termine di esigibilità): si tratta in pratica della **capitalizzazione degli interessi prodotti da un capitale** i quali possono fruttare altri interessi.

L'art 1283 vieta l'anatocismo, ma sono fatti salvi 3 casi:

- **Anatocismo legale:** gli interessi scaduti possono generare altri interessi (anatocistici) con l'intervento di una **domanda giudiziale**.
- **Anatocismo convenzionale:** per effetto di una **convenzione posteriore alla loro scadenza**

In entrambi i due casi si deve trattare di interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi.

- L'articolo inoltre fa espressamente salvi gli **usi contrari**.

Anatocismo bancario: Il termine anatocismo bancario si usa per indicare l'operazione con cui la banca aggiunge alla somma capitale di un proprio credito gli interessi su di esso maturati per poi prendere tale importo complessivo come base per calcolare nuovi interessi sullo stesso. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti **composti**.

2. L'OBLIGAZIONE ALTERNATIVA

Le obbligazioni che prevedono l'esecuzione di un'unica prestazione sono dette **semplici**, mentre quelle che hanno ad oggetto più prestazioni sono dette **complesse**.

Quest'ultime sono le **obbligazioni alternative**, ovvero quando sono dovute dal debitore due o più prestazioni, ma il debitore si libera prestandone una (**art 1285 c.c.**). Quindi si ha come elemento la **pluralità dell'oggetto** e qualora ci siano più di due prestazioni si parlerà di **obbligazioni alternative multiple**.

L'obbligazione alternativa diventa semplice nel momento della c.d. **concentrazione**, ovvero quando l'alternatività delle prestazioni viene sciolta mediante la **facoltà di scelta**. L'effettuazione della prestazione scelta estingue l'obbligazione.

Di solito il potere di scelta spetta al debitore se non è disposto in modo diverso nel titolo dell'obbligazione, ma può anche essere affidato al creditore o a un terzo. Il soggetto di tale facoltà, qualora non la eserciti nel termine, finisce per perderla a vantaggio della controparte, mentre provvede il giudice nel caso la scelta non effettuata nel termine fosse rimessa a un terzo.

Nel caso delle obbligazioni alternative l'impossibilità originaria di una delle due prestazioni comporta la concentrazione dell'obbligazione, che diventa semplice. Il **debitore si libererà** prestando l'unica prestazione possibile.

In caso di **impossibilità sopravvenuta** di una delle prestazioni dedotte in obbligazione si deve distinguere se l'impossibilità sia o no imputabile a una delle parti del rapporto obbligatorio. Se l'impossibilità non sia imputabile l'obbligazione alternativa diventa semplice.

Se l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile alla parte che ha il diritto potestativo di scelta, questa perde il diritto di scelta o è tenuta al risarcimento del danno.

Se l'impossibilità è dovuta alla parte che non ha il diritto di scelta, l'altra parte non perde il diritto di scelta. Se il diritto di scelta compete al creditore e l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile al debitore, il creditore potrà scegliere tra la prestazione rimasta possibile, e il risarcimento del danno che deriva dall'impossibilità dell'altra prestazione.

Se l'impossibilità sopravvenuta è relativa ad entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione e l'impossibilità non sia imputabile alle parti, **l'obbligazione si estingue**.

L'obbligazione alternativa non va confusa con l'**obbligazione facoltativa**, in quanto nella prima tutte le prestazioni dedotte in obbligazione sono *ab origine* e fino alla concentrazione dovute, mentre nella seconda una sola risulta dovuta, ma al debitore è data la facoltà di liberarsi eseguendone un'altra.

3. LE OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE. L'OBBLIGAZIONE SOLIDALE. SOLIDARIETA' E PARZIARIETA'. LE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI.

Le **obbligazioni solidali** integrano la più ampia categoria delle **obbligazioni soggettivamente complesse**.

Il concetto di solidarietà rimanda alla presenza di una pluralità di soggetti nel lato attivo e/o passivo del rapporto obbligatorio:

- **Solidarietà attiva:** quando più soggetti siano creditori di un unico debitore
- **Solidarietà passiva:** quando ci sono più debitori di un solo creditore
- È ipotizzabile anche la presenza nel contempo di più debitori di una pluralità di creditori.

Sono invece soggettivamente semplici le obbligazioni che vedono vincolato un solo debitore nei riguardi di un unico creditore.

Quel che conta è che la prestazione dovuta dai vari debitori o pretesa dai diversi creditori sia unica, invece non esclude la solidarietà il fatto che ciascun debitore sia vincolato con modalità diverse rispetto agli altri.

Nell'obbligazione plurisoggettiva **passiva** la regola è quella della **solidarietà**, per cui ciascun dei condebitori può essere costretto ad adempiere, liberando gli altri e al contempo acquisendo nei loro confronti un credito avente ad oggetto la restituzione di quanto prestato.

Alla solidarietà si contrappone la **parziarietà**, ovvero che ognuno dei condebitori sia tenuto esclusivamente **per la propria parte**.

Emerge da qui il nesso tra le obbligazioni parziarie e le **obbligazioni divisibili**, un nesso che rende indistinguibili le due categorie. Secondo l'art 1314, nel caso di obbligazioni divisibili, quando la legge o il titolo **escludono il vincolo solidale**, l'obbligazione è parziaria, quindi «ciascun creditore non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascun debitore non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte».

Nessun legame invece sussiste tra obbligazioni parziarie e **obbligazioni indivisibili**, in quanto l'indivisibilità sussiste quando (art 1317 c.c.)

- a) Il bene oggetto della prestazione conserva la sua identità fisica o funzionale solo se unitariamente considerato (quadro)
- b) L'interesse delle parti può essere soddisfatto solo dall'intero bene

Infatti le obbligazioni indivisibili fanno ricorso alla disciplina delle obbligazioni solidali.

La **solidarietà passiva** avvantaggia il creditore, ed è per questo che senza il suo consenso non può essere esclusa. Il creditore può però favorire una dei condebitori **rinunciandolo** solo nei suoi confronti **alla solidarietà**, ma gli consente comunque si esigere da ciascuno degli altri l'intera prestazione. Ovviamente la rinuncia alla solidarietà non estingue l'obbligazione.

In caso di **solidarietà attiva**, ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione al debitore e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (art 1292 c.c.). Il debitore ha facoltà di determinare a quale concreditore pagare in solido, almeno che non sia stata proposta nei suoi confronti una **domanda di adempimento in giudizio**, il che vincola l'obbligato verso l'attore.

Per quanto riguarda i rapporti interni tra debitori o creditori solidati:

Nei rapporti interni tra condebitori e concreditori le obbligazioni si dividono in base alle **rispettive parti**, le quali si presumono eguali.

Così viene configurato il **diritto di regresso**: Consiste nel diritto per un condebitore di rivalersi verso gli altri condebitori solidali nel caso in cui il primo abbia effettuato per l'intero il pagamento al comune creditore. Con l'azione di regresso, chi ha pagato chiede il rimborso delle quote corrispondenti alle parti di debito che gravavano sugli altri.

Invece, nel caso in cui l'obbligazione fosse stata contratta **nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori**, se il soggetto che ha pagato è diverso dall'interessato, allora potrà richiederli il rimborso dell'intera somma corrisposta, se invece il soggetto che ha pagato è l'interessato, questo non avrà regresso nei confronti di nessun condebitore.

Quando un condebitore (sul quale è esercitato il regresso) sia insolvente, la perdita non viene sopportata in via esclusiva da chi ha pagato, ma viene ripartita tra gli altri condebitori.

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'OBBLIGAZIONE. GENERALITA'.

Si parla di **modificazione dell'obbligazione** quando quest'ultima subisce un'alterazione in uno o più elementi rispetto all'iniziale conformazione, ma si tratta di una trasformazione che non innova né estingue l'obbligazione.

Possono essere alterazioni:

- Sul piano oggettivo (es. *datio in solutum*)
- Sul piano soggettivo, che interessano debitore o creditore e sono quelle che analizzeremo.

1. LA MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE

Quando si ha la sostituzione della persona del debitore, non può mancare il consenso del creditore. I **negozi di assunzione del debito altrui** sono: la **delegazione**, l'**espromissione** e l'**accollo**.

DELEGAZIONE

Esistono due tipi di delegazione: **delegazione di debito** e **delegazione di pagamento**.

Partiamo con la prima.

Con la **delegazione di debito**, il debitore (**delegante**) ordina ad un terzo (**delegato**) di assumere il debito che ha nei confronti del creditore (**delegatario**). Quindi il delegato, in esecuzione dell'ordine, si obbliga verso il delegatario ad eseguire la prestazione.

L'art 1268 c.c. sancisce che la delegazione non comporta la liberazione del debitore originario, salvo che il creditore non dichiari espressamente di liberarlo.

La delegazione è di norma **delegazione cumulativa**, appunto perché all'originario debitore si affianca, e non si sostituisce il delegante. Da ciò ne trae vantaggio il creditore che può contare su due soggetti debitori e non più solo sul debitore originario.

Anche se il creditore che ha accettato la delegazione non può rivolgersi al debitore originario se prima non ha chiesto l'adempimento al nuovo debitore.

Viene così a configurarsi a vantaggio del delegante il **beneficio dell'ordine** e il delegato assume la veste di debitore principale.

Il carattere cumulativo della delegazione viene meno solo se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario: in questo caso si parla di **delegazione liberatoria** e si presta ad essere inquadrata nel fenomeno della **novazione soggettiva** (art 1235 c.c.).

La novazione soggettiva fa pensare all'estinzione dell'originaria obbligazione facente capo al delegante, che viene sostituita da altra obbligazione, ovvero quella assunta dal delegato.

Effetti delegazione liberatoria:

- a) Il delegatario, se il delegato diviene insolvente, non può rivolgersi al debitore originario, a meno che o non ne avesse fatto **espressa riserva** o nel caso in cui l'insolvenza del delegato fosse preesistente all'assunzione del debito (art 1274 c.c.)
- b) Estinzione delle **garanzie**, ma il debitore liberato, i fideiussori e i terzi datori di pegno e ipoteca possono consentire espressamente a mantenere tali garanzie
- c) Quando il negozio di assunzione del nuovo debitore è nullo o è annullato **rivive l'obbligazione** del debitore originario liberato dal creditore

Il **rapporto** tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo ad obbligarsi è detto "**rapporto di provvista**", mentre quello tra debitore originario e creditore è detto "**rapporto di valuta**".

Quando le parti fanno riferimento a entrambi i rapporti si parla di **delegazione titolata**, quando invece è omesso ogni riferimento ai rapporti sottostanti si parla di **delegazione pura**.

Il delegato sempre e comunque può opporre al delegatario le **eccezioni** relative ai suoi rapporti con quest'ultimo (art 1271 c.c.).

La **delegazione di pagamento** è quando il delegato riceve l'ordine del delegante di eseguire materialmente il pagamento nei riguardi del creditore, in questo caso non vi è assunzione del debito altrui da parte del delegato (es. rapporti tra cliente e banca).

La delegazione di norma è coperta (prelievo soldi della banca dal conto bancario del delegante), ma può anche essere scoperta (quando vi è fondo insufficiente), in questo caso il delegato è debitore del delegante.

Il delegato **non ha l'obbligo di accettare la delega di pagamento**, mentre con l'accettazione il delegato è vincolato ad adempiere immediatamente l'obbligazione.

Il delegante può estinguere la delegazione **revocandola** prima che il delegato assuma l'obbligazione o adempia.

L'ESPROMISSIONE

L'**espromissione (1272 c.c.)** ha luogo quando un terzo assume un debito altrui verso il creditore, non in esecuzione di una delega e quindi a prescindere da un ordine del debitore.

Qui nasce un rapporto contrattuale tra terzo (**espromittente**) e creditore (**espromissario**), quindi il debitore originario (**espromesso**) rimane estraneo alla vicenda.

L'espromissione è di norma **espromissione cumulativa**: il creditore beneficia della duplicazione delle posizioni debitorie.

Ove il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario si ha un'**espromissione liberatoria**, che a differenza della delegazione liberatoria, quando vi è rischio d'insolvenza dell'espromittente, questo grava sul creditore che ha accettato la sostituzione del debitore originario.

In questo caso vi è irrilevanza del **rapporto di provvista**, quindi l'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con l'espromesso, ma è inevitabile presupposto il **rapporto di valuta** tra l'espromesso e l'espromissario.

L'ACCOLLO

L'accollo consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest'ultimo (**accollante**) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (**accollatario**) il pagamento di un debito del primo (**accollato**).

Può essere:

- **Accollo interno:** si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante: quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore accollato. Il creditore in questo modo non acquista accanto a quello originario un nuovo debitore, perciò:
 - il creditore non ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito
 - il terzo accollante in caso di mancata osservanza dell'obbligo risponde dell'inadempimento solo nei confronti del debitore accollato
 - il terzo accollante ed il debitore accollato possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dall'accollante stesso
- **Accollo esterno:** si ha quando l'accordo tra accollante e accollato si presenta come un **contratto a favore di terzo** (art 1411 c.c.), cioè quando terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall'accollante stesso l'adempimento del proprio credito. L'accordo tra debitore e terzo può essere modificato o posto nel nulla solo fin quando il creditore non vi aderisca, perché da quel momento l'impegno assunto dall'accollante diviene irrevocabile. Può essere:
 - **Cumulativo:** se il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante, in questo caso gode del beneficio dell'ordine.
 - **Liberatorio:** quando il debitore originario viene liberato tramite una dichiarazione espressa del creditore o tramite la sua adesione all'accollo.

Al creditore accollatario il terzo accollante può opporre oltre che le eccezioni relative al contratto in forza del quale si realizza l'accollo anche quelle che avrebbe potuto opporgli il debitore originario.

2. LA MODIFICAZIONE NEL LATO ATTIVO DELL'OBBLIGAZIONE

SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

La **surrogazione per pagamento** di cui all'art 1201 c.c. determina la modificazione della titolarità del credito o la sostituzione dell'originario creditore.

La surrogazione può adoperare anche per volontà del debitore e si verifica quando il debitore, che prende a **mutuo** una somma di denaro o altra cosa per pagare il proprio debito, surroga il mutuante (cioè il soggetto da cui ha preso a mutuo il denaro) nei diritti che spettano al creditore, anche senza il consenso di costui (art 1202 c.c.), quindi il mutuante diventerà il nuovo creditore.

CESSIONE DEL CREDITO

Si tratta di un contratto, oneroso o gratuito, concluso tra il creditore (**cedente**) ed un terzo (**cessionario**), volto a determinare il trasferimento a quest'ultimo della ragione creditoria di cui il primo è titolare.

Il contratto ha efficacia sin dal momento della stipulazione e non è necessario il consenso del debitore (**ceduto**).

- Se la cessione è notificata al debitore, questi può liberarsi dalla sua obbligazione solo effettuando la prestazione dovuta al nuovo creditore. Il pagamento rivolto al cedente non costituisce esatto adempimento.

- Se la cessione non viene notificata, il debitore, ignaro dell'avvenuto trasferimento, si può liberare anche col pagamento effettuato al cedente.

Tutti i crediti per loro natura sono suscettibili di cessione, ma non è consentita qualora:

- Il credito abbia carattere **strettamente personale**
- il trasferimento sia vietato dalla **legge**
- la cedibilità sia stata **convenzionalmente esclusa** dalle parti.

Oggetto di cessione possono essere anche i **crediti futuri**, essendo sufficiente che essi siano determinati o determinabili.

L'art 1263 sancisce che il credito è ceduto con tutti i suoi accessori (privilegi, garanzie reali e personali) compresi i frutti e gli interessi in scadenza.

Per quanto riguarda il pegno (garanzia accessoria reale), che si realizza tramite lo spossessamento del bene a vantaggio del creditore, il debitore può opporsi al trasferimento materiale del bene al cessionario, ma non anche del trasferimento giuridico della garanzia.

L'art 1265 stabilisce il criterio in base al quale risolvere l'eventuale **conflitto tra più cessionari del medesimo credito**. Tale criterio è quello della prima notifica al debitore o la sua accettazione.

Per quanto riguarda i rapporti tra cedente e cessionario:

- a. se la cessione è a **titolo oneroso**, il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del credito al momento della cessione. Se il credito ceduto non esisteva oppure non era nella titolarità del cedente è tenuto a risarcire i danni e restituire al cessionario quanto ricevuto.
Il cedente non garantisce la solvenza del debitore.
(cessione *pro solvendo*)
- b. se la cessione è a **titolo gratuito**, il cedente garantisce l'esistenza del credito solo se l'ha espressamente promessa e anche qui non garantisce la solvenza del debitore.
(cessione *pro solvendo*)

Sia in caso di cessione a titolo oneroso e a titolo gratuito il cedente può assumere anche la garanzia della solvenza del debitore, in tal caso si parla di cessione *pro solvendo*.

Per quanto riguarda le **eccezioni**, il debitore ceduto può opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

DELEGAZIONE ATTIVA

- **delegazione di credito**: quando il creditore (**delegante**) assegna al proprio debitore (**delegato**) un nuovo creditore (**delegatario**), nei confronti del quale il delegato si obbliga ad effettuare la prestazione dovuta
- **delegazione attiva di pagamento**: quando il creditore (**delegante**) avente diritto all'adempimento di un'obbligazione già scaduta, ordina al proprio debitore (**delegato**) di indirizzare la prestazione verso un nuovo creditore (**delegatario**), autorizzando quest'ultimo a ricevere dal delegato il pagamento.

Anche la delegazione attiva può essere

- **cumulativa**: è il debitore che trae vantaggio dal fatto che al creditore originario si affianchi un nuovo creditore
- **liberatoria**: quando il debitore sia liberato dall'obbligazione verso il delegante e la posizione di avente diritti alla prestazione sia unicamente riconosciuta al nuovo creditore.

L'INADEMPIMENTO

L'inadempimento è sicuramente il più naturale e chiaro riscontro alla patologia dell'obbligazione. L'inadempimento è categoria dell'obbligazione, ma è tendenza parlare anche di contratto inadempito nel caso di mancata realizzazione dell'assetto di interessi programmati e trasfusi in un contratto. A ciò si affianca la radicata propensione a considerare equivalenti le espressioni di **responsabilità per inadempimento e responsabilità contrattuale**, infatti al centro di quest'ultima è posto l'art 1218 che attiene alla responsabilità per inadempimento e anche gli artt. 1223-1227 c.c. fanno riferimento sia al danno da inadempimento sia del danno contrattuale.

La patologia si manifesta nell'inadempimento già realizzato, ma le avvisaglie dell'inadempimento posso scorgersi ancora prima quando per esempio «*il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesso*» (art 1186 c.c.). Da qui emerge l'esigenza di **tutela preventiva del credito** contro il pericolo dell'inadempimento, dove appunto, il creditore può esigere immediatamente la prestazione.

L'inadempimento è **tutto ciò che non è esatto adempimento**.

L'inadempimento può assumere diverse facce:

- **inadempimento totale**: totale inesecuzione della prestazione dovuta
- **inadempimento inesatto**: quando la prestazione effettuata risulti difforme rispetto a quella dedotta a oggetto dell'obbligazione.
- **Inadempimento parziale**, è una specie di inadempimento inesatto.
- Distinzione tra **inadempimento assoluto**, quando l'adempimento non effettuato non potrà più verificarsi, e **inadempimento relativo**, ovvero provvisorio
- **Inadempimento definitivo**

IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO

Quando si registra un ritardo nell'adempimento, l'interesse del creditore di vedere eseguito quest'ultimo permane e non è incompatibile con l'esigenza di veder riparati ex art. **1218 c.c.** i danni causati del **ritardo nell'adempimento**.

L'ipotesi classica di ritardo è quella legata al decorso del termine fissato per l'adempimento, ma ritardo può palesarsi anche là dove l'obbligazione non rechi fissazione di un termine. L'**art 1183** prevede infatti che in assenza di un termine fissato dalle parti la prestazione più essere pretesa dal creditore **immediatamente** e in caso di positivo riscontro apre la via alla tutela risarcitoria a norma dell'art 1218 c.c. riferita ai danni provocati dal ritardo:

- Il creditore ha l'onere di provare il titolo vantato, dovrà allegare il ritardo e dar dimostrazione del danno
- Il debitore per non incorrere in responsabilità deve provare che il ritardo è **giustificato dall'impossibilità di effettuare in tempo debito la prestazione per una causa a lui non imputabile**.

In questo caso due sono le svolte possibili al ritardo dell'adempimento:

- O dal ritardo segue l'esecuzione della prestazione (**adempimento ritardato**)
L'adempimento ritardato può però essere rifiutato dal creditore in modo legittimo se il debitore è in mora e può richiedere il risarcimento dei danni collegati al ritardo.
- O si verifica il **consolidamento della situazione di inadempimento**
In questo caso il creditore può pretendere legittimamente il risarcimento del danno

L'ADEMPIMENTO IN NATURA. LA MORA DEL DEBITORE. L'INADEMPIMENTO DEFINITIVO.

Finché è possibile l'effettuazione della prestazione dovuta, il creditore ha diritto a pretenderla: ciò vale anche laddove il debitore sia inadempiente. Si parla di diritto all'**adempimento naturale** dell'obbligazione.

L'adempimento in natura opera *in primis* anche mediante la correzione della prestazione inesattamente eseguita, quindi precede il risarcimento in luogo della prestazione e la coesistenza tra i due non è ipotizzabile. È invece configurabile il risarcimento del danno accanto alla prestazione che il creditore abbia conseguito in ritardo.

L'adempimento in natura può essere spontaneo o sollecitato dal creditore che ne faccia istanza.

Quando l'istanza è effettuata nelle forme previste dall'art 1219 c.c. si parlerà di **mora del debitore** e verranno a determinarsi gli effetti che alla mora sono associati.

I presupposti per la costituzione in mora sono: il ritardo nell'inadempimento di una prestazione esigibile e quali siano le cause che lo abbiano determinato.

La costituzione in mora è un **atto formale** e si deve realizzare tramite **intimazione o richiesta scritta** (a pena d'invalidità dell'atto). (*mora ex persona*)

Ci sono 3 ipotesi dove la costituzione in mora non è necessaria (quindi gli effetti della mora si producono automaticamente), dove è corretto parlare di *mora ex re*, **art 1219 c.c.**:

- a) Quando l'obbligazione deriva da **fatto illecito**
- b) Il debitore dichiara per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione
- c) Quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, almeno che il creditore non ne conceda una dilazione. In questo caso se il termine si consuma dopo la morte del debitore, la *mora ex re* si converte in *mora ex persona* nei confronti degli eredi, decorsi otto giorni dal ricevimento dell'intimazione.

L'art 1222 c.c. precisa che le disposizioni sulla mora non si applicano sulle obbligazioni di non fare, in quanto non può aversi ritardo nell'adempimento né adempimento ritardato.

L'offerta della prestazione dovuta, anche non formale, da parte del debitore al creditore vale ad escludere la mora e pone al riparo il debitore delle conseguenze legate al ritardo dell'inadempimento, salva la possibilità del rifiuto opposto dal creditore per motivo legittimo (art 1220 c.c.).

Effetti della mora del debitore:

1. **Sopportazione del rischio per la sopravvenuta impossibilità** della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. In questa ipotesi l'obbligazione non si estingue, ma il rischio in questione si trasferisce al debitore che va incontro a responsabilità come se la sopravvenuta impossibilità della prestazione fosse a lui imputabile.
Ciò si giustifica presumendo che l'esecuzione della prestazione verso il creditore avrebbe impedito l'impossibilità della medesima. Vi è la previsione di una **prova liberatoria** a favore del debitore, il quale, pur essendo in mora, si libera comunque dall'obbligazione, **dimostrando che pure nel caso di tempestivo adempimento l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.**
2. **Effetto interruttivo della prescrizione**
3. Obbligo del **pagamento degli interessi moratori** per quanto riguarda le obbligazioni pecuniarie

La costituzione in mora ha dunque a che fare col sistema della responsabilità per inadempimento e si possono individuare 2 diverse aspirazioni di fondo:

- **Concezione soggettiva:** mora come espressione della responsabilità del debitore che, con colpa o dolo, abbia causato ritardo ingiustificato e da questo ritardo scaturiscono tutte le conseguenze a carico del debitore responsabile
- **Concezione oggettiva:** costituzione in mora relazionata con l'emergere del diritto del creditore a ottenere il risarcimento del danno. Infatti, a seguito della mora, o il debitore adempie in natura o il creditore acquista la legittimazione ad agire ex art 1218 c.c., non avendo più interesse a ricevere la prestazione-

Qui si materializza il concetto di **inadempimento definitivo**, come conseguenza della costituzione in mora del debitore e che quindi non è più possibile adempiere.

IL REGIME DELL'ONERE DELLA PROVA. LA C.D. PROVA LIBERATORIA

L'art 1218 c.c. non esplicita alcuna regola relativa all'**onere della prova** che incombe sul creditore, mentre è chiaro nel porre a carico del debitore la c.d. **prova liberatoria**.

L'orientamento attualmente consolidato pone a carico del creditore la sola dimostrazione del proprio diritto a ricevere la prestazione, mentre gli basterà allegare che il debitore ha mancato ad effettuarla; sarà invece onere del debitore, che voglia liberarsi da responsabilità, di provare di aver adempiuto o che l'adempimento si è rivelato impossibile per causa a lui non imputabile.

Nella prova liberatoria il debitore deve dimostrare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione derivi da causa non imputabile al debitore.

L'art 1218 delinea un regime unitario: nel momento che la prestazione consiste sempre nell'esatto svolgimento, la disposizione supera la distinzione tra **obbligazioni di mezzi**, che potevano dirsi adempiute con la semplice osservanza delle regole di diligenza, e **obbligazioni di risultato**, che invece esigevano il conseguimento di un risultato.

I DUE MODELLI DI RESPONSABILITA'

- **Art 1176 c.c.:** *Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.*

È un **modello soggettivo**, in quanto questa norma, per appurare se l'inadempimento sia o meno imputabile al debitore, impone di verificare se il comportamento da questi tenuto sia conforme al canone astratto della **diligenza del buon padre di famiglia**, canone che rimanda al comportamento che un uomo medio, sufficientemente saggio ed avveduto, avrebbe tenuto nelle stesse circostanze concrete.

Nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale rileva invece la **diligenza-perizia**, parametrata sulla padronanza delle regole dell'arte che sono proprie dell'attività considerata.

- **Art 1218 c.c.:** *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*

È un **modello oggettivo**, in quanto qui non è la diligenza a decidere, ma il fatto che la prestazione sia esattamente eseguita o non lo sia.

La rigidità di tale giudizio è alleviata dalla prova liberatoria che è concessa al debitore.

È dalla prova liberatoria dell'art 1218 che avviene la conciliazione di questi due modelli; infatti la prova liberatoria impone di valutare se sia stato o meno il debitore a dare luogo alla causa che ha reso impossibile l'adempimento. Questa valutazione viene effettuata tramite il criterio della diligenza di cui l'art 1176 c.c.

Quindi nella stessa formulazione dell'art 1218 c.c. si registra la compresenza di due dati:

- Uno di carattere oggettivo: rappresentato dall'impossibilità della prestazione
- Uno di carattere soggettivo: rappresentato dalla non imputabilità dell'evento

L'impossibilità liberatoria è dunque da ancorare al c.d. **fatto impeditivo dell'esatto adempimento dell'obbligo** non superabile né evitabile nonostante l'impiego dello sforzo diligente dovuto.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La responsabilità dell'inadempimento del debitore trova riscontro in una disciplina che differisce dalla responsabilità civile/extracontrattuale ex art 2043 c.c.

Le regole del **risarcimento del danno** sono in larga parte però le stesse sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, ma non è omogeneo il contesto in cui operano:

- Il danno aquiliano si sostanzia nella perdita di un bene, mentre il danno da inadempimento si lega al mancato incremento della sfera patrimoniale del creditore
- Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve identificare il danneggiante tra i consociati, mentre nella responsabilità per inadempimento il creditore non ha lo stesso problema perché il soggetto con cui prendersela è individuato nella persona del debitore.

Anche nel caso in cui il debitore si avvalga di terzi per effettuare la prestazione dovuta, è sempre il debitore che risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art 1228 c.c.).

- Il **risarcimento per equivalente**, ovvero la prestazione di una somma di denaro pari al danno accertato è valido sia in ambito contrattuale sia in ambito aquiliano, ma qui è prevista anche una modalità diversa, ovvero quella del **risarcimento in forma specifica**, che obbliga il danneggiante a risarcire il danneggiato ricostruendo lo stato di cose a come erano prima del danno procurato (art 2058 c.c.).

Di fronte all'inadempimento assoluto o definitivo, la prestazione risarcitoria prendere il posto di quella originaria oggetto dell'obbligazione, mentre per l'inadempimento relativo, il risarcimento si aggiunge alla prestazione tardivamente effettuata o ancora da eseguire.

Secondo l'art 1223 c.c. è risarcibile solo il danno **costituente conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo**. Quindi tra il danno e l'inadempimento/ritardo deve sussistere un **rapporto di diretta e immediata causalità**.

Per determinare l'entità del risarcimento occorre guardare sia alla **perdita subita** dal creditore (**danno emergente**) sia al **mancato guadagno (lucro cessante)**.

La tendenza è quella di associare al **danno emergente** il valore della prestazione inseguita.

L'art 1223 c.c. fa leva sul **principio del risarcimento integrale**, ovvero che il responsabile debba risarcire tutti i danni che l'inadempimento ha cagionato. Quindi non solo il danno patrimoniale è oggetto di risarcimento, ma anche quello non patrimoniale, ove l'inadempimento cagioni lesione di diritti inviolabili della persona.

Inoltre l'art 1225 c.c. prevede il **criterio della prevedibilità**, secondo il quale il risarcimento per inadempimento o ritardo è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, ma quando l'inadempimento o il ritardo sono dipendenti da dolo del debitore anche il danno non prevedibile è oggetto di risarcimento.

Per quanto riguarda il **regime probatorio**, incombe sul creditore che pretende di essere risarcito l'onere di provare il danno subito.

Ove un danno risulti in modo certo essere stato provocato dall'inadempimento o ritardo, ma non sia possibile dar prova del suo preciso ammontare il giudice è autorizzato a provvedere con la **liquidazione equitativa**, il quale, di fronte alla prova cui il creditore è tenuto, quantifica monetariamente il pregiudizio da questo subito in base a un giudizio equitativo che tenga conto delle circostanze del caso concreto.

L'art 1227 c.c. afferma che se a cagionare il danno, oltre al comportamento del debitore, v'è il fatto colposo del creditore, entrambi sono in pratica responsabili, il che equivale a dire che il creditore è responsabile verso sé stesso.

In base a ciò, il danneggiante deve subire le conseguenze del danno, ma solo in relazione alla parte che risulti a lui imputabile.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, i quali sono conseguenza esclusiva dell'inadempimento del debitore e il creditore ha solo mancato di attivarsi per limitare gli effetti pregiudizievoli cagionati dall'illecito altrui.

Altro principio è quello della **compensazione del lucro col danno** (*compensatio lucri cum damno*), e si riferisce ai casi nei quali il compimento del danno produce anche conseguenze vantaggiose. In queste ipotesi la determinazione del risarcimento va fatto calcolando anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno, e detraendoli dall'ammontare del danno da risarcire.

Occorre far riferimento anche alle **clausole di esonero da responsabilità** (art 1229 c.c.), che sono clausole concordate dalle parti e predette a escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore. Sono valide solo se hanno riguardo alla mera colpa o colpa lieve, non si può quindi escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

LA CLAUSOLA PENALE

Come si vede dall'art 1382, alle parti di un contratto è concessa la possibilità di evitare, in caso di inadempimento, di dover ricorrere al giudice per ottenere tutela: si è convenuta infatti una **clausola penale**, che obblighi l'inadempiente ad una determinata prestazione. Quest'ultima ha valenza risarcitoria e l'intervento del giudice si renderà necessario solo quando essa risultasse ineseguita. Si associa all'idea di clausola penale quella di **pena privata**, per evidenziarne la fonte pattizia.

Con la pattuizione della clausola penale, verificatosi l'inadempimento, la prestazione stabilita deve essere eseguita indipendentemente dal fatto che la parte richiedente abbia effettivamente subito il danno, quindi il creditore è esentato dal fornire la prova del danno.

Qualora il danno subito sia superiore da quello pattuito nella clausola, allora la parte danneggiata può chiedere l'ulteriore risarcimento solo se questa possibilità era stata preventivamente pattuita dalle parti.

E' escluso il **cumolo** tra penale e risarcimento e tra penale e prestazione principale, almeno che la penale sia prevista per il solo ritardo nell'adempimento.

L'art 1384 prevede la c.d. **reductio ad aequitatem**, con la quale è riconosciuto al giudice un potere di intervento sull'ammontare della penale determinato dalle parti. La contestazione può avvenire o nel caso in cui l'adempimento non sia totale ma solo parziale o quando l'ammontare sia manifestamente eccessivo.

La valutazione che il giudice è chiamato a compiere dovrà avere come parametro non il valore della prestazione inadempita o l'ammontare del danno risarcibile, ma l'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

DANNI E RISARCIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DI VALUTA E DI VALORE

Alcune regole particolari valgono per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento di un'**obbligazione pecuniaria**.

A fronte del ritardo nel pagamento, l'art 1224, prevede che al creditore siano dovuti, dal giorno della costituzione in mora del debitore, gli interessi secondo il saggio legale: si tratta degli **interessi moratori** che si definiscono così in quanto per l'appunto collegato alla mora.

Diversi sono gli interessi ex art 1282 c.c., i quali hanno **natura accessoria** rispetto al credito e sono dovuti di pieno diritto, quindi a prescindere dall'inadempimento del debitore.

Gli interessi moratori spettano al creditore anche in assenza di una clausola che li prevedesse espressamente o della prova da parte del creditore di aver subito un danno, in quanto il mancato godimento di denaro costituisce di per sé una ragione di danno.

In presenza di una previa determinazione convenzionale per gli interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello legale, la medesima misura sarà applicata a quelli moratori.

Se gli interessi non soddisfano il danno provocato dall'inadempimento, anzi fanno modo che sussistano ulteriori danni (es. a causa di inflazione o svalutazione monetaria) il creditore può effettuare la **prova di aver subito un maggior danno** e quindi il diritto a ottenere l'ulteriore risarcimento, salvo il caso in cui le parti avessero convenuto già la misura degli interessi moratori.

In ordine al **maggior danno** il creditore deve fornire la prova, in mancanza della quale nessun risarcimento è dovuto.

Il maggior danno corrisponde alla differenza tra il **tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi** e quello **degli interessi legali**, salva possibilità per il debitore di provare che il creditore non abbia subito un maggior danno o lo abbia subito in minore misura rispetto a quella differenza, e per il creditore di ottenere a titolo di maggior danno una somma superiore.

Questo per quanto riguarda le obbligazioni di valuta.

Per quanto riguarda le **obbligazioni di valore**, come viene liquidato il danno da ritardo nell'adempimento?

- a) In *primis* è necessario tradurre in valore monetario l'importo accertato attraverso la rivalutazione della somma con riferimento alla data di liquidazione
- b) Una volta attualizzato l'importo dovuto dal debitore moroso e riparato il c.d. danno emergente, il creditore può altresì ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno rappresentato, qualora la liquidazione avvenga a distanza dal danno, dalla perdita possibilità di disporre della somma dovutagli.

IL RITARDO DEL PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Le **transazioni commerciali** sono dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro un corrispettivo consistente nel pagamento di un prezzo in denaro.

Il ritardo nei pagamenti è molto frequente e per contrastare questo fenomeno il legislatore (con il **dlgs 231/2002**) ha stabilito che il pagamento va di norma effettuato entro 30 giorni, ma rimane ferma per le parti la possibilità di pattuire termini superiori con l'osservanza di alcuni limiti.

Sino alla scadenza del termine, che sia legale o convenzionale, l'obbligazione pecuniaria non è esigibile, ma alla scadenza del termine di pagamento decorrono automaticamente gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Il creditore quindi acquista, oltre al diritto degli interessi moratori, anche il diritto al rimborso delle spese legali e il diritto al risarcimenti di ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

Il saggio degli interessi nelle transazioni commerciali è quello concordato dalle parti.

Il debitore cui sia richiesto di corrispondere gli interessi moratori ha l'unica strada di dimostrare che il ritardo nel pagamento è stato frutto dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sia la disciplina legale del termine di pagamento, sia quella diretta a regolare gli effetti del ritardo del pagamento possono essere derogate dalle parti, ma esse non sono libere di inserire nel contratto ogni tipo di clausola, i fatti sono nulle le clausole che risultano gravemente dannose per il creditore e in questo caso vengono sostituite dalla disciplina legale.

CAPITOLO XV

LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E LE GARANZIE

LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, LIMITI E CAUSE DI PRELAZIONE

L'ordinamento ha escogitato un sistema di tutele dirette e indirette del creditore il cui interesse sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inadempimento del debitore.

L'art 2740 c.c. è dedicato alla **responsabilità patrimoniale** e prevede che «*il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*». Appare chiaro come questa norma intervenga quando:

- Obbligazione pecuniaria rimasta inadempita
- Obbligazione di diverso contenuto inadempita che non sia suscettibile di adempimento coatto per il tramite di esecuzione in forma specifica o dell'esecuzione indiretta

Quindi il riferimento della norma ai beni, quindi al patrimonio, del debitore comporta l'esigenza di soddisfare l'interesse creditorio in denaro e ciò è possibile con un'**esecuzione che prelevi forzosamente la somma dovuta** oppure con la **liquidazione giudiziale del relativo patrimonio**.

Tutto ciò può avvenire a seguito di un ricorso del creditore all'autorità giudiziaria che gli consenta di munirsi di **titolo esecutivo**, cioè un provvedimento che accerti via giudiziale il proprio diritto e che gli consenta di attivare la tutela esecutiva tramite **pignoramento**=imposizione al debitore di non sottrarre i beni individuati per la successiva vendita all'asta.

Vi sono due tipi di esecuzione forzata:

- **Esecuzione in forma specifica**: mira a far conseguire al creditore esattamente quanto dovutogli; questo non è possibile per es. nelle prestazioni di fare infungibile o se l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro
- **Espropriazione (o esecuzione per equivalente)**: Il creditore può fare espropriare i beni del debitore, convertendo in tal modo in denaro il patrimonio e soddisfacendosi su di esso

Ciò che il codice individua come responsabilità patrimoniale è in realtà una **garanzia patrimoniale generica** che consente al creditore di tutelare il suo diritto di credito anche in caso di inadempimento del debitore.

Se il debitore si rileva inadempiente, non solo nei confronti di un singolo creditore, ma nei confronti di una platea di creditori, essi si distinguono in due categorie

- **Creditori privilegiati**: soggetti che vantano un credito assistito da una **causa legittima di prelazione**, ossia una giustificazione che consenta loro di soddisfarsi con priorità, individuate nei privilegi, pegno e ipoteche.
- **Creditori chirografari**: creditori che non sono assistiti da cause di prelazione

Tranne nel caso in cui sussistono cause di prelazione, i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore comune, in forza del principio della **par condicio creditorum**, quindi la soddisfazione dei creditori sarà proporzionale al credito vantato (art 2741 c.c.).

Il principio dell'art 2740 c.c. per cui tutti i beni del debitore costituiscono garanzia patrimoniale generica per il creditore ha alcuni limiti:

- Il primo limite lo si trova nella **natura** del bene soggetto a pignoramento e successiva liquidazione, infatti sono esclusi:
 - Beni necessari per garantire la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia
 - Beni di particolare affezione (fedele nuziale)
 - Beni necessari per l'adempimento di un pubblico servizio (armi per i militari)
 - Alcuni crediti considerati impignorabili, come quelli alimentari

In alcuni casi la pignorabilità è limitata, per via:

- Della **natura** del bene (stipendi e salari pignorabili nella misura massima di 1/5)
- Della sua **utilizzazione** (res necessaria per l'esercizio della professione)

- Del **rapporto che intercorre col fondo coltivato**
- Un secondo limite è dato dalla **segregazione patrimoniale** consentita dalla legge per esempio per i **patrimoni destinati ad uno specifico affare** da parte delle società per azioni.
2 modelli di segregazione:
 - **Modello operativo:** in cui lo svolgimento di un affare determina una separazione nel patrimonio della società, così da limitare solo al patrimonio separato le responsabilità in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte per lo specifico affare
 - **Modello finanziario:** si tiene separato un finanziamento estero della società dal suo patrimonio

L'istituto più importante di segregazione patrimoniale è costituito dal **trust**, che si tratta di un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato **trustee**, al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato **settlor** o disponente, per uno **scopo prestabilito** o un fine, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari.

La convenzione internazionale dell'Aja consente di riconoscere nell'ordinamento italiano i **trust** costituiti in paesi diversi dall'Italia, mentre una prima apertura del **trust** interno si è avuta con l'introduzione dell'art 2645-ter c.c., che prevede come unica condizione di operabilità del **trust** interno l'onere di pubblicità dichiarativa con la trascrizione dei pubblici registri per gli atti di destinazione rivolti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

La legge "dopo di noi" ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano il **trust** quale **situazione affidante** per la gestione del patrimonio destinato a favore di soggetti disabili privi di assistenza

- Un terzo limite è dato dall'istituto dell'**esdebitazione**, il quale costituisce lo strumento con il quale il Tribunale dichiara inesigibili i crediti insoddisfatti con la procedura concorsuale, quindi i beni futuri dell'imprenditore sono al riparto da eventuali azioni esecutive dei creditori insoddisfatti (perché abbiamo visto come nelle procedure concorsuali non sempre la *ratio* principale è quella della *par condicio*, ma anche il proseguimento/riavvio dell'azienda senza il peso insostenibile dei debiti regressi come ad es. le procedure di **concordato preventivo** e **amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**).
- In questo caso il debitore non assoggettato a può proporre ai creditori, con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi.
- Il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbe pregiudicare il piano di ristrutturazione, e una volta verifica l'ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano con sentenza si dichiara chiusa la procedura.

I LIMITI CONVENZIONALI AL POTERE DEL CREDITORE DI AGGREDIRE I BENI DEL DEBITORE

Il potere d'impulso dell'avente diritto in ordine alla instaurazione del processo di esecuzione appartiene al novero dei diritti disponibili, quindi, obbedisce soltanto all'interesse individuale dell'avente diritto e quindi egli può rinunciare all'azione esecutiva.

- **Pactum de non petendo:** (di tradizione romanistica) il creditore si impegna a non chiedere la prestazione cui ha diritto e a non procedere né in via di cognizione né in via d'esecuzione.
- **Pactum de non exsequendo:** (più recente) impegno del creditore che vanti un titolo esecutivo a non agire per il soddisfacimento del proprio diritto tramite esecuzione forzata.

Le due tipologie possono dare luogo a una tutela reale tramite l'*exceptio pacti* che va a paralizzare le pretese che la parte avversaria ha contro l'altra nonostante pattuizioni.

L'impegno dell'avente diritto a non richiedere l'adempimento o non esercitare l'azione esecutiva può essere:

- *Tempus*: il patto contiene una merla dilazione
- *Perpetuum*: l'obbligazione sottoposta ad un vincolo perpetuo di incoercibilità finisce col rimettere alla volontà dell'obbligato la decisione circa come e quando adempiere.

La prassi riconosce inoltre i c.d. **accordi di postergazione** in cui il creditore postergato rinuncia all'ordine dettato dalla *par condicio creditorum* e si impegna a non riscuotere il proprio credito prima del soddisfacimento integrale di altro creditore, collocandosi al di sotto di esso.

La postergazione può essere:

- Legale: trova disciplina nell'art 2467 c.c. in tema di finanziamenti del socio
- Convenzionale: ha tratto origine dall'art 2843 c.c., il quale menziona la postergazione di grado dell'ipoteca e l'opponibilità nei confronti degli altri creditori di tale postergazione dipende dall'annotazione a margine dell'iscrizione.

Il problema della loro liceità si è posto per gli accordi di postergazioni c.d. atipici, in quanto pivi di qualsiasi aggancio normativo e questo problema si aggancia all'art 2741 c.c. che stabilisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

La giurisprudenza ha affermato che gli accordi in esame non pregiudicano gli altri creditori estranei al patto e si limitano ad assicurare al creditore postergatario i benefici del titolo di preferenza riconosciutogli dal creditore postergato.

Una funzione diversa ha il **patto sull'ordine dei beni da sottoporre in esecuzione**, con cui si fissa un ordine convenzionale dei beni del debitore aggredibili con l'esecuzione forzata. Gli altri creditori possono comunque rivalersi sui beni cronologicamente più in basso ma anche su quelli cronologicamente preposti.

L'ordinamento riconosce, infine, due schemi negoziali che consentono alla privata autonomia di regolare in modo convenzionale il diritto di agire in via d'esecuzione:

- **La cessione dei beni ai creditori (art 1977 c.c.):** contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti, al fine di evitare la procedura esecutiva. Ai creditori che hanno aderito alla cessione non è ceduta alcuna proprietà, ma è solo attribuito il potere di vendere i beni del debitore insolvente, che non può più disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.), ma ha diritto di esercitare il controllo sull'operato dei creditori e di ottenere l'eventuale residuo della liquidazione. Il debitore è liberato verso i creditori solo nei limiti di quanto abbiano effettivamente ricevuto e solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione.
- **Anticresi (art 1960 c.c.):** Con questo contratto il debitore o un terzo si obbliga a consegnare al creditore un immobile a garanzia della realizzazione del suo credito: il fine che si persegue è quello per il quale il creditore percepisca i frutti del bene concesso (per un massimo di dieci anni, che è il termine legale del contratto in difetto di diversa pattuizione) imputandoli dapprima agli interessi, qualora dovuti, e infine al capitale. Il contratto in discorso non attribuisce al creditore nessun diritto di prelazione ma gli riconosce una modalità preferenziale di soddisfacimento rispetto agli altri creditori.

IL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

L'art 2744 c.c. sancisce la nullità del **patto commissorio**, ossia il patto con cui debitore e creditore convengono che, in caso di inadempimento dell'obbligazione entro il termine pattuito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca.

La *ratio* di questo divieto è evidente:

- Il codice intende affidare al mercato tramite le vendite giudiziarie, e non al creditore sulla base di un accordo, la funzione liquidatoria del patrimonio del debitore e il conseguimento del prezzo realizzato: con alcune eccezioni espressamente previste ma attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria, come il pegno e l'ipoteca
- Può essere posto a presidio della *par condicio creditorum*, visto che il patto commissorio finirebbe con il sottrarre interamente il bene costituito in garanzia all'azione esecutiva degli altri creditori
- Tutela del debitore in presenza di una sproporzione tra l'ammontare del credito garantito e il valore del bene dato in garanzia

Secondo la giurisprudenza il divieto ex art 2744 c.c. si estende a qualsiasi pattuizione/contratto che venga impiegata per conseguire il trasferimento della proprietà di un bene a favore del creditore come conseguenza della mancata estinzione del debito, risultato vietato dall'ordinamento:

- o Le ipotesi in cui il patto prevede non il trasferimento del diritto di proprietà, ma di un diritto reale minore
- o Patti che conferiscono al creditore il diritto di fare proprio in caso di inadempimento del debitore un bene non di quest'ultimo ma di un terzo, come il coniuge
- o Le c.d. **pattuizioni commissorie autonome**, ossia dirette a attribuire al creditore la proprietà di beni non previamente costituiti in garanzia

Il divieto di patto commissorio non comprende anche gli accordi in forza dei quali all'obbligato viene consentito di estinguere il proprio debito attraverso la dazione di un determinato bene (es. *datio in solutum*).

Si ritiene invece valido il **patto marciano**, ovvero in forza del quale, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, il bene viene sì trasferito in proprietà del creditore insoddisfatto, ma ad un valore stimato da un terzo al momento di detto trasferimento, con la conseguenza che il creditore è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra il valore del bene e l'ammontare del credito inadempito.

I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA

Il patrimonio del debitore, con tutti i suoi beni presenti e futuri, costituisce la **garanzia patrimoniale generica** per il creditore.

Rappresenta comunque un grave rischio per il creditore il fatto che prima che i beni del debitore siano sottoposti a pignoramento egli ne abbia il pieno godimento e disposizione, e quindi potrebbe causare una diminuzione o esaurimento del patrimonio che si tradurrebbe in una diminuzione della garanzia generica di cui dispone il creditore.

Allo scopo di scongiurare questo pericolo, l'ordinamento appresta alcuni **mezzi di conservazione** della garanzia patrimoniale, e sono mezzi di:

- **Tutela preventiva:** questi mezzi sono attivabili nella prima fase del rapporto obbligatorio, nel momento in cui il creditore non sa se il debitore sarà inadempiente.

- **Tutela cautelare:** esigenza di salvaguardare l'integrità del patrimonio del debitore in vista del futuro e dell'eventuale esercizio dell'esecuzione in forma specifica e dell'espropriazione. Il vincolo patrimoniale opera solo dopo l'inadempimento dell'obbligo primario e l'inesecuzione della condanna ad adempiere.
- **Tutela generale-residuale:** tali mezzi saranno di fatto utilizzati solo da quei creditori che non hanno a disposizione una garanzia specifica, anche se possono usarli tutti i creditori

Questi mezzi di conservazione/atti conservativi della garanzia patrimoniale sono: **azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo.**

L'AZIONE SURROGATORIA (art 2900 c.c.)

È un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e ha alcuni requisiti:

- *Periculum damni*: ovvero pericolo attuale di un danno futuro derivante dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della propria garanzia generica
- **Inerzia** del debitore nel tutelare propri diritti nei confronti di terzi, che non si tratti di uno stato di inerzia giustificato da un impedimento legale. Essa deve essere effettiva e può essere anche parziale

Al fine di evitare un pregiudizio, la legge attribuisce al creditore (**surrogante**) la legittimazione a sostituirsi al debitore (**surrogato**) nell'esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano e che omette di esercitare.

Il creditore è legittimato a esercitare i diritti e i poteri che competono al debitore nei confronti di terzi, ma non a disporne o comunque a farne oggetto di scelte riservate all'autonomia del titolare. Non si tratta di una forma di rappresentanza quindi, in quanto il creditore agisce nel proprio interesse ed a proprio rischio e pericolo, anche se pur sempre nel nome del debitore.

Essa trova il proprio fondamento in un **diritto potestativo** del creditore che nasce dalla lesione del suo interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale.

L'azione surrogatoria va anche a garantire il rispetto della *par condicio creditorum*, avendo come effetto quelle di reintegrare il patrimonio del debitore a vantaggio di tutti i creditori.

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione, oltre al *periculum damni* e all'inerzia, è necessario dimostrare l'esistenza del credito vantato e quindi la qualità di creditore del soggetto che agisce.

Non tutti i diritti che il debitore omette di far valere sono suscettibili di surrogazione, infatti ai sensi dell'art 2900 c.c., deve trattarsi di diritti e di azioni che spettano al debitore verso terzi, che abbiano contenuto patrimoniale e che non siano, per loro natura o per legge, esercitabili esclusivamente dal loro titolare. Quindi sono esclusi i diritti reali, in quanto non aspettano al debitore verso terzi, i diritti e le azioni che si riferiscono a rapporti familiari e i diritti della personalità.

L'azione surrogatoria può esercitarsi sia in **via giudiziale** sia in via **stragiudiziale**.

Quando il creditore si surroga al debitore nell'esercizio di un'azione giudiziaria contro un terzo, deve partecipare anche il debitore, classica ipotesi di **litisconsorzio necessario**, in quanto il creditore dovrà citare in giudizio anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Nel caso in cui il creditore agisca in via stragiudiziale, non deve promuovere alcun accertamento preventivo dei presupposti che legittimano l'azione surrogatoria.

Il creditore però in ogni caso deve informare preventivamente il debitore dell'intervento sostitutivo.

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

L'**azione revocatoria ordinaria**, presuppone, a differenza dell'azione surrogatoria, non l'inerzia del debitore, ma la sua attività; infatti, l'**art 2901 c.c.** stabilisce che se il debitore compie, essendo in ritardo nell'adempire, **atti di disposizione** del suo patrimonio tali da pregiudicare le ragioni del creditore, il creditore medesimo può chiedere al giudice di dichiarare l'**inefficacia** di tali atti nei propri confronti.

Quindi ha una funzione cautelare, ovvero permette al creditore di mantenere inalterato il patrimonio del debitore in vista dell'eventuale azione esecutiva.

Requisiti:

• **OGGETTIVI**

- È necessaria l'effettiva esistenza del credito, che può essere non ancora esigibile o anche illiquido
- Deve ricorrere un danno (***eventus damni***), ossia un pregiudizio per il creditore che può consistere in una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore o un'alterazione qualitativa della sua composizione.
- È necessario un **atto di disposizione** del patrimonio del debitore, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o costituendo su propri beni diritti a favore di terzi.

È esclusa la possibilità di assoggettare a revoca l'**adempimento di un debito scaduto**, in quanto questo debito già incideva sul patrimonio del debitore.

• **SOGGETTIVI**

- La c.d. ***scientia fraudis***, ovvero il fatto che il debitore deve avere consapevolezza del pregiudizio che l'atto causa alle ragioni del creditore.
La consapevolezza si **presume** ogni volta in cui sia oggettivamente riscontrabile il ***periculum damni***.
La regola in questione vale nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, se invece l'atto è stato compiuto prima della nascita del credito, non occorre solo la ***scientia fraudis***, ma anche il c.d. **dolo specifico**, ovvero la dolosa preordinazione da parte del debitore (futuro) al fine di ostacolare o impedire la soddisfazione della pretesa del creditore (futuro).
- Per quanto riguarda la condizione soggettiva del **terzo contraente**, bisogna distinguere se l'atto è:
 - Atto a titolo gratuito: ciò che conta è solo la conoscenza del debitore circa il pregiudizio arrecato.
 - Atto a titolo oneroso: è necessario dimostrare anche la mala fede del terzo acquirente, ossia che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.
Se l'atto è successivo al sorgere del credito, allora è richiesta la sola consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, se invece l'atto è anteriore, è richiesta l'esistenza della partecipazione del terzo al progetto dolosamente elaborato dal debitore per recare un danno al creditore.

Per quanto riguarda gli effetti dell'azione revocatoria, va a determinare l'**inefficacia relativa** dell'atto di disposizione. Cioè non ricostituisce il patrimonio del debitore, ma l'atto diviene

inopponibile al revocante (creditore), conservando comunque la sua efficacia verso le parti e altri creditori che non abbiano agito in revocatoria.

Una volta ottenuta la revocatoria, essa consente al debitore di promuovere nei confronti del terzo acquirente, le stesse azioni conservative o esecutive sui beni oggetto della revocatoria che avrebbe potuto promuovere se l'atto di disposizione revocato non fosse mai stato posto in essere, quindi come se il bene stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Il terzo acquirente non può impedire l'espropriazione forzata del suo bene, ma ha diritto al risarcimento del danno da parte del debitore.

In materia di azione revocatoria, di regola, l'inefficacia dell'atto stipulato tra debitore ed acquirente al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori estende automaticamente i suoi effetti solo al **terzo sub-acquirente** che abbia acquistato a titolo gratuito. Diversamente, nel caso in cui venga provata in giudizio la buona fede dei terzi e l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso, l'atto posto in essere in frode ai creditori non pregiudicherà, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in alcun modo i diritti acquisiti dal sub-acquirente (**art 2901 c. 4 c.c.**).

L'azione revocatoria si prescrive in **5 anni** che decorrono dalla data dell'atto di disposizione.

La revocatoria semplificata ex art 2929-bis c.c.:

Consente al creditore, che sia pregiudicato da un atto a titolo gratuito di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione (quindi un bene che prima faceva parte del patrimonio del debitore ma che questo ha disposto a favore di terzi), avente ad oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato posto in essere dal debitore in un momento posteriore al sorgere del suo debito, di procedere, se munito di idoneo **titolo esecutivo**, all'espropriazione forzata su detto bene, senza dover passare prima per l'azione revocatoria.

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE

Una variante dell'azione revocatoria ordinaria è l'**azione revocatoria fallimentare**, disciplinata in caso di fallimento dell'imprenditore per gli atti compiuti durante lo stato di insolvenza e potenzialmente pregiudizievoli nei confronti dei creditori.

Ci sono alcuni atti che vengono considerati automaticamente inefficaci dalla legge (**atti a titolo gratuito**), mentre altri (**atti a titolo oneroso**) la quale inefficacia è subordinata ad una sentenza di revoca e si suddividono in:

- **Atti anormali:** per essere revocati, devono essere compiuti entro un certo termine anteriore alla dichiarazione di fallimento e devono appartenere a determinate categorie previste dalla legge: questi requisiti fanno presumere che il terzo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza e se quindi quest'ultimo vuole impedire la revocatoria deve dimostrare la sua ignoranza.
- **Atti normali:** possono essere revocati se il curatore dimostra che il terzo conosceva lo stato di insolvenza e che sono stati compiuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Per gli atti che non rientrano nelle categorie previsti è ammesso l'esercizio dell'azione revocatoria.

Le azioni revocatorie devono essere esercitate dal curatore entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso non oltre i 5 anni dal compimento dell'atto.

Effetti: in seguito alla revocazione, colui che ha restituito quanto aveva ricevuto dal fallito è ammesso al fallimento per il suo eventuale credito.

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il **sequestro conservativo** non è ben definito dal nostro codice civile, il quale rinvia al c.p.c., che autorizza il giudice, su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale generica da cui è assistito il proprio credito, a disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o della somme o cose a lui dovuti.

L'azione ha come scopo quello di consentire la temporanea sottrazione alla libera disponibilità, sia materiale sia giuridica, da parte del debitore dei suoi beni, impedendo che sfuggano alla futura azione esecutiva.

Il sequestro si può convertire in pignoramento in caso di condanna del debitore all'inadempimento. In questo modo, col sequestro conservativo, non hanno effetto, solo nei confronti del creditore sequestrante, gli atti dispositivi di cui il debitore dovesse fare eventualmente oggetto il bene sequestrato.

Va distinto dal **sequestro giudiziario**, al quale si fa ricordo quando sorge una controversia sulla proprietà/possesso di beni in attesa della definizione della lite.

LE GARANZIE PERSONALI

Così denominate perché ciò che garantisce l'adempimento del debitore non è uno specifico bene, come avviene nel pegno o nell'ipoteca, ma il patrimonio personale del terzo garante, e sono:

- **Contratti di garanzia: la fideiussione, il mandato di credito, il contratto autonomo di garanzia e l'anticresi**
- **L'avvallo**, che non è un contratto ma un'**obbligazione cambiaria di garanzia**
- **Lettere di *patronage***

LA FIDEIUSSIONE

Il creditore, al fine di evitare il rischio che il debitore non adempia all'obbligazione, può premunirsi stipulando un contratto con un terzo, detto **fideiussore**, il quale garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento dell'obbligazione del debitore.

Quindi il fideiussore garantisce al creditore l'adempimento del debitore, non con uno specifico bene, ma con tutto il suo patrimonio.

Il codice prevede che il contratto di fideiussione sia concluso in **modo espresso**, non tacito, anche se non è imposta nessuna forma determinata.

È un contratto **gratuito** e rientra nella categoria del **contratto con obbligazioni del solo proponente**, in quanto genera obbligazioni a carico di una sola delle parti.

Le parti del contratto sono il creditore e il fideiussore. Al contratto resta estraneo il debitore, denominato **debitore principale** per distinguerlo dal fideiussore e anche l'obbligazione del debitore viene chiamata **obbligazione principale**, contraddistinta dall'**obbligazione accessoria** (quella tra creditore e fideiussore). La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.

Il fideiussore è **obbligato in solido** col debitore principale al pagamento del debito e quindi si può pretendere dall'uno e dall'altro pagamento, ma le parti possono convenire il c.d. **beneficio d'escussione**, con il quale il fideiussore non è tenuto a pagare prima dell'escussione (azione legale intentata contro un debitore) del debitore principale.

L'istituto della **cofideiussione** si ha quando più persone hanno prestato fideiussione in garanzia del medesimo debito, quindi ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia pattuito il **beneficio della divisione**, con conseguente ripartizione del debito tra i fideiussori.

Essendo la fideiussione un'*obbligazione accessoria*, non può mai eccedere quanto è dovuto dal debitore principale.

Dopo la scadenza dell'obbligazione principale il fideiussore rimane obbligato nei confronti del creditore il quale ha l'onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione contro il debitore, pena l'estinzione della fideiussione.

Inoltre il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Il fideiussore che ha pagato al creditore principale è **surrogato** nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, dal momento che l'adempimento dell'obbligazione sarebbe spettata a quest'ultimo.

Il fideiussore ha **azione di regresso** nei confronti del debitore, ovvero il fideiussore subentra nella medesima posizione che il creditore aveva nei confronti del debitore, e può ottenere il rimborso di ogni somma pagata al creditore principale.

Qualora, prima del pagamento, la possibilità di mettere in atto l'azione di regresso appaia compromessa per il fideiussore (es. debitore divenuto insolvente), egli ha il **diritto al rilievo**, ovvero ottenere dal debitore la liberazione della garanzia.

LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Si parla di fideiussione *omnibus* per indicare l'impegno assunto da un soggetto vero una banca, con cui si garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli futuri, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento in cui la banca deciderà di domandare il saldo dei propri crediti.

Quindi l'aspetto caratteristico è che il fideiussore garantisce anche i debiti che non sono né individuati né ancora sorti al momento in cui sorge la fideiussione.

L'oggetto della garanzia, sebbene non perfettamente determinato è pur sempre determinabile *per relationem* secondo la giurisprudenza, quindi attraverso un rinvio ad elementi esterni che integrano il contenuto della garanzia.

La stessa giurisprudenza ritiene inoltre inefficace la fideiussione *omnibus* nel caso in cui la banca, essendo consapevole dell'insolvenza/dell'insufficiente patrimonio del debitore, continui a erogare credito al debitore, facendo affidamento non più sulla capacità patrimoniale del debitore ma piuttosto su quella del fideiussore.

IL MANDATO DI CREDITO

La funzione del mandato di credito è molto simile a quella della fideiussione ed è il contratto con il quale una persona (A) si obbliga verso un'altra persona (B) a far credito a un terzo (C): la persona (B) che ha richiesto all'altra (A) di far credito risponde come fideiussore di un debito futuro (quello che sarà assunto da C).

IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

È uno strumento di garanzia elaborato dalla prassi nell'ambito del commercio internazionale, per dare sicurezza alla parte che si trova titolare di crediti pecuniari.

Il **garante** (solitamente un soggetto altamente solvibile, come una banca/assicurazione), incaricato dal debitore, assume nei riguardi del creditore l'impegno ad effettuare una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.

Il pagamento da parte del primo deve avvenire "a prima richiesta" del garantito e presuppone la rinuncia del garante a far valere qualunque eccezione inerente al rapporto garantito.

In particolare, l'istituto in esame implica l'esistenza di, almeno, tre rapporti: il debitore, invero, incarica con un mandato il garante di stipulare un contratto di garanzia con il creditore e di assumere l'obbligo di pagare "a prima richiesta" una somma di denaro a vantaggio di quest'ultimo, con lo scopo di garantire l'adempimento da parte del debitore del principale contratto intercorrente tra i due.

L'elemento caratterizzante di questo accordo è l'**autonomia** dell'obbligazione assunta dal garante, a differenza dell'accessorietà della fideiussione.

Naturalmente, una volta che il garante versa l'importo al beneficiario, si rivale nei confronti del suo mandante.

Nel caso in cui il beneficiario abusi della garanzia, si può applicare l'istituto dell'**exceptio doli generalis**, ovvero ottenere una sospensione del pagamento dimostrando che il beneficiario della garanzia sta abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta.

LE LETTERE DI PATRONAGE

Non sono disciplinate dal legislatore e nella pratica sono utilizzate nei rapporti tra **gruppi societari** e istituti bancari e consistono in dichiarazioni unilaterali, il più delle volte richieste dalla banca, nelle quali, la società capogruppo rilascia specifiche informazioni sulla società partecipata, il più delle volte collegate con l'esposizione debitoria affermando ad es. che ne manterrà il controllo sino all'estinzione dei debiti verso la banca.

Difficilmente ciò possa scaturire in una responsabilità contrattuale di chi ha rilasciato la dichiarazione, ma piuttosto una responsabilità extracontrattuale quando magari il comportamento del dichiaratore è non conforme a quello enunciato nel patronage.

L'ANTICRESI

È un contratto che era diffuso nell'Italia Meridionale e in forza di tale contratto il debitore o un terzo si obbligava a consegnare un immobile o un fondo produttivo al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisce i frutti, imputandogli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

È ammesso che i frutti siano imputati ai soli interessi, in questo caso si parla di **anticresi compensativa**.

In tal modo la garanzia fornita al creditore, che è un detentore, consente di realizzare la graduale estinzione del debito.

L'anticresi si estingue con il venire meno del credito garantito e non può avere durata superiore di dieci anni.

LE GARANZIE REALI

L'IPOTECA

L'ipoteca è un **diritto reale di garanzia** su un bene immobile. Essa attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene su cui grava e di essere soddisfatto con preferenza sulla somma ricavata dall'espropriazione (**art 2808 c.c.**).

In quanto diritto reale è caratterizzato dal **diritto di seguito**, ovvero il creditore può espropriare il bene anche nei confronti del terzo che lo abbia acquistato dopo la costituzione della garanzia.

L'oggetto dell'ipoteca può ricomprendere anche i beni mobili registrati.

Per costituire l'ipoteca sono necessari:

- **Iscrizione nei pubblici registri**, che gli permette di essere opponibile a terzi ed è una forma di pubblicità costitutiva
- **Titolo**, che può essere presentato da un contratto o un atto unilaterale del proprietario del bene (**ipoteca volontaria**)

La concessione dell'ipoteca necessita di un atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In alcuni casi è la stessa legge ad attribuire a determinati creditori il diritto ad iscrivere ipoteca (**ipoteca legale**), per esempio per l'alienante di beni immobili, sopra l'immobile alienato, a garanzia del pagamento del prezzo.

Inoltre, ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (**ipoteca giudiziale**).

L'iscrizione dell'ipoteca si ottiene attraverso il titolo costitutivo insieme a una **nota** contenente alcune informazioni, per esempio se vi sono più ipoteche a ciascuna di esse viene assegnato un grado, per determinare la precedenza tra i diversi creditori ipotecari.

Caratteri:

- **Specialità**: occorre far conoscere ai terzi precisamente quali sono i beni vincolati e per quale importo, non sono ammesse ipoteche generali.
Inoltre, l'ipoteca iscritta su un immobile, si estende a tutte le accessioni dell'immobile (principio di accessione)
- **Indivisibilità**: l'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati. È previsto però il procedimento di **riduzione dell'ipoteca** che si opera per es. restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.
- **Accessorietà**: l'ipoteca esiste solo in funzione della garanzia del credito in relazione alla quale essa è costituita, da ciò ne consegue che l'estinzione/inesistenza del credito comporta l'estinzione/nullità dell'ipoteca.

Nel caso di mancato adempimento da parte del debitore il creditore ipotecario potrà promuovere l'esecuzione forzata sul bene ipotecato. Il bene verrà poi pignorato e venduto all'asta: sul prezzo ricavato dalla vendita il creditore ipotecario potrà soddisfarsi con precedenza rispetto agli altri creditori.

Essendo caratterizzata dal diritto di seguito, in caso di inadempimento del debitore anche il terzo acquirente è soggetto all'azione esecutiva del creditore e per sottrarsene può:

- Pagare i creditori
- Lasciare il bene

- Procedimento della **purgazione dell'ipoteca**, con il quale il terzo libera il bene dall'ipoteca pagando ai creditori non il credito garantito, ma il valore dell'immobile ipotecato.

L'**estinzione** dell'ipoteca si ha per: a) estinzione obbligazione garantita, b) perimento bene ipotecato, c) cancellazione dell'iscrizione o suo mancato rinnovo dopo venti anni

IL PEGNO

Il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene mobile, un'universalità di beni e su diritti aventi per oggetto beni mobili. Tale garanzia attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (quindi realizzare il proprio credito con preferenza rispetto agli altri creditori).

È caratterizzato dal **diritto di seguito**: il creditore può espropriare il bene anche nei confronti del terzo che lo abbia acquistato dopo la costituzione della garanzia.

Il pegno si costituisce normalmente con la **consegna** al creditore della cosa o del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità.

Ciò serve a tutelare effettivamente il creditore e svolge anche il ruolo di rendere pubblicamente conoscibile la situazione della cosa: infatti il possesso per i beni mobili svolge un ruolo simile a quello della pubblicità per i beni immobili, ne segue quindi che la prelazione non ha luogo se la cosa non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti e, inoltre, non ha luogo neanche se il pegno non risulta da scrittura con data certa.

Se la cosa è consegnata al creditore, questi è tenuto a custodirla e risponde per la sua perdita o deterioramento, può difenderla con le azioni possessorie e ha diritto al rimborso delle spese eventualmente occorse per la conservazione della cosa.

Colui che ha costituito il pegno può esigere la restituzione della cosa una volta che abbia pagato interamente il capitale, gli interessi e rimborsato le eventuali spese relative al debito e al pegno.

In caso di inadempimento, il creditore può vendere la cosa, soddisfacendosi sul ricavato e restituendo l'eventuale residuo al debitore.

La legge prevede anche il pegno dei crediti, il c.d. **pegno di crediti**, per cui la prelazione ha luogo se:

- Il pegno risulta da atto scritto
- La costituzione del pegno è stata notificata al debitore del credito dato in pegno o tale debitore l'ha accettata con atto avente data certa.

Il **creditore pignoratizio**, alla scadenza del credito ricevuto in pegno è tenuto a riscuoterlo:

- Se il credito non è ancora scaduto, custodirà quanto ricevuto
- Se il credito è scaduto, riterrà dal denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituirà il residuo al concedente

In molti casi è opportuna la permanenza del bene presso il debitore ai fini della sua conservazione (es. prosciutti)

In altri casi può apparire vantaggioso riservare al debitore la possibilità di sostituire nel tempo il bene oggetto della garanzia: **pegno rotativo**.

Il legislatore ha introdotto anche la figura del **pegno mobiliare non possessorio**, che può essere concesso solo da imprenditori iscritti nel registro delle imprese e solo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Questo pegno ha effetto verso terzi a seguito dell'iscrizione nel "registro

dei pegni non possessori”. Se non è diversamente disposto nel contratto, il debitore può trasformare o alienare il bene gravato da pegno e in tal caso il pegno si trasferisce sul prodotto trasformato.

Vi è anche il **pegno irregolare**, che si ha quando, a garanzia del soddisfacimento di un credito, vengono consegnate al creditore cose fungibili (somma di denaro, titoli di credito) e quest’ultimo ne acquista la disponibilità. In caso di adempimento il creditore non deve restituire proprio quelle cose che gli erano state date, ma il *tantundem eiusdem generis et qualitatis*, ovvero la medesima quantità.

In caso di inadempimento il creditore insoddisfatto deve invece consegnare al debitore l’eventuale eccedenza tra il valore che le cose consegnategli hanno al momento della scadenza del credito e l’importo dovuto. Il valore delle cose che non eccede compensa il debito dell’inadempiente.

Si parla in questo caso di **cauzione**.

I PRIVILEGI

Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge ad alcuni crediti, ritenuti meritevoli di una particolare tutela sulla base della **causa del credito**, e perciò sottratti al principio fondamentale della parità di trattamento.

Il privilegio può essere:

- **Generale:** si esercita su tutti i beni mobili del debitore. Essi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti a terzi sui beni mobili che ne formano oggetto e non attribuiscono un diritto di seguito, quindi non consentono di perseguire il bene che il debitore abbia alienato a terzi. Può essere esercitato solo fin quando i beni mobili fanno parte del patrimonio del debitore.
- **Speciale:** si esercita solo su determinati beni mobili o immobili del debitore, e sono dovuti dal particolare legame tra il credito e l’oggetto/bene del privilegio. Possono essere esercitati in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo il loro sorgere e quindi hanno una sorta di diritto di seguito.

La causa dei crediti determina l’**ordine dei privilegi**, cioè la posizione dei diversi creditori privilegiati nel concorso con altri crediti verso il medesimo debitore.

I **crediti per spese di giustizia** (es. quelle per atti di espropriazione) sono preferiti a ogni altro credito in quanto si tratta di spese fatte nell’interesse di tutti i creditori, e dunque opponibili a tutti.

Dopo le spese di giustizia ci sono i **crediti riguardanti le retribuzioni**.

Seguono poi i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti poi i crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane, etc...

Il conflitto tra privilegio speciale e creditore pignoratizio si risolve con la prevalenza del secondo, mentre, al contrario, tra privilegio speciale e creditore ipotecario, prevale il primo (art 2748 c.c.).

Sul privilegio, in quanto accessorio del credito garantito, incidono le vicende modificative ed estintive del credito cui si riferisce, quindi l’estinzione del credito comporta l’estinzione del privilegio.

CAPITOLO XVI

GLI ALTRI ATTI O FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONI

LE PROMESSE UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO

Le fonti delle obbligazioni annoverano, oltre al contratto e i fatti illeciti, gli **atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico**.

Tra questi atti sono da ricomprendere gli **atti unilaterali** i quali sono idonei a far sorgere effetti di contenuto obbligatorio a carico del soggetto che li pone in essere.

Nella disciplina del codice civile tali atti consistono in **promesse unilaterali** e che sono caratterizzate da un **principio di stretta tipicità** (art 1987 c.c.), cioè producono effetti obbligatori per il promittente solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quindi l'autonomia privata non può creare promesse unilaterali atipiche (come avviene per es. per i contratti).

Sono promessi unilaterali:

- **Dichiarazioni unilaterali astratte: promessa di pagamento e ricognizione di debito**, cioè senza riferimento al rapporto sottostante
- **Dichiarazioni unilaterali titolate**: con riferimento ad un rapporto sottostante

L'emissione di una promessa unilaterale di pagamento o ricognizione di debito danno luogo ad un effetto non sul piano sostanziale, ma sul piano processuale, infatti determinano l'**inversione dell'onere della prova**, in quanto spetterà al promittente provare l'inesistenza del debito oggetto della promessa, non colui a favore del quale è fatta la promessa.

I **titoli di credito** integrano una promessa di pagamento, ed è un **documento cartolare autonomo** che incorpora un diritto di credito, un'obbligazione. Deriva da un rapporto fondamentale, ma è indipendente da esso. (cambiale, assegno)

Chi del titolo ne ha conseguito il possesso acquista il credito incorporato nel titolo restando legittimato a ricevere dal debitore la prestazione letteralmente indicata nel documento.

Nessuna eccezione può essere opposta dal debitore al possessore del titolo, che se quest'ultimo ha acquisito in buona fede il possesso, non è soggetto all'azione di rivendicazione.

Il rapporto fondamentale rimane estraneo alla vicende circolatore del titolo di credito, di tale rapporto si può:

- Fare menzione nel titolo: **titolo di credito causale**
- Non farvi menzione: **titolo di credito astratto** (cambiale)

Il rapporto fondamentale comunque costituisce la ragion d'essere della creazione del titolo di credito.

Nell'ipotesi in cui la cambiale sia stata erroneamente rilasciata al creditore e questi l'abbia ceduta ad altri, il nuovo legittimo possessore della cambiale, alla scadenza, si presenta al debitore per chiedere il pagamento e questi deve adempiere, in quanto la cambiale è un titolo astratto, ragione per cui, non essendoci indicato nessun rapporto fondamentale, nei confronti del possessore del titolo non potranno opporsi le eccezioni fondate sul rapporto originario tra cedente del titolo e lo stesso debitore. Resta salva la possibilità per il debitore di agire nei confronti del creditore cui la cambiale fu erroneamente rilasciata per ottenere la restituzione di quanto pagato.

Il codice classifica i titoli di credito in:

- a) **Titoli al portatore**: È il **titolo** di credito non intestato, sul quale non è cioè indicato il nome del soggetto a cui spetta la prestazione. Il trasferimento del **titolo** avviene mediante la sua consegna e quindi il titolare è semplicemente colui che lo possiede.

- b) **Titoli all'ordine:** sono la cambiale e l'assegno. È intestato e in caso di trasferimento non è sufficiente la mera consegna del documento ma occorre che dallo stesso emerga il **nominativo del nuovo possessore**. Il negozio giuridico che permette il trasferimento del titolo è la **girata**; con la girata il girante dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originario indicato nel titolo.
- c) **Titoli nominativi:** Titoli di credito indicanti il nome di una determinata persona, la cui intestazione, a differenza dei titoli all'ordine, deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente.

E' presente il richiamo ai **titoli rappresentativi di merci**, che non incorporano un diritto di credito, ma il diritto alla consegna delle **merci** in esso indicate, il possesso delle medesime ed il potere **di** disporre mediante trasferimento del **titolo** stesso.

Altri titoli di credito particolari sono quelli **di partecipazione** (es. titoli azionari di una società) che incorporano il diritto di partecipare alla vita dell'ente.

Non sono titoli di credito i **documenti di legittimazione** (es. biglietto ferroviario), non sono destinati alla circolazione.

L'obbligazione cambiaria può essere garantita da un'altra obbligazione cambiaria denominata **avallo**. L'avallo è un'obbligazione con cui un soggetto (*avallante*) garantisce l'obbligazione cambiaria di un altro soggetto (*avallato*). In altre parole, il pagamento di una cambiale può essere garantito tramite l'avallo.

È soggetto al **principio di:**

- **Autonomia:** prevale rispetto ai vizi che riguardano il contenuto dell'obbligazione principale, quindi se l'obbligazione garantita è nulla, l'avallo resta valido.
- **Accessorietà:** prevale rispetto ai vizi formali dell'obbligazione principale, quindi se manca un requisito di forma, come la sottoscrizione dell'emittente, l'avallo è nullo

L'avallante, se paga estingue il debito del terzo garantito ed è quindi surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, come il fideiussore.

LA PROMESSA AL PUBBLICO

Con la promessa al pubblico (art 1989 c.c.) il promittente si rivolge al pubblico e promette una prestazione a favore di colui che si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (es. ricompensa a chi ritrova il cane smarrito).

In questo caso sorge un vero e proprio vincolo obbligatorio a carico del promittente dal momento in cui la promessa è resa nota al pubblico e può essere nota con i mezzi più diversi.

Nel momento in cui la promessa diviene vincolante per il promittente il creditore è ancora indeterminato. Colui che compirà l'atto acquisterà il diritto alla prestazione promessa nello stesso momento in cui si troverà nella situazione richiesta dalla promessa.

Se l'azione è compiuta da più persone la prestazione promessa spetta a colui che per primo ne abbia dato notizia al promittente.

È diversa dall'**offerta al pubblico**, che è proposta contrattuale a destinatario indeterminato, che diviene vincolante solo con l'accettazione (la promessa al pubblico viene vincolante quando resa nota al pubblico) e può essere revocata fino a quando l'accettazione non giunga a conoscenza del proponente (la promessa invece può essere revocata solo per giusta causa sempre che la revoca sia resa nota al pubblico).

LA GESTIONE DI AFFARI

La gestione di affari appartiene agli “altri fatti” idonei a produrre obbligazioni ex art 1173 c.c. e si ha nei casi in cui taluno, senza esservi obbligato, assume consapevolmente la gestione di un affare altrui e quindi si comporta al pari di un mandatario senza che però gli sia mai stato conferito un mandato. L’assunzione della gestione avviene in via di mero fatto e il gestore può agire spendendo il proprio nome o quello del soggetto nel cui interesse egli agisce.

Si ha come conseguenza per il gestore il sorgere dell’obbligazione di continuare la gestione e portarla a termine sino a che l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso.

Se la gestione è stata **utilmente iniziata**, essa è fonte di obbligazioni per l’interessato che in particolare dovrà adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto nei confronti dei terzi in nome dell’interessato medesimo.

IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO

L’esecuzione di una prestazione o di un pagamento privo di giustificazione, cioè non dovuto ad alcun titolo, costituisce un **indebito oggettivo**. Lo si constata per esempio nel caso in cui il contratto in esecuzione del quale il corrispettivo sia stata pagato sia nullo o sia stata sciolto per risoluzione.

In questa ipotesi il soggetto che ha eseguito la prestazione non dovuta può:

- Ripetere quanto ha pagato insieme ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede
- Oppure dal giorno della domanda restitutoria, se chi lo ha ricevuto era in buona fede

Si ha invece un **indebito soggettivo** quando chi adempie alla prestazione altrui ritiene in base ad un errore scusabile di essere debitore, mentre in realtà debitore è un terzo.

Colui che ha pagato (*solvens*) può ripetere quanto ha pagato solo se versava in errore al momento del pagamento.

Qualora la ripetizione non possa operare colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Se ad essere stata indebitamente consegnata è una cosa determinata:

- Se colui che l’ha ricevuta era in mala fede, è tenuto a restituirla e se la cosa è perita deve corrisponderne il valore
- Se colui che l’ha ricevuta era in buona fede allora non risponde del deterioramento/perimento di essa

Se colui che ha ricevuto la cosa in buona fede e che l’abbia poi alienata a un terzo deve restituirne il prezzo. Se il prezzo non è ancora stato pagando dall’alienante a colui che gli ha alienato la cosa allora il *solvens* subentra nel diritto di chi ha alienato la cosa a ricevere il corrispettivo.

Le regole della ripetizione dell’indebito non possono essere applicate in caso di **obbligazioni naturali** e in caso di **prestazioni contrarie al buon costume**.

L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L’arricchimento senza causa è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo ad ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni. La fattispecie può ricorrere anche senza

attività dell'arricchito, che potrebbe persino ignorare di trovarsi in una situazione del genere. Essa comporta l'obbligazione per l'arricchito di restituire al danneggiato quanto ottenuto senza causa.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata sorge l'obbligo di restituire in natura la cosa ricevuta.

L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, quindi può essere esercitata da colui che ha subito un danno solo in mancanza di altra tutela.

CAPITOLO XVII

LA RESPONSABILITA' CIVILE

I FATTI ILLECITI NELLE FONTI DELL'OBBLIGAZIONE. IL SISTEMA CODICISTICO

IN EVOLUZIONE: DALLA COLPA ALLA PLURALITA' DEI CRITERI DI IMPUTAZIONE

Tra le fonti dell'obbligazione l'art 1173 c.c. richiama accanto al contratto, il fatto illecito. La norma in questione si riferisce a “**i fatti illeciti**” di cui si occupa il Titolo IX dello stesso Libro quarto del codice civile (artt. 2043-2059 c.c.).

Il complesso dei fatti illeciti, la cui ricorrenza determina il sorgere dell'obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto, è tradizionalmente qualificato con il termine **responsabilità civile**, in contrapposizione con la **responsabilità penale**, che è diretta a punire il colpevole di comportamenti ritenuti dannosi per l'intera collettività.

La responsabilità civile assolve una **funzione risarcitoria** orientata a sanzionare il comportamento anomalo che ha prodotto un danno nella sfera giuridica di altri, violando così il principio del *neminem laedere*.

In questa direzione si muovono gli articoli 2043 (**qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno**) e 2046 (*non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa*), che sono gli **indici fondamentali per delineare la struttura dell'illecito aquiliano**.

La responsabilità civile è chiamata ad operare se il danno prodotto nella sfera giuridica di un terzo derivi da un comportamento negligente (colpa) o intenzionale (dolo) posto in essere da un soggetto nella pienezza delle capacità di intendere e di volere, con conseguente onere della prova a carico di chi lamenta il danno e ne pretende il risarcimento dal colpevole.

La responsabilità civile sembra così destinata ad operare in presenza di una colpa.

Lo sviluppo tecnologico non solo ha portato ad una crescita dei danni ma anche a un loro mutamento qualitativo. In molti casi è estremamente difficile se non impossibile far risalire un evento dannoso a un comportamento colpevole di uno specifico soggetto e ciò ha cambiato l'indirizzo interpretativo degli enunciati normativi del nostro codice.

La responsabilità civile continua tuttora a perseguire la funzione risarcitoria, ma non più nella sola direzione che porta alla ricerca del colpevole, ma è orientata in vista della **più razionale allocazione dei costi dei danni** in grado di meglio assicurare la protezione dei danneggiati e di potenziare gli effetti di **prevenzione**.

Ciò ha portato all'individuazione, accanto alla colpa, di una **pluralità di criteri di imputazione**, diversi a seconda della fattispecie di responsabilità.

Così si è sentita la necessità d'invocare una responsabilità da accadimento distinta da quella (classica) da comportamento (colpa), ovvero la **responsabilità oggettivo** o **responsabilità senza colpa** è un tipo di responsabilità giuridica nella quale il soggetto è chiamato a rispondere di un illecito, civile o penale, senza che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.

Una simile situazione costituisce una deroga al principio della responsabilità, che trova origine nel “*neminem laedere*”, secondo il quale è necessario che ci sia l'esistenza di un preciso nesso psichico tra il fatto illecito e il comportamento dell'individuo, in modo che allo stesso gli possano essere attribuite le conseguenze giuridiche.

È una figura che implica l'esistenza del **solo nesso causale**. Da tale presupposto deriva che il **danneggiante risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta**. L'unica possibilità che l'agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di **dimostrare l'assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento**. La dottrina più moderna ritiene che

le ipotesi di responsabilità oggettiva siano volte proprio a **garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante**.

Come ad esempio: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia.

TUTELA REALE E TUTELA RISARCITORIA

La responsabilità civile costituisce un rimedio di ordine generale applicabile nel caso di **danno ingiusto**, ossia legato alla lesione di una situazione giuridicamente rilevante. Essa permette al soggetto che ha sofferto il danno di ottenere in termine monetari l'eliminazione delle sole conseguenze negative causate dalla lesione.

Quindi bisogna tenere separate:

- **Tutela risarcitoria:** che è quella appena descritta, non è in grado di eliminare l'interferenza che comporta la lesione della sfera giuridica altrui, ma solo a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'ingiusta lesione.
- **Tutela reale:** come la tutela dei diritti soggettivi assoluti (come i diritti reali, i diritti della personalità), delle situazioni di fatto (possesso) o delle attività (iniziativa economica), che mirano a rimuovere lo stesso fatto produttivo della lesione, ovvero gli eventi che ostacolano l'esercizio del diritto.

Es. nel caso di spoglio del possesso, una cosa è la tutela destinata al ripristino della situazione di fatto violata (azione di reintegrazione) che è una tutela reale, e un'altra è il risarcimento dei danni che il soggetto ha subito nel periodo in cui ha perso il godimento del bene.

Sicuramente le situazioni giuridicamente rilevanti, la cui lesione integra gli estremi del **danno ingiusto** meritevole di risarcimento, sono ben più numerose di quelle a cui l'ordinamento riserva anche la tutela reale.

La tutela reale inoltre è sicuramente quella più forte e assicura al titolare del diritto una protezione anche nel caso in cui la perdita inflitta dal terzo (dopo l'azione mossa dal titolare) sia maggiore del pregiudizio sofferto dalla vittima della lesione.

LA FATTISPECIE GENERALE DI RESPONSABILITA' DA FATTO DOLOSO E COLPOSO

L'art 2043 rappresenta una **disposizione di carattere fondamentale** per due ragioni:

- 1) Racchiude una **fattispecie di responsabilità generale**, in quanto rinvia a qualsiasi fatti doloso o colposo che provoca una lesione nella sfera giuridica altrui e si contrappone agli artt. 2048-2054 i quali disciplinano ipotesi ben circoscritte (danni cagionati da animali, da attività pericolose...).
- 2) Individua elementi comuni a tutte le ipotesi disciplinate, indispensabili perché ricorra il **fatto illecito**. Infatti, perché operi la responsabilità civile non è sufficiente che un soggetto lamenti un pregiudizio legato da un **nesso di causalità** con un evento imputabile a un terzo, ma è necessario che tale pregiudizio sia il risultato di una lesione apportata alla sfera giuridica del terzo e rilevante in termini di danno ingiusto.

Con riferimento a qualunque fatto doloso o colposo, l'art 2043 c.c., funge da **norma di chiusura**: tutte le ipotesi da fatto illecito che non rientrano in fattispecie circoscritte, rientrano nel suo ambito di operatività. In questa prospettiva la dottrina parla di un'**atipicità** dell'illecito fondato sull'art 2043 c.c. contrapposto alla **tipicità** degli illeciti disciplinati dalle altre disposizioni.

L'IMPUTABILITA'

Nella fattispecie contemplata dall'art 2043 c.c., l'**elemento soggettivo** assume un rilievo centrale per il richiamo alla colpa e al dolo.

Il codice civile richiede che al momento dell'azione il soggetto sia dotato della **capacità di intendere e di volere (art. 2046 c.c., che regola appunto l'imputabilità)**.

Il codice civile, a differenza del codice penale, non conosce graduazioni nella valutazione della capacità e lascia al libero apprezzamento del giudice la verifica in ordine alle condizioni del soggetto al momento dell'azione, in considerazione dell'età, dell'assenza di malattie...

L'unica ipotesi in cui la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere non esclude l'imputabilità del soggetto, si ha quando tale stato di incapacità sia dovuto da un comportamento colposo dello stesso (es. ubriachezza).

La capacità di intendere e volere richiesta dall'art 2046 non corrisponde a quella cui richiama l'art 428 c.c. (che ammette l'annullamento del negozio unilaterale o contratto concluso dall'incapace naturale) e tale capacità non interferisce con la capacità di agire, in quanto possono essere in grado di intendere e di volere anche un minore o un interdetto.

Se il danneggiante è incapace, alla tutela della vittima provvede chi era tenuto alla sua sorveglianza, sempre se il sorvegliante non riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto.

In caso di assenza di un sorvegliante alla tutela della vittima provvede il danneggiato stesso nella forma dell'**equa indennità**, che a differenza del risarcimento del danno non corrisponde necessariamente all'intera entità del danno.

LA COLPA E IL DOLO

La valutazione del comportamento dell'agente è affidata nell'art 2043 c.c. rispettivamente alla **colpa** e al **dolo**, di cui la norma non offre una precisa definizione e quindi occorre far riferimento alle nozioni elaborate sulla base della disciplina penalistica:

- **Dolo:** intenzionalità, ovvero coscienza e volontà dell'evento lesivo
- **Colpa:** ricorre quando l'evento lesivo non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Netta è la differenza in questo campo tra diritto civile e diritto penale: mentre nel diritto penale assume un ruolo fondamentale il dolo, per cui la colpa rileva solo nelle ipotesi tassativamente previste, nell'ambito della responsabilità civile da fatto illecito in linea di principio non emergono differenze disciplinari tra il dolo e la colpa, quindi sul piano disciplinare e delle conseguenze sono del tutto equiparate.

Per quanto riguarda la colpa, la diligenza, la prudenza e la perizia si valutano alla luce di un **parametro oggettivo**, quindi la valutazione non è affidata al confronto tra i comportamenti normalmente tenuti dal singolo soggetto, ma nell'ordinamento italiano il parametro oggettivo di valutazione del comportamento del danneggiante è comunemente identificato nella **diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.)**, cioè fondato sullo standard di diligenza dell'uomo medio.

Tale riferimento è da interpretarsi in senso relativo ed elastico, adeguandolo quindi alle particolari e diverse situazioni concrete.

Per esempio, nel caso di **colpa professionale**, la valutazione della colpa andrà a commisurarsi con il livello medio di diligenza che caratterizza le rispettive professionalità in quel particolare settore.

La colpa, ai fini della responsabilità civile, è pur sempre **colpa commissiva**, fondata sulla mancata adozione da parte del soggetto delle precauzioni che bisognava adottare nell'azione, quindi quando l'agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente. Difficile appare invece l'ammissibilità della **colpa omissiva**, ossia della colpa che si fonda sulla semplice mancata attivazione del soggetto. La mancata cooperazione da parte di un consociato può contribuire al verificarsi di un danno per il solo fatto di essersi astenuto dall'agire SOLO se vi sia stata la violazione di una norma che imponga espressamente siffatto dovere di condotta.

La valutazione oggettiva della colpa sulla base della diligenza media prevede in linea di principio l'**irrilevanza del grado della colpa**, anche se in alcuni casi la responsabilità è limitata soltanto alla ricorrenza della **colpa grave**, ossia quella colpa dove vi è un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare. In questo caso la prevedibilità del danno è così accentuata che tale colpa è equiparata al dolo.

A sua volta la l. 117/1988 ha previsto la **responsabilità del magistrato** solo in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni (una responsabilità indiretta in quanto chi è danneggiato da un giudice deve citare lo Stato).

Per quanto riguarda la **prova della colpa**, l'onere di fornire la prova della colpa spetta al danneggiato, salvo i casi dove la colpa si presume.

Per quanto riguarda il **dolo**, a differenza della colpa che opera come criterio di valutazione della condotta, rinvia essenzialmente a un dato psicologico, in quanto richiede necessariamente la consapevole assunzione dello stesso nell'esito dell'azione.

La presenza del dolo implica sempre quella della mala fede, cioè la consapevolezza di ledere altrui diritto, ma non è vero il contrario.

Vi sono taluni illeciti civili in cui è indispensabile la presenza del dolo, ad esempio gli atti emulativi.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: ESERCIZIO DEL DIRITTO, LEGITTIMA DIFESA E STATO DI NECESSITA'

La sussistenza della fattispecie illecita di cui si occupa l'art 2043 c.c. può mancare qualora emergano alcune circostanze che tradizionalmente sono conosciute come **cause di giustificazione**, espressione derivante dal diritto penale, il quale individua alcuni casi in cui la contrarietà al diritto della condotta, ovvero la **antigiuridicità**, viene rimossa dalla presenza di alcune cause che la rendono *secundum jus*.

Anche il diritto civile conosce una nozione di illecito che abbraccia tutte le situazioni *contra jus*, quindi le condotte che si pongono in contrasto con espliciti divieti normativi (**atto illecito in senso stretto**), ma non è corretto sostenere che il risarcimento del danno operi direttamente come sanzione di una condotta antigiuridica e che la stessa responsabilità civile si configuri come una norma secondaria chiamata ad intervenire in presenza di una norma primaria.

Perché ricorra l'ipotesi prevista dall'art 2043 c.c. non è necessario che sussista solo un atto illecito in senso stretto, quindi un comportamento antigiuridico, ma è sufficiente solo che sia stato leso un interesse tutelato dalla legge.

Data questa premessa, nel campo della responsabilità civile le cause di giustificazione non mirano a rimuovere una presunta antigiuridicità della condotta, ovvero rendere l'atto lecito, ma a introdurre accanto alla categoria degli atti illeciti dannosi, una nuova categoria degli **atti leciti dannosi**.

In questo campo le cause di giustificazione danno rilievo a certe circostanze che pur in presenza di un danno ingiusto impediscono il perfezionamento del "fatto illecito" e di conseguenza l'integrale produzione degli effetti previsti.

Per questi casi l'ordinamento prevede risposte diversificate costruite sulla misura dei contrapposti interessi in gioco tra le parti.

ESERCIZIO DEL DIRITTO (art 51 c.p.): nel diritto penale l'azione posta in essere da un soggetto all'esercizio di un diritto ha come effetto quello di rimuovere l'antigiuridicità del comportamento, che quindi diventa lecito.

Nel diritto civile invece, ai fini dell'esclusione della responsabilità non basta invocare che si è agito nell'esercizio di un proprio diritto, ma ciò che rileva è il **modo** in cui si è esercitato il diritto. Il danneggiante incorrerà nella responsabilità civile e sarà tenuto al risarcimento se si accerterà che il danno ingiusto prodotto era evitabile.

Nel campo della responsabilità civile insomma l'esercizio del diritto opera come causa di giustificazione (cioè esclude che sorga l'obbligazione di risarcire INTEGRALMENTE il danno) solo nei casi in cui la produzione del danno è **inevitabile** ai fini dell'esercizio del diritto.

Per queste ipotesi la disciplina prospetta risposte modulate in relazione alla diversa valutazione degli interessi contrapposti e agli scopi perseguiti.

Es. L'art 843 riconosce, nei rapporti di vicinato, al proprietario vicino il diritto di accesso o di passaggio nel fondo altrui quando ciò si rilevi necessario al fine di costruire o riparare un muro o altra opera, ma dispone che se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità. L'ordinamento bilancia quindi la tutela del soggetto cui ha riconosciuto il diritto di accesso con quella dell'altro proprietario che subisce il danno, ponendo al carico del primo una parte sostanziosa del danno sotto forma di adeguata indennità.

In alcuni casi può sussistere il **consenso dell'avente diritto**, ovvero quando il rischio del danno è condiviso ed accettato dai soggetti che partecipano alla medesima attività. Basata sul consenso dell'avente diritto è per esempio la c.d. **scriminante sportiva**, la quale poggia sul rischio sportivo consentito e si applica come causa di esclusione della responsabilità penale la responsabilità civile ex art 2043 c.c. nel caso in cui si verifichi una lesione (che normalmente porterebbe alla produzione di illeciti penali) durante l'esercizio di uno sport.

STATO DI NECESSITA' (art 2045 c.c.): quando taluno è costretto a produrre un fatto dannoso al fine di salvare sé o altri da una situazione di pericolo, non volontariamente causata e non altrimenti evitabile, di grave danno alla persona (riferibile ai diritti fondamentali). (es. per evitare di travolgere un ciclista si è costretti a tamponare una vettura in sosta)

La soluzione disposta dall'art 2045 c.c. deriva dal confronto tra il danno provocato nella sfera giuridica del terzo e il danno alla persona che è stato evitato attraverso la produzione del primo, e prevede l'attribuzione a favore del danneggiato di un'indennità il cui ammontare è rimesso all'equo apprezzamento del giudice.

La giustificazione ex art 2045 non opera quando il soggetto che ha prodotto il danno sia lo stesso che abbia provocato la situazione di pericolo.

Invece, nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo che induce il soggetto ad agire sia determinata da fatto doloso o colposo di una terza persona, il danneggiato può agire in via alternativa (non cumulativa), quindi sia nei confronti del danneggiante che è tenuto nei limiti dell'indennità, sia dell'altro soggetto la quale condotta colposa abbia determinato la situazione di pericolo.

Così se il danneggiato ha ottenuto dal danneggiante l'indennità, può agire per la differenza rispetto all'integrale risarcimento del danno nei confronti del secondo.

Il danneggiante che abbia pagato l'indennità, può agire in rivalsa nei confronti del terzo che con il proprio fatto colposo ha posto in essere la situazione di pericolo.

LEGITTIMA DIFESA (art 2044 c.c.): si ha legittima difesa quando si è costretti a cagionare un danno ingiusto all'aggressore per respingere un'offesa ingiusta che viene arrecata a sé o ad altri.

Inizialmente l'art 2044 si limitava a non apprestare alcuna tutela risarcitoria all'aggressore danneggiato, ovviamente sempre in presenza del fatto che la difesa deve essere **proporzionata** all'offesa.

Poi è stato inserito un secondo comma, che dichiara che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa nei casi di cui all'articolo 52 del c.p., ovvero per colui che difende la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui.

È stato aggiunto anche un terzo comma in base al quale all'aggressore danneggiato spetta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenendo conto della gravità e delle modalità realizzative.

IL NESSO DI CAUSALITA': DANNO EVENTO E DANNO CONSEGUENZA

La presenza della fattispecie illecita richiede che sussista un legame tra l'evento dannoso venuto a esistenza ed una delle circostanze che si rilevano come possibili criteri di imputazione della responsabilità civile: il danno ingiusto deve risultare quindi cagionato da fatto doloso o colposo oppure dall'attività pericolosa, da cose in custodia, dalla rovina di edificio ecc...

Solo l'individuazione di questo **nesso di causalità** permette l'individuazione del:

- **Danno evento:** complessiva sequenza di eventi rilevanti ai fini dell'attribuzione della responsabilità, quindi si tratta di rilevare se un evento dannoso sia collegato sul piano materiale a uno o più eventi precedenti considerati come criteri di imputazione della responsabilità dal legislatore.
- **Danno conseguenza:** fissazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile, quindi individuare le conseguenze dannose che da tale evento si sono prodotte e a cui va fatto riferimento nella liquidazione del danno.

Nel fatto illecito, il problema del nesso di causalità rileva sotto due aspetti che corrispondono alla diversità di significati che il termine danno assume nell'art 2043 c.c.:

- 1) **Danno ingiusto:** lesione ingiusta cagionata ad altri
- 2) **Pregiudizio scaturito da tale lesione**

Il codice non esprime una disciplina esaustiva circa il nesso di causalità, infatti l'art 2056 riguarda solo la determinazione del pregiudizio sofferto, quindi la fase del danno conseguenza.

Per la fase del danno evento, secondo un orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si può far richiamo alla formula della **causalità adeguata**, che la disciplina penalistica ha posto alla base del collegamento materiale tra la condotta e l'evento.

La causalità adeguata va a completare la teoria della **condicio sine qua non**, la quale ritiene che un evento lesivo può ritenersi cagionato da un altro precedente quando quest'ultimo costituisca una condizione senza la quale l'altro non si sarebbe prodotto, richiedendo un'ulteriore condizione ai fini della sussistenza del nesso, ovvero occorre che l'uomo vi abbia contribuito con un'azione adeguata a determinare quell'evento, sulla base della comune esperienza.

Il nesso di causalità rilevante ai fini della responsabilità civile si è andato sempre di più differenziando da quello utilizzato ai fini della responsabilità penale:

- Nella responsabilità penale, indirizzata a verificare la presenza di un colpevole da punire, vige la regola della prova che deve andare oltre il ragionevole dubbio (necessità di un alto grado di probabilità di colpevolezza dell'imputato).
- Nella responsabilità civile, che è diretta a tutelare il danneggiato, ci si accontenta della regola del "più probabile che non", in questo modo ricadono sul danneggiante tutti i rischi che normalmente sono connessi alla condotta da lui tenuta ex art 2043 c.c.

Viceversa, restano a carico del danneggiato, ovvero si collegano a una distinta sequenza causale, quei danni che presentano **caratteri di eccezionalità** e che dunque si collocano fuori dalla sequenza causale già individuata, ciò non opera ovviamente a favore del danneggiante, cioè non va a ridimensionare il nesso di causalità.

La particolare attenzione alla tutela del danneggiato nell'ambito della responsabilità civile si nota nella disciplina dettata dall'art 2055 c.c. per il **fatto dannoso imputabile a più persone**, cioè l'ipotesi di concorso di più criteri di imputazione rispetto a un medesimo fatto dannoso.

La responsabilità grava su tutti i danneggianti che sono coinvolti **in solido** nell'obbligazione risarcitoria. Colui che ha subito il danno può agire nei confronti di uno qualsiasi dei responsabili e pretendere l'intero ammontare del danno indipendentemente dall'incidenza causale che ha quel soggetto nell'evento dannoso. Spetterà poi al danneggiante che ha risarcito l'intero danno agire **in regresso** nei confronti degli altri responsabili, e soltanto in questa sede risulterà rilevante la gravità della corrispettiva colpa di ciascun coobbligato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Diverso è il trattamento riservato al caso in cui vi sia stato **concorso di colpa del danneggiato** sia nella produzione dell'evento dannoso, sia nell'aggravamento delle sue conseguenze.

L'art 1227 stabilisce che il risarcimento è diminuito o escluso nei casi in cui il danneggiato abbia contribuito al verificarsi del danno per negligenza e imprudenza.

In questo modo il risarcimento del danno dovuto dal terzo subirà una diminuzione secondo la misura della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Mentre è escluso del tutto il risarcimento quando il danno poteva essere evitato dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, ovviamente ciò è circoscritto ai soli casi in cui il danneggiato sia capace di intendere e volere.

LE FATTISPECIE SPECIALI DI RESPONSABILITA': LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI,

TUTORI E PRECETTORI

Il fatto illecito disciplinato dall'art 2043 racchiude una soltanto delle ipotesi di responsabilità previste dal sistema civilistico e a questa ipotesi ne vanno aggiunte altre dove la responsabilità si basa su criteri di imputazione distinti da quelli che animano l'art 2043.

Questi criteri rispondono all'esigenza di far fronte alle conseguenze dannose derivanti dallo svolgimento di attività che comportano inevitabilmente l'insorgere di rischi, e pongono l'obbligazione risarcitoria a carico dei soggetti che sono più in grado di adottare le opportune misure atte a prevenire i rischi di danno e a tenerli sotto controllo.

Tra le altre fattispecie disciplinate nel codice vanno segnalate le ipotesi di responsabilità per fatto altrui, a carico:

- Art 2047 c.c.: dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace autore del danno
- Art 2048 c.c.: dei genitori, tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni provocati dai figli minori e dagli allievi e apprendisti

- Art 2049 c.c.: dei padroni e dei committenti per i danni derivanti dall'illecito provocato dai loro domestici e commessi nell'esercizio dei compiti a cui sono adibiti.

Questi articoli sono accomunati da un fatto illecito posto in essere da altro soggetto ma gli artt. 2047-2048 si distinguono dall'art 2049, in quanto solo in quest'ultimo si è in presenza di responsabilità oggettiva senza alcuna possibilità di prova liberatoria, mentre nei primi due la responsabilità per il fatto illecito altrui può essere esclusa ove si provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso di danno prodotto a terzi dall'incapace ex art 2047 c.c. si ha la **responsabilità del sorvegliante** ove ricorra tale figura, ed è colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace al momento del fatto (questa figura può coincidere anche con i genitori).

Viceversa, la **responsabilità dei genitori e dei precettori** ex art 2048 c.c. presuppone che l'autore del danno, per quanto minore d'età, sia capace di intendere e di volere, pertanto la responsabilità del figlio e dei genitori è solidale.

La giurisprudenza fonda la responsabilità dei genitori su di una presunzione di colpa relativa non soltanto alla vigilanza (**culpa in vigilando**) da attuare nei confronti del minore, ma anche all'educazione da impartire allo stesso (**culpa in educando**). Non si può certo sostenere che si tratti di un'ipotesi di responsabilità oggettiva e la prima conseguenza di questo orientamento è che la **prova liberatoria** si è trasformata nella prova non solo di aver sorvegliato adeguatamente, ma soprattutto di aver ben educato il minore.

Nel caso dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte, la responsabilità è circoscritta al tempo in cui gli allievi e gli apprendisti si trovino sotto la loro vigilanza.

Anche per i precettori non è facile fornire la prova liberatoria, in quanto si tratta di dimostrare di aver tenuto un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere e all'immediato esercizio di un intervento correttivo e repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno.

Questa ipotesi di responsabilità si sta andando sempre di più ad oggettivare, ad esempio:

- 1) Fatti illeciti commessi da alluni in scuole pubbliche: i danneggiati possono agire in giudizio solo nei confronti della p.a. da cui dipende il personale docente tenuto alla vigilanza
- 2) Responsabilità civile del magistrato: il danneggiato può agire per ottenere il risarcimento nei confronti dello Stato, che si rifarà in un secondo momento mediante un'azione di rivalsa sul magistrato responsabile.

LA RESPONSABILITA' DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

Art 2049 c.c.: *«i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.»* (ipotesi di responsabilità oggettiva).

Solitamente si fa coincidere l'ambito di operatività di questa disposizione con il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, e in particolare nel porre a carico del datore di lavoro/imprenditore le conseguenze dannose prodotte a terzi dal fatto illecito dei suoi dipendenti, senza alcuna possibilità di prova liberatoria e l'impossibilità di richiamo a una semplice presunzione di colpa.

In questo caso opera in criterio di imputazione fondato sul **rischio d'impresa**, in base al quale i danni provocati dall'organizzazione aziendale sono ricondotti al soggetto destinatario del profitto che di tale organizzazione è titolare.

In realtà, tale responsabilità, opera tutte le volte in cui l'atto illecito viene a realizzarsi nell'ambito di un'attività svolta dal danneggiante al servizio e nell'interesse di un altro soggetto, quindi più che fondarsi sul rischio di impresa attribuisce rilievo alla presenza di un'organizzazione entro cui va ad inserirsi l'attività produttiva del danno e quest'ultimo viene così imputato al soggetto a cui si riferisce tale organizzazione.

Presupposti perché operi la responsabilità ex art 2049 c.c.:

- È necessario che l'autore dell'illecito (domestico o commesso) sia legato da un rapporto di **preposizione** con un altro soggetto (padrone o committente). Condizione sufficiente purché vi sia preposizione è che emerga un vincolo di **subordinazione**, ovvero quando un soggetto svolge un'attività per conto di un altro (senza necessita di un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto contrattuale).
- È necessario che il danno sia stato provocato dal danneggiante nell'esercizio delle attività a cui era stato adibito, quindi tale responsabilità non opera nel caso in cui ad esempio il dipendente, fuori dall'orario di lavoro e della stessa struttura aziendale, commetta un fatto illecito produttivo di danni a terzi.

Anche se vi è la tendenza ad attirare nell'orbita della responsabilità del committente anche i rischi connessi ad attività poste in essere dal danneggiante legato solo da un **nesso di occasionalità necessaria e marginale** rispetto alle mansioni a loro assegnate.

In ogni caso è sempre possibile che il committente, tenuto al risarcimento, agisca in regresso nei confronti dell'autore del danno.

LE ATTIVITA' PERICOLOSE

L'art 2050 c.c. è relativo all'esercizio di **attività pericolose**, secondo il quale, in presenza di un'attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, risponde dei danni da questa cagionati colui che svolge tale attività, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La pericolosità dell'attività non deve attenere alla condotta del soggetto agente, ma a condizioni oggettive e per altro verso, la semplice possibilità che l'esercizio di un'attività determini l'insorgere di un'opportunità per il verificarsi di condotte illecite non è sufficiente a qualificare come pericolosa quella attività.

La responsabilità non si evita semplicemente provando di aver tenuto una condotta conforme a un parametro di diligenza, ma è indispensabile fornire la prova di aver organizzato tale attività ponendo in campo i mezzi più avanzati tecnologicamente ed oggettivamente idonei ad evitare il prodursi dei danni.

DANNI CAGIONATI DA COSE O DA ANIMALI

Le due ipotesi di responsabilità previste dagli artt. 2051-2052 c.c. sono ipotesi di responsabilità oggettiva e sono accomunate dal fatto che l'unica via offerta al presunto responsabile per sottrarsi dall'imputazione dell'obbligazione risarcitoria è quella di provare il caso fortuito, ovvero provare l'intervento di un evento esterno, inevitabile e imprevedibile, che possa ritenersi causa del danno. Nell'ipotesi di danni cagionati da cose o animali la relativa imputazione non va a considerare né la condotta dei soggetti né la misura dei rimedi eventualmente da adottarsi/adottati per prevenire il rischio del danno.

Danno da cose (art 2051 c.c.): non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma è sufficiente che la cosa abbia in concreto svolto un ruolo attivo nel verificarsi dell'evento dannoso. La disposizione non prevede una selezione tra le cose e il danno può essere provocato:

- Dalla struttura della cosa (ostacoli lungo una pista da scii)
- Da una sua qualità (marciapiede dissestato)
- Da una sua condizione temporanea (pavimento bagnato)

La responsabilità in questo caso grava sul soggetto che ne ha la **custodia**, con la quale si intende il **potere effettivo di controllo** sulla cosa. Oltre al proprietario possono essere custodi della cosa anche il possessore o il detentore.

L'esistenza del nesso causale tra la cosa e danno è sufficiente a far insorgere la responsabilità, per evitarla è necessario appunto fornire la prova del caso fortuito.

Danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.): questa disposizione richiama come responsabile del danno il proprietario dell'animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Perché operi la responsabilità non è rilevante la natura o l'indole dell'animale, ma non viene applicata agli animali selvatici che vivono allo stato libero nell'ambito di una riserva.

L'esistenza del nesso causale tra il fatto dell'animale e danno è sufficiente a far insorgere la responsabilità, per evitarla è necessario appunto fornire la prova del caso fortuito.

LA ROVINA DI EDIFICI

La disposizione relativa alla **rovina di edifici (art. 2053 c.c.)** delinea una fattispecie particolare rispetto a quella di più ampio spettro dell'art 2051 c.c.

Per rovina si intende sia il crollo sia la disgregazione, anche solo di una parte, dell'edificio, da cui derivi un danno.

In questo caso la responsabilità grava sul **proprietario**, pur se il godimento del bene e la relazione di fatto con la cosa spettino ad altro soggetto, salvo che si provi la colpa dell'appaltatore.

Perché operi la responsabilità è sufficiente che il danneggiato provi che l'evento dannoso sia direttamente legato da un rapporto di causalità con la rovina totale o parziale dell'edificio o con la disgregazione di un suo elemento.

La prova liberatoria deve dimostrare il caso fortuito.

LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

L'art 2054 c.c. si occupa della circolazione dei veicoli.

Con il termine "veicolo" comprende ogni mezzo destinato alla circolazione su strada (no rotaie) trasportante persone o cose, a trazione meccanica, umana o animale.

Quanto alla circolazione cui si riferisce la norma comprende sia le fasi di movimento sia le soste e le fermate.

Il conducente è responsabile dei danni prodotti a cose o persone dalla circolazione del veicolo.

Il conducente però non è liberato dalla responsabilità se si limita soltanto a provare di aver tenuto una condotta diligente, infatti, in linea di principio, grava sul conducente anche il rischio legato all'imprudenza di terzi: per sottrarsi alla responsabilità egli deve dimostrare che ha comunque adottato tutte le manovre possibili per impedire il prodursi del danno.

Per il caso di scontro tra veicoli opera una **presunzione di pari corresponsabilità** nella causazione del danno, vincibile con la prova della responsabilità esclusiva o maggiore di uno dei due conducenti. Accanto alla responsabilità del conducente, la norma pone anche quella eccezionale del proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio), la quale è una

responsabilità totalmente oggettiva, in quanto si collega al semplice fatto di avere la disponibilità giuridica del veicolo. Tali soggetti possono sottrarsi alla responsabilità solo se riescono a provare che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà.

Anche nel caso di vizi di costruzione o manutenzione del veicolo che possono essere sconosciuti dal conducente, quest'ultimo risponde comunque con esclusione della prova liberatoria.

LA RESPONSABILITA' DA PRODOTTI DIFETTOSI

Un'importante fattispecie di responsabilità oggettiva prevista fuori dal codice civile è quella attualmente disciplinata dagli artt. 114-127 del codice del consumo in materia di **danni da prodotti difettosi**.

La disciplina contenuta nel codice del consumo ha previsto un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico fondamentalmente del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto: responsabilità che si sposta sul fornitore quando non sia possibile individuare il produttore.

La normativa si riferisce soltanto ai **beni mobili** anche se incorporati in un altro bene mobile o immobile.

Quanto ai difetti, la cui sussistenza costituisce condizione necessaria per l'operare della responsabilità, il termine non richiama i vizi (quindi una carenza di qualità), ma il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere.

L'onere della prova a carico del danneggiato si riduce alla dimostrazione della connessione causale tra l'uso del bene e il prodursi del danno.

Il produttore, per sottrarsi alla responsabilità, può fornire la prova della non difettosità del prodotto e in particolare mettere in discussione che vi sia stato un uso ragionevole del prodotto anche alla luce delle istruzioni fornite.

Un'altra ipotesi di esclusione della responsabilità oggettiva del produttore è relativa ai **rischi da sviluppo**, cioè se al momento della messa in circolazione del prodotto lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.

RESPONSABILITA' CIVILE DA DANNO AMBIENTALE

Innanzitutto per danno ambientale si intende un *qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima* e spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia di esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno ambientale sia di procedere con propria ordinanza.

L'art. 311 del codice ambientale prevede che due diverse fattispecie di responsabilità:

- Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da operatori esercenti in una delle attività elencate dal medesimo codice si è davanti a una responsabilità oggettiva
- Tutti gli altri soggetti che hanno cagionato un danno ambientale rispondono solo se vi è colpa o dolo.

Vi è l'obbligo a carico del responsabile di provvedere al risarcimento in forma specifica, ovvero adottare delle misure di riparazione concrete.

Nel caso di concorso di più soggetti nella produzione del danno ambientale ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale.

L'INGIUSTIZIA DEL DANNO: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Abbiamo una netta distinzione tra l'illecito civile in senso stretto, che si lega alla trasgressione di precisi divieti relativi a determinate condotte cui corrisponde la previsione di puntuali e adeguate sanzioni, e la responsabilità aquiliana, che si esaurisce nell'imputazione ad un soggetto dell'obbligo di risarcire il danno recato ad altri.

Quest'ultima trova il suo fondamento nella presenza di una lesione, in particolare di un **danno ingiusto**, le cui conseguenze, patrimoniali e non, una volta commisurate, sono poste a carico del soggetto individuato attraverso l'applicazione dei diversi criteri di imputazione sopra analizzati.

Quindi, l'area di operatività della responsabilità civile è diversa e decisamente più ampia rispetto a quella in cui ricorre un illecito civile in senso stretto.

Prima era l'illiceità dell'atto il presupposto dell'ingiustizia del danno, ora invece è l'ingiustizia del danno il presupposto per la ricorrenza di uno dei fatti illeciti previsti dal legislatore quali fonti dell'obbligazione risarcitoria.

L'ingiustizia del danno è espressione della situazione soggettiva pregiudicata: soltanto il danno così connotato è in grado di qualificare il fatto come fatto illecito e dunque ricorrere alla tutela risarcitoria.

Perché ricorra un danno ingiusto e operi il risarcimento, non basta che emerga un pregiudizio economico, è pur sempre necessario che tale pregiudizio si leghi alla lesione di una situazione giuridicamente rilevante.

IL DANNO AI DIRITTI REALI, AI DIRITTI DELLA PERSONALITA' E ALLA SALUTE. LA LESIONE DEL CREDITO. LA LESIONE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI E DELLE SITUAZIONI DI FATTO GIURIDICAMENTE RILEVANTI

Uno stesso evento può produrre una molteplicità di pregiudizi che ricadono in capo a più soggetti, ma non tutti questi pregiudizi sono dal punto di vista giuridico meritevoli di tutela risarcitoria.

La funzione selettiva è stata affidata dall'ordinamento italiano all'ingiustizia del danno, ossia alla ricorrenza della lesione di una situazione giuridicamente rilevante.

I diritti che tradizionalmente sono destinatari di questa tutela sono i **diritti soggettivi assoluti**, quindi ricomprendono anche le lesioni che toccano i **diritti reali** o i diritti a contenuto patrimoniale opponibili *erga omnes* o altrettanto può dirsi per le lesioni dei **diritti della persona**.

Per le situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi assoluti, in particolare per i **diritti di credito**, l'esperienza giuridica italiana ha ammesso questa tutela, quindi la risarcibilità dei danni a favore del creditore nel caso in cui un terzo con un fatto a lui imputabile pregiudichi l'adempimento dell'obbligazione.

In questo caso, al criterio della causalità adeguata spetta anche il compito di delimitare il risarcimento del danno ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Nella lesione del credito l'attività del danneggiante può compromettere sia il bene oggetto della prestazione sia la stessa persona del debitore. In quest'ultimo caso si è riconosciuto il risarcimento del danno all'impreso che ha subito la perdita delle insostituibili prestazioni professionali che il debitore avrebbe dovuto fornire. La soluzione non cambia anche in caso di impossibilità temporanea della prestazione da parte del debitore per fatto imputabile a terzo.

Un'ipotesi significativa è rappresentata dalla **perdita di chance**, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, che rappresenta quindi una lesione di semplici aspettative giuridicamente rilevanti.

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto la tutela aquiliana anche a favore dei consumatori finali che hanno pagato prezzi più alti a seguito di illecite intese anticoncorrenziali.

Quanto al risarcimento del danno da **lesione di interessi legittimi**: in questi casi non è sufficiente limitarsi a constatare il verificarsi di un danno a carico del privato ai fini del risarcimento, ma resta sempre necessario che sussista un danno ingiusto e l'ingiustizia del danno non può dedursi semplicemente dall'illegittimità del comportamento della p.a.

Inizialmente vigeva l'impossibilità del risarcimento dell'interesse legittimo, tesi fondata sull'idea negativa della tutela in sede aquiliana degli interessi legittimi, quindi il giudice poteva annullare l'atto illegittimo ma non pronunciare una sentenza di condanna sul risarcimento del danno, ma dopo importanti pronunce della Corte di cassazione questo limite è stato superato.

Quanto infine alle **situazioni di fatto** pur sempre giuridicamente rilevanti, la relativa lesione integra un'ipotesi di danno ingiusto come tale risarcibile.

IL DANNO RISARCIBILE. IL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Dal danno ingiusto, quale lesione cagionata a terzi, la cui ricorrenza è necessaria perché sussista il fatto illecito fonte di responsabilità civile, si distingue il **danno risarcitorio**. Questo si identifica con le conseguenze pregiudizievoli che discendono dall'ingiusta lesione e che determinano in concreto il contenuto dell'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile.

Nell'ambito del danno risarcibile si ascrive fondamentalmente il **danno patrimoniale**, che comprende tutte le conseguenze patrimoniali immediate e dirette (**art. 1223 c.c.**) che derivano dalla lesione apportata al terzo.

Compresi nel danno patrimoniale sono:

- **Danno emergente**: perdita che si è venuta a determinare nel patrimonio del danneggiato
- **Lucro cessante**: il mancato guadagno di cui risente lo stesso soggetto per effetto del danno ingiusto subito

Sebbene l'art. 1223 c.c. faccia riferimento ai soli danni che siano conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso, la giurisprudenza ha ampliato l'area del danno risarcibile ammettendo il risarcimento anche di danni indiretti, sempre che siano collegabili all'evento dannoso.

In linea di principio spetta al danneggiato fornire la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui richiede il risarcimento e che può essere dimostrato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.

Nell'ipotesi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare interviene la valutazione equitativa del giudice.

Il lucro cessante invece viene valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Nella quantificazione del danno risarcibile è necessario tener conto del fatto che l'evento dannoso può determinare anche conseguenze vantaggiose per la vittima; da qui la necessità dell'applicazione della c.d. **compensatio lucri cum damno** al fine di evitare che, a svantaggio questa volta del danneggiante, l'altra parte conseguenda un ingiusto guadagno.

La **compensatio** richiede pur sempre che pregiudizio ed incremento patrimoniale discendano dallo stesso fatto.

In ordine al concorso del danneggiato, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia contribuito a cagionare, secondo il nesso di causalità materiale, lo stesso evento lesivo, il risarcimento va diminuito in ragione della rilevanza causale del suo comportamento.

Inoltre vengono sottratti dal danno risarcibile i pregiudizi patrimoniali conseguenti al fatto lesivo che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

IL DANNO NON PATRIMONIALE: DAL DANNO MORALE AL DANNO BIOLOGICO

Accanto alla tutela del danno patrimoniale, il sistema italiano prevede anche quel del **danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)**.

Secondo l'art. 2059 il risarcimento di tale danno è connotato dalla tipicità in quanto è ammesso solo nei casi previsti dalla legge.

Per lungo tempo il "danno non patrimoniale" è stato identificato nel solo **danno morale**, con cui si faceva riferimento ai dolori e alle sofferenze morali, di cui il danneggiato risente per effetto della lesione subita, in forza del rilievo conosciuto dell'art 185 c.p. che ammette il ristoro del danno non patrimoniale quale conseguenza del reato.

Il concetto è stato poi ampliato dalla giurisprudenza, così da comprendere nella nozione:

- **Danno biologico**, danno morale in senso stretto
- **Danno esistenziale**

A conferma della natura oggettiva di tale danno non patrimoniale, ossia della sua irriducibilità al tradizionale danno morale, la recente giurisprudenza ne ha riconosciuto la risarcibilità non solo a favore di persone che per l'incapacità di cui sono affette non sono in condizioni di subire dolori o privazioni consapevoli, ma anche a favore di persone giuridiche in caso di lesione ai diritti della personalità a loro spettanti.

La quantificazione del danno non patrimoniale è effettuata dal giudice in via equitativa nel rispetto dell'esigenza di una razionale correlazione tra l'evento lesivo e l'equivalente pecuniario e la sua liquidazione tiene conto anche delle condizioni economiche dello stesso responsabile, per cui la condanna al risarcimento del danno finisce con lo svolgere anche una funzione punitiva.

Il danno non patrimoniale si distingue nettamente da quello patrimoniale, infatti esso sfugge ad una misurazione precisa, perché l'attribuzione di una somma di denaro alla vittima appare rivolta sostanzialmente a lenire le sofferenze del soggetto leso (*pecunia doloris*).

IL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEGLI ALTRI

DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI.

Delicata si è rivelata la gestione dei danni legati alla lesione di situazioni giuridiche non aventi contenuto patrimoniale.

Ciò ha riguardato particolarmente i danni ingiusti subiti dalla persona umana, a partire innanzitutto dalla lesione del **diritto alla salute** ex art. 32 Cost., intesa come integrità psico-fisica della persona umana.

La figura del danno alla persona ha subito nei decenni un progressivo cambiamento, partendo da un'ottica puramente patrimoniale ad un'ottica non patrimoniale, per cui qualsiasi tipo di lesione deve essere risarcita.

In ordine ai danni patrimoniali permanenti e in particolare al lucro cessante si può osservare come una lesione dovuta ad un incidente può colpire tanto soggetti che lavorano e producono un reddito,

sia soggetti che non lavorano, quindi anche se vi è parità della lesione, le conseguenze in ordine patrimoniale sono profondamente differenti da soggetto a soggetto.

Di fronte a questa molteplicità di situazioni, per risarcire i danni patrimoniali futuri legati alla lesione dell'integrità psico-fisica, la giurisprudenza per lungo tempo faceva riferimento a una generica capacità di guadagno di ogni individuo.

Inoltre ha introdotto anche altre figure di danni patrimoniali, quali:

- **Il danno estetico:** tutela risarcitorio nel caso in cui la lesione fisica coinvolga il solo aspetto fisico, che potrebbe ripercuotersi sulle possibilità di inserimento del soggetto nel mondo del lavoro (perdita di chance)
- **Il danno alla vita di relazione:** ristoro alle probabili perdite patrimoniali legate alle ridotte possibilità di contatti con i consociati

La soluzione illustrata si mostra insufficiente in quanto concentra attenzione sui soli riflessi reddituali della lesione all'integrità psico-fisica, non tiene conto in maniera esplicita della complessiva incidenza che una lesione ad una persona può avere sulle molteplici attività non produttive di reddito monetario che il soggetto svolge.

La soluzione a ciò è stata rinvenuta nel **danno biologico**, che è stato ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale e il sistema giuridico lo ha acquisito come strumento per assicurare una soddisfacente tutela risarcitoria in presenza di lesioni che riguardino la salute, che va risarcito a prescindere dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

Tuttavia ai fini della sua quantificazione è pur sempre necessaria una personalizzazione.

Il risarcimento del danno biologico implica necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso, quindi, in caso di letalità dell'incidente, il danno biologico non può abbracciare anche l'ipotesi della perdita della vita stessa (**danno tanatologico**).

Nell'ipotesi di incidente mortale, i congiunti possono agire per ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale da loro subito, sia dei danni non patrimoniali sofferti.

Per assicurare uniformità di valutazione del danno biologico che eviti disparità di trattamento, la giurisprudenza di legittimità ha fatto proprio il criterio fondato sul valore punti di invalidità adottato dai giudici di Milano (c.d. *tabelle di Milano*).

La giurisprudenza da un lato configura questa necessità di uniformare la valutazione ma esige anche che vengano prese in considerazione tutti gli aspetti e le voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce (danno biologico, danno morale in senso stretto, **danno esistenziale**, ovvero il peggioramento della qualità di vita della vittima).

Vi rientra anche il caso in cui l'illecito si traduca nella violazione di un **diritto della persona costituzionalmente protetto**, ai quali è sempre assicurata una tutela risarcitoria.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE E IN FORMA SPECIFICA

Nel sistema italiano, la tecnica di tutela nei confronti dei danni è costituita dal **risarcimento per equivalente**, che consiste nella traduzione in termini monetari dei pregiudizi subiti dal danneggiato, siano essi patrimoniali o non.

L'obbligazione risarcitoria da sempre vita a un **debito di valore**: ciò significa che il giudice è tenuto ad attribuire al danneggiato l'equivalente in monete del reale valore del bene o dei vantaggi di cui tale soggetto sia stato privato.

La prova circa l'esistenza del danno incombe sempre sul richiedente, tranne alcuni casi isolati dove il danneggiato è esonerato dall'onere della prova.

La **valutazione equitativa** da parte del giudice è limitata ai soli casi in cui l'entità del danno non può essere provata nel suo preciso ammontare.

Accanto al risarcimento del danno per equivalente, l'**art. 2058 c.c.** prevede che, a richiesta del danneggiato, la tutela risarcitoria si attui attraverso il **risarcimento del danno in forma specifica**. In questo caso si chiede la condanna del danneggiante alla rimozione a sua spese della situazione lesiva dell'altrui diritto, da attuarsi mediante l'eliminazione della causa del danno e il ripristino della situazione a com'era prima di subire il pregiudizio.

Per attuare il risarcimento del danno in forma specifica innanzitutto è indispensabile che ciò sia possibile e il ricorso a tale risarcimento non è ammesso qualora risulti eccessivamente oneroso per il debitore.

Il risarcimento in forma specifica rimane distinto dalla tutela reale, la quale non prevede il limite dell'onerosità eccessiva per il debitore.

Per quanto riguarda il **danno non patrimoniale**, il codice penale prevede la possibilità che il giudice adotti una specifica misura riparatoria a favore della vittima di un reato, che consiste nella pubblicazione a spese del responsabile della sentenza di condanna.

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE E CONTRATTUALE

L'obbligazione risarcitoria trova la sua fonte non soltanto nei fatti illeciti, ma anche nell'inadempimento di una obbligazione.

- L'inadempimento dell'obbligazione configura un'ipotesi di **responsabilità contrattuale**, qualunque sia la fonte da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
- Contrapposta vi è la **responsabilità extracontrattuale**, che ricomprende tutte le ipotesi di obbligazioni risarcitori che trovano fonte nel fatto illecito e che dunque escludono la violazione di un preesistente rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante tra le stesse parti.
- Da entrambe si differenzia la **responsabilità precontrattuale**, che interviene appunto quando tra le parti si è venuto a determinare un semplice contatto in vista della conclusione del contratto, che impone l'osservanza della buona fede.

La responsabilità contrattuale e extracontrattuale presentano differenti caratteristiche:

- Per quanto riguarda i criteri di imputazione: per la responsabilità extracontrattuale il sistema prevede molteplici criteri di imputazione (tra i quali la colpa), mentre quella contrattuale non trova certo il suo fondamento nella colpa.
- Onere della prova: nel fatto illecito extracontrattuale spetta al danneggiato provare innanzitutto che l'evento lesivo sia riconducibile, sulla base del nesso di causalità e criteri di imputazione, ad un terzo. Nel caso di inadempimento dell'obbligazione, l'onere della prova a carico del creditore riguarda semplicemente il fatto dell'inadempimento; spetterà poi al debitore, se intende sottrarsi alle conseguenze di legge, dimostrare di non aver potuto adempiere per impossibilità sopravvenuta della prestazione a lui non imputabile.

Per quanto riguarda la **responsabilità medica**, innanzi tutto occorre dire che la professione medica rientra nelle *obbligazioni di mezzi e non di risultato*, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento dello scopo.

Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

Mentre i **medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale**, e quindi ai sensi dell'art 2043 c.c., **le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale**, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione.

- Effetti giuridici: la responsabilità extracontrattuale prospetta una più ampia tutela al danneggiato rispetto a quella prevista per la responsabilità contrattuale. Infatti per quest'ultima il debitore risponde soltanto dei **danni prevedibili**, ossia dei pregiudizi subiti dal danneggiato che potevano essere previsti nel tempo in cui è sorto l'obbligazione da parte di un soggetto di normale diligenza. Il superamento della soglia della prevedibilità del danno è ammessa solo nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo siano conseguenti ad un comportamento doloso del debitore.
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale comporta che il danneggiante sia tenuto sempre a risarcire tutti i danni, sia prevedibili che non.
- Termine di prescrizione dell'azione diretta al risarcimento del danno: per il risarcimento del danno contrattuale trova applicazione il termine previsto per le azioni nascenti da contratto (quello ordinario decennale), mentre l'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale è di regola soggetta al termine di prescrizione più breve di 5 anni.
Esso decorre non già dal momento in cui è intervenuto il comportamento doloso o colposo, ma dal momento in cui è emerso il danno ingiusto.

La differenza di regime tra i due tipi di responsabilità impone di risolvere il problema se nel caso concreto ricorra un'ipotesi di *responsabilità contrattuale o extracontrattuale*; l'interrogativo si è prospettato in particolare nelle seguenti fattispecie, dove la giurisprudenza ha chiarito il proprio orientamento:

- Obblighi di protezione: natura contrattuale della responsabilità in quanto sono ritenuti corollari della prestazione principale. Stessa conclusione anche per quanto riguarda l'ipotesi di obbligazioni senza prestazione.
- Responsabilità precontrattuale: per anni si era pronunciata la sua responsabilità extracontrattuale, in quanto ancora non si è perfezionato il contratto. Ma ultimamente la giurisprudenza sembra essersi orientata nel senso opposto ravvisandovi un'ipotesi di "contratto sociale qualificato".
- Rapporti contrattuali di fatto: in caso di condotta lesiva posta in essere da una delle parti vi è l'applicazione del modello di responsabilità contrattuale, ritenendo che tra gli interessi sorga comunque un rapporto obbligatorio da "contratto sociale qualificato".

Inoltre, un medesimo fatto, può costituire sia inadempimento di un'obbligazione, sia fatto illecito dannoso. Così la giurisprudenza ammette il c.d. **concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale**, lasciato al danneggiato la facoltà di scegliere se agire in via contrattuale o in via aquiliana.

RESPONSABILITA' CIVILE E TUTELA ASSICURATIVA

Abbiamo già detto che con lo sviluppo tecnologico si è sviluppata la possibilità di produzione di danni.

Ciò ha indotto le imprese ad adottare misure per prevenire il prodursi di lesioni a terzi e fronteggiare i costi mediante il ricorso a **contratti di assicurazione**.

Questo, più che ridurre i sinistri ha realizzato una sicurezza circa la possibilità che il danneggiato ottenga il risarcimento dei pregiudizi sofferti.

Ciò ha indotto il legislatore a prevedere ipotesi di assicurazione obbligatoria, penalmente sanzionata ove non rispettata (es. *assicurazione per gli infortuni sul lavoro, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione*); il danneggiato ha così la possibilità di rivolgersi direttamente all'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti, nei limiti, ovviamente, del massimale previsto nel contratto e sempre se sussista la responsabilità.

CAPITOLO XVIII

IL CONTRATTO:

I REQUISITI E LA FORMAZIONE

IL CONTRATTO

L'ordinamento giuridico riconosce ai privati, seppure a certe condizioni ed entro certi limiti, il potere di **autoregolare** i propri interessi economici, attraverso lo strumento del **contratto**.

Gli individui e gli enti devono entrare in relazione tra loro, al fine di scambiare beni e servizi e cooperare per la realizzazione di un obiettivo comune, e l'incontro di queste volontà producono effetti rilevanti per il diritto.

Il contratto è una delle fonti delle obbligazioni (art 1173 c.c.): dalla sua valida stipulazione trae origine un vincolo giuridico che legherà le parti, obbligando entrambe o una di esse a un comportamento (dare, fare, non fare) a vantaggio dell'altra parte che vanterà al riguardo una pretesa.

La funzione del contratto è esplicitata dall'**art 1321 c.c.: il contratto è l'accordo di due o più parti diretto a costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.**

Vediamo innanzitutto che nell'ampia categoria degli atti giuridici, il contratto rientra tra i **negozi giuridici**, ma si caratterizza per:

- La necessaria presenza di almeno due parti; il contratto è così un negozio necessariamente **bilaterale o plurilaterale**. Il **contratto unilaterale** è comunque contratto con la presenza di due parti, infatti l'unilateralità si riferisce al solo profilo del rapporto obbligatorio: il contratto si dice unilaterale quando da esso sorgono obblighi a carico di una sola parte.
- La **patrimonialità**, la quale non caratterizza l'interesse della parte, che può essere di varia natura, ma devono essere suscettibili di valutazione economica gli impegni assunti e le conseguenze prodotte nella sfera giuridica delle parti.

Fuori dal campo dei rapporti patrimoniali non può mai parlarsi di contratto. Non è contratto ma negozio giuridico il **matrimonio**; è invece considerato contratto il **contratto di convivenza**, con cui i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

La maggior parte dei rapporti giuridici patrimoniali tra vivi si costituisce, modifica o estingue per contratto: la legge tuttavia non esclude che anche una manifestazione unilaterale di volontà possa produrre effetti giuridici di natura patrimoniale. È il caso dell'art 1324 c.c., che fa riferimento agli *atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale*, al fine di estendervi la disciplina del contratto solo se diretti a produrre effetti quando chi li ha posti in essere è in vita e se gli interessi che tendono a realizzare sono economicamente apprezzabili (pertanto è escluso il testamento).

Nelle espressioni usate dal legislatore il termine contratto si presta ad indicare sia l'atto di autonomia privata, cioè l'accordo, sia il testo del documento contrattuale, nel quale è versato tale accordo, sia il regolamento contrattuale che da quell'accordo discende e dunque il rapporto giuridico sui cui l'accordo interviene.

Quando però si parla dell'esecuzione del contratto e degli effetti giuridici da esso prodotti appare più corretto riferirsi al **rapporto contrattuale**: ovvero i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo, le vicende del rapporto giuridico di cui l'accordo è fonte.

Le singole previsioni nelle quali si articola e si specifica l'accordo costituiscono le **clausole del contratto**, le quali vanno considerate unitariamente e nel loro complesso: da qui la regola secondo cui *esse si interpretano le une per mezzo delle altre* (art 1363 c.c.); sono inoltre suscettibili di una considerazione separata: la nullità di una singola clausola non travolge l'intero contratto quando risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza questa parte.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO TRA AUTONOMIA PRIVATA E LEGGE

Il principio che sta alla base della disciplina del contratto è quello dell'**autonomia contrattuale**, ovvero la libertà dei privati, salvi i limiti previsti dalla legge, di autoregolare i propri rapporti economici attraverso appunto il contratto.

L'**art 1322** fa espresso riferimento all'autonomia contrattuale:

«Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.»

Dal secondo comma si evince che è consentito ai privati concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, cioè **contratti atipici**, con l'unico limite che devono essere volti a perseguire scopi compatibili con le strutture dell'ordinamento giuridico.

A rafforzare il principio sancito dall'art 1322 è l'**art 1372** circa l'**efficacia del contratto** che afferma che *il contratto ha forza di legge tra le parti*, cioè il potere di darsi da sé delle regole vincolanti di forza pari a quella della legge, ma, salvo i casi previsti dalla legge, *il contratto non produce effetto rispetto a terzi*, quindi il vincolo vale solo per le parti che l'hanno voluto.

Con l'autonomia privata i privati sono liberi di decidere se stipulare un contratto, *quando, come e con chi*, anche se la maggiore espressione dell'autonomia contrattuale è ovviamente la scelta del **tipo contrattuale** e soprattutto del contenuto. Le parti possono decidere anche sulle cause di scioglimento (es. **clausola risolutiva espressa**, che prevede la risoluzione in via stragiudiziale per un inadempimento previsto) o sulle conseguenze dell'inadempimento (**clausola penale**).

La disciplina dei contratti è affidata a norme dispositive, che possono essere cioè derogate dalle parti e a norme suppletive, cioè che svolgono una funzione di supplenza nel caso in cui un aspetto del contratto non sia stato determinato dalle parti.

Ma l'autonomia contrattuale incontra dei **limiti** in **norme inderogabili** e **imperative**. Ad esempio alcuni accordi sono vietati dalla legge, ma il controllo più penetrante dell'ordinamento è la verifica sull'esistenza e liceità della causa.

Le parti possono inserire nel contratto clausole limitative della responsabilità per violazione delle obbligazioni nascenti dal contratto, ma non escludendo anche la responsabilità per dolo o colpa grave.

Anche l'apposizione di un termine alla durata del contratto certe volte un termine minimo può essere previsto dalla legge con una norma inderogabile, con la conseguenza che una eventuale clausola pattizia che preveda un termine inferiore da quello minimo sarà nulla e sostituita di diritto dalla regola di fonte legale. In questo caso si è in presenza di una **integrazione cogente** della volontà dei privati, ovvero quando viene applicata la disciplina legale in sostituzione di quella prevista dalle parti.

Diverso è il regime delle c.d. **clausole d'uso**, le quali intervengono a completare il contenuto del contratto a meno che le parti non abbiano espresso una volontà contraria, quindi non si tratta di integrazione cogente.

È diverso anche l'operare delle c.d. **clausole di stile** che vengono inserite nell'accordo dalle parti, ma che non esprimono una specifica volontà delle parti, ma solo un modo formale di completare l'atto nella sua veste stilistica. Esse sono pertanto inefficaci o nulle per indeterminatezza dell'oggetto.

A fronte della generale **libertà di forma** la legge può imporre che il contratto sia stipulato con una determinata forma, a pena di nullità.

Per quanto riguarda invece la libertà di contrarre, la legge pone a carico dell'imprenditore che svolge la sua attività in regime di monopolio legale un **obbligo di contrarre** con chiunque lo richieda. Inoltre, la scelta dell'altro contraente non è libera nei casi di **prelazione legale** (diritto di preferenza di un soggetto rispetto a un altro).

Non può ricondursi nell'ambito dei limiti posti dalla legge all'autonomia privata l'**integrazione degli effetti** del contratto di cui all'**art 1374 c.c.**, la quale interviene a completare gli effetti del contratto per la parte non regolata dall'autonomia privata e appunto sancisce che *il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità*.

Quindi in definitiva, il contratto, pur essendo espressione dell'autonomia dei privati, non vive fuori dalla legge, ma anzi prescinde da essa. Infatti se l'accordo di due o più parti produce degli effetti giuridici, è pur sempre l'ordinamento giuridico che termina i presupposti e le condizioni affinché l'atto di autonomia privata possa produrre tali effetti e ciò lo rende esplicito l'**art 1325 c.c.** che indica quali **requisiti** debba avere l'atto di autonomia per definirsi contratto.

In ciascun ordinamento i limiti all'autonomia privata possono essere diversamente individuati come può variare anche la disciplina generale del contratto, per questo è necessario stabilire quale legge si applichi al contratto.

Il problema non si pone tra soggetti che appartengono al medesimo Stato, ma quando le parti contraenti hanno diversa nazionalità (**contratti transfrontalieri**).

In Italia la legge rinvia alle regole contenute in una fonte internazionale, vale a dire la **Convenzione di Roma del 19 giugno 1980**.

Il principio generale è quello della libertà di scelta: il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

Se nessuna scelta viene espressa dalle parti, la legge che regola il contratto sarà individuata per il tramite dei **criteri di collegamento**:

- Se il contratto ha come oggetto il diritto reale/di utilizzazione su un bene immobile si applicherà la legge del Paese in cui l'immobile è situato.
- In caso di vendita di beni mobili si fa riferimento alla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale.
- Quando non è rintracciabile uno di tali criteri di collegamento sarà decisiva la residenza abituale del debitore.

Considerando le **fonti del diritto** secondo la loro gerarchia:

- COSTITUZIONE: possiamo dire che l'autonomia contrattuale è regolata indirettamente dalla nostra costituzione, in quanto strumento di esercizio di altre libertà costituzionalmente garantite, come quella dell'iniziativa economica e la proprietà. *I principi costituzionali costituiscono piuttosto la cornice entro la quale deve esprimersi l'autonomia contrattuale.*
- LEGGE DELLO STATO: è considerata la fonte principale di regolazione del contratto, in quanto è legge ordinaria anche il codice civile, il cui Libro quarto contiene il nucleo fondamentale della disciplina del contratto.

- DIRETTIVE UE: esse vengono a far parte dell'ordinamento italiano per tramite di una delega e attraverso questo procedimento sono entrate a far parte dell'ordinamento interno le discipline riguardanti in maniera particolare i contratti tra professionisti e consumatori.
- REGOLAMENTI: nella materia del contratto rileva in particolare il potere regolamentare attribuito alle autorità amministrative indipendenti, quali la CONSOB o l'AGCM.

Come già sottolineato, il contratto è lo strumento consegnato ai privati per regolamentare tra di essi gli scambi e gli interessi economici. Lo svolgimento delle attività economiche sul mercato non è però lasciato alle sole autonome determinazioni dei privati: l'ordinamento giuridico interviene in funzione di correzione/regolamentazione dei rapporti di mercato.

CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI

Come si è già detto, l'art 1322 al comma 2 precisa che ai privati è consentito anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, cioè **contratti atipici**, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

I **contratti tipici** sono quelli previsti e disciplinati espressamente dal legislatore, e per essere tipico un contratto non basta che sia solamente richiamato (**contratto nominato**), ma deve esserci una disciplina completa, ferma la possibilità delle parti, laddove possibile, di aggiungere o modificare tale contenuto legale.

La disciplina dei contratti tipici è affidata, come già detto, in linea generale, a norme dispositive che svolgono un funzione di norme suppletive quando un aspetto del regolamento contrattuale non sia stato determinato dall'accordo delle parti.

Solo quando sono in gioco interessi generali e principi fondamentali, l'autonomia contrattuale trova limiti in norme inderogabili o imperative.

I **contratti atipici** sono contratti che non sono previsti dal legislatore e che magari sono socialmente riconosciuti, ed è possibile ricorrere anche a questi schemi con un limite, ovvero che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Il **controllo di meritevolezza** per il contratto tipico è fatto a monte, quindi si dà per scontato che nel momento in cui si ricorre a un contratto tipico quel contratto in astratto persegue interessi meritevoli di tutela. Per quanto riguarda i contratti atipici il controllo viene fatto a valle e viene effettuato dal giudice.

Il contratto atipico pone inoltre un problema di qualificazione, in quanto il giudice dovrà cercare di costruire cosa le parti hanno in concreto voluto e da qui verificare se è possibile o meno risalire ad un tipo contrattuale.

Il contratto atipico, spesso, è il risultato della combinazione di più schemi o tipi contrattuali: in tal caso si è in presenza di un **contratto misto**. Il contratto è comunque unico e ha un'unica causa, ma essa non rimanda a una delle fattispecie tipiche bensì ad elementi di tipi contrattuali tra loro combinati.

I criteri che si prospettano in questo caso per rintracciarne la disciplina sono:

- **Criterio di combinazione**: in base al quale al contratto si applicherà, tenuto conto dei suoi contenuti, la disciplina di tutti i tipi contrattuali che vi risultano combinati.
- **Criterio dell'assorbimento**: ove sia rintracciabile un tipo di riferimento comunque prevalente.

L'art 1323 c.c. conferma l'applicabilità della disciplina generale del contratto ai contratti atipici e da per implicito una conferma della scontata sottoposizione a tale disciplina generale anche ai contratti tipici.

Tale regola va a delineare un rapporto da *genus a species* tra le disposizioni riferite a *i contratti in generale* di cui al Titolo II del Libro quarto e quelle *particolari* contenute nel Titolo III.

All'interno delle discipline particolari si delinea la fisionomia dei singoli contratti tipici.

DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO E REGOLE PARTICOLARI PER I CONTRATTI DEL CONSUMATORE

A partire agli anni 80 la legislazione europea ha iniziato ad occuparsi dei consumatori e ha iniziato ad emanare delle direttive che si sono occupate di pressoché tutti gli aspetti del contratto del consumatore, che il nostro ordinamento ha recepito nel Codice del Consumo.

Il contratto in questione presuppone che come parti sia abbiano:

- Un consumatore o utente: persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale
- Un professionista: è la persona giuridica o fisica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Il contratto del consumatore deve considerarsi una peculiare tipologia di negozio a cui si applica, oltre alla disciplina generale del contratto, quella speciale prevista dal Codice del Consumo.

L'intervento di fonte europea su tali contratti non è quasi mai stato un intervento trasversale (cioè riferito a tutti i contratti tra professionista e consumatore), ma piuttosto si è focalizzato su taluni contratti o modalità di conclusione dei contratti, questo vuol dire che hanno un ambito di applicazione riferito a tutti i contratti stipulati tra professionisti e consumatori, ma solo quando si rintraccino particolari modalità di conclusione del contratto, vale a dire si tratti di **contratti negoziati fuori dai locali commerciali** o di **contratti stipulati a distanza**.

Tali interventi prevedono regole di "protezione" a beneficio della parte ritenuta meno forte e identificano in maniera diversa la controparte del professionista a seconda della natura del contratto stipulato: **cliente** (nei contratti bancari), **investitore** (nei contratti per la negoziazione di strumenti finanziari), **viaggiatore** (nei contratti per il godimento di servizi turistici).

L'unica disciplina trasversale riferita dunque *ai contratti del consumatore in generale*, quindi destinata a regolare qualsiasi contratto concluso tra consumatore e professionista a prescindere dal tipo e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, è rimasta a lungo quella in materia di **clausole vessatorie**, considerata clausole squilibranti e che hanno come rimedio la nullità.

Altri aspetti caratterizzanti della disciplina dei contratti di consumo sono:

- La rilevanza del **principio di trasparenza contrattuale**, da cui discende l'imposizione di rigorosi e dettagliati obblighi di informazione precontrattuale a carico del professionista.
- L'attribuzione al consumatore del potere di sottrarsi ad un vincolo assunto senza adeguata ponderazione, mediante l'esercizio di un **diritto di recesso libero**.

I REQUISITI DEL CONTRATTO

Perché si abbia un contratto validamente costituito non basta l'accordo come definito dall'art 1321 c.c., ma occorre che siano presenti tutti i requisiti indicati dall'**art 1325 c.c.** che possono definirsi come **elementi essenziali**, e sono:

- **L'ACCORDO DELLE PARTI**
- **LA CAUSA**
- **L'OGGETTO**
- **LA FORMA, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità**

La mancanza di tali elementi, o anche uno soltanto tra essi, o la loro non conformità ai caratteri che devono per legge rivestire costituisce **causa di nullità** del contratto ai sensi dell'**art 1418 c.c.**

L'ACCORDO E LE PARTI

Perché il contratto sia concluso e produttivo di effetti occorre che sia rintracciabile il requisito dell'**accordo**, cioè l'incontro di due o più volontà validamente espresse.

A differenza degli altri casi di nullità per assenza di uno dei requisiti, la mancanza di accordo (non l'illiceità) rende irrintracciabile un vero e proprio contratto.

La volontà negoziale deve essere espressa dal soggetto che abbia la capacità di compiere atti giuridici, cioè la capacità di agire, e deve essersi formata liberamente e senza condizionamenti di sorta.

La disciplina dei vizi della volontà (errore, violenza, dolo) interviene ad assicurare tale libertà, consentendo alla parte che abbia prestato il suo consenso a seguito di uno di questi vizi di chiedere l'annullamento del contratto.

Ovviamente per avere un accordo è necessaria la presenza delle **parti del contratto** e la loro manifestazione di volontà.

Il concetto di parte del contratto non si riferisce ai soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale, ma ai centri di interesse. Può essere parte di un contratto una persona fisica o giuridica.

Purché il contratto sia valido occorre che chi lo stipula sia in possesso della **capacità legale di contrattare**, a cui fa riferimento l'**art 1425 c.c.**, che fa riferimento alla generale capacità di agire, che si acquista con la maggiore età e si perde a seguito di interdizione giudiziale o legale e subisce limitazioni a seguito di inabilitazione o provvedimenti di amministrazione di sostegno.

La dottrina da tempo giustifica la validità degli atti della vita quotidiana posti in essere dal minore, richiamando il fatto che il minore che compie un acquisto sarebbe in questo caso rappresentante del genitore (con riferimento all'art 1389 c.c. ai fini della validità del contratto concluso dal rappresentante).

L'ordinamento inoltre consente l'annullamento dei contratti conclusi da chi, pur legalmente capace di contrarre, si trovi in stato di **incapacità naturale**, cioè di **incapacità di intendere e di volere** al momento in cui ha compiuto l'atto.

Il termine **accordo** indica l'incontro delle due o più volontà, che può avvenire con modalità diverse, ma il codice civile si preoccupa di fissare delle regole in base alle quali può dirsi avvenuto l'incontro delle volontà quando le parti sono lontane. Secondo l'**art 1326 c.c.** il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'individuazione del momento nel quale l'accordo tra le parti può dirsi raggiunto non è sempre agevole, per questo l'ordinamento non appunta la sua attenzione solo sui modi di conclusione dell'accordo, ma dà rilevanza anche alla fase che la precede, delle trattative.

TRATTATIVE E RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art 1337 c.c. le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e il comportamento da osservare in questa fase è fonte di **responsabilità precontrattuale**.

Una fattispecie specifica prevista dal nostro codice di responsabilità precontrattuale è l'obbligo in carico alla parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, a risarcire il danno da questa risentito.

È importante fare la differenza tra:

- Fase di definizione del contratto: nella quale prendono corpo proposta e accettazioni e dove si sta andando definendo l'accordo.
- Fase delle trattative: fase che precede, in cui le parti, pur intendendo volgersi alla stipulazione del contratto, non pongono ancora in essere alcuni di quegli atti in cui possano individuarsi i caratteri di una proposta e di una accettazione.

L'obbligo che incombe in capo a ciascun contraente è quindi di comportarsi secondo **buona fede**, intesa in **senso oggettivo**, cioè di tenere cioè una condotta conforme ai parametri di correttezza e lealtà nel momento delle contrattazioni e l'obbligo delle parti di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi.

È considerata una violazione dell'obbligo di buona fede:

- **Rottura ingiustificata delle trattative**, cioè se lo svolgimento delle trattative è stato tale da determinare nella parte un affidamento sulla positiva conclusione e dunque sulla stipulazione del contratto, allora la parte che recede dalle trattative in mancanza di giusta causa sarà tenuta a risarcire i danni alla controparte, quale responsabilità precontrattuale.
- Violazione dell'**obbligo di corretta informazione e trasparenza**, che impone alla parte di fornire alla controparte tutti i dati di cui essa sia a conoscenza rilevanti ai fini della stipulazione del contratto.

Gli obblighi di trasparenza sembrano così essere passati dal profilo specifico delle discipline relative i contratti di consumo a essere connotato proprio della disciplina generale del contratto.

L'obbligo informativo ovviamente non può essere esteso fino al punto da imporre al contraente di esplicitare anche i motivi e le convenienze proprie per cui si intende stipulare il contratto.

Nel caso di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è di regola identificato con il c.d. **interesse negativo**, che comprende oltre alle spese sostenute per la trattativa (danno emergente) la perdita di altre occasioni (lucro cessante), ma non può coprire i mancati profitti che sarebbero derivati da un contratto non concluso oppure invalido (in caso di rottura ingiustificata delle trattative), in quanto la trattativa obbliga solo a comportamenti leali e corretti, ma non a giungere comunque alla conclusione del contratto.

La violazione di questi obblighi assume rilievo con la conseguente responsabilità anche quando il contratto posto in essere sia valido, quindi già concluso e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto.

In questo caso la responsabilità è pur sempre responsabilità precontrattuale, ma cambia il criterio di quantificazione dei danni: il risarcimento dovrà tener conto della circostanza che il contratto è stato stipulato a condizioni diverse da quelle in cui sarebbe stato stipulato senza l'interferenza del comportamento scorretto.

Quindi di solito nelle trattative le parti discutono il contenuto del futuro contratto e ciascuna di esse cerca di strappare le condizioni che reputa per sé più vantaggiose. Ma questo procedimento non può essere sempre adottato per esempio quando si tratta di contratti di massa, cioè contratti che un'impresa conclude con un gran numero di persone: in questi casi è ovvio che l'impresa non può mettersi a discutere con ciascun cliente circa le condizioni del singolo rapporto.

Allora queste imprese predispongono moduli o formulari contrattuali, nei quali inseriscono clausole uniformi e standardizzate, si parla in questo caso di **condizioni generali di contratto** (art 1341 c.c.). Da qui la diffusa prassi di definire questi contratti *per adesione*, in quanto il cliente non può negoziare: o aderisce o rifiuta.

Ovviamente ci sono delle condizioni:

- Queste condizioni generali di contratto sono efficaci solo se la parte che le ha predisposte abbia fatto in modo di garantire che l'altro contraente le conoscesse o fosse in grado di conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- Per l'efficacia delle clausole vessatorie è richiesta una specifica, puntuale approvazione scritta delle medesime

La protezione del contraente aderente ad un regolamento contrattuale da altri predisposto è stata fortemente incrementata nel caso in cui l'aderente sia un consumatore, in quanto gli scambi tra questo e il professionista si caratterizzano sempre per l'irrintracciabilità di una trattativa.

In questo caso grava sul professionista un obbligo di informazione precontrattuale in ordine a una serie di elementi, per esempio le caratteristiche principali dei beni e servizi, il prezzo totale, la sua identità, ecc...

È posto a carico del professionista l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi di informazione precontrattuale.

Nel caso di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, più che di informazione sarebbe corretto parlare di *comunicazione*, in quanto gli elementi oggetto di informazione non possono essere in questi contratti liberamente e unilateralmente modificati da chi li ha forniti, occorrendo un accordo espresso dalle parti.

VINCOLI, UNILATERALI E BILATERALI, NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Dal principio di libertà contrattuale discende che le parti non sono in alcun modo vincolate né a concludere il contratto né alle obbligazioni da questo derivanti finché l'accordo non sia stato validamente stipulato.

Colui il quale manifesta la volontà di giungere alla conclusione di un contratto, formulando quindi una **proposta**, potrà sempre revocarla, seppure prima che con l'accettazione dell'altra parte il contratto sia concluso. Ma il proponente può autolimitare la propria libertà di revocarla, attraverso la **proposta irrevocabile** (art 1329 c.c.): in questo modo il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo e, dunque, in quel periodo la revoca è senza effetto.

In questo caso si ha un vincolo unilaterale, a carico del solo proponente.

Non molto diversa è l'**opzione** (art 1331 c.c.) che anche in questo caso si tratta di un vincolo unilaterale; infatti le parti convengono, con il **patto di opzione**, che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione, mentre l'altra abbia la facoltà di accettarla o meno: in questo caso la *dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile*.

Il **diritto di prelazione** consiste nel diritto di essere preferiti ad altri nella conclusione di un contratto e può essere:

- **Prelazione convenzionale/patto di prelazione:** si tratta di un contratto con il quale una parte si obbliga a preferire l'altra nella stipulazione di successivi contratti. La legge limita a cinque anni il termine di durata dell'obbligo a carico del prelazionante e un termine superiore non sarà valido.
- **Prelazione legale:** strumento previsto dalla legge per favorire una circolazione mirata verso determinati soggetti di alcuni beni e si inquadra, come precedentemente detto, tra i limiti legali all'autonomia privata.

La fonte legale rende più forte il vincolo, ma solo nei confronti di terzi: infatti, sia nel caso di prelazione legale, sia nel caso di prelazione convenzionale il vincolo riguarda solo la scelta del contraente, mentre le condizioni del contratto saranno quelle decise dall'obligato che dovrà sottoporre all'avente diritto alla prelazione, che potrà accettarle o meno.

Tuttavia, se nella prelazione convenzionale gli effetti obbligatori rimangono nella sfera delle parti, e dunque un contratto stipulato con un terzo in violazione dell'obbligo convenzionale di prelazione rimarrà valido, quando la prelazione ha la sua fonte nella legge è accompagnata dal carattere dell'opponibilità a terzi, cioè l'avente diritto alla prelazione legale potrà agire per sostituirsi nel contratto che l'obligato abbia stipulato con il terzo violando l'obbligo di prelazione.

Il più diffuso tra i negozi preparatori è il **contratto preliminare**. Il codice a riguardo si limita a regolarne la forma, con riferimento a quella prevista per il contratto definitivo.

Ricorrendo a tale figura le parti si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (**il contratto definitivo**) e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali del definitivo.

In questo modo si assicurano che il reciproco impegno sia giuridicamente rilevante e gli aspetti essenziali del futuro contratto siano fissati.

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all'obbligazione, il preliminare potrà condurre alla produzione degli effetti del definitivo per il tramite di una sentenza costitutiva, invocata dalla parte che voglia addivenire al definitivo, malgrado la indisponibilità dell'altra.

Lo strumento del contratto preliminare si è manifestato assai utile specie nella contrattazione immobiliare: diffusissimo è il **preliminare complesso o ad effetti anticipati**, che si tratta, in sostanza, di un contratto in cui le parti anticipano alcuni degli effetti del definitivo fin dal momento della stipula del **preliminare**, per esempio le parti pattuiscono che già in funzione del preliminare il promissario acquirente sia immesso nel godimento del bene a fronte del pagamento di acconti sul prezzo.

È ammessa anche la figura del **preliminare unilaterale**, allorché le parti concordano che solo una di esse è obbligata verso l'altra al contratto.

Nella prassi è nata anche la figura del c.d. **contratto preliminare di preliminare**, significa che viene concluso preliminarmente un accordo al quale seguirà la stipula del **contratto preliminare**.

La giurisprudenza di legittimità in un primo momento ha escluso l'ammissibilità di tale contratto, rintracciando nel primo contratto un'inutile ripetizione del secondo e quindi nullo per mancanza di causa.

Ma con la moderna accezione della causa del contratto come causa concreta si è puntualizzato che potrà parlarsi di preliminare di preliminare solo nei casi in cui il secondo contratto sia volto alla mera ripetizione del primo con identici contenuti.

Quindi si ha la sequenza contratto preliminare di preliminare - contratto preliminare - contratto definitivo.

Il primo contratto si può dire che ha ad oggetto un *obbligo di contrattare*.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Stabilire in quale momento l'accordo si è perfezionato è evidentemente agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo, è più complicato quando le trattative si svolgono o in tempi successivi o tra persone lontane.

In questo caso, nel procedimento di formazione del contratto, due sono gli atti fondamentali: uno è quello con il quale il procedimento medesimo s'inizia, la **proposta**, l'altro è quello con cui si chiude, l'**accettazione**.

Essi sono atti unilaterali recettizi, perché producono effetto da quando giungono a conoscenza del destinatario, formativi di un negozio giuridico, il contratto.

Quando alla proposta segue l'accettazione allora si ha l'accordo. Affinché ciò accada occorre:

- a) l'accettazione deve pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello necessario, secondo la natura dell'affare o gli usi
- b) la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata deve essere conforme alla proposta (non ci devono essere variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa) per il principio secondo il quale "un'accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta"
- c) l'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente

L'art 1326 c.c. stabilisce che *il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (il proponente) ha conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della controparte.*

Questo articolo è da leggere in combo con l'art 1335 c.c., il quale stabilisce una generale **presunzione** secondo la quale la proposta e l'accettazione si reputa conosciuta non appena giunta all'indirizzo del destinatario; graverà su quest'ultimo l'onere di provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

La proposta e l'accettazione possono essere ritirate e private di effetto mediante la **revoca**, almeno che, come già visto, il proponente non si autolimiti la propria libertà di revoca con la proposta irrevocabile: l'irrevocabilità assicura anche la sopravvivenza della proposta alla morte se il suo autore.

L'art 1328 c.c. tratta distintamente della revoca rispettivamente della proposta e dell'accettazione. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, mentre per quanto riguarda la revoca dell'accettazione essa non ha effetto se non giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga l'accettazione.

La revoca della proposta è considerata come atto non recettizio e pertanto essa impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte: quindi non è necessario che la revoca giunga a conoscenza dell'accettante prima di quel momento, mentre la revoca dell'accettazione deve giungere a conoscenza del proponente prima che allo stesso giunga l'accettazione.

Vale sempre la presunzione di conoscenza disposta dall'art 1335 c.c.

L'eventuale iniziata esecuzione della prestazione da parte dell'accettante prima della conclusione del contratto e della ricezione della dichiarazione di revoca della proposta, se avvenuta in buona fede, fa sorgere il diritto dell'accettante di essere rimborsato dei costi sostenuti e delle perdite subite.

La proposta perde automaticamente efficacia se, prima che il contratto si sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace. Del pari perde efficacia l'accettazione se l'accettante muore o diventa incapace nell'intervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e l'arrivo di questa al proponente.

Con riguardo alla conclusione del contratto occorre far la differenza tra:

- **contratti consensuali:** dove il consenso, dunque la volontà delle parti, è sufficiente perché nasca il vincolo
- **contratti reali (mutuo, deposito, comodato, pegno, riporto):** qui il contratto si perfeziona con la consegna, ma la consegna non sostituisce la manifestazione del consenso, ma si aggiunge come requisito in più.

La prassi riconosce meccanismi assai più articolati di conclusione del contratto:

- **contratto concluso mediante esecuzione (art 1327 c.c.):** in questo caso non si ha la necessità di una preventiva accettazione da parte dell'oblato (destinatario della proposta) e il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione; questo è possibile solo quando:
 - lo richieda il proponente
 - lo imponga la natura dell'affare
 - sia previsto dagli usi

Dell'inizio dell'esecuzione l'accettante dovrà tempestivamente informare il proponente e in mancanza sarà tenuto al risarcimento del danno. Ovviamente anche in questo caso occorre la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta.

Questo modo di conclusione del contratto non può riguardare i **contratti formali**, per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità.

Inizio di esecuzione e **silenzio**, pur essendo entrambi dei comportamenti concludenti dell'oblato, sono due figure alternative, infatti di fronte ad una proposta l'oblato potrà dare inizio all'esecuzione o potrà rimanere inerte e silente. Solo nel primo caso si avrà un comportamento che conduce alla conclusione del contratto, mentre nel secondo caso va escluso che il silenzio dell'oblato equivalga ad assenso.

- **Contratto con obbligazioni del solo proponente (art 1333 c.c.):** un altro caso di contratto che prescinde dalla preventiva accettazione è previsto per i contratti unilaterali, dai quali cioè discendono obbligazioni soltanto in capo al proponente. In questo caso, nel momento in cui la proposta entra nella sfera di conoscenza dell'oblato diventa **irrevocabile** e porta alla conclusione del contratto, almeno che il destinatario non la rifiuti nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. È fatta salva la possibilità per l'oblato anche di evitare la conclusione del contratto esprimendo il proprio rifiuto.
- **Contratti stipulati con a distanza:** il codice del consumo definisce il contratto a distanza come *qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso*.

In questo caso vige sul professionista l'obbligo di fornire o mettere a disposizione del consumatore tutte le informazioni, quali le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista; l'indirizzo del professionista e il suo numero di telefono, il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione.

Inoltre, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore mediante invio delle caratteristiche principali dell'offerta su supporto cartaceo o comunque su supporto durevole. Il consumatore resta

vincolato nei confronti del venditore solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Infine è sempre necessario che il professionista fornisca al consumatore tutte le informazioni inerenti al contratto in copia scritta del contratto o su altro supporto durevole entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto.

- **Contratto negoziato fuori dai locali commerciali:** è il contratto tra consumatore e professionista che si presume non avvenga su iniziativa del consumatore, ma bensì dal professionista (carattere differenziale tra questo tipo di contratto e il contratto a distanza). Quindi non è il consumatore che si reca nei locali commerciali spinto dalla decisione di procurarsi il bene o il servizio, ma è il professionista che intercetta in qualche modo il consumatore. Si definisce negoziato fuori dai locali commerciali quando si conclude in un luogo diverso dai locali del professionista, ovvero l'immobile dove il professionista in modo permanente esercita la sua attività sia il locale mobile in cui la eserciti a carattere abituale.

Anche in questo caso il professionista è tenuto al rispetto di obblighi particolari e sia in questo caso che nel contratto a distanza il consumatore ha poi un margine di tempo adeguato per esercitare il **diritto di recesso** senza subire costi o penali o dover dare una giustificazione.

- **Offerta al pubblico (art. 1336 c.c.):** si tratta di una proposta che non si rivolge ad un destinatario determinato ma ad una platea più o meno vasta. In questo caso il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione di qualunque interessato giunge a conoscenza del proponente. Quest'ultimo può revocare la proposta in qualsiasi momento prima della conclusione del contratto, ma la revoca è efficace solo se effettuata con le stesse modalità comunicative con cui è avvenuta l'offerta.
- **Contratti per adesione:** altra modalità di conclusione particolare, dove ulteriori parti, oltre quelle che vi hanno dato vita, possono aderire successivamente al contratto, presentando una struttura aperta. Si tratta di contratti plurilaterali.

LA RAPPRESENTANZA

L'istituto della rappresentanza, nella sua versione propria, vale a dire di **rappresentanza diretta** si ha quando l'incaricato (**rappresentante**) potrà impegnare la sfera giuridica altrui (**rappresentato**) e, dunque, concludere un contratto non solo nell'interesse ma altresì in nome del rappresentato, in quanto ne abbia ricevuto il potere di rappresentanza.

L'art 1387 c.c. ne indica le fonti: *il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall'interessato*. Da qui la distinzione tra:

- **Rappresentanza legale:** è posta dalla legge per il compimento di atti giuridici di soggetti privi della capacità di agire (minori, interdetti) ed è la legge a regolarla, definendo anche gli ambiti di potere.
- **Rappresentanza volontaria:** che invece trova fonte nell'autonomia privata

Parzialmente diverso è il regime della **rappresentanza organica**, qui gli organi dell'ente compiono atti giuridici in nome e per conto dell'ente stesso: pare evidente che non rientra nel concetto di rappresentanza, l'organo, infatti, non è un rappresentante dell'ente, ma è parte di esso; tant'è che il rapporto tra organo e ente si definisce anche come di immedesimazione organica.

Nella rappresentanza volontaria si ha un rapporto giuridico tra rappresentante e rappresentato da cui trae origine l'incarico, la remunerazione, la durata ecc...e il contratto potrà essere validamente stipulato in nome del rappresentato solo se il rappresentante ne avrà ricevuto il potere del rappresentato mediante il negozio di **procura** e avrà reso noto tale potere alla controparte, dunque avrà dichiarato in nome di chi contratta (**spendita del nome**).

Il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Nel caso in cui l'intermediario non ha potere di spendere il nome dell'interessato si parla di **rappresentanza indiretta**. In questo caso l'incaricato non potrà che stipulare contratti a proprio nome che produrranno dunque effetti esclusivamente nella sua sfera giuridica. Sarà in conseguenza del contratto con cui gli è stato conferito l'incarico di agire nell'interesse altrui che dovrà ritrasferire nella sfera giuridica dell'interessato gli effetti del contratto che egli ha stipulato in proprio.

Solo nel caso della rappresentanza diretta si determina una divaricazione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale: quindi da un lato vi è chi ha *formalmente* stipulato il contratto e dunque manifesta la volontà che darà luogo all'accordo e dall'altro chi *sostanzialmente* sarà vincolato dagli obblighi nascenti da quel contratto stipulato a suo nome o ne acquisterà i diritti.

Sarà all'autore del contratto che occorrerà avere riguardo quando si tratti di verificare i presupposti di una valida manifestazione di volontà (capacità di intendere e di volere e volontà non viziata), mentre dovrà rintracciarsi in capo del rappresentato la capacità legale di agire e eventuali divieti di contrarre.

Gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si producono direttamente nei confronti del rappresentato, ma nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante: i limiti della procura (dunque del potere di rappresentanza) rilevano sia a garanzia del rappresentante sia a garanzia del terzo contraente.

Quando chi contratta lo fa come rappresentante ma senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli si parla di **rappresentanza senza potere**, così stipulando un contratto che non è idoneo a trasferire diritti o far sorgere obblighi in capo a chi, non atteggiandosi come rappresentato, dovrà considerarsi estraneo alla vicenda.

In questo caso il terzo contraente, a parte se conoscesse i limiti dei poteri di chi si presentava quale rappresentante, avrà diritto ad ottenere dal *falsus procurator* il risarcimento del danno per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto; tutto questo a meno che non intervenga un successivo negozio di **ratifica**.

La ratifica è equiparabile ad una procura successiva, è cioè un negozio unilaterale con cui l'interessato fa propri gli atti conclusi in suo nome da chi non ne aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato dai poteri concessigli. Di conseguenza la ratifica deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio a cui si riferisce. Ha effetto retroattivo: cioè si considera efficace fin dall'inizio, come se fosse stato posto in essere originariamente da persona fornita di procura. Questa retroattività della ratifica non può però pregiudicare i diritti acquistati dai terzi.

Se il contratto stipulato da *falsus procurator* è privo di ratifica, rimane **inefficace** (NON NULLO O ANNULABILE) e il terzo contraente ha diritto di chiedere il risarcimento del danno allo pseudo-rappresentante solo se *questi abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto*: se sapeva che colui che agiva in nome altrui non aveva il relativo potere oppure se ne sarebbe potuto accorgere usando la normale diligenza non può pretendere alcun risarcimento.

Diversa è la posizione del terzo in caso in cui il contratto concluso dal rappresentante sia contrario all'interesse del rappresentato, cioè in **conflitto d'interessi**, anche se il potere di rappresentanza è validamente conferito. Il rimedio apprestato dall'ordinamento in questo caso è quello dell'annullamento del contratto, che ci si potrà fare ricorso solo se il conflitto era a conoscenza del terzo contraente. Legittimato a chiedere l'annullamento è soltanto il rappresentato.

L'art 1395 c.c. prende in considerazione ancora una volta l'interesse del rappresentato e consente l'annullabilità del **contratto con se stesso**: è il caso in cui il rappresentante stipuli il contratto o i contratti dei quali è stato incaricato non con terzi ma con sé stesso. Tale contratto è annullabile almeno che il rappresentante non sia stato a ciò autorizzato dal rappresentato o almeno che il *contenuto del contratto sia stato determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi*.

La figura del falso rappresentante non ha niente a che fare con l'istituto dell'**interposizione fittizia**: l'interposto "fittiziamente" è colui che appare come destinatario di diritti ed obblighi di un contratto, dunque come parte del contratto per sé e non come rappresentante di altri, mentre in realtà gli effetti del contratto sono destinati a prodursi nei confronti di un altro soggetto che preferisce non comparire.

Il codice vicino alla rappresentanza disciplina delle figure diverse, ma in un qualche modo vicine ad essa, e sono:

- **Il contratto per persona da nominare**: nel quale una parte si riserva, al momento della conclusione del contratto, di indicare successivamente il soggetto che figurerà come parte sostanziale del contratto e sul quale ricadranno i relativi effetti. Ovviamente la parte che si è riservata di nominare come parte sostanziale un'altra persona deve provvedervi entro un **termine** e purché la nomina sua efficace è necessaria l'**accettazione** del soggetto nominato o una **procura** rilasciata dallo stesso allo stipulante i data anteriore alla stipula del contratto.
- **Contratto per conto di chi spetta**: Il contratto per conto di chi spetta o per conto dell'avente diritto è stipulato in rappresentanza di un soggetto che sarà determinato successivamente in base alla titolarità di una certa situazione giuridica soggettiva. Trovano fondamento nel codice civile la vendita per conto di chi spetta in caso di divergenze sulla qualità e condizione della cosa venduta e della conseguente verifica giudiziale dei difetti (art. 1513), nonché l'assicurazione per conto di chi spetta.
- **Contratto a favore di terzi**: consente alla parte stipulante, purché vi abbia interesse, di impegnare la sua controparte (promittente) ad una prestazione a beneficio di un terzo, il quale non è parte del contratto né in senso formale né in senso sostanziale.

LA CAUSA

Il nostro legislatore non dà una definizione di causa e la funzione della causa all'interno del contratto ha vissuto di profonde discussioni, anche a riguardo dell'opportunità della sua previsione all'interno dei requisiti del contratto.

Abbiamo quattro posizioni principali che si sono affermate nei vari momenti storici, che si sono spostate da una visione oggettiva di causa a una visione soggettiva della stessa:

- Tesi di Domat Pothier dell'800 che vedeva nella causa l'elemento giustificativo del contratto; quindi abbiamo in questo primo caso una accezione oggettiva di causa, che finiva per leggere nei contratti a titolo oneroso la causa come la reciprocità degli impegni assunti dalle parti e nei contratti a titolo gratuito come lo spirito liberale a senso lato.
- Sempre nel 19esimo secolo si sposta questa concezione verso elementi più soggettivi, e si legge la causa come scopo ultimo o motivo prossimo che spinge le parti a stipulare il contratto stesso; qui abbiamo un avvicinamento dell'idea di causa a quello di motivo, che da

un punto di vista tecnico dobbiamo tenere separati, perché i motivi sono tendenzialmente irrilevanti sul contratto in termini di gestione degli effetti e nella lente della validità. Il termine motivo prossimo secondo questa lettura è sempre unico nel tipo di contratto, mentre il motivo remoto, quello irrilevante per il diritto, cambia da contratto a contratto e da parte a parte.

Es. contratto di compravendita: un venditore vende un bene per ricevere un corrispettivo in denaro, questo è il motivo prossimo che è standard per il contratto in questione, il motivo remoto è perché il venditore vende e questo cambia da contratto a contratto.

Questa teoria recava dei problemi rispetto alla sicurezza delle circolazioni, quale interesse di ordine generale.

- 20esimo secolo: **CAUSA IN ASTRATTO**, cioè causa intesa come funzione economico-sociale del contratto; qui si torna in una prospettiva oggettiva di causa ed è una formula ancora oggi funzionale. Il problema emerge quando dobbiamo dare in significato a questa formula. In questo caso la causa è molto lontana dal terreno del motivo. Si considera la causa nella sua oggettività. La causa come funzione economico-sociale viene elaborata in un periodo storico di regime, dove l'accento non veniva posto sull'individuo ma sulla collettività. Ero lo stato che concentrava e dirigeva l'economia e in questa cornice il contratto veniva inteso come uno strumento giuridico privatistico che doveva però essere concepito come un negozio funzionale di attuazione in chiave individuale dei valori fondamentali che venivano fissati dallo stato.

Motivo per cui la causa aveva un ruolo di controllo sul contratto e andava a verificare la coerenza dei fini e degli interessi perseguiti dai privati rispetto ai fini fissati dal legislatore e quindi dall'ordinamento. Questo voleva dire che la liceità dell'agire delle parti del contratto non dipendeva solo dalla non contrarietà delle norme imperative, ma anche dalla verifica del fatto che attraverso il contratto venissero perseguitate le finalità generali dell'ordinamento.

Quindi causa intesa come ragione giustificativa del riconoscimento del contratto stipulato dalle parti all'interno dell'ordinamento giuridico.

Questo era un riconoscimento a priori (automatico) quando si trattava di un contratto tipico, modello di contratto scolpito dal legislatore; mentre si trattava di un riconoscimento a *posteriori* rispetto ai contratti atipici devono quindi affrontare un **controllo di meritevolezza** che viene operato dal giudice nel caso concreto.

- **CAUSA IN CONCRETO**: causa vista in una prospettiva soggettiva e si riavvicinano quindi causa e motivi, che comunque rimangono sempre distinti. Dopo l'avvento della nostra Costituzione, in quanto fondata sull'individuo, cambia il rapporto tra individuo e stato. La causa deve essere dedotta dal regolamento negoziale concretamente e complessivamente considerato, è una causa che permette di dare una rilevanza vera a quelli che sono gli interessi e bisogni delle parti trasfusi in modo esplicito all'interno del contratto. Qui possiamo dire che i motivi hanno un ruolo solo se sono stati recepiti all'interno del contenuto contrattuale: quindi il motivo è oggettivizzato e la causa soggettivizzata.

La causa conduce a un giudizio di controllo sulla giustificazione di ogni singolo affare che coinvolge l'interesse concreto delle parti fissato e oggettivizzato all'interno del contratto stesso e in definitiva all'interno dell'operazione economica-giuridica perfezionata dalle parti. La causa continua a distinguersi in modo netto dai motivi, che sono particolari bisogni, desideri, aspirazioni che spingono ciascun contraente a stipulare il contratto stesso, ma che

non trovano rilievo all'interno del regolamento contrattuale e quindi continuano a essere completamente irrilevanti se non sono esplicitati.

Es. compravendita nel caso della causa in concreto essa sarà ancora la vendita del bene contro corrispettivo ma anche tutti quegli altri interessi delle parti che le hanno spinte a stipulare il contratto e che hanno avuto rilievo all'interno del contratto, che sono state trasfuse all'interno del contratto.

Essendo il motivo irrilevante giuridicamente, gli errori sul motivo sono irrilevanti quindi non portano all'annullamento del contratto. Il motivo diventa rilevante solo quando sono verificati i presupposti **dell'art 1345**: *Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.*

Secondo l'**art 1343 c.c.** la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, e l'illiceità della causa determina la nullità del contratto.

L'**ordine pubblico** e il **buon costume** sono da intendersi quali clausole generali, cioè criteri di valutazione e di giudizio flessibili, destinati a riempirsi di contenuto in relazione alle circostanze e al tempo in cui vengono utilizzati.

Se è stata eseguita una prestazione in esecuzione di un negozio avente causa illecita, essendo il negozio nullo e non producendo effetto, chi l'ha eseguita avrebbe diritto ad ottenere la restituzione di ciò che ha dato (ripetizione dell'indebito); la contrarietà della causa al buon costume (**contratto immorale**), invece, esclude la ripetibilità di quanto ha pagato/della prestazione se è rivolta a uno scopo che anche da parte di chi l'ha eseguita costituisca *offesa al buon costume*.

L'art 1344 precisa inoltre che si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere all'applicazione di una norma imperativa. Viene qui in considerazione il **contratto in frode alla legge**, ovvero quando le parti utilizzano un contratto con causa lecita ma attraverso il regolamento posto in essere lo piegano per raggiungere un risultato vietato dalla legge.

Per i contratti tipici, ossia disciplinati specificatamente dal legislatore (es. compravendita), l'esistenza e la liceità della causa, ossia della giustificazione dell'accordo, di una sua funzione che lo rende meritevole di tutela giuridica, è già valutata positivamente dalla legge; ma resta da valutare se anche in concreto il singolo accordo sia meritevole di approvazione.

Per i contratti atipici o innominati, ossia quelli che la pratica pone in essere pur in assenza di uno schema legislativo, la valutazione deve riguardare non solo il contenuto *concreto* dell'accordo, ma pure lo stesso schema generico della pattuizione (es. contratto di sponsorizzazione o di pubblicità: interesse dei produttori ad attirare l'attenzione del pubblico sulle proprie merci e servizi, e dunque sorretti da una causa giuridicamente rilevante).

Altra categoria è rappresentata dai **contratti misti**, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici. Es.: causa della locazione è la concessione del godimento di una cosa contro corrispettivo e causa del rapporto di lavoro domestico è lo scambio di servizi domestici contro corrispettivo; la fusione di queste due cause dà luogo ad un contratto misto, ad esempio il contratto con il quale una persona concede ad altri, contro un corrispettivo, alloggio e provvede a lavare e rammendare la biancheria dell'ospite.

Diversi sono i **contratti collegati**, ovvero quando le parti stipulano negozi tra loro distinti, ma che funzionalmente sono preordinati dalle parti per la realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai

contraenti; in tal caso, se gli effetti di uno dei due contratti non si possono produrre, anche quelli dell'altro vengono meno (*simul stabunt, simul cadent*).

Ogni negozio deve avere la sua causa, perché ogni negozio deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile. In alcuni negozi tuttavia gli effetti si producono astraendosi dalla causa, la quale resta accantonata e vengono definiti **negozi astratti**, in contrapposto ai negozi causali.

Es. possono essere la cambiale.

Mancanza della causa: La causa può mancare fin dall'origine del negozio (**mancanza genetica**) o può avvenire che pur esistendo originariamente per vicende successive non sia più realizzabile il risultato a cui il negozio era diretto (**mancanza funzionale della causa**).

- *Difetto genetico della causa:* nei negozi tipici la causa esiste sempre, se considerata in astratto, perché il legislatore l'ha prevista nel dettare le regole di quel determinato tipo o "modello" di contratto; essa tuttavia può mancare nel caso concreto. Ciò avviene quando, per la situazione in cui dovrebbe operare, il negozio non può esplicare la sua, è privo di causa il contratto di assicurazione contro un rischio inesistente.
- La mancanza originaria della causa produce la nullità del negozio (1418.2).
- Se sopraggiungono circostanze che impediscono alla causa di funzionare (difetto sopravvenuto o funzionale della causa: es. il compratore non paga il prezzo), ma anche in caso di inadempimento o di eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto non è nullo e la parte può agire per la risoluzione e così sciogliersi dal vincolo.

Particolare rilievo hanno le distinzioni che rimandano alla causa del contratto:

- **Contratti onerosi:** quando ciascuna parte sopporta un sacrificio a fronte del vantaggio che il contratto le procura.

La presenza di prestazioni a carico delle parti non esclude che l'entità di una di esse sia incerta e dipende dal caso:

- o **Contratto commutativo:** quando l'entità della prestazione è certa e determinata
- o **Contratto aleatorio:** quando a fronte di una prestazione certa della sua controparte, la parte si obbliga ad una prestazione la cui entità è rimessa al caso (contratto di assicurazione)

Oppure si può avere il caso le prestazioni si giustificano l'una in ragione dell'altra, essendo legate dal nesso di reciprocità, sicché l'una è reciproca rispetto all'altra e deve trovare il suo corrispettivo nell'altra: **contratti a prestazioni corrispettive o con causa sinallagmatica** (es. compravendita). Il sinallagma contrattuale deve ravvisarsi sia al momento in cui il contratto nasce (**sinallagma genetico**), e permanere nella fase di attuazione del rapporto (**sinallagma funzionale**)

- **Contratto gratuito:** quando una parte, beneficiaria, si avvantaggia della prestazione dell'altra, ma senza sopportare alcun sacrificio.

L'OGGETTO

L'**oggetto** è un requisito del contratto ai sensi dell'art 1325 c.c. e deve essere secondo l'art 1346 c.c.:

- POSSIBILE: suscettibile di esecuzione
- LECITO: non deve essere in contrasto con norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
- DETERMINATO/DETERMINABILE: occorre che sia chiaro a che cosa le parti si impegnano.

La mancanza dell'oggetto o la mancanza dei suoi requisiti rende nullo il contratto.

L'interprete va alla ricerca della nozione di "oggetto del contratto" che il codice non fornisce, motivo per cui sono sorte differenti tesi:

inizialmente e tradizionalmente è stato inteso come il bene oggetto delle prestazioni, tesi che era comunque difficile da applicare nei contratti a effetti meramente obbligatori (contrapposti ai contratti a effetti reali). Motivo per cui si è passato a un'altra interpretazione, un concetto di oggetto più ampio: la somma delle prestazioni del contratto.

Definizione che ancora una volta non si adattava a tutte le realtà contrattuali, quindi si è andato oltre definendo l'oggetto come **il contenuto del contratto** che deve essere inteso sia con riferimento alla volontà delle parti, sia con riferimento a quelle previsioni normative che su quel determinato contratto hanno incidenza.

Le parti possono decidere che l'oggetto della prestazione sia determinato da un terzo, il quale è chiamato **arbitratore**; la sua attività è chiamata arbitraggio.

Art. 1349: il terzo deve procedere con equo apprezzamento, e le parti possono rivolgersi al giudice se la determinazione dell'arbitratore è manifestamente iniqua o erronea, o se il terzo non provvede alla determinazione affidatagli. In tal caso sarà il giudice a provvedere alla determinazione.

Le parti possono anche rimettersi al mero arbitrio del terzo, lasciandogli carta bianca: in tal caso non potranno impugnare la determinazione se non nel caso estremo in cui si riesca a provare la sua mala fede.

LA FORMA

La **forma** del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta.

L'ordinamento italiano si ispira in generale al principio della libertà della forma in materia di contratti, quindi qualsiasi modalità espressiva (anche comportamenti concludenti) è ammessa come idonea alla formazione di un valido vincolo contrattuale, purché palese in modo inequivocabile la volontà delle parti. Solo eccezionalmente è richiesta l'adozione di una forma prescritta dall'ordinamento, pena l'invalidità del contratto: si tratterà della **forma scritta**, nelle varianti della **scrittura privata** e dell'**atto pubblico**.

Il codice annovera la forma tra i requisiti del contratto soltanto nell'ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge "a pena di nullità" (art. 1325 n° 4).

I contratti che devono farsi per iscritto sotto pena di nullità sono indicati dall'art 1350, ma l'elenco non è esaustivo, in quanto all'ultimo comma rinvio a tutte le specifiche previsioni di legge che vincolano il contratto alla scrittura.

Rispetto a tutti questi contratti la forma scritta è richiesta **ad substantiam**, ovvero ai fini della validità del contratto (che è quella che si intende come elemento essenziale del contratto); ci sono

altri casi in cui la forma scritta è richiesta soltanto ai fini della prova, **ad probationem**, come ad esempio nel contratto di transazione.

Alcuni vincoli di **forma** disposti dalla legge in relazione al compimento di peculiari atti giuridici sarebbero previsti non **ad substantiam**, né **ad probationem**, bensì **ad regularitatem**, ossia affinché siano raggiunte specifiche finalità e/o perseguiti determinati ulteriori effetti.

L'imposizione della forma solenne, a pena di nullità, si caratterizza nel codice quale regola propria degli atti che hanno ad oggetto la costituzione, modificazione, o la circolazione di diritti su beni immobili e si ritiene che il vincolo di forma, quando previsto, si estenda a tutti i contratti strumentali o modificativi di un contratto a forma solenne.

L'art 1352 c.c. fa riferimento alle **forme convenzionali**, ovvero che il contratto può essere vincolato dalla forma scritta oltre che dalla legge anche dalla volontà delle parti. In tal caso la legge presume che la forma sia stata convenuta **ad substantiam**, ossia ai fini della validità dei futuri accordi, a meno che non risulti che essa sia stata richiesta soltanto ad altri fini, ossia, per esempio ai soli fini della prova.

Ci si riferisce al fenomeno del **neoformalismo negoziale** con funzione protettiva per indicare l'importanza che il legislatore ripone sul requisito della forma quando la stessa assolva ad una funzione di informazione e protezione della parte che si trovi in un piano di asimmetria contrattuale rispetto ad una parte più forte; come i contratti professionista-consumatore, i contratti banca-cliente, anche nei contratti che si concludono a distanza vi è l'obbligo per il professionista di fornire al consumatore la conferma del contratto concluso per iscritto o su un mezzo durevole.

Nel c.d. neoformalismo nei contratti dei consumatori, il vincolo di forma si proietta anche al di fuori del contratto e investe atti che lo precedono ed in particolare atti o comunicazioni che debbano garantire l'informazione in fase precontrattuale. La mancanza di una forma scritta si ritiene dia luogo a responsabilità precontrattuale del professionista.

Questo vincolo di forma nell'ambito di questi contratti garantisce una trasparenza, che se violata il rimedio è individuato nella regola che per le clausole disposte dal professionista per iscritto si fa prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Inoltre il legislatore vuole che gli elementi proposti dal professionista e accettati dal consumatore, essendo elementi destinati a regolare il loro rapporto, siano chiaramente illustrati nel testo contrattuale, a beneficio della trasparenza del contratto. In generale la legge delinea una sorta di "modello" standardizzato al quale le parti devono attenersi e che sarà riempito dei contenuti della singola concreta operazione (prescrizioni forma-contenuto).

Quindi, parlando invece del formalismo classico, si affida a due varianti:

- **Atto pubblico:** L'art 2699 c.c. definisce l'atto pubblico come il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e gli effetti dell'atto pubblico sono che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

È quindi l'atto che dota di maggior forza il contratto sia sul piano della certezza tra le parti sia sul piano della resistenza a fini probatori nei confronti dei terzi.

L'atto pubblico non ha però valore di prova legale per quanto riguarda la corrispondenza tra "volontà" e "dichiarazione", sarà dunque impugnabile per vizi della volontà o per simulazione.

(richiesto soprattutto per le donazioni e soggetti di diritto)

- **Scrittura privata:** atto non proveniente da un pubblico ufficiale e sottoscritto dalle parti e fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. La sua efficacia probatoria è ridotta quindi rispetto all'atto pubblico. Diverso è il caso della **scrittura privata autenticata:** qui il documento proviene sempre dalle parti ma la sottoscrizione è apposta davanti al notaio o al pubblico ufficiale. L'efficacia probatoria si estende qui non solo alla provenienza delle dichiarazioni, ma anche **alla data**. La funzione del notaio o del pubblico ufficiale non è quello di attestare quanto dichiarato dalle parti, ma che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza, da persona di cui egli abbia accertato l'identità e quindi non potrà essere disconosciuta dal firmatario.

Occorre invece far riferimento al codice dell'amministrazione digitale per la disciplina del **documento informatico**, che è definito come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e l'idoneità del documento a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutati in giudizio.

Il codice si preoccupa di regolare anche il valore degli strumenti diversi dalla tradizionale scrittura, per esempio è riconosciuto valore di scrittura privata alla conclusione del contratto via telefax (art 2712 c.c.).

IL CONTENUTO

Il contenuto del contratto è l'insieme delle pattuizioni che determinano diritti e obblighi delle parti, prestazioni e modalità per la loro esecuzione, quindi è l'insieme delle disposizioni e clausole concordate dalle parti che costituiscono regole che esse hanno pattuito e con cui intendono regolare i propri interessi.

L'ordinamento lascia le parti libere di determinare il contenuto del contratto pur nei limiti imposti dalla legge (art 1322 c.c.). Un controllo fatto sul contenuto del contratto potrebbe essere il controllo che si traduce **nell'integrazione cogente**, ovvero contenuti del contratto disposti da norme imperative o cogenti che non possono essere derogate dall'autonomia contrattuale; l'eventuale previsione contraria è considerata nulla e sostituita automaticamente da quella sancita dalla legge.

Se le condizioni sono predisposte unilateralmente da una parte in via generale per una serie di contratti c.d. di massa, l'altra parte potrà esservi vincolata purché al momento della conclusione del contratto abbia avuto modo o avrebbe avuto modo di conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Di diversa natura e assai più incisivo è il regime delle **clausole abusive**, ora denominate **vessatorie**, nei contratti professionista-consumatore.

Nei contratti tra professionista-consumatore possono essere dichiarate nulle tutte le clausole che malgrado la buona fede risultino determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore.

Questo sistema di tutela è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità.

La verifica di vessatorietà può essere esclusa solo dove si provi che la clausola sia stata oggetto di una vera e propria negoziazione e che quindi sia stato consentito al consumatore di intervenire nella formulazione della clausola.

L'onere probatorio di provare la svolgimento di una trattativa riguardante la clausola cade sempre sul professionista.

Sono vessatorie per esempio le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore o che escludono o limitano le azioni a tutela del consumatore per inadempimento del professionista, comunque vi è un elenco tassativo (la c.d. **black list**).

La vessatorietà non è carattere che la clausola presenta a priori, ma si svela alla stregua delle conseguenze: infatti una clausola del medesimo contenuto potrebbe manifestare una valenza squilibrata ed essere dunque giudicata vessatoria in un contratto e non invece in un altro.

La legge esplicitamente esclude che il carattere della vessatorietà possa riguardare la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo: l'intervento sulle clausole vessatorie vuole intercettare uno squilibrio normativo e non economico.

La conseguenza della vessatorietà accertata dal giudice con riguardo al singolo contratto è quella della **nullità** della clausola.

Il diritto dell'UE privilegia alcuni strumenti preventivi di tutela come il controllo esercitato da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si tratta di un controllo "in astratto", in quanto non incide sugli effetti diretti nei singoli contratti, in quanto è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario per il controllo all'interno del singolo contratto.

L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'interpretazione di un contratto è volta a determinare quali effetti il negozio sia idoneo a produrre, valutandolo in base ai criteri legali dettati dal legislatore in tema di interpretazione.

Le regole di interpretazione si distinguono in due gruppi:

- a) **regole di interpretazione soggettiva**, quelle che sono dirette a ricercare l'intento comune dei soggetti del negozio; per farlo si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
- b) **regole di interpretazione oggettiva**, che intervengono quando non riesca possibile attribuire un senso al negozio nonostante il ricorso alle norme di interpretazione soggettiva.

Il giudice deve rispettare il c.d. **principio del gradualismo**, ovvero potrà fare ricorso ai criteri interpretativi oggettivi solo quando non siano stati sufficienti i criteri c.d. soggettivi: l'interpretazione data dal giudice potrà essere censurata perché non abbia rispettato i criteri di ermeneutica secondo la "gradualità".

Il punto di riferimento dell'attività dell'interprete deve essere il testo della dichiarazione negoziale: occorre ricercare quale sia stata "**la comune intenzione delle parti**", ossia il significato che entrambe attribuivano all'accordo.

Valgono come sussidiari i seguenti principi:

- a) *gli usi interpretativi* (ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso o, se una delle parti è un imprenditore, nel luogo in cui si trova la sede dell'impresa);

- b) la regola secondo cui le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese in quello più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto;

c) la clausola predisposta da una delle parti nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, nel dubbio si interpreta a favore dell'altro.

Se nonostante il ricorso alle regole il contratto non risulti chiaro si applica una regola finale, che stabilisce che il negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo compensamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso.

Art. 1366: dispone che il contratto debba interpretarsi secondo buona, intesa ovviamente in senso oggettivo, quindi come canone di lealtà e correttezza.

Il criterio di buona fede va applicato sia con riguardo alla ricerca dell'effettiva intenzione delle parti (criterio soggettivo), sia con riguardo alla ricerca di un senso (oggettivo) al contratto.

In base alla regola della "buona fede", bisogna dare al contratto il significato che gli attribuirebbero contraenti corretti e leali; questo criterio può condurre a dare al contratto un significato diverso dal significato testuale delle espressioni che in esso sono contenute.

REGOLAMENTO CONTRATTUALE E BUONA FEDE

La buona fede è parametro aperto, quindi clausola generale, il cui contenuto è lasciato all'apprezzamento del giudice e in nome dell'interpretazione secondo buona fede la giurisprudenza perviene ad arricchire il contenuto del regolamento contrattuale di obblighi a carico delle parti pur non espressi, si da prospettare la buona fede come strumento di **integrazione del contenuto del contratto**, piuttosto che un'interpretazione del contratto.

Norma-chiave per valorizzare il ruolo della buona fede in funzione di una vera e propria integrazione del contenuto del contratto è l'**art 1375 c.c.**, che obbliga le parti ad eseguire il contratto secondo buona fede.

La giurisprudenza ha ricondotto il principio di buona fede inteso in senso oggettivo nel più ampio dovere di solidarietà contenuto nell'art. 2 Cost., ai sensi del quale a ciascuno è richiesto di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Dal rispetto del principio di buona fede inteso in senso oggettivo, così come delineato ed applicato, deriva che il vincolo contrattuale, seppur frutto dell'autonomia contrattuale, non può violare certi limiti impliciti e costituzionalmente garantiti di solidarietà; chiaro sintomo della violazione del principio di buona fede si rinviene **nell'abuso del diritto**.

La funzione integratrice della buona fede è stata invocata soprattutto per conformare rispetto all'interesse della controparte l'esercizio dei diritti nascenti dal contratto, riconoscendo alla parte un diritto di risarcimento del danno in caso di esercizio di tali diritti non conforme a buona fede.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Quando si parla di effetti del contratto ci si riferisce alle conseguenze e ai cambiamenti che sotto il profilo giuridico (in termini dunque di diritti e obblighi) esso è idoneo a determinare nella situazione giuridica patrimoniale delle parti.

L'**art 1372** stabilisce che **il contratto ha forza di legge tra le parti** e che **il contratto non produce effetti rispetto i terzi che nei casi previsti dalla legge**.

Essendo che il contratto si definisce come atto di autonomia e/o regolamento, gli effetti giuridici sono conseguenza di quanto le parti hanno voluto e disposto. Tutta via, il legame tra accordo, regolamento contrattuale e conseguenti effetti del contratto può essere impedito, interrotto o corretto dalla legge:

- quando norme imperative escludono a monte che un certo assetto di interessi sia lasciato alla libera determinazione delle parti (divieto patti successori)
- quando scelte un determinato assetto di interessi non sia consentito alle parti escluderne o modificarne determinate conseguenze
- quando la norma inderogabile interviene a sostituire la regola convenzionale (per esempio quando le parti stabiliscono un termine maggiore nella vendita con patto di riscatto, esso si riduce a quello legale)

Anche il rispetto della causa del contratto si pone come vincolo all'autonomia privata non consentendo alle parti di gestire gli effetti del contratto (es. la compravendita priva di prezzo sarà nulla).

La più importante distinzione con riguardo agli effetti è quella tra:

- **contratti ad obbligatori:** producono solo la nascita di diritti e obblighi tra le parti ma non l'effetto reale (es. locazione, mandato, comodato)
- **contratti ad effetti reali:** idonei a produrre, oltre alla nascita di un vincolo obbligatorio tra le parti anche la costituzione o il trasferimento o anche l'estinzione di diritti reali o il trasferimento di qualsiasi altro diritto. (es. compravendita)

Sono menzionati dall'art 1376 c.c. che oltre a menzionare le diverse fattispecie appena dette, sancisce il c.d. **principio consensualistico** (o **del consenso traslativo**), ovvero: *la proprietà o il diritti si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato*. Quindi la produzione dell'effetto è legata all'accordo delle parti. L'operatività di questo principio generale è in certi casi impedita:

- o es. quando l'effetto traslativo è pur sempre prodotto dal contratto, ma differito ad un momento successivo (vendita di cosa futura)
- o es. quando la legge richiede qualcosa in più dell'accordo per il prodursi dell'effetto reale (per costituire il diritti di ipoteca non basta l'accordo, ma anche la trascrizione nei registri mobiliari)

Un'altra distinzione, che si riferisce all'efficacia del contratto nel tempo è quella tra:

- **contratti ad esecuzione istantanea:**
 - o **contratti ad esecuzione immediata:** l'esecuzione si concentra per ciascuna parte in un unico effetto e in un'unica operazione e non si protrae nel tempo (vendita di cosa determinata, dove l'effetto traslativo si produce contestualmente alla stipula del contratto)
 - o **contratti ad esecuzione differita:** l'esecuzione è sempre istantanea, ma può collocarsi in momenti diversi (vendita a rate)
- **contratti di durata:** le prestazioni o almeno una di esse non si esauriscono in un'unica operazione o in un unico effetto istantaneo, al contrario, il contratto prevede obbligazioni il cui adempimento deve protrarsi nel tempo o con continuità (**contratti ad esecuzione continuata**) o a carattere di periodicità (**contratti ad esecuzione periodica**).

Solo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita può determinarsi quello scostamento di valore delle prestazioni rispetto a quello determinato al momento dell'accordo, per effetto di circostanze straordinarie e imprevedibile, che consente il rimedio della risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta.

Art 1372 c.c.: *il contratto ha forza di legge tra le parti- il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge: principio di relatività del contratto.*

Nessuno può subire un cambiamento della propria situazione patrimoniale o essere vincolato ad un rapporto obbligatorio se non per propria volontà, mai per volontà di altri.

Il principio trova espressione nell'art 1381 riguardo agli effetti della **promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo**.

Si tratta del contratto con il quale una parte (promittente) promette all'altra (promissario) la prestazione di un terzo soggetto. Questo contratto non obbliga il terzo, ma solo la parte promittente, tanto che, nel caso in cui il terzo non dovesse eseguire la prestazione o realizzare il fatto promesso, il promissario può far valere il suo diritto ad essere indennizzato soltanto nei confronti del promittente.

Il rinvio che fa l'art. 1272 ai casi previsti dalla legge, quindi in cui il contratto può produrre effetti nei confronti dei terzi, rimanda invece alla figura del **contratto a favore di terzi**.

In questo caso gli effetti del contratto si producono in capo a un terzo soggetto. In questo contratto una parte (stipulante) indica all'altra (promittente) il soggetto terzo nei cui confronti deve essere eseguita la prestazione (contratto di assicurazione). Gli effetti nei confronti del terzo si producono sin dal momento della conclusione del contratto e acquisisce la titolarità del diritto a pretendere dal promittente l'esecuzione della prestazione. È comunque possibile che il terzo rifiuti di volerne beneficiare, ma se accetta di essere il beneficiario questa sua volontà rende irrevocabile e immodificabile la designazione operata dallo stipulante. Condizione di validità del contratto in questione è che lo stipulante vi abbia interesse, diversamente la stipulazione dovrà ritenersi nulla.

Occorre soffermarsi anche sui **contratti** definiti dalla dottrina e giurisprudenza come **in danno al terzo**, dal momento che gli stessi producono effetti negativi nella sfera giuridica di soggetti rimasti estranei al vincolo negoziale. Ciò detto, è bene subito precisare come gli **effetti negativi**, che possono scaturire da tali contratti, siano solo quelli **definiti indiretti e riflessi**, connessi alla rilevanza esterna del negozio. Quest'ultimo, infatti, non potrà essere volto proprio a produrre effetti diretti negativi e dannosi nella sfera del terzo, dal momento che, in tal caso, verrebbe in rilievo un contratto nullo per causa o motivo illecito ovvero per contrarietà all'ordine pubblico.

Classico esempio di negozio rientrante in questa categoria è quello della **doppia alienazione**. In tale fattispecie, infatti, il primo acquirente che non abbia ancora trascritto, può subire un danno, riflesso, dal contratto di vendita stipulato successivamente dal medesimo acquirente sullo stesso bene immobile con altro soggetto che abbia provveduto a trascrivere prioritariamente l'acquisto. Il primo acquirente che non abbia trascritto è destinato a soccombere rispetto al secondo acquirente, primo trascrivente. Al verificarsi della fattispecie in esame, pacifica la responsabilità contrattuale dell'alienante che viene meno all'obbligo di far acquistare la proprietà della cosa al primo acquirente; si è ritenuta, poi, configurabile anche una responsabilità aquiliana del secondo acquirente laddove in mala fede, poiché a conoscenza della prima alienazione.

L'INTEGRAZIONE DEGLI EFFETTI

Il codice sancisce la regola della **integrazione degli effetti del contratto (art 1374 c.c.)** in forza della quale *il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.*

Si tratta di una compartecipazione tra autonomia privata e legge nella produzione degli effetti giuridici, che vede la legge delineare gli effetti del contratto al di là di quanto voluto dalle parti (**integrazione suppletiva**).

Intervento diverso è quello dell'**integrazione cogente** che riguarda il contenuto del contratto e costituisce espressione dei limiti che la legge pone all'autonomia (a differenza di quella suppletiva).

La lacuna riscontrata nell'atto di autonomia privata viene colmato con fonti che nell'ordine sono: LA LEGGE, GLI USI (usi normativi, cioè fonti del diritto costituite da consuetudini), EQUITA', intesa come un intervento (del giudice) che colma la lacuna mediante soluzioni equilibrate e ritenute più giuste e più adeguate al caso concreto. Non va confusa con l'equità quale criterio di giudizio, in quanto nella disciplina del contratto non serve per risolvere una controversia tra le parti, ma per regolare un aspetto non regolato in via convenzionale.

AUTONOMIA PRIVATA E GOVERNO DEGLI EFFETTI: SCIoglimento PER MUTUO CONSENSO E RECESSO UNILATERALE

La legge consente alle parti, o anche una sola delle parti, di porre fine al contratto fuori dai casi di patologia (es. inadempimento), con conseguente cessazione degli effetti.

Il contratto, secondo l'art. 1372 non può essere sciolto che per mutuo consenso o per causa ammesse dalla legge.

Il **MUTUO CONSENSO** altro non è che un nuovo contratto, un nuovo accordo, con cui entrambe le parti manifestano una volontà contraria alla precedente, concordando cioè di sciogliersi dal vincolo precedente con effetto retroattivo. Il mutuo consenso è espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare e anche eliminare gli effetti prodotti da un precedente negozio. La risoluzione per mutuo consenso di un contratto può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta *ab substantiam*. La regola generale è che l'accordo con cui si scioglie un contratto a forma solenne deve rispettare anch'esso tale forma a pena di nullità.

Il rinvio alle *cause ammesse dalla legge* conferma la regola generale per la quale dopo il perfezionamento del contratto non è più possibile un "ripensamento" cioè sciogliere il vincolo contrattuale per iniziativa di una sola delle parti, a meno che in capo ad essa non sia riconosciuto dalla legge o dal contratto il **diritto di recesso**=potere unilaterale di scioglimento del contratto.

- **Recesso legale:** si ha nei casi in cui è riconosciuto con espressa previsione di legge in considerazione del tipo di contratto e può essere considerato anche come strumento che consente alla parte di svincolarsi dal contratto a fronte di variazioni delle condizioni originariamente pattuite decise dalla controparte in corso di rapporto.
- **Recesso convenzionale (art 1373 c.c.):** quando non trova fonte nella legge, ma nello stesso accordo delle parti e può essere esercitato con i limiti previsti dalla normativa. Quindi si parla di recesso convenzionale quando questa facoltà sia stata pattuita e l'art 1373 ne fissa il limite di esercizio non oltre il momento in cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione. Invece, per quanto riguarda i contratti a esecuzione periodica o continuata, cioè quando l'esecuzione non si esaurisce in un unico atto, il recesso può essere esercitato in qualunque momento del rapporto contrattuale, anche dopo che sia iniziato l'adempimento. Esso tuttavia opera *ex nunc*, cioè dal momento del suo esercizio rendendo così incontestabili le prestazioni sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione.

Nel caso di recesso convenzionale, le parti possono subordinare il suo esercizio al pagamento di una somma di denaro, rendendo così **oneroso** l'esercizio di tale diritto:

- o **Multa penitenziale:** quando la somma deve essere consegnata nel momento in cui il titolare del diritto di recesso intende esercitarlo e ha la funzione di indennizzare la controparte

nell'ipotesi dell'esercizio di tale diritto. Il diritto di recesso avrà effetto quando la prestazione del corrispettivo pattuito sarà eseguita.

- **Caparra penitenziale:** quando la somma deve essere consegnata già dal momento della conclusione del contratto, così: se il recedente è colui che ha ricevuto la caparra dovrà restituire il doppio, mentre se a recedere è chi ha versato la caparra la controparte che subisce il recesso potrà trattenerla.

Diversa è la **caparra confirmatoria** che è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto, per **garantire l'adempimento delle obbligazioni** contrattuali.

Se la parte che ha versato la caparra diventa **inadempiente** l'altra parte può recedere dal contratto e **trattenere la caparra** a titolo di risarcimento del danno, senza bisogno di dimostrare l'ammontare del danno subito. Se però la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra.

Istituto tipico dei contratti tra professionista e consumatore è il c.d. **recesso di pentimento**. Specialmente nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, a fronte dell'assenza di trattativa e squilibrio informativo, il consumatore può sottrarsi al vincolo gratuitamente, senza alcuna penalità e senza dover fornire giustificazioni entro il termine di 14 giorni.

Il *dies a quo* decorrerà dalla conclusione del contratto se si tratta di contratti di servizi, fornitura di gas o elettricità; dal giorno in cui il consumatore abbia conseguito il possesso fisico del bene nel caso di contratto di vendita.

Il professionista ha l'obbligo di informare il consumatore delle condizioni, termini e procedure per l'esercizio del diritto di recesso e in caso di violazione dell'obbligo di informazione sul diritto di recesso si determina il prolungamento di tale termine di dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Il diritto di recesso è escluso solo quando oggettivamente incompatibile con la natura del contratto e delle prestazioni (es. bene deteriorabile e confezionato su misura, bene con prezzo legato a fluttuazioni di mercato).

Il recesso comporta la risoluzione di diritto degli eventuali contratti accessori.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO: CONDIZIONE, TERMINE E MODO

Alle parti è consentito governare il se e quando della produzione degli effetti di un contratto: si parla al riguardo di **elementi accidentali** del contratto, chiamati così in quanto la loro presenza è eventuale, un contratto può esserne anche privo, ma quando le parti li prevedono, essi entrano a far parte a pieno titolo del regolamento contrattuale e spiegano effetti su di esso.

TERMINE: consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale (**termine iniziale**) o fino al quale (**termine finale**) debbono prodursi gli effetti del contratto.

Al termine il codice civile non fa alcun cenno e il termine di efficacia del negozio si distingue da quello di adempimento o scadenza, che riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art 1184 c.c.).

Il termine può essere indicato con una data oppure con rinvio alla produzione di un evento futuro.

Il termine finale fa cessare gli effetti del contratto, mentre rimarranno ovviamente salvi quelli compiutisi fino a quel momento. (efficacia *ex nunc*)

CONDIZIONE: è ampiamente disciplinata dal codice, infatti all'art 1353 c.c. si fa menzione al contratto condizionale, che è il contratto nel quale le parti abbiano subordinato l'efficacia

(**condizione sospensiva**) o la risoluzione (**condizione risolutiva**) del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.

L'apposizione di una **condizione illecita**, sia che sia sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto.

Opera in modo diverso invece la **condizione impossibile**:

- **Condizione impossibile sospensiva**: quando il prodursi degli effetti del contratto è subordinato ad un evento impossibile equivale a non valer far nascere alcun contratto e per questo rende nullo il contratto.
- **Condizione impossibile risolutiva**: quando la cessazione degli effetti viene subordinata ad un evento impossibile equivale a voler dotare della ordinaria stabilità tali effetti, per questo si considera come non apposta.

La condizione, sia sospensiva che risolutiva, si distingue in:

- **Causale**: quando presuppone l'estraneità dell'accadimento alla sfera di intervento delle parti, quindi dipende dal caso o dalla volontà di terzi (es. scoppierà la guerra)
- **Potestativa**: dipende dalla decisione o dal comportamento di una parte, per la quale però non è indifferente l'avverarsi o meno dell'evento, ma deve incidere su un suo preciso interesse.
- **Mista**: quando l'evento dipende in parte dal caso o da scelte estranee alla sfera di influenza dei contraenti e in parte da atti di uno di loro.
- **Meramente potestativa (art 1355 c.c.)**: è quella in cui l'evento dipende dalla mera volontà della parte, ovvero dal suo arbitrio.

Se tale condizione fa dipendere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo dalla mera volontà dell'alienante o del debitore, rende nullo il negozio a cui è apposta (condizione sospensiva); se, invece, è l'acquisto del diritto o del credito che dipende dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore non v'è ragione perché il negozio non sia valido (condizione risolutiva). Quindi la legge prevede la nullità dell'alienazione di un diritto o dell'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa.

Quando la condizione sospensiva si è verificata, si producono tutte le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo al tempo in cui è stato concluso. L'inverso avviene se la condizione è risolutiva: gli effetti del negozio si considerano come non mai verificati. Gli effetti dell'avveramento della condizione risolutiva sono retroattivi e retroagiscono al momento in cui il contratto è stato concluso. Nel caso di contratti di durata interviene la regola generale secondo cui con l'avverarsi della condizione risolutiva non vengono comunque travolte le prestazioni già eseguite.

Il codice regola anche la situazione di **pendenza della condizione**, ovvero il momento in cui l'avvenimento non si è ancora verificato, ma può ancora verificarsi (situazione di incertezza).

Nel corso della pendenza una delle parti esercita il diritto, mentre l'altra parte ha speranza di divenirne titolare, se la condizione si verificherà. Si tratta di una **aspettativa**, che è trasmissibile agli eredi. A tutela di questa posizione la legge riconosce alla parte la facoltà di compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.), ad es. chiedere un sequestro conservativo del bene del quale, al verificarsi della condizione, diverrà proprietario.

Correlativamente, l'altra parte deve comportarsi in buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (art. 1358 c.c.)

Nel caso in cui l'avverarsi della condizione dipenda seppure in parte da atti di uno dei contraenti, che potrebbe avere interesse al non avverarsi della condizione, il comportamento comporterà la c.d. **finzione di avveramento della condizione** (art. 1359 c.c.). La condizione deve considerarsi come

avverata se colui che aveva interesse contrario all'avveramento ne ha impedito il verificarsi, e tale fatto impeditivo deve dipendere da una condotta dolosa o colposa e contrastante con il principio della correttezza e della buona fede.

La norma non si applica se la condizione sia nell'interesse di entrambe le parti.

Questo non deve confondersi con l'ipotesi di **condizione unilaterale**: ci si riferisce in questo caso alla condizione che per volontà delle parti sia stata pattuita nell'esclusivo interesse di una parte e non in quello di entrambe.

Si parla di "condizione implicita" a proposito della figura della **presupposizione**, istituto studiato dalla dottrina: ricorre la presupposizione laddove le parti pur non avendo fatto espressa menzione nel regolamento contrattuale circa la situazione di fatto e/o di diritto (presupposta, per l'appunto), la ritengono pacificamente quale elemento determinante ed imprescindibile ai fini della conclusione del negozio e della sua successiva esecuzione.

Es. Si pensi al caso in cui Tizio, al fine di assistere al passaggio del corteo organizzato in occasione della festa di paese, stipuli con Caio un contratto di locazione avente ad oggetto il balcone di casa di quest'ultimo; balcone che si affaccia proprio sulla via principale ove dopo pochi giorni sfilerà il corteo. Il contratto viene stipulato senza fare alcun espresso riferimento alla manifestazione, anche se è pacifico ed implicito per entrambe le parti che la finalità (la causa concreta del negozio) è proprio quella di consentire a Tizio di assistere al passaggio del corteo beneficiando di una posizione e di una vista privilegiate. Appare infatti chiaro che, tornando ai due esempi offerti, Tizio non avrà alcun interesse ad usufruire del balcone e dunque a pagare il canone pattuito con Caio a fronte dell'annullamento della manifestazione paesana.

L'area ricoperta dalla presupposizione è quella ricompresa tra l'ambito dei motivi e quella delle circostanze strettamente connesse alla realizzazione dell'assetto di interessi delineato dalle parti. È comunque tutt'ora aperto un dibattito circa l'ammissibilità della figura nel nostro ordinamento e circa i relativi rimedi.

MODO: nei contratti a titolo gratuito o in quelli caratterizzati da spirito di libertà, cioè nelle donazioni, può essere apposto, quale elemento accidentale, un onere (**modus**) che obbliga il beneficiario ad una prestazione o a destinare in parte ad una determinata finalità quanto ricevuto. (es. donazione modale)

Il **modus** impossibile o illecito è nullo, ma non comporterà la nullità della donazione, a meno che non ne abbia costituito il solo motivo determinante.

LA SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Con la successione nel contratto ci si riferisce ai casi, ammessi dalla legge, in cui, successivamente alla stipula del contratto e durante la vita di esso, si determini il trasferimento ad altro soggetto della posizione di un contraente, per atto tra vivi o a causa di morte.

La successione riguarda dunque non il contratto come atto, che si è già perfezionato, ma la **posizione contrattuale** che da quell'atto si è originata, dunque i diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

Se invece tale successione avesse come oggetto solo il diritto di credito o solo uno o più obblighi derivanti dal contratto si tratterebbe di successione nel credito o nel debito.

La **cessione del contratto** presuppone che si tratti di contratto a prestazioni corrispettive e che queste non siano ancora state eseguite. In presenza di questi presupposti la parte (**cedente**), con il consenso dell'altra (**ceduto**), potrà sostituire a sé un terzo (**cessionario**).

Così il cedente di un contratto originario stipula con il cessionario un apposito contratto, detto appunto **di cessione**, con il quale il cedente e cessionario si accordano per trasferire a quest'ultimo l'insieme di tutti i rapporti, attivi e passivi, derivanti dal contratto originario.

Il contratto di cessione è un contratto a effetti reali, poiché il consenso delle parti determina il trasferimento di diritti dal cedente al cessionario e si ritiene debba avere la stessa forma del contratto oggetto della cessione.

Il ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto (nullità, annullabilità) e viceversa; mentre rimarranno estranee al loro rapporto le vicende che attengono ai rapporti tra ceduto e cedente.

Il cedente dovrà garantire al cessionario solo la validità del contratto del quale gli ha trasferito la propria posizione; tuttavia è possibile che la cessione non sia liberatoria (*pro soluto*), ma *pro solvendo*: il cedente assume la garanzia dell'adempimento e in tal caso risponde come fideiussore del ceduto.

In alcuni casi la legge consente la cessione del contratto senza subordinarla al consenso del contraente ceduto. Es. il contratto del turismo organizzato può essere ceduto dal turista senza bisogno del consenso del professionista.

Si parla di **cessione legale** quando sia la legge a disporla direttamente. Le ipotesi di cessione legale riguardano principalmente contratti di utilizzazione e contratti di assicurazione di un bene i quali si trasferiscono automaticamente con l'alienazione di esso.

La regola della generale trasmissibilità, in caso di morte del titolare deve temperarsi con la natura del singolo contratto: l'ordinamento infatti detta spesso regole particolari nel segno della intrasmissibilità per taluni contratti: es. la morte dell'appaltatore potrà portare allo scioglimento del contratto se la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto.

Questa eccezione non vale per i contratti di locazione o di affitto, dove invece è prevista una **successione legale**, infatti in caso di morte del conduttore nel contratto di locazione è prevista per legge la successione a favore dei coniugi, eredi e parenti e affini che vivono con lui abitualmente.

Non si ha un fenomeno di successione con riguardo al **subcontratto**: in questo caso una parte conclude con un terzo un contratto per cedergli non la propria posizione contrattuale ma diritti che da quella posizione discendono. Es. il conduttore cede al subconduttore in cambio di un canone il diritto di godere dell'appartamento che egli ha in locazione.

Il codice non fornisce una disciplina del subcontratto, ma in alcuni casi è esplicitamente ammesso, ma di regola, con il consenso dell'altra parte del contratto principale (es. submandato, subcomodato), mentre certo volte la legge lo vieta (come nel caso di subaffitto di fondi rustici).

CAPITOLO XIX

LE TUTELE CONTRATTUALI

LA SIMULAZIONE

È un classico problema del negozio giuridico quello in cui ad una dichiarazione esteriorizzata non corrisponda ad un'effettiva volontà del dichiarante; in questo modo vi sarà divergenza tra l'atto apparente e tra la reale e diversa volontà dei soggetti.

Si ha così un negozio apparente o simulato quasi sempre racchiuso in un documento definito **controdi chiarazione**, ovvero il contenuto REALE di un negozio simulato.

Si distingue:

- **Simulazione assoluta:** quando le parti non vogliono alcun negozio
- **Simulazione relativa:** quando le parti vogliono un negozio diverso (negozio dissimulato) da quello che emerge dalla dichiarazione (negozio simulato)

La simulazione può riguardare anche solo i soggetti: si parla in tal caso di **interposizione fittizia**, cioè una simulazione relativa soggettiva. Essa consiste nell'attribuzione della qualità di parte ad un soggetto estraneo al negozio che si stipula. L'interposto si limita unicamente a prestare il proprio nome mentre titolare del rapporto giuridico è, sul piano sostanziale, un soggetto diverso. È il caso di chi non volendo, per ragioni fiscali, apparire acquirente di un immobile si accordi con il venditore per fare apparire che l'acquisto è stato fatto da un terzo.

Che non va confusa con l'interposizione reale che è certamente estranea al fenomeno simulatorio, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente.

L'interposizione reale integra gli estremi dell'**interposizione reale di persona**: L'interposizione reale di persona o intestazione fiduciaria si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio. Attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fiduciante.

Quindi vi è la creazione di obblighi giuridici a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte del fiduciante per ottenerne l'adempimento, quindi può configurare come un **mandato senza rappresentanza**.

Effetti tra le parti: il contratto simulato non produce alcun effetto: In caso di simulazione relativa, tra le parti produce effetto il contratto dissimulato, a condizione che presenti i requisiti di sostanza e forma.

Effetti per i terzi: Si distinguono le situazioni:

- Terzi interessati a dedurre la simulazione (1415.2 c.c.): i terzi estranei al contratto simulato, qualora ne siano pregiudicati, possono farne accertare l'inefficacia.
- Terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente: se la vendita simulata da Tizio a Caio è priva di effetti, non dovrebbe produrre effetti neppure un successivo atto di disposizione posto in essere da Caio; al terzo che sia in buona fede, la simulazione non può essere opposta e l'atto con il quale egli ha acquistato dei diritti produrrà i suoi effetti benché posto in essere non dal vero *dominus* del bene, ma da un titolare apparente (principio della tutela dell'affidamento) (1415.1). Terzo è sia chi ha acquistato a titolo oneroso che a titolo gratuito.

Effetti nei confronti dei creditori: In merito agli effetti della simulazione nei confronti dei creditori delle parti avremo due categorie:

- I creditori del simulato alienante, che avranno tutto l'interesse a far valere la simulazione poiché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore; possono far accertare la simulazione che pregiudica i loro diritti e, facendo prevalere la realtà sull'apparenza, agire sui beni dei quali il loro debitore si è solo apparentemente spogliato (1416)

- I creditori del simulato acquirente, che hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. In questo caso, si tratta di stabilire quando e a quali condizioni la simulazione sia a loro opponibile dal simulato alienante (o dai suoi aventi causa) e/o dai creditori di lui.

La simulazione è inopponibile al creditore che abbia acquistato un diritto reale di garanzia (pegno o ipoteca) sui beni che hanno formato oggetto dell'apparente alienazione, subordinatamente alla buona fede del creditore garantito. Inoltre, la simulazione non è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto, in buona fede, atti di esecuzione sui beni oggetto dell'acquisto simulato.

La simulazione è opponibile ai creditori chirografari cioè non muniti di garanzia reale che non abbiano ancora avviato un procedimento esecutivo sui beni simulatamente acquistati dal loro debitore

Nel conflitto tra i creditori chirografari delle due parti del negozio simulato la legge preferisce i creditori chirografari del simulato alienante soltanto se il loro credito è anteriore all'atto simulato. In questo caso la legge ritiene giusto far prevalere la realtà sull'apparenza, perché i creditori del simulato alienante concessero il credito prima che il debitore si spogliasse dei beni, ed è perciò da ritenere che essi fecero affidamento pure su quei beni che sono poi usciti, solo apparentemente, dal patrimonio del debitore

L'azione di simulazione è ritenuta un'azione tipica di **accertamento negativo** con cui la parte o il terzo tendono a far emergere un assetto di interessi divergenti da quello apparente. In altri termini, chi agisce mira a far accertare l'inefficacia del negozio simulato. Nel caso di simulazione assoluta, l'azione è ritenuta **imprescrittibile**, mentre nel caso di simulazione relativa, è ricondotta al **termine di prescrizione ordinario** ovvero a quello **previsto per il diritto oggetto del contratto simulato**

La vicenda della simulazione non va confusa con quella del **negozio indiretto**, Il negozio è indiretto **quando, attraverso la combinazione di diversi atti, si giunge a un risultato diverso rispetto a quello tipico dei singoli atti utilizzati**, risultato che è il vero scopo che vogliono raggiungere le parti con il negozio indiretto. Anche qui è possibile rilevare una divergenza tra il negozio stipulato e l'obiettivo perseguito dalle parti, ma il negozio indiretto è un negozio voluto e dunque valido.

L'istituto della simulazione va anche tenuto distinto dallo **schema negoziale fiduciario**: Di negozio fiduciario si parla quando un soggetto detto fiduciante trasferisce senza corrispettivo o fa trasferire da un terzo (pagando lui il prezzo o mettendo a disposizione il denaro per farlo) ad un fiduciario la titolarità di un bene (immobile o mobile), ma con il patto che l'intestatario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha già impartito o si riserva di impartirgli successivamente. Nel negozio fiduciario, dunque, le parti vogliono effettivamente che il fiduciario acquisti la titolarità del diritto trasferitogli, ma vogliono al contempo che egli non utilizzi questa titolarità nel proprio interesse, bensì solo nell'interesse del fiduciante e attenendosi alle sue istruzioni. Quindi a differenza del negozio indiretto, in cui si utilizza un certo negozio per un fine diverso da quello tipico, nello schema fiduciario può intravedersi un **collegamento negoziale** tra un

determinato contratto e un patto ulteriore (c.d. *pactum fiduciae*), attraverso il quale le parti realizzano il loro scopo.

Lo schema negoziale della fiducia può essere assimilato al fenomeno del **trust**, ovvero a quel **rapporto giuridico** per cui un soggetto (*settlor*) trasferisce taluni beni ad un altro soggetto di fiducia (*trustee*), il quale sarà tenuto a gestirli nell'interesse di un terzo (*beneficiary*).

I VIZI DEL CONSENSO

Nel procedimento formativo della volontà negoziale può inserirsi un elemento di disturbo che non elimina la volontà stessa, ma la altera, sicché il soggetto non si è determinato in modo libero e consapevole.

In questi casi l'ordinamento interviene concedendo al soggetto la possibilità di annullare (annullabilità) il negozio.

La volontà può essere viziata:

- O perché il soggetto, a causa della violenza morale esercitata da terzi, non si è determinato a stipulare il negozio in modo libero
- O perché il soggetto non ha agito con piena consapevolezza di taluni elementi

Qualsiasi negozio consiste in una manifestazione di volontà di un individuo, percepibile da terzi e quindi dichiarata, assumendo così rilievo sociale e giuridico.

Può accadere che la dichiarazione sia divergente dalla reale volontà del soggetto. Ancora, la dichiarazione potrebbe essere intenzionalmente divergente dalla reale volontà del soggetto (caso della *simulazione*). Vi è contrasto quindi tra **volontà** e **dichiarazione**: se la dichiarazione diverge dall'intero volere o se questo non si è correttamente formato, deve essere protetto l'affidamento dei terzi che hanno regolato la loro condotta considerando pienamente attendibile ed efficace quella dichiarazione (TEORIA DELL'AFFIDAMENTO). Tale teoria vale per i negozi patrimoniali inter vivos a titolo oneroso.

ERRORE: Il soggetto è in **errore di fatto** quando ha la **falsa rappresentazione** di quegli elementi della realtà che hanno determinato la sua volontà. È in **errore di diritto** quando ignora l'esistenza, il significato o l'applicabilità di una norma giuridica.

L'errore deve essere:

- **Essenziale**
 - L'errore di fatto è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del negozio, o sull'identità o qualità dell'oggetto della prestazione (un soggetto che stipula un comodato pensando che sia una locazione)
Non è invece rilevante l'errore sui motivi che hanno determinato il soggetto (es. si prende in locazione una villetta nel falso convincimento che si trovi nella stessa località dove trascorrono le vacanze degli amici)
 - L'errore di diritto è essenziale quando verte su un elemento o una circostanza che è stata la ragione unica o principale che ha indotto il soggetto a stipulare il negozio
- **Riconoscibile** dall'altro contraente: si considera riconoscibile quando, in relazione a contenuto, circostanze del contratto o qualità dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.

VIOLENZA: mentre la violenza fisica è causa di nullità, la **violenza morale**, ovvero la **minaccia**, fatta dall'altra parte o da un terzo, ad oggetto un **male ingiusto e notevole** rende il contratto annullabile.

La **minaccia di esercitare un proprio diritto** in generale non può integrare gli estremi della violenza, ma se l'esercizio del diritto tende a conseguire vantaggi eccedenti l'interesse tutelato dando luogo a un'ipotesi di abuso del diritto, il contratto può essere annullato.

DOLO: è un raggiro con cui si induce un soggetto in errore allo scopo di addivenire alla stipula del negozio. Perché sia rilevante è necessario che sia un inganno insolito e apprezzabile, proveniente dalla controparte, o comunque noto al contraente che ne trae vantaggio.

Il *dolus bonus*, ovvero un'intollerabile e innocua esaltazione della propria prestazione, è irrilevante, proprio perché questi comportamenti non possono definirsi "raggiri".

Possiamo distinguere:

- **Dolo omissivo:** che si ha quando si tacciono circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell'atto

Differenza tra dolo e errore a livello dell'accertamento:

- Nel caso dell'errore l'accertamento deve essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà.
- Nel caso del dolo occorre accertare la condotta del *deceptor* e le conseguenze da essa prodotte sul *deceptus*, verificando se la condotta omissiva o commissiva del primo abbia determinato il secondo alla contrattazione.

Il contraente il cui consenso risulti viziato da dolo può richiedere giudizialmente il **risarcimento del danno** conseguente all'illecito della controparte lesivo della libertà negoziale, sulla base della previsione in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

- **Dolo incidente:** quando il dolo incide sul contenuto del contratto, ma non è stato determinante alla sua conclusione; esso non rende il contratto annullabile, mentre la vittima può richiedere il risarcimento del danno subito. Si tratta in questo caso di **responsabilità precontrattuale**, poiché non deriva dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale. Tendenzialmente il danno verrà quantificato sulla differenza tra le utilità che la vittima del dolo trae dal contratto così come stipulato e quelle che invece avrebbe ricavato se l'assetto di interessi si fosse realizzato in assenza di raggiri.

L'INVALIDITA'

Si parla di invalidità ogni volta che l'atto di autonomia privata non presenti i requisiti necessari che lo rendono conforme allo schema normativa o quando l'atto di autonomia privata si rivela essere in contrasto con le esigenze tutelate da norme imperative, dal sistema.

L'invalidità può assumere due configurazioni: la **nullità** e l'**annullabilità**, a cui si è aggiunta nei nuovi tempi una figura ibrida rappresentata dalle **nullità protettive**, di derivazione comunitaria.

Quest'ultime sono uno speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale debole contro l'introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell'assetto generale del contratto.

La categoria dell'invalidità si ricollega alla categoria dell'**inefficacia**, perché la sanzione che colpisce il contratto invalido consiste nella mancata produzione degli effetti del contratto e la possibilità di rimozione degli effetti del contratto. Non di meno sono due categorie che vanno tenute rigorosamente distinte: il concetto di inefficacia copre un terreno decisamente più ampio rispetto a quello dell'invalidità. Quindi non parliamo di inefficacia solo quando ci troviamo in un contesto di invalidità contrattuale, ma, per esempio, se pensiamo a un condizione sospensiva o un termine

iniziale ci troviamo davanti a un contratto che seppur valido è pur sempre inefficace fino al momento in cui la condizione non si verifica.

Possiamo dire che il contratto è invalido quando è idoneo ad acquisire pieno valore giuridico perché si rileva essere un contratto carente con i presupposti o requisiti stabiliti dalla legge. Lo stesso quando il contratto è stato compiuto oltrepassando i limiti previsti dall'ordinamento per la libertà negoziale. Allo stesso modo il contratto sarà invalido quando il processo formativo della volontà sia stato oggetto di anomalie, sia stato viziato.

Il codice civile del 1865, dell'unità d'Italia, non prevedeva la categoria dell'annullabilità, quindi non prevedeva questa dicotomia tra nullità e annullabilità. Era disciplinata solo la categoria della nullità. Questo cambia con la codificazione del 1942 dove la figura dell'invalidità contempla anche la figura dell'annullabilità, che deriva proprio da una elaborazione della dottrina tedesca. Questa dicotomia trova espressione nel nostro codice civile attraverso due trattazioni differenti: nullità artt. 1418 e seguenti; annullabilità artt. 1425 e seguenti.

Si può separare il tema dell'invalidità da quello dell'**inesistenza**. Si parla di inesistenza tutte quelle volte in cui consideriamo un fatto che è privo del valore minimo che consenta di qualificare quell'atto/negozio/fatto alla stregua di un atto di autonomia privata. Es. matrimonio celebrato in uno spettacolo teatrale.

LA NULLITÀ

La **nullità** è la risposta dell'ordinamento ad un vizio genetico grave dell'atto di autonomia privata. La nullità comporta quindi un **rifiuto immediato e definitivo** del contratto da parte dell'ordinamento. Il contratto nullo non produce effetti e a differenza della nullità, le cause della nullità non sono sempre testuali, e cioè previste espressamente.

In ogni caso, quando si discute di nullità, l'anomalia è originaria poiché anche per cui, quando si parla di **nullità sopravvenuta** si allude in realtà ad un contratto originariamente valido che l'ordinamento, in un tempo successivo alla sua conclusione, priva dei suoi effetti.

Art 1418 c.c.: *Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.*

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità può essere:

- **Strutturale (2 comma):** in questo caso sussiste una difformità formale del contratto rispetto al modello legale o normativo, in ragione dell'assenza di uno dei suoi elementi costitutivi (accordo, causa, oggetto, forma).
Il requisito può mancare del tutto o può esistere, ma è politicamente disapprovato perché si pone in contrasto con una norma imperativa e con gli interessi della stessa protetti: in questo caso si parla di **contratto illecito** se il contrasto con la norma imperativa, con l'ordine pubblico o il buon costume riguarda la causa o l'oggetto o il motivo. L'interprete dovrà valutare ad es. la liceità della causa o dell'oggetto se la norma imperativa è implicita.

Sono comunque poche le cause di nullità strutturale in senso stretto, quindi quando manca completamente il requisito: l'unica ipotesi sembra quella del **contratto atipico** ex art 1322 c.c. che non persegua interessi meritevoli di tutela e possa così ritenersi sprovvisto di causa.

- **Virtuale (1 comma):** quando il contratto viola una norma imperativa. In questo caso si parla di **contratto illegale**. Perché una norma possa dirsi imperativa è necessario che l'interesse sotteso e protetto dalla norma sia generale, ma anche individuale, purché indisponibile: in tal senso, anche una norma posta a tutela di una sola parte del contratto che presiede un interesse indisponibile può essere considerata imperativa. (es. nullità che sanziona la clausola vessatoria)

Significato da attribuire all'espressione «*salvo che la legge disponga diversamente*»: sembra sia possibile ritenere che la contrarietà a norma imperativa comporti di regola la nullità del contratto illegale, ma che ciò non possa dirsi quando la nullità sia esclusa espressamente o quando a tutela dell'interesse protetto dalla norma imperativa l'ordinamento prevede una conseguenza diversa dalla nullità (es. una sanzione amministrativa).

È sembrato possibile anche ritenere che l'inciso in questione consenta all'interprete di valutare se la stessa *ratio* della norma imperativa esiga la nullità del contratto illegale: quindi la nullità sarebbe congruente con la *ratio* se gli effetti prodotti dal contratto sono esattamente ciò che la norma si propone di evitare.

Es. esiste una norma imperativa che indica che il mutuo fondiario concesso da una banca non possa superare una certa somma, proporzionale al valore dell'immobile da acquistare: il legislatore non dice se il superamento del tetto comporti o meno la nullità del contratto. Se si ritiene che la ratio della norma imperativa in questione sia quella di tutelare l'interesse della singola banca, si conclude che il contratto anche se supera il tetto massimo è comunque valido; nel caso in cui sia quella di tutelare la stabilità dell'intero sistema bancario, si avrà la nullità del contratto di mutuo.

Vi sono poi norme imperative che impongono una condotta: la violazione del dovere di buona fede o di doveri di comportamento imposti alle parti, sia nella fase precontrattuale sia in quella di esecuzione del contratto, non possa condurre alla nullità del contratto, ma piuttosto a un rimedio meramente risarcitorio.

- **Testuale (3 comma):** quando la qualificazione in termini di nullità è espressamente sancita dalla legge, quindi quando la legge descrive la fattispecie negoziale colpita da invalidità e ne afferma appunto testualmente la nullità.

Le nullità non sono solo quelle previste dal codice civile, ma anche e soprattutto quelle previste dalla legislazione speciale (**nullità speciali**).

La nullità è di regola **assoluta**, quindi la legittimazione ad impugnare il negozio spetta a chiunque vi abbia interesse.

Può essere anche **relativa**, specialmente il nuovo gruppo di nullità previste dalla legislazione a tutela del consumatore (nullità protettive). In questo caso:

- La legittimazione ad agire è relativa, cioè la nullità può essere fatta valere solo dalla parte debole del contratto.
- La nullità è sempre parziale, comporta cioè l'espunzione di una singola clausola e difficilmente implica la caducazione dell'intero contratto.

Infine occorre considerare l'illiceità che conduce alla **nullità per abuso**, in cui:

- a) Il giudizio di illiceità dell'atto di autonomia privata attiene al comportamento di una delle parti, quella che abusa della propria posizione per imporre condizioni contrattuali ingiuste.

- b) Illiceità non riguarda l'oggetto o la causa, ma altri aspetti del contenuto regolamentare
- c) Il parametro di valutazione della liceità non è più costituito soltanto dalle norme imperative, ma si estende al **diritto dispositivo**, che è un diritto derogabile da entrambe le parti, ma nel contratto standardizzato ad es. la deroga è in realtà operata da una sola parte, la quale non deve abusare di tale speciale potere di autonomia.

LA NULLITA' PARZIALE

La nullità parziale si ha quando il vizio che determina la nullità investe solo una o più clausole del negozio: la nullità parziale di un contratto importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (**art 1419 c.c.**).

L'interprete deve quindi mettere a confronto il regolamento di interessi originario con quello risultante a seguito dell'eliminazione di una clausola.

La regola in questione può essere considerata come un'applicazione del generale **principio di conservazione** del contratto (art 1367 c.c.): che stabilisce che in presenza di un dubbio su una clausola o sul contratto, l'interprete deve privilegiare, tra i significati astrattamente plausibili, quello utile, cioè quello che consenta alla clausola o al contratto di produrre un qualche effetto giuridico.

La nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono **sostituite di diritto da norme imperative** (es. una locazione pattuita per una durata inferiore a quella imposta dalla legge resta valida e la sua durata si estende automaticamente a quella fissata dalla legge). Questa disposizione può anche ritenersi superflua alla luce dell'art 1374 c.c., che indica che *il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge.*

Ancora, la nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto quando è il legislatore a prevedere la conservazione del contratto attraverso un congegno di **nullità parziale necessaria**, ad esempio il codice del consumo stabilisce che le clausole vessatorie in danno al consumatore sono nulle, *mentre il contratto rimane valido per il resto.*

L'AZIONE DI NULLITA'

La disciplina codicistica della nullità prevede:

- La **legittimazione assoluta**, e non relativa della nullità.
- L'**imprescrittibilità** dell'azione: non è soggetta a prescrizione.
- È **insanabile**: quindi è esclusa qualsiasi sanatoria, cioè le parti di un contratto nullo non possono in alcun modo confermare o consolidare gli effetti, rinunciando a far valere il vizio che lo invalida. (non è da confondere con la conversione)
- È un'**azione di mero accertamento o dichiarativa**: in quanto la sentenza non modifica la situazione giuridica preesistente, in quanto il negozio era già nullo ed inefficace prima dell'accertamento giudiziale, limitandosi ad accertare in modo non più convertibile, che il negozio è nullo.
- È **rilevabile d'ufficio** (L'espressione indica i casi in cui una certa attività si svolge ad iniziativa del giudice, senza necessità di una istanza di parte): al contrario di quanto accade per l'annullabilità, se un contratto viene azionato in giudizio da una delle parti (ad es. per ottenere l'esecuzione) il giudice può dichiararne la nullità anche in assenza di domanda a tal proposito dall'altra parte, quindi in assenza di eccezioni (È tale qualsiasi richiesta che abbia,

in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell'attore (o della controparte in genere)).

Si tratta di una deroga al c.d. principio dispositivo secondo il quale, di regola, il giudice può emettere pronunce solo a condizione che una parte gliene abbia fatta esplicita richiesta.

LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO

Il contratto nullo non è sanabile, ma la legge, tuttavia, ammette la **conversione del contratto nullo**, ovvero la sua conversione in un altro contratto valido.

Sono richiesti i presupposti (**art. 1424 c.c.**):

- a) Che sia stato stipulato un contratto nullo, come tale inidoneo a produrre gli effetti tipici;
- b) Che tuttavia quel contratto, sebbene nullo, presenti tutti i requisiti (di sostanza e forma) di un contratto *diverso* da quello concretamente posto in essere;
- c) Che sia possibile ritenere che le parti, qualora al momento della conclusione del contratto nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di concludere, in luogo del primo, quel diverso contratto che sarebbe stato valido;
- d) Che il vizio che affetta il contratto non comporti *illiceità*.

L'effetto di conversione del contratto nullo non richiede una rinnovata manifestazione di consenso negoziale delle parti.

È possibile che i contraenti decidano di stipulare nuovamente il contratto, questa volta evitando la causa di nullità: in questo caso si parla di **rinnovazione del contratto**.

L'ANNULLABILITA'

L'**annullabilità del contratto** si ha in presenza di una anomalia non grave che il legislatore ha comunque tipizzato. In questo caso la norma violata è posta a tutela di un interesse individuale, cioè di una sola parte del contratto, tanto che il contratto annullabile è efficace sinché non venga annullato con sentenza costitutiva.

A differenza di quanto accade per la nullità, il legislatore ha individuato in modo tipico e tassativo le cause di annullabilità, così il contratto è annullabile:

- In caso di **incapacità legale** (incapacità d'agire): è fatta salva l'ipotesi in cui il minore abbia posto in essere raggiri per occultare la propria età. La semplice dichiarazione di essere maggiorenne non accompagnata da altri elementi, non può fare salvo l'affidamento dell'altra parte e rende comunque annullabile il contratto.
- Di **incapacità naturale** (incapacità di intendere e di volere) del soggetto, dove è richiesta la mala fede dell'altro contraente
- In presenza di **vizi della volontà**
- In altre ipotesi indicate dal legislatore

Regole essenziali:

- L'azione di annullamento è un'**azione costitutiva** poiché è volta a modificare la situazione giuridica preesistente, privando il contratto della sua efficacia
- L'azione di annullamento è un'azione a **legittimazione relativa**, potendo essere fatta valere soltanto dal soggetto a cui tutela è prescritta l'invalidità
- L'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio: siccome l'atto, se non è impugnato ad iniziativa di chi vi sia legittimato, è produttivo dei suoi effetti, il giudice non può pronunciare l'annullamento dell'atto in mancanza della domanda di parte.

- L'azione di annullamento è soggetta a **prescrizione** e si prescrive di regola in cinque anni. Se la domanda di annullamento viene proposta dopo che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione del contratto, l'attore ha l'onere di provare che la scoperta dell'errore o del raggirio, o la cessazione delle minacce, si sono verificate entro e non oltre il quinquennio anteriore al momento in cui viene intentata l'azione di annullamento.
- Il contratto annullabile può essere oggetto di **convalida**, che va a sanare il contratto.
La convalida può essere:
 - o **Espressa**: Attraverso la convalida, infatti, il contraente cui spetta l'azione annullamento può porre in essere un nuovo negozio attraverso il quale dichiara di voler convalidare il negozio annullabile. Per la validità del negozio di convalida sarà anche necessario che sia indicato il vizio che inficia il negozio annullabile; la ragione di ciò è intuitiva. Come farebbe, ad esempio, il raggirato a convalidare il negozio se non si sia ancora reso conto di essere stato raggirato?
 - o **Tacita**: Questa si verifica quando il contraente cui spetta l'azione annullamento ha volontariamente dato esecuzione al negozio pur conoscendo il motivo di annullabilità. La sola esecuzione, anche parziale, del contratto accompagnata dalla consapevolezza dell'esistenza del vizio potrà esser considerata come convalida tacita. In ogni caso essendo la convalida un negozio giuridico dovrà essere posta in essere solo da chi è in condizione di concludere validamente il negozio di cui si tratta. Il minore, quindi, non potrebbe convalidare un negozio annullabile propria a causa della sua minore età.
- L' **eccezione** all'azione di annullamento può essere sollevata in ogni tempo dalla parte che sia stata convenuta in giudizio per l'esecuzione del contratto. L'eccezione, a differenza dell'azione, è imprescrittibile. Se così non fosse la parte non legittimata a far valere l'invalidità (es. colui che abbia contrattato con un incapace) potrebbe attendere la prescrizione dell'azione di annullamento senza far valere l'atto viziato e poi pretenderne l'adempimento dopo il decorso del quinquennio prescrizione.

L'annullamento ha effetto retroattivo (si considera come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto giuridico), devono quindi essere restituite le prestazioni eventualmente eseguite in attuazione del negozio annullabile (l'azione per la restituzione è l'azione di ripetizione dell'indebito, art. 2033). Se il negozio è annullato per incapacità di uno dei contraenti, l'incapace è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui essa è rivolta a suo vantaggio.

La sentenza di annullamento fa venir meno gli effetti del contratto. Nei confronti dei **terzi** che abbiano nel frattempo acquistato dei diritti su quanto oggetto del contratto annullato, la sentenza non produce alcun effetto se:

- L'acquisto è avvenuto a titolo oneroso
- L'acquisto è avvenuto in buona fede (soggettiva), ovvero ignorando il vizio del contratto in virtù del quale il dante causa ha acquistato il diritto
- La domanda di annullamento del contratto non sia trascritta prima della trascrizione del contratto di acquisto

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la causa di annullabilità sia lo stato di **incapacità legale** di una delle parti, la sentenza di annullamento travolge anche i diritti nel frattempo acquistati dai terzi in buona fede a titolo oneroso.

LA RESCISSIONE

Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto **in stato di pericolo o in stato di bisogno** di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali. (**art 1447 c.c.**)

RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO

(es. genitore che promette una grossa ricompensa a chi salverà il figlio che sta per annegare)

- Il pericolo deve riguardare esclusivamente un danno grave alla persona, che può essere lo stesso contraente o un'altra persona, e il pericolo deve essere in atto al momento della stipulazione del contratto.
- Lo stato di pericolo deve aver determinato il contraente a stipulare il contratto a condizioni inique
- La parte avvantaggiata deve essere a conoscenza del fatto che il contratto è stato concluso sotto la spinta dello stato di pericolo

In caso di rescissione il giudice potrà assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO/PER LESIONE

(es. chi spinto da uno stato di bisogno vende un bene al di sotto della metà del suo valore)

- La sproporzione tra due prestazioni dev'essere di tale entità che l'una valga più del doppio dell'altra.
- Lo stato di bisogno può essere riscontrato anche quando vi siano delle difficoltà economiche, seppure di natura transitoria, che però rivestano una notevole importanza per il contraente.
- L'altra parte deve essere a conoscenza dello stato di bisogno e se ne è servito per trarne vantaggio.
- Non possono essere rescissi per causa di lesione di contratti aleatori.

Rapporto tra rescissione e usura: quest'ultima è prevista dall'art. 644 c.p. e prevede il caso di chi si fa dare o promettere "in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari" e al terzo comma si fa riferimento a chi pur non ricevendo, o non avendo ricevuto la promessa, di interessi usurari, si approfitti di chi si trova in stato di difficoltà economica o finanziaria; in quest'ultimo caso la somiglianza con la rescissione è evidente. Sarà quindi il giudice a stabilire se il caso concreto di rescissione rientri nell'usura (soprattutto quella del comma 3 dell'art. 644 c.p.), ma se ciò sarà accertato tale contratto non sarà semplicemente rescindibile, ma nullo per contrarietà all'ordine pubblico o per illiceità della causa. In tal modo la vittima della rescissione-usura riceverà un tutela ben più efficace da quella che può ottenere dalla sola rescissione.

L'ordinamento si disinteressa dell'equità delle prestazioni e interviene soltanto quando lo squilibrio delle prestazioni non è frutto di una libera scelta delle parti, ma invece è la conseguenza di un abuso dello stato di debolezza in cui versa una parte del contratto: la rescissione non è consentita perché una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, ma è necessario un ulteriore elemento: cioè che l'iniquità si realizzi in presenza di uno stato di pericolo o di bisogno.

Si pensi anche all'**abuso di dipendenza economica**: il giudice può dichiarare nullo il patto con cui si concretizzi concretamente l'abuso di un'impresa dello stato di dipendenza economica in cui si trova un'impresa cliente o fornitrice.

LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE PER INADEMPIMENTO

Lo scioglimento del vincolo contrattuale può avvenire in ragione del **recesso unilaterale**, quando ciò sia previsto dalle parti o ammesso dalla legge, o per **mutuo dissenso**.

La **risoluzione** costituisce un'ulteriore ipotesi in cui le parti del contratto possono sciogliere il rapporto, in presenza di un'alterazione sopravvenuta e funzionale del vincolo.

Il codice civile prevede tre tipi di risoluzione: **risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità**. Questi hanno presupposti e effetti diversi, ma sono accomunati dalla circostanza che il nesso tra le prestazioni del contratto risulta viziato.

L'ipotesi più importante è quella della **risoluzione per inadempimento**. L'**art 1453 c.c.** prevede che *nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua volta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.*

La risoluzione opera, dunque, soltanto nei **contratti a prestazioni corrispettive/sinallagmatici**, in cui le prestazioni risultano reciprocamente collegate (es. contratti di vendita).

L'ambito operativo della risoluzione sembra estendersi anche oltre la corrispettività delle prestazioni: es. il mutuo può essere sciolto con risoluzione per espressa previsione codicistica, se il mutuatario non adempie all'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può infatti richiedere la risoluzione del contratto.

La risoluzione giudiziale può chindersi solo se l'inadempimento è di non scarsa importanza, quindi vediamo come l'ambito operativo **dell'azione di adempimento** rimane più esteso, in quanto è sufficiente un inadempimento anche non grave. In entrambi i casi, per quanto riguarda l'onere probatorio, chi agisce in giudizio deve limitarsi a provare il titolo, mentre deve semplicemente allegare l'inadempimento.

L'art 1453 al comma 2 stabilisce che *la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può chindersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.* In questo modo si tutela l'affidamento dell'inadempimento, il quale ormai ritiene che l'altra parte non abbia più interesse a ricevere la prestazione.

È tuttavia possibile che la domanda di risoluzione non venga accolta: in questo caso il creditore può anche chiedere l'adempimento.

Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione malgrado non sussistano i relativi presupposti, la giurisprudenza ritiene che il contratto si risolva comunque.

Infine, *dalla data di domanda di risoluzione non è più possibile per la parte inadempiente una tardiva esecuzione della prestazione.*

La **ratio** è quella di attribuire alla domanda di risoluzione l'effetto di rendere **definitivo** l'inadempimento della parte non fedele, impedendo all'altra parte di effettuare offerta formale e di costituire in mora l'inadempiente.

Prima della domanda di risoluzione è sempre possibile adempiere, ma ove la prestazione abbia perso oggettiva utilità per il creditore, non si può imporre l'adempimento, anche se la domanda non sia ancora stata presentata.

I dispositivi di tutela descritti all'art. 1453 c.c. non esauriscono l'apparato rimediale che l'ordinamento ha in caso di inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive: la disciplina codicistica delle obbligazioni (art. 1218 c.c.) prevede che l'inadempimento espone il debitore al risarcimento del danno e cioè alla responsabilità contrattuale, ma quando l'inadempimento consiste

nella mancata o inesatta esecuzione di una prestazione di un contratto a prestazioni corrispettive, alla parte fedele del contratto si offre sia il rimedio della responsabilità, sia quello della risoluzione per inadempimento.

Occorre tuttavia precisare che l'ordinaria reazione all'inadempimento è la domanda di adempimento: il creditore finché la prestazione è possibile ha il diritto e il dovere di chiedere l'adempimento; solo al venire meno dell'oggettivo interesse creditorio, allora, si avrà titolo ad ottenere il risarcimento.

Non è detto che i presupposti della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e della risoluzione per inadempimento siano identici: infatti è possibile immaginare anche l'ipotesi in cui sussistano i presupposti della risoluzione e non anche della responsabilità; in questo caso la parte fedele può chiedere lo scioglimento del contratto o in alternativa agire con l'azione di adempimento, ma non può richiedere il risarcimento ad es. perché non sussiste alcun danno contrattuale.

Tra i presupposti della risoluzione per inadempimento, una parte della dottrina e la giurisprudenza indicano anche l'**imputabilità** dell'inadempimento.

Per ottenere la risoluzione occorre proporre una *domanda giudiziale*, e spetterà al giudice, in caso di contestazione, accertare se veramente vi sia stato inadempimento del contratto e se di tale inadempimento sia responsabile il convenuto. La sentenza ha natura **costitutiva**, in quanto scioglie il vincolo che il contratto aveva prodotto e libera dai conseguenti obblighi. Inoltre il giudice, per dichiarare risolto il contratto, deve anche accertare che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

La risoluzione ha efficacia retroattiva (art.1458 c.c.), il che significa che non soltanto il contratto risolto non produce più effetti per l'avvenire e le parti sono liberate per il futuro dalle loro obbligazioni, ma che pure le prestazioni già eseguite devono essere restituite, salvo che per i contratti a esecuzione continuata o periodica.

Nonostante il fatto che la risoluzione abbia efficacia retroattiva, il risarcimento non è limitato all'interesse negativo, come accade quando un contratto non è mai stata concluso o è stata concluso un contratto non valido. Si ritiene che il **danno da risoluzione** debba essere liquidato avendo riguardo all'**interesse positivo**, depurato dal valore di mercato della prestazione non più dovuta.

LA RISOLUZIONE DI DIRITTO

La risoluzione per inadempimento può essere anche **risoluzione stragiudiziale o risoluzione di diritto**.

Ciò accade in tre ipotesi:

- 1) Il contratto può essere risolto con **diffida ad adempiere**: è possibile cioè intimare all'altra parte di adempiere entro un dato termine, non inferiore a 15 giorni, con l'avvertenza che in caso contrario il contratto si considererà risolto di diritto (**art. 1454 c.c.**). Il debitore potrà sempre chiedere al giudice di accertare l'insussistenza di un adempimento di scarsa importanza. Il creditore invece non può cambiare idea e rinunciare all'effetto risolutorio, a tutela dell'affidamento del debitore.
- 2) Le parti possono stipulare una **clausola risolutiva espressa**, prevedendo la risoluzione di diritto in caso di inadempimento (**art. 1456 c.c.**). Essa opera nel momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita la clausola, comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere.

- 3) Il contratto è poi risolto di diritto quando le parti abbiano fissato un **termine essenziale**, cioè l'improrogabilità del termine dedotto in contratto. Anche qui è possibile per il debitore chiedere al giudice di accertare l'inesistenza di un termine essenziale.

LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Si è già detto che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione, liberando la parte che era tenuta ad eseguirla.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile alla parte obbligata priva di giustificazione l'altra prestazione, sicché il contratto si risolve di diritto: per le prestazioni eseguite si applica la disciplina sulla **ripetizione dell'indebito**, con l'insorgenza, dunque, dell'obbligo di restituzione.

Affinché ciò si verifichi è necessario che:

- La prestazione venga a meno a seguito di un evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto
- L'evento non sia evitabile dalla parte obbligata usando la diligenza richiesta nello specifico settore di mercato (ipotesi di **forza maggiore**)
- Tale fatto si verifichi nella fase esecutiva del contratto

In giurisprudenza si tende a valorizzare anche la c.d. "*causa concreta*", quindi si considera impossibile anche la prestazione che ha perso utilità per il creditore per causa a lui non imputabile, né imputabile al debitore.

L'**impossibilità temporanea**, invece, non estingue l'obbligazione e non risolve il contratto, almeno che il protrarsi dell'impossibilità non conduca a una prestazione eseguibile tardivamente ma non più esigibile dal debitore o non più utile per il creditore.

LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è un rimedio tipico dei contratti a prestazioni corrispettive destinati a durare nel tempo, e cioè dei **contratti di durata** o dei **contratti ad esecuzione istantanea differita**. Tale tipo di risoluzione è invece esclusa quando il contratto a prestazioni corrispettive ha immediata esecuzione.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta consiste nel fatto che successivamente alla conclusione del contratto interviene un evento che modifica significativamente l'equilibrio tra le prestazioni, sì da generare uno squilibrio.

Affinché questa situazione possa comportare la **risoluzione del contratto** è necessario:

- Che lo squilibrio sia **significativo**
- Che l'evento che ha generato lo squilibrio sia oltre che **straordinario** anche **imprevedibile**.

In tal caso la parte svantaggiata può domandare al giudice la risoluzione del contratto (dunque è un'ipotesi di risoluzione giudiziale, non di diritto). La parte avvantaggiata (quindi quella convenuta con l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta) può evitare lo scioglimento del contratto offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

La **caparra confirmatoria** svolge essenzialmente due funzioni:

- Le parti determinano in via preventiva il danno da inadempimento
- Prevedono la possibilità che in caso di inadempimento l'altra parte possa recedere dal contratto

La presenza di una caparra confirmatoria rafforza il vincolo contrattuale e in caso di inadempimento la parte fedele potrà ottenere una somma a titolo di risarcimento senza dover provare il danno.

Quindi al contraente fedele si offre la possibilità di svincolarsi dal rapporto contrattuale esercitando un recesso che la disciplina generale del contratto non consentirebbe: svolge un ruolo simile a quello di una clausola risolutiva espressa e costituisce, seppure in senso lato, una sorta di "risoluzione di diritto".

Occorre precisare però che se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Quindi a fronte dell'inadempimento della controparte si può anche richiedere la risoluzione giudiziale per inadempimento: in questo caso si dovrà provare l'intero danno, il quale potrà essere in concreto minore o maggiore rispetto a quanto pattuito a titolo di caparra.

L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Altro rimedio, sempre nei contratti a prestazioni corrispettive, che ha a funzione di tutela della parte non inadempiente, è offerto dalla legge: è la facoltà concessa ad un contraente di rifiutare di eseguire la prestazione, se l'altra parte non adempie o non offre contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto (**art. 1460 c.c.**).

È un mezzo di tutela che può utilmente operare solo a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all'altra parte o successivamente ad essa.

Il rimedio si applica anche in caso di prestazione adempiuta, ma in modo inesatto.

L'istituto dà luogo ad una **forma di autotutela** sinallagmatica della parte, che può proteggere i propri interessi rifiutando di eseguire una prestazione di fronte alla mancata esecuzione della prestazione corrispettiva.

L'autotutela è ammessa soltanto in via del tutto eccezionale dall'ordinamento giuridico. Non basta l'inadempimento dell'altra parte a giustificare il rifiuto della prestazione. Occorre che il rifiuto stesso sia conforme a buona fede; perciò non si può prendere a pretesto un inadempimento di lieve importanza dell'altra parte per giustificare il proprio, sicché l'eccezione non è esperibile quando l'inadempimento non è grave.

Mentre l'eccezione non è rilevabile d'ufficio, la prova dell'adempimento, ovvero l'inesigibilità della prestazione, spetta a colui contro il quale è sollevata l'eccezione d'inadempimento.

L'eccezione di inadempimento non è l'unico strumento di autotutela di cui dispone il creditore: se infatti le condizioni patrimoniali della controparte sono tali da far dubitare che la controprestazione possa essere eseguita, è possibile sospendere l'esecuzione della propria prestazione.

Il **rimedio della sospensione dell'esecuzione della propria prestazione (art. 1461 c.c.)** si ritiene esperibile anche rispetto a mutamenti delle condizioni patrimoniali precedenti alla conclusione del contratto, ma ignorati senza colpa.

CAPITOLO XX

I CONTRATTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI BENI

LA VENDITA

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. (art. 1470 c.c.)

Rappresenta lo schema tipico del **contratto di scambio**, ed è quindi un **contratto oneroso e sinallagmatico** (a prestazioni corrispettive).

Le norme che disciplinano questo tipo negoziale sono norme dispositive, sicché nella prassi l'assetto di interessi che si realizza è regolato da pattuizioni private, anche in deroga alla disciplina legislativa: es. clausola con cui si esclude l'applicabilità della disciplina sulla garanzia per i vizi.

Vi sono invece elementi essenziali inderogabili e indefettibili come il **prezzo**: quest'ultimo non può mancare, anche se si può prevedere un prezzo simbolico o irrisorio.

La compravendita è un **contratto a forma libera**, quindi è sufficiente la forma orale, salvo che la legge non disponga diversamente: ad es. la forma scritta è richiesta per la vendita di beni immobili. Nella prassi sussiste anche l'**onere di trascrizione** ai fini dell'opponibilità del titolo, dove le parti sono solite stipulare nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, proprio perché il notaio possa adempiere all'obbligo di trascrizione (es. diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati).

La vendita si perfeziona con lo scambio del mero consenso, ed è dunque un **contratto consensuale** e non reale, dal momento che non è necessaria la consegna della *res* ai fini della conclusione del contratto.

È invece un **contratto ad effetti reali** e cioè realizza l'effetto traslativo del diritto reale o di credito, anche se in certi casi l'effetto reale può essere differito nel tempo: si parla in questo caso di **vendite obbligatorie**, nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto, ma il trasferimento del diritto si realizza comunque in ragione dell'originario scambio del consenso e non di ulteriore manifestazione di volontà (contratti ad effetti reali differiti).

Ciò vale quindi per:

- a) La **vendita di cosa generica**, ossia di una *res* determinata solo nel genere (ad es. tot chilogrammi di grano)
- b) La **vendita di cosa futura**, quando l'oggetto della vendita è un bene non ancora esistente, come autonomo oggetto di diritto (es. futuro raccolto del campo) o una cosa di nessuno (*res nullis*) che può essere acquistata per occupazione (es. pesci della prossima battuta di pesca)
- c) La **vendita alternativa**, che consiste nella vendita di un bene che l'acquirente potrà scegliere tra due o più dedotti in contratto.
- d) La **vendita di cosa altrui**:

È prevista dagli articoli 1478 e ss. e ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri.

Se si presta attenzione al meccanismo operativo dell'istituto risulta evidente che si tratta di una vendita obbligatoria; il consenso delle parti ha infatti un effetto meramente obbligatorio, e produce unicamente l'obbligo del venditore di procurare la proprietà al compratore, senza trasferimento della proprietà; l'effetto traslativo, invece, è rimandato al momento in cui il venditore riesce ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo.

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Bisogna fare la distinzione tra questo negozio e la **promessa del fatto del terzo**: Con la promessa del fatto del terzo (articolo 1381) le parti possono raggiungere lo stesso risultato perseguibile con la vendita di cosa altrui. Ad esempio io posso vendere l'automobile di mio fratello Primo al mio amico Caio (vendita di cosa altrui) oppure posso impegnarmi con Caio ad ottenere che mio fratello Primo gli venda la sua automobile (promessa del fatto del terzo).

La differenza principale tra le due figure è anzitutto di ordine concettuale, e riguarda l'oggetto del contratto; nella vendita di cosa altrui l'oggetto del contratto è l'automobile; nella promessa del fatto del terzo l'oggetto del contratto è la vendita che Primo farà al mio amico Caio, vendita intesa come fatto giuridico.

Un'altra differenza è riscontrabile negli effetti del contratto; la vendita di cosa altrui ha effetti obbligatori immediati e traslativi differiti, mentre la promessa del fatto del terzo non ha effetti reali, neanche differiti.

Ulteriore - e più significativa - differenza può ravvisarsi nel regime della responsabilità; nella vendita di cosa altrui il regime della responsabilità è quello ordinario, per colpa, mentre nella promessa del fatto del terzo la responsabilità è di tipo oggettivo, sussistendo per il solo fatto che la promessa non sia stata mantenuta (indipendentemente, quindi, dalla colpevolezza del contraente).

Il venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene e il diritto alla **risoluzione del contratto** spetta al compratore qualora, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se intanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.

La risoluzione può essere richiesta indipendentemente dal fatto che il venditore sapesse o meno che la cosa non gli apparteneva. Nel caso in cui sussista colpa o dolo del venditore il compratore può richiedere anche l'ulteriore **risarcimento del danno**.

Quando il compratore viene privato del diritto di proprietà, a seguito dell'accertamento di tale diritto a favore di un terzo (es. vendita di un bene che in realtà non è più del venditore perché è stato usucapito da terzi) si ha il fenomeno dell'**evizione**, cioè la perdita del diritto acquistato, in forza di un diritto preesistente di un terzo. L'evizione opera indipendentemente dalla colpa del venditore o dalla conoscenza del compratore.

Un discorso diverso si deve fare per il **CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA ALTRUI**: in questo caso, il **promissario acquirente** che ignori che il bene appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario.

Nel caso della **VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI**, ovvero quando la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto quando deve ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; oppure può chiedere una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Il compratore può **sospendere il pagamento del prezzo**, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il

pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita. Il pericolo di perdere la proprietà deve essere **serio, concreto e attuale**.

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Il compratore può anche far fissare al giudice un termine e che se entro il quale la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno.

Se il compratore subisce l'**evizione totale** della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno. L'elemento caratterizzante di questa **garanzia per evizione** è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo del terzo sul bene; quindi non si ha evizione per la sola affermazione dell'esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo.

Tuttavia, nel caso in cui sia stata pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio ed è nullo ogni eventuale patto contrario.

Garanzia per i vizi della cosa venduta (art 1490 c.c.): Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

Anche in questo caso la disciplina è dispositiva, quindi può essere esclusa o limitata, ma in ogni caso questa limitazione non ha effetto se il venditore in mala fede ha taciuto al compratore i vizi della cosa. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa. Il compratore in questo caso può domandare a sua scelta o la risoluzione del contratto (**azione redibitoria**) o la riduzione del prezzo (**azione estimatoria**); in questo ultimo caso ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

L'azione si prescrive in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

In caso di consegna **aliud pro alio**, ovvero quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata o sia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dall'acquirente, l'azione è assoggettata alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento, quindi svincolata dai termini della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Il compratore non può esperire un'azione volta all'eliminazione del vizio, in quanto il venditore è tenuto soltanto alla consegna di un bene. Qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di *facere*.

Questi rimedi della garanzia nella vendita non richiedono una responsabilità del venditore, ma l'**assunzione di un rischio** correlato al verificarsi di un evento o ad una data situazione (es. esistenza di vizi della cosa o intervento rivendicativo del terzo). Il venditore assume quindi il rischio circa il verificarsi di un evento pregiudizievole preesistente.

Naturalmente, la circostanza che il contratto di vendita sia ad effetti reali non significa che tale contratto non produca anche **effetti obbligatori**: l'acquirente è infatti obbligato a pagare il prezzo, mentre l'alienante è obbligato a consegnare il bene.

Oggetto di della vendita può essere anche un diritto reale diverso dalla proprietà. È anche possibile vendere quote di comunione o l'oggetto può essere rappresentato anche da un diritto di credito, salvo i diritti di credito strettamente personali.

Un cenno merita la **vendita in danno** di cose mobili, disciplinata dall'art 1515 c.c., il quale prevede che se il compratore non adempie all'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui: ciò rappresenta una tecnica di autotutela del venditore di cui può avvalersi quando la cosa è già diventata di proprietà del compratore. Deve essere fatta a mezzo delle persone indicate dalla norma.

Analogo strumento di autotutela ha il compratore per l'ipotesi in cui inadempiente sia il venditore: se la vendita ha per oggetto cose fungibili e il venditore non adempie alla sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate dal codice civile.

In ogni caso, il compratore che non possa avvalersi della **compera in danno** ed acquisti altrove le cose oggetto della vendita, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare della spesa per l'acquisto e il prezzo convenuto.

LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

Il venditore può avere interesse a realizzare una vendita di un bene mobile o immobile soltanto per un periodo di tempo determinato.

In tal caso le parti potrebbero stipulare una **vendita con condizione risolutiva potestativa**: il venditore si riserva cioè la possibilità di esercitare il diritto potestativo di riscattare il bene, con conseguente risoluzione, con efficacia retroattiva, della vendita.

Il patto di riscatto differisce dal **patto di retrovendita**, dove sussiste l'impegno alla stipula di una nuova vendita, a parti invertite.

Il legislatore ha tipizzato la vendita con **patto di riscatto** prevedendo taluni limiti all'autonomia privata:

- Il patto di riscatto consente all'alienante di rientrare nella proprietà del bene allo stesso prezzo della vendita: la previsione di un prezzo superiore è nulla. (per evitare che l'acquirente abusi della temporanea difficoltà del venditore)
- Tale "proprietà risolubile" non può sussistere per un tempo superiore a due o cinque anni, a seconda che il bene sia mobile o immobile.

Il patto, ove trascritto, è opponibile anche agli eventuali terzi aventi causa dell'acquirente.

LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ'

Art 1523 c.c.: nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Rappresenta una deroga alla regola generale dettata dall'art 1465 c.c., secondo cui il rischio del perimento fa capo al proprietario.

Siamo in presenza di una vendita obbligatoria in tutti i casi in cui il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto con la manifestazione del consenso, ma viene differito ad un momento successivo.

Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, tale tutela non è accordata qualora il compratore non versi più rate anche di valore complessivo inferiore a un ottavo.

Il **patto di riservato dominio** può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In questo caso si ha un'immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e il rinvio dell'effetto traslativo al momento dell'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.

In caso di **risoluzione per inadempimento del compratore**, il venditore deve restituire le rate ricevute, ma ha diritto alla restituzione del bene, al risarcimento del danno e all'equo compenso per l'uso dello stesso; per equo compenso si intende la remunerazione per il godimento del bene e il deprezzamento del valore del bene non più nuovo.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia figurato come **locazione finanziaria**: in questo caso il pagamento delle rate determina l'acquisto della proprietà e non il godimento temporaneo del bene.

LA VENDITA DI BENI MOBILI DI CONSUMO

La vendita di beni mobili di consumo si tratta della vendita, stipulata da un **professionista** (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale) ed un **consumatore**, avente ad oggetto beni mobili di genere o fungibili realizzati in serie.

Il profilo causale di questo contratto si è designato con la formula di **causa di consumo**, per indicare la destinazione del bene acquistato al soddisfacimento di un interesse al godimento del consumatore; si distacca dalla tradizionale **causa di scambio**, tipica della **vendita di specie**, quindi inadeguata a rappresentare la vendita di beni di consumo, che sono invece beni di genere, quindi si tratta di una **vendita di genere**.

La disciplina di consumo, per lo più di origine comunitaria, ha introdotto la figura del **difetto di conformità**: il venditore professionista ha l'obbligo di consegnare al compratore consumatore un bene conforme a quello stabilito nel contratto.

Il requisito della conformità si presuppone sussistente quando il bene è:

- Idoneo all'uso al quale è destinato abitualmente o all'uso particolare che l'acquirente intendeva fare
- Corrisponde alla descrizione fatta dal venditore o al bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello
- Dotato delle qualità o prestazioni *abituale di un bene dello stesso tipo* o che il compratore poteva ragionevolmente attendersi, anche sulla base delle dichiarazioni o della pubblicità commerciale del venditore.

La garanzia non opera quando il compratore era a conoscenza del difetto, o poteva conoscerlo impiegando l'ordinaria diligenza.

Le tutele del consumatore: il compratore ha la facoltà di chiedere la **riparazione o la sostituzione del bene**, che devono essere effettuate entro un opportuno termine dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti notevoli al consumatore. Il venditore non è tenuto a compiere tali interventi che comportino spese irragionevoli.

I rimedi di tipo **restitutorio** possono essere attivati nella vendita di beni di consumo soltanto in via subordinata alla riparazione o sostituzione. Pertanto il compratore non è del tutto libero di scegliere

di rimuovere gli effetti del contratto e farsi restituire il denaro: se il venditore offre la sostituzione della cosa con un'altra priva di difetti, il compratore non può rifiutare.

Può farsi luogo alla **risoluzione del contratto** o alla **riduzione del prezzo** nei seguenti casi:

- La riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose
- Il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine ragionevole
- La sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

(gerarchizzazione dei rimedi)

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Sussiste a carico del compratore l'onere di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta; mentre il termine di prescrizione dell'azione è di ventisei mesi dalla consegna del bene.

È sempre possibile poi che, oltre alla tutela minima e inderogabile prevista dalla legge (che prevede la nullità di qualsiasi patto limitativo della garanzia), le parti aggiungano una **garanzia convenzionale ulteriore**, intesa come *qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.*

La disciplina esaminata trova applicazione non soltanto nel contratto di vendita, ma anche nel contratto di **permuta**, di **somministrazione**, di **appalto**, di **opera** e **tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.**

LA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI

La vendita transfrontaliera si ha quando le parti contraenti hanno la propria sede d'affari in paesi diversi, e in caso di vendita di beni mobili si ha un'articolata disciplina rinvenibile nella **CISG** (*Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) che è un trattato internazionale adottato nell'ambito delle Nazioni Unite, e che appunto disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi.

Questo trattato disciplina con **norme dispositive** sia la formazione e la conclusione del contratto di vendita, sia i suoi effetti, sia le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi.

La CISG si applica al contratto di vendita transfrontaliero ogni volta che le parti non ne abbiano escluso l'applicabilità o abbiano derogato alle sue disposizioni in virtù del principio dell'autonomia contrattuale.

In caso di inadempimento del venditore, la CISG riconosce al venditore stesso il diritto di rimediare all'inadempimento in tempi ragionevoli. Il compratore può, d'altro canto, sciogliere il rapporto dichiarandone la risoluzione.

Come abbiamo visto prima, nel modello europeo si riscontra una gerarchizzazione dei rimedi, cosa che invece non si rinviene nella vendita internazionale, in quanto il compratore può richiedere la risoluzione quando e solo dove ricorre un **inadempimento essenziale**.

Quindi nel modello europeo il compratore non può risolvere il contratto se è possibile la riparazione o la sostituzione, mentre nel modello internazionale, il compratore può farlo solo se l'inadempimento è essenziale.

Per quanto riguarda il termine per la denuncia dei difetti, il compratore è tenuto a dare notizia del difetto di conformità del bene entro un **termine ragionevole**, ovvero un termine che consenta al venditore di scegliere efficienti e adeguate modalità di intervento in tempi brevi, perché il trascorrere del tempo accresce la difficoltà del venditore di provare l'effettivo stato della merce consegnata.

LA VENDITA DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Quando si acquistano immobili non ancora costruiti (cioè quando sia già stato richiesto il permesso di costruire ma non sia ancora stato lasciato il certificato di agibilità) può accadere che il costruttore si venga a trovare in una situazione di "crisi" (es. fallimento) e ciò impedisca l'acquisto o non consenta al compratore di recuperare le somme pagate.

Il legislatore ha indotto alcuni strumenti a tutela dell'acquirente di immobili da costruire:

- Il contratto deve essere stipulato per **atto pubblico o scrittura privata autenticata**
- Il costruttore è tenuto a procurare e consegnare all'acquirente, al momento della stipula del contratto preliminare, una **fideiussione** che garantisca all'acquirente, nel caso di crisi dell'imprenditore, la restituzione di quanto lo stesso abbia versato o verserà
- Il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente una **polizza assicurativa** per l'ipotesi di rovina o gravi difetti dell'immobile

L'omessa consegna della fideiussione o della polizza comporta la **nullità** del contratto preliminare o del contratto definitivo e tale nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente (**nullità relativa**).

LA PERMUTA

Art. 1552 c.c.: la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

Quindi non ha come oggetto lo scambio di cosa contro prezzo come accade nella vendita, ma di cosa contro cosa.

La permuta è un contratto **consensuale, oneroso** e ad **effetti reali**, perché non solo si ha il trasferimento di un diritto, ma tale trasferimento avviene in ragione del mero scambio di consensi delle parti.

Quando la controprestazione è costituita in parte da una cosa in natura e in parte da una somma in denaro, la giurisprudenza ha precisato che per rilevare se si tratta di permuta invece che di compravendita bisogna verificare se le parti hanno concordato lo scambio di beni in natura ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.

Per la permuta sono richiamate in quanto compatibili le norme stabilite per le vendite, tranne regole particolari in tema di:

- **Evizione (art. 1553 c.c.):** è prevista la facoltà per il permutante evitto di chiedere la restituzione del bene dato o del suo valore, a differenza del compratore evitto che può chiedere solo la restituzione del prezzo.
- **Spese (art. 1554 c.c.):** salvo patto contrario sono a carico di entrambi i contraenti, a differenza della vendita in cui, sempre salvo patto contrario, sono a carico del compratore.

È possibile anche un contratto di permuta tra bene esistente e bene futuro, quindi quando il sinallagma negoziale consiste nel trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura.

Un esempio diffuso nella prassi è il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile, in cambio di un appartamento situato nel fabbricato che sarà realizzato sulla stessa area a cure e con mezzi del cessionario.

IL CONTRATTO ESTIMATORIO

Art. 1556 c.c.: con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobile all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

È un **contratto reale** (quindi si perfeziona con la consegna del bene) con cui il produttore o il distributore all'ingrosso di un bene mobile (**tradens**) fornisce al venditore al dettaglio (**accipiens**) un numero determinato di beni da vendere, e di solito si tratta di beni a rapido o immediata obsolescenza (es. giornali).

L'**accipiens** deve pagare il prezzo fissato oppure restituire i beni nel termine stabilito: nel periodo che intercorre tra il momento della consegna dei beni e tale termine, l'**accipiens** può alienare i beni ricevuti a terzi, nonostante non ne sia proprietario.

Può avere sia **effetti reali differiti**, realizzando il trasferimento del diritto di proprietà, sia **effetti obbligatori**: se il bene viene restituito, l'**accipiens** non ha mai avuto la titolarità del diritto di proprietà sul bene.

Grava sull'**accipiens** il rischio di perimento del bene consegnato, nonostante non ne sia il proprietario, ma detentore fino al pagamento del prezzo.

Es. contratto tra editore e edicolante: l'editore consegna i giornali e se l'edicolante li vende, paga il prezzo, in caso contrario restituisce nel termine stabilito l'invenduto all'editore.

LA SOMMINISTRAZIONE

La **somministrazione** è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (**art. 1559 c.c.**).

Es. fornitura di energia elettrica, gas, acqua o rifornimento di beni al rivenditore al dettaglio

In questo modo si va a soddisfare un bisogno durevole nel tempo senza dover ricorrere a plurime e identiche operazioni negoziali.

Il **contratto** è di **durata** e la prestazione può essere:

- **Periodica:** fornitura settimanale di latte da un'azienda agricola
- **Continuativa:** fornitura di metano in un condominio

Il contratto può contenere:

- **Clausola esclusiva a favore del somministrante:** il somministrante si assicura la continuità e la certezza della fornitura e che terzi non gli facciano concorrenza mediante prestazioni al suo stesso somministrato
- **Clausola esclusiva a favore del somministrato**

La circostanza che il somministrante si obblighi a fornire beni, e dunque ad un **dare**, distingue il contratto di somministrazione dal **contratto di appalto**: quest'ultimo ha ad oggetto una prestazione di **fare**.

Il contratto di somministrazione deve anche distinguersi dalla **concessione di vendita**, che è un contratto innominato e consiste in un contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare

singoli contratti di compravendita, ovvero l'obbligo di concludere contratti di pure trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.

Nella somministrazione il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario e quindi la quantità complessiva della prestazione non è determinabile *a priori*, ma diventa determinabile nel corso dell'esecuzione, in base alle finalità che le forniture debbano soddisfare; diversa è invece l'ipotesi della **vendita a consegne ripartite**, dove il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta pur sempre un'unica prestazione predeterminata, ma rappresenta solo una modalità dell'esecuzione, collegata all'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta.

Quando le parti non fissano *a priori* l'entità della somministrazione (es. quanto gas) la legge prevede che il somministrante deve erogare la quantità di beni corrispondente al normale fabbisogno del somministrato, ma le parti sono comunque libere di stabilire un quantitativo minimo o massimo.

CAPITOLO XXI

I CONTRATTI

DI GODIMENTO

LA LOCAZIONE

La **locazione** è il contratto col quale una parte, il **locatore**, si obbliga a far godere all'altra, **conduttore o locatario**, una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (**art. 1571 c.c.**).

È un contratto **consensuale ad effetti obbligatori**: il locatore si obbliga a concedere in godimento al conduttore un bene, mentre quest'ultimo si obbliga a pagare in corrispettivo un **canone**.

Il conduttore o locatario (inquilino se l'immobile viene usato per uso abitativo) non ha il possesso ma la **mera detenzione** del bene e può dirsi quindi titolare di un **diritto personale di godimento** sulla cosa.

Nell'ambito di tale generale descrizione si possono distinguere:

- La locazione di **beni mobili** (macchinari, libri) e di **beni mobili registrati**
- La locazione di **beni immobili urbani**
- La locazione di **immobili non urbani** (es. fabbricati rurali)
- La locazione di **beni produttivi** (es. fondi rustici, aziende)

La disciplina del contratto in esame si articola tra codice civile e leggi speciali: il primo raccoglie una serie di norme sulla locazione in generale, mobiliare o immobiliare, dedicando alcune disposizioni specifiche alla locazione di beni immobili urbani, nonché all'affitto.

La legislazione speciale ha invece introdotto uno statuto complesso con particolare riguardo alle **locazioni di immobili urbani**, suddivise al loro interno tra **locazioni a uso abitativo** e **locazioni a uso non abitativo**.

Le norme del codice civile hanno il valore di regole di generale applicazione, quando non diversamente disposto dalle leggi speciali.

Per il codice civile il contratto di locazione:

- Può essere a tempi determinato (ma non superiore a 30 anni) o senza determinazione di tempo. In quest'ultimo caso è la legge a stabilire appositi limiti di durata del contratto a seconda del tipo di bene che costituisce oggetto della locazione
- Il locatore ha l'obbligo di consegnare e mantenere la cosa *in stato da servire all'uso convenuto*, provvedendo a fare eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore
- Il conduttore ha l'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia e deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta e ha diritto di togliere le eventuali addizioni: se il proprietario preferisce tenerle, deve pagare al conduttore un'indennità
- L'alienazione del bene locato da parte del locatore a un terzo non determina lo scioglimento del contratto, purché la locazione abbia data anteriore all'alienazione/trasferimento. Principio ***emptio non tollit locatum***.
- Con la **sublocazione**, il conduttore di un bene ne attribuisce, in tutto o in parte, il godimento a un altro soggetto verso un corrispettivo (canone).
 - o Il **conduttore di un immobile può sublocarlo**, anche nella sua interezza, **senza il consenso del locatore**;
 - o La **sublocazione di un bene mobile deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi**
- Se la locazione è pattuita per un tempo determinato, il rapporto cessa automaticamente con lo spirare del termine.

La locazione di immobili urbani è stata oggetto di continui interventi di leggi speciali, nella preoccupazione di proteggere i conduttori, che hanno inciso sia sul piano della **durata** del contratto sia su quello del **corrispettivo** (canone) dovuto al locatore. (i quali sono i 2 elementi caratterizzati del rapporto di locazione)

Queste leggi speciali fanno la distinzione in:

- **Immobili ad uso non abitativo (l. 392/1978)**

Nel contratto di **locazione a uso non abitativo** l'immobile locato deve essere destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

- La durata della locazione non può essere superiore a 6 anni o a 9 anni se adibiti ad attività alberghiera. Nel caso in cui le parti prevedano una durata inferiore, il contratto viene integrato *ex lege* con conseguente automatica applicazione della durata minima legale
- Il conduttore può sublocare l'immobile senza bisogno del consenso del locatore purché insieme venga ceduta o locata l'azienda.
- Il locatore che non decide di rinnovare il contratto deve corrispondere al conduttore un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale

- **Immobili ad uso abitativo (l. 431/1998)**

Inizialmente anche essi erano disciplinati dalla l. 392/1978 che prevedeva una durata minima obbligatoria e un corrispettivo determinato dalla legge secondo criteri di equità (equo canone).

La nuova legge invece prevede la possibilità per l'inquilino di stipulare alternativamente due tipologie di contratto:

- **Contratti liberi:** in questo caso la determinazione del canone è lasciata alla libera negoziazione tra le parti ed è prevista una durata minima di 4 anni con possibilità di rinnovo per altri 4 anni
- **Contratti tipo:** contratto stipulato secondo un modello predisposto dalle associazioni di categoria, in cui le parti sono vincolate sia nella determinazione del canone e la durata minima del contratto è prevista in misura inferiore (3 anni)

Per la validità di tali contratti occorre la **forma scritta *ad substantiam***; nell'ipotesi in cui la mancata formazione per iscritto del contratto sia stata imposta dal locatore la nullità del contratto è relativa: può essere fatta valere soltanto dal conduttore.

Il legislatore ha anche disposto la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato: in questo caso il contratto resta valido per il canone risultante dalla legislazione, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è effetto da nullità.

Il codice civile disciplina anche l'**affitto** che è in sostanza una locazione avente ad oggetto un bene produttivo (azienda, fondo...) i cui frutti o altre utilità spettano all'affittuario. L'affittuario deve curarne la gestione in conformità con la sua destinazione economica.

IL COMODATO

Art. 1804 c.c.: Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

È un **contratto reale ad effetti obbligatori**: il comodante non trasferisce alcun diritto al comodatario, ma quest'ultimo, in ragione del rapporto obbligatorio sarà titolare di un **diritto personale di godimento** sul bene mobile o immobile che ha in **detenzione**.

Il legislatore prevede l'essenziale **gratuità** del comodato: dove viene previsto un corrispettivo si avrà un contratto di locazione.

A differenza del deposito, il comodato realizza un interesse patrimoniale del comodatario e viene soddisfatto un interesse non patrimoniale del comodante.

Infine, il comodato è un **contratto con obbligazioni a carico del solo proponente** ed a **titolo gratuito**: cioè non è un contratto a prestazioni corrispettive quindi non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento.

Obbligazioni del comodatario:

- Custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
- Non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa
- Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante

Se il comodatario non adempie agli obblighi il comodante può chiedere l'**immediata restituzione della cosa**, oltre che al risarcimento del danno (art. 1804 c.c.).

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante.

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto (**termine implicito**). Se però, durante il periodo convenuto, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigere la restituzione immediata.

Il comodato si dice **precario** quando non ha né una durata determinata né un termine implicito: in questo caso il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richiede.

L'azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario e diretta a ottenere la **restituzione** della cosa concessa in comodato, ha natura di **azione personale** e prescinde dalla prova del diritto di proprietà: essa può essere quindi proposta da chiunque, avendo avuto la disponibilità materiale della cosa stessa, dimostro di averla consegnata ad altri a titolo di comodato.

IL RENT TO BUY E LA LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE

RENT TO BUY: è una nuova fattispecie contrattuale diversa dalla locazione finanziaria, che provvede a regolamentare tutti quei contratti che prevedono "l'**immediata concessione del godimento di un immobile**, con **diritto** per il conduttore **di acquistarlo** entro un termine determinato **imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone** indicata nel contratto".

Quindi il *rent to buy* è volto a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile e rinvia ad un momento successivo ed eventuale il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte del canone a corrispettivo del trasferimento.

Trascrizione: è previsto l'obbligo di **trascrizione del contratto**, che deve quindi rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Le parti contraenti definiscono la parte del canone da imputare al corrispettivo della vendita dell'immobile: la **doppia imputazione del canone**, che è elemento essenziale del contratto.

Es. canone di 1000€: 700€ per il godimento del bene e 300€ per il corrispettivo della futura eventuale vendita.

Si ha inadempimento contrattuale da parte del conduttore quando sussiste un mancato pagamento di un numero minimo di canoni fissato dalle parti: in questo caso il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione è risolto.

Il concedente ha diritto a chiedere la restituzione dell'immobile ed a trattenere i canoni ricevuti a titolo di acconto, ma solo se così è pattuito nel contratto; altrimenti dovrà restituirli ed eventualmente agire per il risarcimento del danno da inadempimento.

Nel caso di inadempimento del concedente questi dovrà restituire quella parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.

LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE: la fattispecie prevede due negozi collegati:

- 1) **Un contratto di *leasing*** (contratto atipico), con cui il concedente si impegna ad acquisire o far realizzare un immobile su scelta e indicazioni dell'utilizzatore e con il quale vengono fissati taluni aspetti essenziali del rapporto (durata, canoni...)
- 2) **Un contratto di vendita**, poiché sul bene immobile oggetto del *leasing* esiste un **diritto di riscatto** a favore dell'utilizzatore.

Quindi è un contratto tra due parti: la società di leasing e l'utilizzatore dell'immobile.

Alla scadenza del contratto, se non viene esercitato dall'utilizzatore il diritto di riscatto, consegue una detenzione *sine titulo* del bene da parte sua, con obbligo di restituzione, anche in caso di mancata indicazione delle modalità di consegna.

CAPITOLO XXII

I CONTRATTI DI PRODUZIONE DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

L'APPALTO E LA SUBFORNITURA

L'APPALTO: l'appalto costituisce il normotipo di quei contratti nei quali una parte si obbliga ad un *facere* consistente nella produzione di un bene o di un servizio tra cui vanno annoverati anche il contratto d'opera e il contratto d'opera professionale.

Nel contratto di appalto un'impresa (l'**appaltatore**) si obbliga a compiere un'opera o un servizio a favore dell'altra parte (il **committente**) a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Caratteristiche principali:

- È un **contratti di impresa**, perché l'appaltatore non può che essere un'impresa a mente dell'**art. 1655 c.c.**, il quale espressamente richiede un'**organizzazione dei mezzi necessari e una gestione a proprio rischio da parte di chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio**.
- È un **contratto a titolo oneroso** giacché è previsto come elemento necessario un corrispettivo in denaro
- È un contratto concluso **intuitu personae**, che sono quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti. Infatti le qualità dell'appaltatore sono determinanti nella scelta fatta dal contraente e dunque anche per il **subappalto** (contratto derivato dall'appalto originario con cui l'appaltatore affida a un altro soggetto il compimento dell'opera) è necessaria l'autorizzazione del committente.

La qualità di imprenditore dell'appaltatore è l'elemento che distingue l'appalto dal **contratto d'opera** e dal **contratto d'opera intellettuale**, nei quali l'obbligato è una persona fisica e un professionista intellettuale.

Il contratto d'appalto va distinto inoltre dalla **vendita di cosa futura**: nell'appalto, per la costruzione di un'immobile, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del committente che gli sottoporrà un progetto dal quale non potrà discostarsi senza sua autorizzazione; nella vendita di cosa futura il venditore propone all'acquirente di acquistare un bene già completamente determinato la cui consegna verrà in un momento successivo.

Durante l'esecuzione dell'opera si potranno determinare degli scostamenti rispetto al progetto originario, le c.d. **varianti**. Tali varianti potranno essere concordate tra il committente e l'appaltatore e in questo caso non daranno luogo a modifiche del corrispettivo; solo se superano il sesto del prezzo l'appaltatore avrà diritto ad una maggiorazione del corrispettivo.

Per le c.d. **variazioni necessarie**, quindi quegli interventi che devono essere eseguiti per realizzare l'opera a regola d'arte, per motivi di sicurezza o per far fronte a problemi imprevisti, se il loro importo supera il sesto del prezzo originariamente stabilito, l'appaltatore può recedere dal contratto (unico caso in cui anche all'appaltatore è concesso il recesso unilaterale) e ha diritto ad un'equa indennità che può ottenere dal giudice.

Lo stesso equo indennizzo va riconosciuto al committente che voglia recedere dal contratto perché le variazioni sono eccessivamente onerose.

Se a causa di eventi imprevedibili, il costo dei materiali o della mano d'opera aumenti o diminuisca, l'art 1664 c.c. consente alle parti di rinegoziare il corrispettivo e, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice.

L'appaltatore ha l'obbligo di realizzare l'opera secondo il progetto esecutivo che gli è stato sottoposto dal committente, e se ne può discostare se il progetto sia palesemente errato e il suo rispetto potrebbe determinare un'esecuzione non a regola d'arte.

Il committente ha diritto di verificare come si stia procedendo al compimento dell'opera, per valutare se si stiano rispettando le istruzioni impartite.

Qualora risultino difformità, il committente deve denunciarle all'appaltatore, dandogli un termine per correggerle, pena la risoluzione del contratto e il diritto del committente medesimo al risarcimento del danno.

Prima della **consegna** dell'opera terminata, il committente ha diritto di verificare (il c.d. **collaudo**) se essa sia stata eseguita a regola d'arte e secondo progetto. Una volta accertata l'opera l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo.

Qualora nel corso del collaudo il committente rilevi difformità o vizi, può rifiutare di prendere in consegna l'opera.

L'appaltatore deve garantire che l'opera sia esente da vizi e difetti, sicché il committente può chiederne l'eliminazione oppure pretendere una diminuzione del prezzo, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni se si prova che l'appaltatore abbia agito con colpa.

- **Vizi palesi:** conosciuti o riconoscibili al momento della consegna. L'accettazione dell'opera da parte del committente impedisce il sorgere della responsabilità dell'appaltatore per gli stessi
- **Vizi occulti:** non conosciuti o non riconoscibili, il committente deve fare denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Il termine per agire contro l'appaltatore si prescrive in due anni dall'ultimazione del lavoro.

Secondo l'art 2053 c.c., che disciplina la responsabilità del proprietario di un edificio che rovini in tutto o in parte, per i danni provocati a terzi, salvo che si provi la colpa dell'appaltatore.

Quindi in questo caso la responsabilità dell'appaltatore è **mista**:

- Responsabilità contrattuale nei confronti del committente, quindi tra le parti
- Responsabilità extracontrattuale per i danni subiti dai terzi

È possibile però che l'opera si deteriori o perisca per causa non imputabile a nessuna delle parti: la legge in questo caso prevede che l'evento sia posto a carico del committente o dell'appaltatore a seconda che la materia venga fornita dall'uno o dall'altro.

L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire l'opera nei termini che sono stabili in contratto. Importante è stabilire se il ritardo sia imputabile all'appaltatore (se ne deriva un danno per il committente ne può richiedere il risarcimento), al committente o derivi da causa non imputabile a nessuno dei due.

Il committente per tutelarsi contro l'inadempimento o ritardo dell'appaltatore può inserire nel contratto una **clausola penale**.

Per l'esecuzione dell'opera o del servizio l'appaltatore può a sua volta avvalersi, in tutto o in parte, di altre imprese: in questo caso si parla di **subappalto** che è un **contratto collegato o derivato**, autonomo e distinto rispetto al contratto principale, ma i cui effetti dipendono anche dalle vicende patologiche che possono interessare il contratto di appalto principale (*simul stabunt simul cadent*).

LA SUBFORNITURA: è una forma di cooperazione tra imprese, per cui aziende più grandi affidano la fornitura o la costruzione di parti di un prodotto o fasi di un processo produttivo ad altre.

Il legislatore è intervenuto per evitare situazioni di abuso che si potrebbero instaurare quando l'impresa subfornitrice ha come proprio unico cliente l'impresa committente:

- Il contratto deve avere la forma scritta a pena di nullità
- Deve indicare in maniera completa tutti gli elementi caratterizzanti la prestazione richiesta

Per il perfezionarsi del contratto è sufficiente l'inizio dell'esecuzione della prestazione specificata per iscritto nel contratto.

In generale viene sancita la nullità di ogni clausola che costituisca una posizione di abuso dello stato di dipendenza economica del subfornitore.

L'ENGINEERING: configurazione più complessa e articolata dell'appalto di servizi elaborata dalla prassi.

L'*engineering* si articola in diverse sotto figure. Parliamo infatti di:

- 1) consulting engineering, se il contratto ha ad oggetto soltanto la predisposizione del progetto industriale, architettonico o urbanistico.
- 2) commercial engineering, se il contratto ha ad oggetto anche altre operazioni accessorie
- 3) engineering "chiavi in mano", se l'oggetto è la consegna al committente del prodotto finito e funzionante.

APPALTI PUBBLICI: quando il committente è un ente pubblico che assume la denominazione di stazione appaltante.

Quando il valore dell'appalto supera una certa soglia, la normativa europea impone che si bandisca una gara aperta alla partecipazione di imprese.

La stipula dell'appalto pubblico con un'impresa scelta a **trattativa privata** costituisce l'eccezione ed è possibile limitatamente al caso in cui l'impresa assegnataria dall'appalto pubblico sia la sola in grado di offrire il bene o il servizio richiesti.

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: (disciplinato dal codice dei contratti pubblici) è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la realizzazione di un complesso di attività in cambio della disponibilità del bene realizzato e il suo sfruttamento economico. (es. lo Stato affida ad un privato la costruzione di una autostrada in cambio della riscossione del pedaggio per un periodo determinato).

CONTRATTO D'OPERA E CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

CONTRATTO D'OPERA: (art. 2222 c.c.) si ha quando una parte si obbliga a compiere un'opera o un servizio e l'altra parte a pagare un corrispettivo.

A differenza dell'appalto il prestatore non è un'impresa ma un **lavoratore autonomo** e secondo la giurisprudenza può essere anche una **piccola impresa**.

È un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, non formale, basato sull'*intuitu personae*.

Il prestatore d'opera non ha vincoli di subordinazione e quindi si distingue dal **lavoratore subordinato**, che è invece un dipendente.

In larga misura la disciplina è analoga a quella dell'appalto:

- Il lavoratore è tenuto ad un risultato e ad eseguire l'opera a regola d'arte, altrimenti il committente potrebbe fissare un certo termine per conformarsi alle sue istruzioni se non lo avesse fatto, scaduto il quale il committente può recedere dal contratto, salvo diritto al risarcimento del danno
- Una volta ultimata e accettata l'opera il committente non può denunciare difformità o vizi che fossero noti o facilmente riconoscibili

- Nel caso di vizi occultati, il committente deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta
- Una volta accettata l'opera il prestatore ha diritto al corrispettivo che, in caso di impossibilità sopravvenuta alla realizzazione dell'opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti, è ridotto in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta
- In caso di recesso del committente esso è tenuto alle spese, alla parte di lavoro eseguito e al mancato guadagno del prestatore

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE: in questo caso il prestatore è un **professionista intellettuale**.

Se è richiesta dalla legge l'iscrizione a speciali albi per l'esercizio dell'attività, la mancata iscrizione non consente al professionista di agire e l'intero contratto sarebbe nullo per mancanza di capacità e impedirebbe al professionista di avvalersi dell'applicazione della disciplina dell'**obbligazione naturale**.

Il professionista si libera provando di essersi comportato con la diligenza del buon professionista.

Se la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (medico), il professionista risponderà solo per **dolo o colpa grave**.

Alcune professioni intellettuali hanno dei regimi di responsabilità particolari in ragione della funzione che il professionista svolge nei confronti della società:

- **Responsabilità del notaio:** ha una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei clienti, e extracontrattuale nei confronti dei terzi che abbiano ricevuto un concreto danno a causa del comportamento colposo o doloso del notaio.
- **Responsabilità dell'avvocato:** tale responsabilità è determinata non in virtù degli esiti del processo ma in base alla diligenza professionale impiegata nell'assolvere l'incarico affidato dal cliente ed è pertanto di natura contrattuale. La responsabilità dell'avvocato viene determinata anche in termini deontologici, quindi anche per i comportamenti dell'avvocato tenuti al di fuori dallo stretto esercizio della sua professione.

Il carattere dell'*intuitu personae* giustifica il **recesso del cliente** senza giustificazione, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del compenso per l'opera prestata fino a quel momento.

Il **recesso del professionista** è invece limitato ai soli casi in cui ricorra una **giusta causa** e il suo esercizio non deve arrecare pregiudizio al cliente.

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

La caratteristica fondamentale del contratto di lavoro subordinato è rappresentata dalla **subordinazione**: il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga verso una retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).

La subordinazione si basa dunque sulla soggezione del prestatore alle decisioni e alle direttive del datore di lavoro, e quindi al suo **potere gerarchico e disciplinare**.

Altre caratteristiche fondamentali sono:

- Inserzione del prestatore nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro
- Versamento della retribuzione a scadenze fisse
- Vincolo dell'orario di lavoro

- Previsione di ferie

Il contratto di lavoro è variamente regolamentato da una molteplicità di fonti:

- Carta costituzionale: art. 36 c.c. garantisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e sufficiente ad offrire a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa
- Diritto europeo
- Legge
- Contratti collettivi: ossia accordi stipulati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti: tradizionalmente i compensi retributivi sono stabiliti dai contratti collettivi e l'autonomia individuale può derogare a questa disciplina solo verso l'alto, ossia in senso più favorevole

Il **datore di lavoro** non deve essere necessariamente un'impresa, ma può essere anche un privato non imprenditore o un ente pubblico: in quest'ultimo caso alle regole privatistiche disciplina del contratto si aggiungono le regole amministrative e il lavoratore dipendente potrà assumere anche la qualità di **pubblico ufficiale**, con un aggravamento delle proprie responsabilità.

I lavoratori vengono distinti in quattro categorie:

- 1) **Dirigenti**: che sono collocati al vertice della scala
- 2) **Quadri**
- 3) **Impiegati**
- 4) **Operai**

Il rapporto di lavoro subordinato può essere **a tempo indeterminato**, cioè senza durata prefissata, o **a tempo determinato**, al quale può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi e in alcune circostanze a 24 mesi.

Forma: il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è in genere assoggettato ad alcun vincolo di forma, tranne in alcuni rapporti speciali come il lavoro marittimo e sportivo, dove la forma scritta è richiesta a pena di nullità. Per il contratto a tempo determinato è sempre richiesta la forma scritta.

Estinzione del rapporto di lavoro:

- **Contratti a tempo determinato**: non è consentito ad alcuna delle parti di recedere liberamente, ma ciascuna di esse può recedere anticipatamente senza necessità di preavviso se sopravviene una **giusta causa**, cioè *una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto*.
- **Contratti a tempo indeterminato**: inizialmente ciascuna delle parti poteva recedere **ad nutum** (senza bisogno di giustificazione) dal rapporto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso sostituibile con un'**indennità** corrispondente alla retribuzione che sarebbe stata percepita qualora durante il periodo di preavviso il rapporto fosse continuato. Successivamente tale disciplina fu profondamente innovata dal legislatore:
 - Il lavoratore è tutt'ora libero di recedere in un qualsiasi momento dal rapporto, senza bisogno di dare giustificazioni, con il solo onere di preavviso. Il preavviso non è necessario nel caso di giusta causa.

- Il **licenziamento *ad nutum*** da parte del datore di lavoro può avvenire solo in alcuni casi, fermo onere di preavviso. In ogni altro caso il datore di lavoro può recedere solo se ricorre:
 - a) **Giusta causa:** che può integrare anche un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali oppure un qualsiasi altro fatto, anche esterno al rapporto, tale da determinare il venir meno della fiducia del datore di lavoro.
 - b) **Giustificato motivo soggettivo:** notevole adempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
 - c) **Giustificato motivo oggettivo:** è costituito da ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro.

In ipotesi di accertata illegittimità di un **licenziamento individuale**, non sempre si ha il ripristino del relativo rapporto e bisogna distinguere tra:

- **Tutela reale:** si ha la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; fermo restando il diritto del lavoratore di richiedere, in sostituzione della reintegrazione, un'indennità sostitutiva.
- **Tutela obbligatoria:** consiste nel diritto del dipendente licenziato illegittimamente a ottenere una somma di denaro a titolo di risarcimento (indennità).

Diverso dal licenziamento individuale è il **licenziamento collettivo**, che si tratta dell'ipotesi in cui il datore di lavoro intenda procedere al licenziamento di una pluralità di lavoratori.

Il trasferimento dell'azienda non costituisce motivo di licenziamento, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cessionario risponde in **solido** con il cedente per tutti i crediti che il lavoratore ceduto vantava al momento del trasferimento.

I CONTRATTI AGRARI

La formula "contratti agrari" è utilizzata per indicare il rapporto contrattuale tra il **proprietario di un fondo agricolo** e un **imprenditore agricolo o coltivatore diretto (contratti di scambio o affitto)**. In questa nozione rientravano anche i **contratti di natura associativa** (mezzadria, soccida, ...), dove creandosi una legame tra proprietario e sfruttatore del fondo, la responsabilità nella gestione dell'attività agricola ricade sia sul proprietario che concede il godimento del fondo sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa. In tema di contratti di natura associativa la l. 203/1982 ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto di fondo rustico (i primi).

Prendiamo in esame i contratti di affitto di fondo rustico: costituisce una *specie* del più generale contratto di **affitto** e prevede che una parte, il **concedente**, consegni un fondo all'altra parte affinché lo coltivi e ne ricavi i frutti, verso il pagamento di un corrispettivo.

La legislazione speciale cerca soprattutto di favorire i contratti con i c.d. **coltivatori diretti**, ovvero coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia.

La durata minima del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto è di 15 anni, consentendo però alle parti di prevedere anche una durata inferiore.

L'affittuario può recedere dal contratto con l'onere di preavviso, mentre il concedente può chiedere la risoluzione in caso di grave inadempimento dell'affittuario.

Per quanto riguarda la disciplina dei **miglioramenti** e delle **addizioni** si discosta da quella generale in tema di locazione, salvaguardando soprattutto gli investimenti fatti dal coltivatore diretto di cui il concedente potrà giovare.

È riconosciuto a favore dell'affittuario coltivatore diretto il **diritto di prelazione** a parità di condizioni in caso di vendita del fondo a terzi. Se il proprietario viola il diritto di prelazione, l'affittuario può conseguire la proprietà del fondo (c.d. **retrato**) anche nei confronti dell'acquirente che ne abbia acquistato la proprietà.

Sono vietati i contratti di subaffitto, sublocazione o comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffitto e la risoluzione del contratto di affitto con la restituzione del fondo.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO

Con il **contratto di trasporto** ci si obbliga ad un *facere*, in quanto il vettore di obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

È un contratto a **prestazioni corrispettive**, essenzialmente **oneroso** e a forma libera.

Il codice civile disciplina prevalentemente il trasporto terrestre, mentre gli altri tipi di trasporto sono disciplinati da norme speciali.

Due fattispecie di trasporto diverse:

- **Trasporto di persone:** obbedisce alla funzione di spostamento fisico da un luogo all'altro. Il vettore è responsabile non solo per i danni che subiscano il trasportato o le cose che viaggiano con lui, ma anche per il solo ritardo, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. È riconosciuta la possibilità al trasportato di agire in giudizio sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale. La responsabilità del vettore non muta nel caso di **contratto gratuito di trasporto**; mentre nel **trasporto di cortesia** (autostop), essendo in mancanza di un contratto, il vettore risponde in via extracontrattuale e quindi l'onere della prova dell'esistenza del danno è in capo al trasportato.
- **Trasporto di cose:** il contratto si conclude tra il mittente e il vettore e ha la struttura del contratto a favore del terzo (destinatario). Fino a quando le cose non sono passate nella disponibilità del destinatario, il mittente può intervenire nei confronti del vettore (**diritto di contrordine**), sospendendo il trasporto, modificando il destinatario, chiedendo la restituzione delle cose, salvo rimborso spese. La **responsabilità del vettore** per la perdita o l'avaria delle cose è molto ampia, infatti può esonerarsi solo provando il caso fortuito, oppure i vizi delle cose trasportate, la colpa del mittente o del destinatario. Egli deve assumere pertanto tutte quelle iniziative che possano limitare i danni. Una volta che le cose giungono al destinatario che le accetta senza riserve, non sono più esperibili azioni nei confronti del vettore, salvo che se ne provi il dolo o la colpa grave.

Nei **pubblici servizi di linea** il vettore opera in regime di **monopolio** o **oligopolio**, in virtù di una **concessione amministrativa**, ed è obbligato a contrarre con tutti e a parità di condizioni.

IL CONTRATTO DI DEPOSITO E I CONTRATTI DI CUSTODIA

Ai sensi dell'art. 1766 c.c. con il **contratto di deposito** il depositario assume l'obbligo della **custodia** della cosa che gli viene consegnata e della restituzione della stessa cosa.

È un contratto reale, naturalmente gratuito, avente ad oggetto **beni infungibili**.

Il depositario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e per essere esente da responsabilità, deve provare che i danni, la perdita e ogni altro evento che danneggi il bene custodito o ne renda impossibile la restituzione sia dovuto a causa a lui non imputabile.

Nel **deposito di cortesia**, il depositario, in mancanza di un vincolo contrattuale, risponderà a titolo di responsabilità da fatto illecito.

Al depositario non possono essere imputate responsabilità quanto alla provenienza illecita dei beni oppure sulla titolarità o meno del depositante sui beni, salvo che non ne sia a conoscenza ed abbia omessi di presentare denuncia.

Egli deve restituire la cosa al depositante che gliela richiede, ma se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo, è necessario pure il consenso di quest'ultimo.

Il depositario è tenuto solo alla custodia del bene, perciò se intende servirsene o darla in subdeposito deve essere autorizzato dal depositante.

Nel **deposito irregolare**, quindi quando le cose sono costituite da **denaro** o **beni fungibili**, il depositario può servirsene, ne acquista la proprietà e deve restituire altrettante cose della stessa specie e qualità: in questo caso viene meno la causa di custodia e infatti il codice rinvia alla disciplina del **mutuo**.

IL DEPOSITO IN ALBERGO

Innanzitutto con il termine "albergo" il legislatore intende ogni struttura in grado di ospitare persone fisiche.

La responsabilità dell'albergatore è diversamente regolata a seconda di:

- **Cose portate in albergo (art. 1783 c.c.):** sono quelle cose di cui l'albergatore assume la custodia in ragione del contratto stesso d'albergo.
La responsabilità in questo caso è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino ad arrivare *all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggiato per la giornata*. Spetterà ovviamente al cliente provare e quantificare il valore delle cose.
- **Cose consegnate in custodia (art. 1784 c.c.):** il cliente in questo caso consegna le cose ai fini della loro custodi, perfezionando quindi un contratto di deposito vero e proprio.
L'albergatore potrà liberarsi dalla responsabilità se prova che il danno si è verificato per causa di forza maggiore, per la colpa del cliente o se il cliente ha denunciato con un ritardo ingiustificato il loro deterioramento, distruzione o sottrazione.
Sono **nulli** i patti che abbiano come scopo la limitazione della responsabilità dell'albergatore.

IL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

Il depositario è responsabile della custodia delle merci che vengono depositate in questi magazzini, se non prova che la perdita o avaria è dipesa da caso fortuito, dalla natura delle merci, dai vizi delle merci o dall'imballaggio.

Il depositario è autorizzato a vendere la merce dopo aver avvisato il depositante se non viene ritirata al termine del contratto o se rischia di deteriorarsi.

La **fede di deposito** e la **nota di pegno** sono titoli di credito all'ordine che consentono a chi ne è legittimato di ottenere dal depositario la restituzione della merce.

IL SEQUESTRO CONVENZIONALE

Nel **sequestro convenzionale** due o più persone affidano ad un terzo una o più cose, rispetto alle quali sia in atto una controversia, affinché le custodisca e poi le restituisca, alla fine della controversia, alla persona cui spettano (artt. 1798-1799 c.c.).

Il sequestratario, prima della conclusione della controversia, può essere liberato solo dall'accordo delle parti o per giusti motivi, salvo il rimborso delle spese affrontate.

Non ha nulla a che vedere questa fattispecie con il **sequestro conservativo**, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale a beneficio del creditore.

IL CONTRATTO D'ALBERGO

Il contratto di albergo è un **contratto atipico**, con **causa mista**, perché non ha una disciplina legislativa organica e nella sua causa si fondono cause proprie di altri contratti: secondo la **teoria dell'assorbimento** trova applicazione la normativa riferita a quella causa che prevale.

Per quanto riguarda la modalità di conclusione, nella giurisprudenza di legittimità vi è un richiamo all'offerta al pubblico, in quanto la semplice adesione del cliente, anche tramite la prenotazione, determina il perfezionamento del contratto.

È un contratto a forma libera e può essere concluso quindi anche verbalmente, per fatti concludenti e specialmente in via telematica.

Per quanto riguarda le obbligazioni delle parti: l'albergatore sarà tenuto a fornire l'alloggio e le eventuali altre prestazioni accessorie, mentre il cliente è obbligato al pagamento del prezzo, rispettare divieti e raccomandazioni dell'albergatore, esibire il documento d'identità e rilasciare la stanza nell'orario stabilito.

IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Il codice del turismo disciplina i c.d. **contratti del turismo organizzato**, con i quali l'organizzatore (c.d. **tour operator**) vende pacchetti turistici, cioè viaggi, vacanze, crociere ecc., o meglio una serie di servizi che comprendano almeno due tra trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio ad un **turista** per un prezzo forfettario (cioè in misura fissa, precedentemente convenuta). L'operazione può essere ben più complessa perché il "venditore" può essere a sua volta un cedente di "pacchetti" standardizzati già da lui acquistati, oppure di pacchetti in qualche modo personalizzati.

Il **contratto di pacchetto turistico** è misto, perché la causa è unitaria seppure in essa confluiscono elementi di vari contratti tipici e atipici. Deve avere forma scritta e, secondo la giurisprudenza, sotto pena di nullità. D'altro canto una tale prescrizione riguarda tutti i rapporti contrattuali con il consumatore.

Il turista-consumatore ha rapporti diretti col venditore e quindi la legge si preoccupa di tutelarlo obbligando quest'ultimo ad indicare nel contratto tutta una serie di informazioni riguardanti il contenuto del pacchetto turistico, le modalità del viaggio, i prezzi, l'itinerario, le visite e tutto ciò che riguarda il viaggio, quali sono le spese non comprese nel corrispettivo, ed altri elementi ancora. Il turista, anche nella fase delle trattative, deve essere informato compiutamente dei diritti che gli spettano e delle modalità di esercizio di tali diritti e di ogni altra notizia utile, il tutto contenuto in

un opuscolo che gli deve essere consegnato, salvo che le stesse informazioni non siano fornite per via telematica.

Un'importante tutela offerta al turista è quella riguardante la **immodificabilità del prezzo nei venti giorni antecedenti la partenza del viaggio** oppure può essere espressamente prevista dal contratto e non può essere superiore del 10% rispetto al prezzo originario, altrimenti il turista può recedere con diritto a ottenere il rimborso di quanto pagato.

Qualora prima della partenza si renda necessario modificare alcuni elementi importanti del contratto, tali elementi devono essere portati a conoscenza del turista per iscritto, indicando quale sia l'alternativa offerta. Se il turista non accetta ha diritto di recedere senza penalità; se il problema si verifica a viaggio iniziato, l'operatore deve offrire delle alternative senza alcun aggravio economico, anzi restituendo parte del corrispettivo se l'alternativa è meno costosa rispetto alla prestazione originaria. Se il turista non accetta le soluzioni alternative proposte dall'operatore, può recedere, con diritto ad essere riportato nel luogo di partenza o altrove, con rimborso della differenza tra le prestazioni eseguite e quelle no, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti. L'organizzatore o l'intermediario, in caso di mancato o inesatto adempimento, sono tenuti a risarcire i danni al turista secondo le rispettive responsabilità, salvo che i danni siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, o fatto del terzo.

I danni alla persona sono risarciti nei termini e secondo le condizioni stabiliti dalle normative internazionali ed è nullo ogni patto che tenda ad escludere o limitare tale responsabilità che si prescrive in tre anni dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza; invece, per i danni diversi da quelli alla persona le parti possono convenire limiti di risarcimento nel contratto, che però, sotto pena di nullità, non possono portare ad importi inferiori a quelli previsti nelle convenzioni internazionali.

Ad ogni modo, il turista che abbia riportato danni fisici deve essere immediatamente soccorso e messo in grado di poter proseguire il viaggio, altrimenti deve essere risarcito per i danni patiti, che terranno conto anche del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell'irripetibilità dell'occasione perduta (c.d. **danno da vacanza rovinata**). In ogni caso, l'organizzazione e l'intermediario devono aver stipulato adeguate assicurazioni contro i danni a persone e cose.

IL CONTRATTO DI MULTIPROPIETÀ

È negli anni settanta del secolo scorso che inizia a diffondersi in Italia l'istituto della multiproprietà, consentendo la disponibilità di un appartamento, soprattutto in luoghi di villeggiatura e di turismo, per una durata prefissata per un certo numero di anni.

È ancora fortemente dibattuto quale sia la natura giuridica dell'istituto: due teorie si contrappongono. Una prima qualifica la multiproprietà come una **comunione**, la seconda come **proprietà individuale**. La teoria della comunione evidenzia che tra i comproprietari vige un accordo che consente il godimento turnario dell'immobile tra loro secondo le modalità ivi stabilite; nel contempo un regolamento di condominio consente il godimento delle parti comuni. La teoria della proprietà individuale, invece, configura un diritto di proprietà sui generis, il cui oggetto sarebbe costituito non dall'immobile ma dal tempo e dal bene tra loro interagenti: ma appare difficile, in verità, conciliare questa teoria con quei caratteri di pienezza ed esclusività propri del diritto di proprietà.

Esistono poi la c.d. **multiproprietà azionaria** e la **multiproprietà alberghiera**. Nel primo caso, l'immobile nella sua interezza è di proprietà di una società per azioni, di cui il multiproprietario diventa socio, acquisendo il diritto di uso esclusivo secondo il turno stabilito. La multiproprietà alberghiera è caratterizzata dal fatto che al godimento dell'immobile si accompagna anche la prestazione di alcuni servizi alberghieri.

Il codice del consumo si preoccupa esclusivamente di tutelare compiutamente il consumatore multiproprietario. Si definisce **contratto di multiproprietà** quello *“di durata superiore ad un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”* e **contratto accessorio** quello collegato al contratto di multiproprietà con il quale l’operatore si obbliga a fornire particolari servizi. Sull’operatore incombono specifici obblighi informativi precontrattuali, secondo il principio generale di buona fede, che il legislatore sviluppa nell’obbligo di fornire “al consumatore in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficiente”.

Tali informazioni sono scritte in un formulario informativo standardizzato a livello europeo, indicante i dati identificativi del venditore o proprietario (se diversi), dell’alloggio, “la natura delle condizioni di esercizio di tale diritto”, cioè se reale o obbligatorio, le condizioni e modalità del diritto di recesso ecc. Le informazioni contenute nel formulario integrano il contenuto del contratto e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti oppure in conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e inevitabili da parte dell’operatore neanche con “la dovuta diligenza”.

Il contratto deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità, in lingua italiana o altra del luogo dove risiede il multiproprietario.

L’acquirente ha **diritto di recesso** dal contratto, entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza dover motivare e senza penalità né spese, neanche con riguardo al valore del servizio di cui si sia eventualmente usufruito prima della conclusione. Inoltre, *“sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell’operatore”*.

In conclusione, si tratta di una normativa che tutela compiutamente il consumatore multiproprietario nei confronti dell’operatore, il più delle volte una multinazionale che altrimenti avrebbe potuto approfittare della propria posizione di contraente forte.

CAPITOLO XXIII

I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DI CONTO CORRENTE E BANCARI

IL MUTUO E I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il **mutuo** è il contratto col quale una parte (**mutuante**) consegna all'altra (**mutuatario**) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. (**art. 1813 c.c.**)

Esso è il normotipo dei **contratti di finanziamento**, cioè il tipo contrattuale di riferimento per quelle operazioni nelle quali le banche e intermediari finanziari danno denaro o altre utilità economiche a imprese o persone fisiche, secondo particolari condizioni e termini. Questa categoria comprende sia contratti tipici, sia contratti atipici.

Il mutuo è un **contratto reale**, in quanto si perfeziona con la consegna del denaro nelle "mani del mutuatario, che ne diventa proprietario, quindi si tratta anche di un **contratti ad effetti reali**.

È un **contratto di durata**, perché il mutuatario ha la disponibilità delle cose per un certo periodo di tempo.

Il termine della restituzione, sia esso concordato dalle parti o fissato dal giudice, è essenziale e questa rigidità trova un'attenuazione solo nel caso in cui, se le cose prestate sono diverse dal denaro e, per causa non imputabile al mutuatario, la loro restituzione è divenuta impossibile o di difficile attuazione, il mutuatario può liberarsi offrendone il valore. Ciò non include anche il rischio di aumento del valore delle cose.

Una causa di risoluzione del contratto è il **mancato pagamento degli interessi**, infatti, ai sensi dell'art 1820 c.c. *se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto*.

Il mutuo quindi è naturalmente oneroso, ma può essere anche gratuito.

La misura degli interessi è quella legale, ma se si tratta di **interessi usurari** (cioè di importo superiore al **tasso soglia** pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (ciò riguarda tutti i contratti di finanziamento).

Qualora gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto erano di importo inferiore al tasso soglia, ma nel corso del rapporto hanno superato tale soglia in ragione di un abbassamento di quest'ultima, non determina la nullità.

Per quanto riguarda la responsabilità del mutuante, egli dovrà risarcire i danni sofferti dal mutuatario per i vizi delle cose prestate, salvo che provi di averli ignorati senza sua colpa, ma in caso di mutuo gratuito risponderà solo se non ne ha informato il mutuatario.

Le parti possono convenire che la restituzione avvenga **ratealmente**, in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata consente al mutante, secondo le circostanze, di richiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c.).

"Secondo le circostanze" sta a significare che il mutuatario può chiedere al giudice di valutare se una tale facoltà non si risolva in **abuso del diritto**, quindi è il giudice a valutare caso per caso se la richiesta di richiedere il pagamento dell'intero si giustifichi effettivamente a tutela del proprio credito oppure aggravi soltanto la situazione del debitore con conseguenze dannose anche collaterali: tutto questo a tutela del cliente.

Una fattispecie particolare di mutuo è il c.d. **mutuo di scopo**, dove accanto all'obbligazione di restituire con gli interessi la somma ricevuta, il mutuatario si obbliga anche a destinare detta somma al raggiungimento di un determinato obiettivo (es. acquisto di una casa). La mancata destinazione della somma allo scopo può dar luogo alla risoluzione per inadempimento.

La fattispecie ricorre in particolare negli aiuti pubblici alle imprese e nei c.d. **crediti speciali**.

Assume una peculiare configurazione il **prestito vitalizio ipotecario**, che si tratta di un contratto riservato alle banche e agli intermediari finanziari, con il quale viene concesso un finanziamento a persone fisiche di età superiore ai 60 anni garantito da un'iscrizione ipotecaria su di un bene immobile e si configurare causalmente come un **mutuo garantito da ipoteca**.

LA LOCAZIONE FINANZIARIA

La **locazione finanziaria (o leasing finanziario)** è quel contratto in base al quale un'impresa o un professionista (utilizzatore) chiede ad una banca o società finanziaria (concedente) di acquistare o far costruire un bene mobile o immobile, da un determinato fornitore o appaltatore, di metterglielo a disposizione per un certo periodo di tempo, dietro versamento di un corrispettivo periodico e con la previsione che alla scadenza potrà acquistarne la proprietà con il pagamento di un prezzo prestabilito.

Quindi il contratto è caratterizzato da un punto di vista:

- Soggettivo: il concedente deve essere una **banca o una società finanziaria** e l'utilizzatore deve essere un'**impresa o un professionista**.
- Oggettivo: i beni devono essere strumentali all'esercizio dell'attività di impresa o professionale

Il bene e il fornitore (o appaltatore) sono scelti dall'utilizzatore che assume tutti i rischi attinenti al bene per vizi, difetti e anche in caso di perimento dovuto a causa non imputabile all'utilizzatore stessi: in sostanza in condente è un mere intermediario finanziario.

L'operazione si struttura secondo lo schema del **collegamento negoziale** che intercorre tra:

- **Contratto di compravendita (o appalto)** che intercorre tra il concedente e il fornitore (o appaltatore)
- **Contratto di locazione finanziaria vero e proprio** che intercorre concedente e utilizzatore

La locazione finanziaria ha una **causa di finanziamento**, perché la messa a disposizione del bene all'utilizzatore è finalizzata al finanziamento della sua attività produttiva: il beneficiario, piuttosto di stipulare un mutuo con una banca per acquistare il bene, chiede alla banca stessa di acquistarlo e metterglielo a disposizione.

Il contratto di leasing (o locazione finanziaria) è un contratto atipico, che ricalca il contratto di locazione, ma che si distingue da questo per la presenza di tre parti, ma lo si può considerare anche un contratto nominato per via della presenza di una completa disciplina fiscale e per il fatto che è stato più volte menzionato in provvedimenti legislativi.

Nonostante tutti questi interventi legislativi, la giurisprudenza discute su quale disciplina debba applicarsi nel caso della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; così si è introdotta da tempo una distinzione tra:

- **Leasing traslativo**: quando la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateizzazione del prezzo (riserva di proprietà), dove è applicabile l'art. 1526 c.c., che disciplina l'ipotesi della vendita con riserva di proprietà e che in caso di **risoluzione per inadempimento del compratore**, il venditore deve restituire le rate ricevute, ma ha diritto alla restituzione del bene, al risarcimento del danno e all'equo compenso per l'uso dello stesso.

- **Leasing di godimento:** se lo scopo del contratto è solo quello di consentire l'impiego temporaneo del bene da parte dell'utilizzatore. In questo caso è applicabile la disciplina propria dei contratti di durata (l'art. 1458 c.c.)

La l. 208/2015 disciplina il **contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale**.

In questo caso il concedente (una banca o intermediario finanziario) acquista o fa costruire un immobile destinato ad abitazione, scelto dall'utilizzatore (che è un consumatore), il quale se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo riceve in uso per un determinato periodo di tempo e con la previsione che alla scadenza potrà acquistarlo pagando un prezzo predeterminato.

La differenza evidente rispetto alla locazione finanziaria è che l'utilizzatore non è un'impresa o un professionista e il bene è un immobile destinato ad abitazione principale, e non un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa.

Un richiamo specifico alla locazione finanziaria si trova anche nella disciplina legislativa del **contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili**, il c.d. **rent to buy**.

Si tratta di un contratto che condivide la causa di godimento della locazione, ma nel contempo riserva al conduttore la facoltà di acquistare la proprietà del bene col pagamento dei canoni, qualora le parti si accordino che il canone pagato per una quota sia imputata a corrispettivo dell'eventuale vendita e per la restante quota a titolo di godimento del bene.

Se il contratto si risolve per inadempimento del concedente questi deve restituire la parte imputata a corrispettivo della vendita;

se l'inadempimento è del conduttore, il concedente può trattenere a titolo di indennità anche la quota imputata al corrispettivo della vendita.

Una fattispecie peculiare di locazione finanziaria è il **sale and lease back** (o locazione finanziaria di ritorno): un'impresa vende un proprio bene produttivo al concedente che contestualmente glielo cede in locazione finanziaria. È evidente l'esigenza di ottenere liquidità da parte dell'impresa utilizzatrice, senza rinunciare però a disporre del bene necessario.

L'eventuale inadempimento dell'utilizzatore-debitore autorizza pertanto al concedente a trattenere in proprietà il bene: per escludere che ciò si tratti di un patto commissorio la giurisprudenza ha statuito che è necessario verificare se l'operazione sia orientata

- **Alla garanzia**
- **Al finanziamento**

In questi casi si esclude l'esistenza di un patto commissorio e la disciplina applicabile sarà quella di una ordinaria locazione finanziaria.

LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA

La **cessione dei crediti di impresa (factoring)** è quell'operazione finanziaria nella quale un'impresa cede i propri crediti presenti e futuri verso corrispettivo ad una banca o società finanziaria che li acquista anticipandone l'importo e assume l'obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi variamente combinati in relazione alle richieste e alle esigenze del cedente che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento.

La legge che lo prevede è la l. 52/1991, che prevede che per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione la normativa del codice civile in tema di cessione dei crediti.

L'operazione è caratterizzata:

- Sul piano soggettivo: il cedente deve essere un'impresa o un lavoratore autonomo (non un privato consumatore), il cessionario deve essere una banca o un intermediario vigilato ai sensi del t.u.b.
- Sul piano oggettivo: possono essere ceduti solo crediti che sorgono da contratti stipulati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale. Questi crediti presenti e futuri devono sorgere in 24 mesi e contrariamente alla regola generale per cui la proprietà dei beni futuri si trasferisce solo quando vengono ad esistenza, la proprietà si trasferisce immediatamente dal cedente al cessionario (se il debitore è determinato).

La cessione può avvenire in due modi:

- Pro soluto, il *factor* (il cessionario) si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente. (regola)
- Pro solvendo, lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti. (eccezione, se viene accordata dalle parti)

La sostituzione del creditore tuttavia dev'essere comunicata al debitore ceduto il quale altrimenti potrebbe eseguire il pagamento al vecchio creditore liberandosi legittimamente dell'obbligazione debitoria.

Il factoring viene qualificato come un contratto atipico.

Alla **causa di vendita** manifestata dal "verso corrispettivo" si accompagna la **causa finanziaria** ed anche la **causa gestoria** propria del mandato, secondo lo schema di un **contratto misto**.

Un istituto analogo al *factoring* è la **cartolarizzazione**.

IL FORFAITING

Il forfaiting è una tecnica per chi esporta all'estero. Si può chiedere a una banca o società finanziaria (= *forfaiter*) di ottenere subito un anticipo sul venduto, attraverso la cessione dei titoli collegati. Quando l'importatore inizierà a pagare a rate, con le stesse l'azienda pagherà la banca.

Quindi i soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- L'**importatore** (debitore estero)
- L'**esportatore** (creditore nazionale)
- Società finanziaria o banca specializzata nello sconto di titoli di credito che generalmente sono **cambiali tratte internazionali, vaglia cambiari o lettere di credito**

IL PROJECT FINANCING

Il **project financing** è una complessa operazione di finanziamento di un progetto di investimento, che una volta realizzato, è in grado non solo di rimborsare ma anche di remunerare il finanziatore. Il compito dell'esecuzione del progetto viene affidata alla società di progetto e svolge un ruolo di controparte dei finanziatori e di tutti gli altri soggetti coinvolti.

Il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi di opere pubbliche, o opere di pubblica utilità, in vista di entrate economiche future rappresenta la caratteristica principale del *project financing*.

IL CREDITO AL CONSUMO

Con l'espressione **credito al consumo** ci si riferisce a quei contratti stipulati tra le banche o intermediari finanziari ed i consumatori.

La presenza come parte contrattuale del consumatore giustifica il rafforzamento di quegli obblighi che fanno capo alle banche e agli intermediari finanziari nei rapporti con il consumatore stesso.

Infatti, nella fase precontrattuale, al consumatore vanno fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole informazioni attinenti alla regolamentazione del credito di consumo, ispirandosi ai criteri di trasparenza, chiarezza e completezza, in modo che il consumatore abbia una conoscenza ampia del contratto che andrà a stipulare.

La legge prescrive che ancor prima della conclusione del contratto la banca/intermediario deve valutare le esigenze del cliente e la sua situazione finanziaria, in quanto spetta del loro c.d. **merito creditizio** ossia dell'idoneità del consumatore a restituire il finanziamento ricevuto.

Il contratto deve avere forma scritta sotto pena di nullità e contenere tutte le condizioni giuridiche ed economiche che regola il rapporto.

Quando il contratto di credito è finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico viene definito **contratto di credito collegato**.

In caso di risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento del fornitore, si risolve anche il contratto di credito e il finanziatore dovrà rimborsare al consumatore le rate già pagate.

Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto.

I CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO

Si tratta di **contratti aleatori** dove si "scommette" sull'andamento e la variazione di titoli, valute e quant'altro (come le azioni di una società quotata in Borsa) in un arco di tempo e alla scadenza di determinerà chi avrà guadagnato e chi perso nella differenza tra il prezzo di vendita e quello di riacquisto (es. *swap*).

Questo contratto viene concluso tra l'intermediario e il risparmiatore consumatore.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità e prima della sottoscrizione l'intermediario deve procedere ad una sorta di istruttoria della situazione economica del cliente, nonché del grado di conoscenza che il consumatore ha del mercato finanziario.

Il legislatore prevede l'inversione dell'**onere della prova**, imponendo all'intermediario, chiamato in giudizio dall'investitore per il risarcimento dei danni patiti, la prova di aver agito con la diligenza specificamente richiesta in quel caso.

IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO

Art 1823 c.c.: Il contratto di conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili o indisponibili fino alla chiusura del conto.

Questo tipo di contratto è stipulato, di regola, tra imprenditori che intrattenendo reciproci rapporti commerciali, hanno anche reciproci rapporti di credito e debito. Essendo stipulato generalmente tra imprenditori lo si denomina **ordinario**, per distinguerlo dal **conto corrente bancario**, dove il credito è sempre esigibile dal correntista.

Con il conto corrente si agevola la compensazione tra debiti e crediti e se alla chiusura vi è una differenza (saldo), questa verrà corrisposta da chi risulterà debitore.

L'inesigibilità di tali crediti non comporta la limitazione della facoltà di esercitare le azioni e le eccezioni relative agli atti che sono fonte dei crediti inclusi nel conto (art. 1827 c.c.).

I CONTRATTI BANCARI

Le banche sono imprese che esercitano l'**attività bancaria**. Per attività bancaria si intende la **raccolta di risparmio** tra il pubblico e l'**esercizio del credito**, ossia la concessione di prestiti alla clientela.

Le banche possono operare solo se abbiano ottenuto una particolare autorizzazione e siano iscritte nell'apposito Albo, curato dalla Banca d'Italia.

Alcune regole generali sui contratti bancari sono:

- **Trasparenza delle condizioni dei contratti bancari:** le banche sono tenute a dare pubblicità a tutti gli elementi economici dei servizi e prodotti offerti alla clientela, come tassi di interesse, prezzi, spese ecc.
- I contratti con i clienti devono essere stipulati, a pena di nullità, **per iscritto** (consegnandone una copia al cliente) in modo da consentire piena conoscenza di tutte le singole clausole
- Sono nulle le clausole che prevedano condizioni per il cliente più sfavorevoli di quelle pubblicizzate e non è possibile far riferimento ad **usi bancari**
- Sono previste anche alcune restrizioni alla facoltà delle banche di riservarsi uno **ius variandi**, ossia la facoltà di modificare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse o qualsiasi altra condizione economica; è ammissibile la pattuizione della facoltà di modificare le condizioni di ordine economico qualora sussista un giustificato motivo.
La banca deve comunque avvisare il cliente entro un certo periodo e il cliente ha in tal caso la facoltà di recedere, senza spese, dal contratto.

IL CONTO CORRENTE BANCARIO

Nel **conto corrente bancario**, come nel conto corrente ordinario, vi sono delle partite di dare e avere tra i contraenti (cliente e banca), ma differentemente il credito del cliente è sempre **esigibile**.

Il contratto è redatto in forma scritta a pena di nullità e la banca è soggetta all'obbligo di inviare al correntista periodici estratti conto del rapporto.

Il contratto di conto corrente bancario generalmente contempla servizi aggiuntivi (come pagamenti predeterminati a scadenza periodiche). In questo caso il rapporto prende il nome di **conto corrente di corrispondenza**, ossia il contratto con cui la banca assume il mandato di compiere per conto del cliente e dietro il suo ordine pagamenti e riscossioni. Si tratta di un contratto misto in cui convivono prestazioni proprie del mandato e quelle delle operazioni bancarie annotate nel conto corrente bancario.

IL CONTRATTO DI DEPOSITO BANCARIO

Il contratto di deposito bancario può distinguersi in:

- **Deposito bancario di denaro:** è un contratto reale integrante un'ipotesi di **deposito irregolare** con cui la banca depositaria acquista la proprietà del denaro depositato dal cliente e si obbliga alla restituzione di pari somma, ma non le stesse banconote.
La banca può rilasciare dei **libretti di deposito**, sui quali si annotano le operazioni di deposito e di prelievo, e possono essere:
 - Nominativi: c'è l'indicazione dell'intestatario

- Al portatore: senza alcun riferimento soggettivo

Si tratta di **documenti di legittimazione** e non di titoli di credito, perché non sono destinati alla circolazione, consentono solo all'intestatario (se nominativi) o a chi ne dispone (se al portatore) di prelevare o depositare.

- **Deposito bancario di titoli**: si tratta di **depositi regolari**, in quanto non trasferiscono la proprietà del depositante al depositario, ma la banca si obbliga a custodirli e anche ad amministrarli, cioè a curare per conto del depositante l'esercizio di tutti i diritti che gli fanno capo, usando la **diligenza del buon banchiere**. Per tale attività la banca ha diritto a un compenso.

IL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

Il **servizio di cassette di sicurezza** è un'attività tipica ma non esclusiva della banca: si tratta di un contratto misto che presenta sia la causa di custodia propria del deposito sia quella della messa a disposizione di uno spazio propria della locazione.

Il cliente non è tenuto a dichiarare quali cose e di quale valore inserisce nella cassette di sicurezza, quindi in questo modo si pone il problema del danno risarcibile alla banca: spetta pertanto al cliente dichiarare il valore di quale immesso e provare successivamente l'effettivo inserimento di quei beni nella cassetta.

Sono nulle le clausole che tendano ad escludere o a limitare la responsabilità delle banche, facendo valere la **colpa grave** in caso di furto; la banca non risponde solo per **caso fortuito e forza maggiore** (es. alluvione).

Alluvione di Firenze del 1966: condanna delle banche a risarcire i clienti le cui cassette di sicurezza erano state invase dal fango: si ritenne che le banche doveva prevedere la possibilità di alluvione data la loro vicinanza all'Arno.

L'APERTURA DI CREDITO

L'apertura di credito è un contratto consensuale a effetti obbligatori che si caratterizza per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro per una dato tempo o a tempo indeterminato. Se il cliente non utilizza la somma non deve nulla, in caso contrario la banca può fissare interessi il cui tasso non deve superare la soglia prevista dalla legge antiusura.

L'apertura di credito può essere:

- **Allo scoperto** (senza garanzie) o **garantita**, quindi assista da garanzie reali o personali a favore della banca (La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somme di denaro messa a sua disposizione), al fine di tutelarla dall'eventuale inadempimento dell'accreditato. Laddove la garanzia diminuisca diventando insufficiente la banca può richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante.
- **In conto corrente**: se al cliente è data la possibilità di prelevare e di versare sul **conto corrente bancario**.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato la banca può recedere solo per giusta causa; se è a tempo indeterminato può recedere con un preavviso determinato dal contratto, dagli usi o in mancanza di almeno 15 giorni.

L'ANTICIPAZIONE BANCARIA

L'**anticipazione bancaria** di cui all'art. 1846 c.c. è una forma particolare di apertura di credito, che si configura quando la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro a fronte della

concessione di una specifica **garanzia** da parte di quest'ultimo, consistente in un pegno su titoli o merci.

Caratteristica dell'anticipazione bancaria è la conservazione della proporzionalità tra il credito concesso e la garanzia pignorizia durante tutto il rapporto, cosicché se la garanzia diminuisce di almeno un decimo, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia, per ripristinare il criterio di proporzionalità e in mancanza si procederà alla vendita dei titoli e delle merci dati in pegno.

La differenza con l'apertura di credito è che questa può essere anche non garantita.

LO SCONTO BANCARIO

Lo **sconto bancario** è il contratto con il quale un cliente (generalmente un'impresa) cede *pro solvendo* a una banca un credito vantato verso terzi non scaduto. La banca cessionaria (detta **scontatrice**) anticipa al cedente (detto **scontatario**) l'importo del credito oggetto della cessione trattenendo per sé una parte dello stesso (appunto lo "sconto").

Il cliente così può godere subito dell'importo del credito, seppur decurtato, senza dover aspettare il termine di scadenza.

Alla scadenza la banca esige il credito dal debitore ceduto e se questi non adempie chiede allo scontatario l'importo anticipato.

Se il credito è incorporato in una cambiale o in un assegno bancario, lo sconto si effettua con la girata del titolo nei confronti della banca.

La banca scontatrice può a sua volta scontare lo stesso credito a un'altra banca con il c.d. **risconto**.

IL RIPORTO

Il **riporto** è un contratto reale e ad effetti reali con il quale una parte, il **riportato**, trasferisce a un'altra, il **riportatore**, la proprietà dei titoli di credito di una data specie e di un determinato prezzo e che si perfeziona con la consegna dei titoli. Il **riportatore** a sua volta assume l'obbligo di ritrasferire al **riportato**, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della medesima specie verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito.

Come si vede dalla definizione, abbiamo una vendita (riportato --> riportatore) di titoli. Al termine convenuto il riportato vende titoli della stessa specie al riportatore (riportato<-- riportatore).

Se queste operazioni fossero fatte "alla pari" questo contratto non avrebbe ragione di essere; in realtà bisogna verificare quanto pagherà il riportato all'altra parte al momento della restituzione dei titoli:

- Se pagherà una somma inferiore a quella sborsata in precedenza ne avrà tratto un guadagno
- Se pagherà una somma superiore a quella avuta in precedenza il riportato subirà una perdita, ma rientrerà comunque in possesso dei titoli

In caso di inadempimento di una parte, l'altra può procedere all'esecuzione coattiva/espropriazione forzata (art. 1551 c.c.).

Se entrambe le parti sono inadempienti il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.

CAPITOLO XXIV

I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE

IL MANDATO E I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE GESTORIA

Il contratto di **mandato** si configura come il normotipo di quei contratti nei quali una parte svolge un'attività nell'interesse dell'altra: la commissione, la spedizione, l'agenzia, l'affiliazione commerciale, la mediazione.

Ai sensi dell'**art. 1703 c.c.**, con il contratto di mandato una parte (**mandatario**) si obbliga a compiere nell'interesse dell'altra (**mandante**) uno o più atti giuridici.

Principali caratteri:

- L'**attività del mandatario** è circoscritta al compimento sia di negozi giuridici sia di atti giuridici non negoziali
- Il mandato può svolgersi non soltanto nell'interesse esclusivo del mandante, ma anche del mandatario (**mandato in rem propriam**) o di un terzo.
- È basato sulla **fiducia** tra il mandante e il mandatario, infatti il carattere personale del rapporto fa sì che la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario producano l'estinzione del mandato e che il mandatario che si faccia sostituire nell'esecuzione dell'incarico senza l'autorizzazione del mandante risponda dell'operato del sostituto: in questo caso si ha un'ipotesi di **submandato**.
- Il mandatario deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni del mandante, che a sua volta deve dotarlo dei mezzi necessari all'esecuzione dell'incarico. Può discostarsi dalle istruzioni solo se, in caso di eventi ignoti al mandante, il mandatario ritiene che anche il mandante avrebbe dato la sua approvazione.
- Il mandatario deve eseguire il mandato con la **diligenza del buon padre di famiglia**, avendo riguardo dell'interesse del mandante e ponendo in essere anche tutte quelle attività che sono necessarie per il corretto adempimento dell'incarico.
- Il mandatario è tenuto anche alla custodia delle cose spedite per conto del mandante, a procedere anche alla vendita dei beni, se il compratore sia inadempiente (vendita in danno) e rendicontare e a consegnare al mandante tutti i documenti di cui sia venuto in possesso in esecuzione del mandato.
- Il mandato si presume **oneroso**, pertanto il mandante deve pagare il compenso al mandatario e rimborsare anche le spese e risarcire gli eventuali danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico.

Il mandato può essere:

- **Con rappresentanza:** per fare in modo che l'attività posta in essere dal mandatario verso i terzi possa produrre effetti diretti nella sfera giuridica del mandante è necessario che questi conferisca apposita **procura** al mandatario.
- **Senza rappresentanza:** gli atti posti in essere ricadono solo nella sfera giuridica del mandatario e i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante; l'assoluta indipendenza tra il rapporto mandante-mandatario e il rapporto mandatario-terzo dà luogo alla c.d. **interposizione reale di persona**, ossia al fatto che la persona interposta (il mandatario) acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto concluso con terzo, ma ha l'obbligo di trasferirli al mandante mediante la conclusione di un altro negozio. Il mandante può tuttavia esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.

Nel mandato senza rappresentanza la disciplina degli acquisti posta in essere dal mandatario sono disciplinati diversamente a seconda che si tratti di:

- **Beni immobili o mobili registrati:** il mandatario deve trasferirli con un atto apposito e se non vi provvede il mandante può agire con l'esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.
- **Beni mobili:** se il mandatario non provvede al trasferimento è attribuita al mandante l'azione di rivendicazione, fatti salvi i diritti dei terzi secondo il principio *possessione di buona fede vale titolo*

Se il mandatario eccede dai limiti del mandato bisogna distinguere se si è in ipotesi di:

- Mandato con rappresentanza:
 - se eccede alla procura, l'atto posto in essere è inefficace e il mandatario risponde, verso il mandante per inadempimento del contratto e verso i terzi per i danni
 - se eccede il mandato ma non la procura, il mandante risponde nei confronti dei terzi, salvo il potersi rivalere nei confronti del mandatario per gli eventuali danni patiti
- Mandato senza rappresentanza: l'atto che ecceda i limiti del mandato è inefficace nei confronti del mandante, salvo che questo non lo ratifichi.

La **ratifica** è un **atto unilaterale ricettizio** con il quale si approva l'operato del rappresentante o del mandatario. La ratifica non deve rispettare determinati requisiti formale, può anche risultare da atti concludenti.

Cause di estinzione del mandato:

- **REVOCA:** è un negozio unilaterale ricettizio con effetti *ex nunc*. Può essere espressa o tacita (es. nomina di un altro mandatario). Il principio è che il mandante può sempre revocare il mandato, ma se il mandato era stato pattuito irrevocabile, salvo che ricorra una giusta causa, il mandante deve risarcire i danni al mandatario.
Se però si tratta di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo, la revoca non ha effetto, salvo che sia stato diversamente pattuito e che ricorra una giusta causa: in questo caso il mandato non si estingue neanche per morte o incapacità del mandante.
- **RINUNZIA:** la rinuncia del mandatario estingue il mandato e lo obbliga a risarcire i danni, in assenza di una giusta causa
- Per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante o del mandatario

Fino a quando il mandatario non abbia conoscenza della causa di estinzione del mandato, gli atti da lui compiuti sono validi e efficaci nei confronti del mandante; il mandatario risponde solo in caso di ignoranza colpevole dell'estinzione del mandato.

LA COMMISSIONE

La **commissione** ha, come il mandato, una **causa gestoria** in cui il **commissionario** acquista o vende in nome proprio e per conto del **committente (art. 1731 c.c.)**.

A questo contratto si applicano pertanto le regole generali per il mandato senza rappresentanza, salvo le disposizioni speciali per esso stabilite.

Il compenso che spetta al commissionario prende il nome di **provvigione**.

Se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito dell'affare, ossia risponde con il proprio patrimonio nel caso di inadempimento della persona con cui ha concluso il contratto, si dice che egli è tenuto allo **star del credere** e ha diritto a una maggiore provvigione.

Il commissionario può anche acquistare in proprio i beni, basta che non paghi un prezzo inferiore e che il committente non l'abbia vietato.

La commissione si differenzia dal contratto di agenzia, dal procacciamento d'affari e dalla mediazione perché in questi la prestazione è un'attività materiale finalizzata alla stipula di contratti futuri, mentre nella commissione l'oggetto è proprio la stipula del contratto di vendita.

LA SPEDIZIONE

La spedizione è un sottotipo del contratto di mandato in forza del quale lo **spedizioniere** si accorda con un vettore in nome proprio e nell'interesse del **mandante**.

Lo spedizioniere non deve essere quindi confuso con il vettore quale parte del contratto di trasporto. Lo spedizioniere è tenuto a rispettare le istruzioni del mandante, ma il mandante non ha nulla a che fare con il rapporto tra spedizioniere e vettore.

Lo spedizioniere ha diritto alla retribuzione per l'attività esercitata nonché al rimborso delle spese.

IL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL *trust*

Nel **contratto fiduciario**, che trova alla sua base un patto fiduciario (*pactum fiduciae*), il **fiduciante** trasferisce la proprietà di un proprio bene a un altro soggetto, il **fiduciario**, con l'obbligo per quest'ultimo di amministrarlo secondo le direttive e le finalità espresse dal fiduciante e ritrasferirlo al fiduciante stesso o a un terzo a una determinata scadenza.

Il negozio fiduciario è un istituto non regolato dal codice civile

Tradizionalmente si distingue la **fiducia dinamica**, caratterizzata dall'effetto traslativo, strumentale alla realizzazione dello scopo fiduciario, dalla **fiducia statica**, dove invece il fiduciario è già titolare del diritto e si obbliga ad esercitarlo secondo le istruzioni fiduciante.

Altra differenza è quella tra la **fiducia cum amico** e la **fiducia cum creditore**. Nel primo caso, la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e di una gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo, ulteriore trasferimento della titolarità allo stesso fiduciante ovvero ad un terzo.

Nella fiducia *cum creditore* invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore e l'interesse del fiduciante è quello di trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante se questi adempie regolarmente al proprio debito. Questa seconda tipologia esige nel nostro ordinamento un'attenta valutazione, diretta ad accertare che non si realizzi un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio.

Il c.d. *pactum fiduciae* ha rilevanza solo nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario e non può essere opposto ai terzi, per i quali, dunque, il fiduciario resta titolare dei beni amministrato con il vincolo di fiducia.

Il contratto fiduciario si distingue dal **trust**, rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato **trustee**, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato **settlor** o disponente, per uno **scopo prestabilito** o un fine, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari.

La convenzione internazionale dell'Aja consente di riconoscere nell'ordinamento italiano i *trust* costituiti in paesi diversi dall'Italia, mentre una prima apertura del *trust* interno si è avuta con l'introduzione dell'art 2645-ter c.c., che prevede come unica condizione di operabilità del *trust* interno l'onere di pubblicità dichiarativa con la trascrizione dei pubblici registri per gli atti di destinazione rivolti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

La legge “dopo di noi” ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano il *trust* quale **situazione affidante** per la gestione del patrimonio destinato a favore di soggetti disabili privi di assistenza.

IL CONTRATTO DI AGENZIA

L’**agenzia** è un contratto in cui una parte (l’**agente**) si obbliga stabilmente a promuovere la stipula di contratti per conto dell’altra parte (**preponente**).

Non vi è un rapporto di lavoro subordinato tra i due, in quanto l’agente è autonomo e esercita la sua attività in modo professionale.

L’elemento di un vincolo stabile e non occasionale consente di distinguere il contratto di agenzia rispetto alla **mediazione**.

L’agente non stipula lui stesso i contratti con i clienti per conto del proponente, ma si limita a trasmettere a quest’ultimo “gli ordini” che raccoglie nella sua zona. All’agente può essere conferito anche un potere di rappresentanza del proponente, in questo caso si ha un **agente con rappresentanza**.

Per il contratto non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, ma solo *ad probationem*.

La retribuzione dell’agente è costituita da una **provvigione** sugli affari conclusi per suo tramite.

L’agente può essere chiamato a restituire la provvigione già da lui riscossa soltanto nel caso in cui sia certo sia certo che il contratto al quale la provvigione si riferisce non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

È **nullo** qualsiasi patto più sfavorevole all’agente.

Per l’agenzia vale un **diritto di esclusiva** reciproco:

- L’agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro
- Il preponente non può nominare altri agenti nella zona assegnata ad un agente

La violazione dell’esclusività dà luogo responsabilità contrattuale.

L’agente e il preponente devono comportarsi secondo **lealtà** e **buona fede**: vi sono precisi reciproci obblighi informativi affinché il contratto possa essere correttamente eseguito e il preponente possa avere sempre il controllo della situazione e dare adeguate e tempestive istruzioni.

Il contratto d’agenzia può essere **a tempo determinato** o **a tempo indeterminato**.

Alla cessazione del rapporto l’agente può avere diritto ad un’**equa indennità** quando l’attività dell’agente abbia procurato un notevole incremento e sviluppo nell’attività del preponente.

L’indennità non spetta in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e di recesso dell’agente.

L’eventuale **patto di non concorrenza** dell’agente nei confronti del preponente per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, deve avere forma scritta *ad substantiam* e non può eccedere i due anni e deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni per i quali il contratto di agenzia era stato concluso.

A fronte di tale limitazione l’agente ha diritto ad una indennità.

LA MEDIAZIONE

L'art 1754 c.c. definisce il **mediatore** come colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Quindi le caratteristiche principali sono:

- Piena autonomia rispetto alle parti
- L'attività di mettere in relazione due o più parti, informandole anche dei fatti che possano influire sulla conclusione dell'affare

Il mediatore ha diritto alla **provvigione** da ambedue le parti, anche quando il contratto sia soggetto a condizione risolutiva, sia annullabile o rescindibile, salvo che non ne conoscesse la causa di invalidità. Non ha diritto alla provvigione se il contratto è nullo.

IL FRANCHISING

L'**affiliazione commerciale (franchising)** è disciplinata dalla l.129/2004 ed è il contratto con cui un imprenditore attribuisce ad un altro imprenditore, verso corrispettivo, la possibilità di utilizzare i suoi marchi e le sue insegne, gli fornisce assistenza tecnica e commerciale e, talvolta, anche i prodotti da mettere in vendita.

L'**affiliato** è autonomo dal punto di vista imprenditoriale, ma è vincolato contrattualmente al rispetto di determinate condizioni e modalità operative.

La legge si preoccupa in particolare di tutelare l'affiliato affinché l'affiliante non abusi della propria posizione di superiorità.

Il fenomeno è molto diffuso nelle reti commerciali dei supermercati, tra i fast food e anche nell'abbigliamento.

La caratteristica più evidente è quella visiva: ad es. l'affiliante impone che i negozi utilizzino determinati colori.

CAPITOLO XXV

I CONTRATTI ALEATORI E LE RENDITE

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La disciplina codicistica del contratto di assicurazione è articolata in una parte generale e in due sezioni: **l'assicurazione contro i danni** (dove è inclusa l'assicurazione per la responsabilità civile) e **l'assicurazione sulla vita**.

Con il **contratto di assicurazione** l'**assicuratore** si obbliga a risarcire l'**assicurato** dei danni sofferti a seguito di un sinistro oppure a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un evento riguardante la vita, mentre l'assicurato deve pagare il premio assicurativo (**art. 1882**).

Si tratta di un **contratto di impresa** perché l'assicuratore deve essere una società per azioni assoggettata al controllo di un'autorità indipendente, l'IVASS.

L'assicurazione è contratto stipulato per iscritto ai fini della prova ed è un **contratto aleatorio**: quindi fa parte di quella categoria di contratti dove la prestazione o la controprestazione non solo possono non essere esattamente determinate ma il loro stesso avverarsi dipende da un fattore d'incertezza. Elemento fondamentale di questi è il **rischio** (l'alea); infatti nel contratto di assicurazione deve sempre esistere il rischio, vale a dire quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto.

La mancanza di rischio prima della conclusione rende nullo il contratto, mentre il suo venir meno nel corso del contratto ne produce lo scioglimento, con diritto dell'assicuratore a ricevere il pagamento dei premi maturati fino a quel momento.

Incidono fortemente sulla disciplina dell'esecuzione del contratto anche:

- **La diminuzione del rischio:** in questo caso l'assicuratore avrà diritto a un premio di ammontare minore
- **Aggravamento del rischio:** In questo caso l'assicuratore può decidere di recedere dal contratto. *es. si pensi all'assicurazione contro il furto di un veicolo contratta dall'assicurato, il quale abbia poi cambiato residenza andando ad abitare in una località dove il verificarsi dei furti è molto più frequente.*

La finalità è quella di tutelare l'assicuratore che potrebbe trovarsi esposto a un rischio superiore rispetto a quello esistente al momento della conclusione del contratto.

L'art. 1900 c.c. afferma che il comportamento **doloso o gravemente colposo** del contraente, dell'assicurato o del beneficiario **libera** l'assicuratore **dall'obbligo di indennizzare** i danni cagionati, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, infatti la copertura può estendersi anche alla colpa grave SOLO se è stato previsto dal contratto.

Il **mancato pagamento del premio** non determina il venir meno del rapporto ma solo la sua **sospensione** che sarà:

- Immediata, nel caso in cui l'assicurato non paga il primo premio
- Dopo quindici giorni dalla scadenza, nel caso in cui l'inadempimento riguardi i premi successivi.

Il contratto si risolve di diritto se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione.

L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Nell'**assicurazione contro i danni** vi deve essere un interesse da parte dell'assicurato ad essere indennizzato del danno subito: l'evento deve incidere negativamente sul suo patrimonio e non di un terzo, altrimenti il contratto è nullo.

L'assicurato non deve ottenere un indennizzo maggiore del danno sofferto perché egli non può stipulare sul danno subito. Il danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto.

Inoltre è previsto che il valore delle cose perite o danneggiate si deve calcolare all'epoca del sinistro, e se l'assicurato ha dolosamente attribuito un valore superiore di quello reale alle cose assicurate, l'assicurazione non è valida.

Salvo che il contratto non preveda diversamente, l'assicuratore non risponde per i danni conseguenti ad eventi eccezionali come terremoti, guerre, ecc...

L'assicuratore che ha indennizzato l'assicurato si surroga nei suoi diritti verso i terzi responsabili, fino a concorrenza di quanto pagato: in questo caso non deve esserci un indebito arricchimento da parte dell'assicuratore.

L'art. 1917 c.c. disciplina l'**assicurazione della responsabilità civile**. L'assicuratore deve indennizzare il terzo per i danni che l'assicurato gli ha procurato.

È coperta la condotta colposa dell'assicurato, ma dei danni derivanti da fatti dolosi, invece, risponde unicamente l'assicurato.

L'assicurazione copre sia la responsabilità derivante da fatto illecito, sia quella contrattuale.

L'assicuratore risponde però nei limiti di un massimale concordato in contratto.

Di norma, l'assicurazione copre i danni verificatisi durante la vigenza del contratto di assicurazione e tale modello è denominato **losses occurring**.

È possibile anche assicurarsi per fatti accaduti prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e la clausola dei contratti di assicurazione che prevede tale possibilità è la c.d. clausola **claims made**. In questo caso la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, quindi consente di coprire quei danni di cui si è venuti a conoscenza nel periodo di vigenza contrattuale, anche se accaduti precedentemente.

Quindi il fatto rilevante ai fini assicurativi non è più il sinistro-danno, ma il fatto-denuncia del sinistro. L'inserimento di una clausola **claims made**, in un contratto di assicurazione, non lo rende atipico.

È evidente che l'assicurazione costituisce una forma di tutela per l'assicurato, ma lo è anche per il danneggiato, quando il danneggiante potrebbe non essere solvibile: a tal fine il legislatore ha ampliato sempre di più l'area delle **assicurazioni obbligatorie**. I casi più noti sono quelli dell'assicurazione della **responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti** e della **responsabilità professionale** (riguardante gli iscritti ad ordini professionali, come per es. medici e avvocati).

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

L'**assicurazione sulla vita** comprende tutte quelle fattispecie nelle quali la prestazione dell'assicuratore è legata alla durata della vita umana.

È consentito stipulare un'assicurazione non solo sulla **propria vita** ma anche **su quella di un terzo**; in tale ultimo caso il **consenso del terzo** è elemento essenziale per la validità del contratto.

L'assicurazione sulla vita può concludersi anche **a favore di un terzo**. L'assicurato può designare il **beneficiario** per iscritto già al momento della conclusione del contratto di assicurazione o con una comunicazione successiva, o ancora per testamento. In questo caso i beneficiari hanno diritto di ottenere la somma assicurata.

La designazione può essere revocata in qualsiasi momento; la revoca della designazione è un **diritto personale** del soggetto contraente che non può essere esercitato né dai suoi eredi, né dai suoi creditori.

La designazione perde efficacia se il beneficiario abbia attentato alla vita dell'assicurato.

L'assicuratore deve conoscere quali sono le condizioni di salute e l'attività svolta dall'assicurato al momento di concludere il contratto. Se tali condizioni si modificano occorre comunicare ciò immediatamente all'assicuratore, il quale valuterà se far cessare o meno gli effetti del contratto.

È delicata la disciplina del **suicidio**: è previsto che l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata se il suicidio interviene quando non siano ancora trascorsi due anni dalla stipula della polizza.

Nel caso dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo si riproduce lo schema del **contratto a favore di terzo**.

LA RIASSICURAZIONE

La **riassicurazione** è il contratto con il quale l'assicuratore assicura presso un'altra impresa in tutto o in parte i rischi che ha assunto. In genere ciò avviene quando si tratta di rischi rilevanti.

Non si tratta di una cessione del contratto, perché l'assicurato è completamente estraneo al rapporto tra l'assicuratore e il riassicuratore.

GIUOCO E SCOMMESSA

Se il **giuoco** e la **scommessa** sono vietate dalla legge, il contratto è nullo e quindi il perdente può ottenere la restituzione di quanto pagato.

Se invece sono leciti, il giocatore (vincitore) non può pretendere il pagamento, ma se esso viene eseguito spontaneamente il perdente non può richiedere la ripetizione perché si tratta di un'**obbligazione naturale**.

È riconosciuta invece l'azione per ottenere il pagamento della vincita a chi abbia scommesso in eventi sportivi o giuocato in lotterie autorizzate.

Se l'organizzatore dei giochi si tutela facendosi pagare in anticipo, secondo la giurisprudenza, si può parlare di **contratti reali**.

LA RENDITA PERPETUA E LA RENDITA VITALIZIA

Il codice civile prevede due tipi di rendita:

- **Rendita perpetua**: una parte si obbliga nei confronti dell'altra e dei suoi eredi di pagare periodicamente una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, come corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale, oppure come onere se l'alienazione o la cessione è gratuita. La rendita si dice **fondiaria** se è costituita mediante l'alienazione di un immobile; **semplice** se mediante cessione di un capitale (in questo caso la rendita deve essere garantita con ipoteca).
Se l'alienazione dell'immobile o la cessione del capitale avviene a titolo oneroso si applicano le regole sulla vendita, se avviene a titolo gratuito sulla donazione.
Il legislatore attribuisce al debitore la facoltà di sciogliersi dal vincolo mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, accompagnata dal pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale (**riscatto**)
- **Rendita vitalizia**: quando l'obbligazione di corrispondere la rendita dura finché dura la vita di una persona designata dalle parti, la quale può essere sia il beneficiario della rendita sia un terzo.

La rendita vitalizia, a differenza di quella perpetua, ha natura **aleatoria**. Nel momento in cui il disponente cede l'immobile o la somma per costituire a favore suo o di un terzo la rendita vitalizia, nessuno può dire se dal contratto sarà avvantaggiato il costituente o il soggetto tenuto al pagamento della rendita, in quanto l'esito dipende dalla durata della vita del beneficiario: se sarà longevo, il soggetto obbligato potrà trovarsi a pagare un importo superiore al valore di quanto ricevuto.

L'**alea** è un requisito essenziale, se manca il contratto è nullo.

La rendita vitalizia può costituirsi, oltre che per contratto, anche per testamento e può costituirsi anche a favore di un terzo: si applicano in questo caso le regole generali relative al contratto a favore del terzo.

La rendita non è risolubile per **inadempimento**: in caso di mancato pagamento delle rate il vitaliziando può far sequestrare e vendere i beni dell'obbligato.

Differisce dalla rendita vitalizia il contratto atipico di **vitalizio alimentare/contratto di mantenimento**, in cui una parte si obbliga, verso l'alienazione di un immobile o altri beni, a dare all'altra per tutta la vita e con riguardo ai suoi bisogni, vitto, alloggio e assistenza.

CAPITOLO XXVI

I CONTRATTI DI

PREVENZIONE E

COMPOSIZIONE DELLE LITI

LA TRANSAZIONE

La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (**art. 1965 c.c.**).

L'elemento caratterizzante è che ciascuno sacrifica parzialmente la propria pretesa verso l'altra, perché se così non fosse, ci si troverebbe di fronte alla rinuncia di una sola parte.

L'espressione "transazione" viene utilizzata nel linguaggio giuridico ed economico anche con altri significati:

- Transazioni commerciali: sono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo
- Transazioni finanziarie: sono le operazioni di compravendita di strumenti finanziari
- Costi di transazione: indicano gli oneri che si devono sostenere per le operazioni di scambio o attività di impresa

La transazione non può riguardare diritti indisponibili (non si può transigere una lite riguardante la paternità di un figlio e deve essere stipulata da chi abbia la **capacità di disporre dei propri diritti** (la transazione di un minore deve essere autorizzata da un giudice tutelare).

È richiesta la forma scritta ai fini della prova in giudizio dell'avvenuta transazione (forma *ad probationem*), mentre è richiesta la forma scritta per la validità del contratto (forma *ad substantiam*) quando la controversia abbia ad oggetto diritti reali su beni immobili.

A seguito della transazione il rapporto preesistente si estingue per **novazione** e quindi, se le prestazioni previste dal contratto di transazione non vengono adempiute, la transazione non può essere risolta per inadempimento al fine di tornare a far valere le pretese originarie, salvo che non sia stato pattuito diversamente.

Se il contratto oggetto della transazione è illecito, è nulla anche la transazione; mentre la transazione relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito è **annullabile** solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità.

Inoltre la transazione è annullabile:

- Se è stata fatta sulla base di documenti che in seguito si sono rivelati falsi
- Se ambedue le parti o anche una sola di esse ignorava che la lite fosse stata decisa da una sentenza passata in giudicato.
- Se si viene a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui la stipulazione è stata conclusa
- Se si prova che una parte era consapevole della **temerarietà della lite** (ossia un'azione legale esperita con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto)

La transazione **non può essere annullata per errore di diritto** relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

È escluso che la transazione possa essere impugnata per **lesione**, in quanto considerando che la transazione prescinde dall'equità della soluzione cui le parti sono giunte con le reciproche concessioni: se fosse possibile rescindere il contratto per lesione verrebbe frustrata la sua stessa finalità.

(Art. 1448. *(Azione generale di rescissione per lesione). Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.*)

LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

La **cessione dei beni ai creditori** è il contratto a forma scritta *ad substantiam* col quale il debitore incarica i creditori o alcuni di essi a vendere tutti o parte dei propri beni per ripartirne il ricavato a soddisfacimento del debito.

Il contratto presenta la struttura del **mandato in rem propriam** perché i creditori incaricati della liquidazione agiscono anche nel proprio interesse.

In tal modo il debitore evita che i creditori possano instaurare procedure esecutive sui suoi beni.

Con la cessione il debitore non può più disporre dei beni e la loro amministrazione è assunta dai creditori cessionari.

Il debitore però ha un potere di controllo sulla gestione e può chiederne il rendiconto.

Trattandosi di una **cessione pro solvendo** il debitore rimane obbligato verso i creditori solo per la parte eccedente da quanto essi hanno ricevuto dalla liquidazione, salvo se non sia stata espressamente liberato.

La liquidazione dei proventi della cessione deve essere ripartita proporzionalmente ai rispettivi crediti tra i creditori e considerando i diritti di prelazione.

Qualora la liquidazione dei beni soddisfi tutti i creditori, il residuo spetta al debitore.

Il debitore se torna in grado di soddisfare completamente i creditori, può recedere dal contratto riacquisendo la piena disponibilità dei beni.

Il principio di buona fede giustifica che il contratto è annullabile se il debitore dichiara di cedere tutti i suoi beni e invece ne ha dissimulato una parte notevole di essi, con l'occultamento o la simulazione di passività.

Diversi sono gli **accordi di ristrutturazione** con i quali un'impresa in gravi difficoltà economiche si accorda con le banche e con gli intermediari finanziari, che ne sono creditori, per ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento.

LA CONVENZIONE D'ARBITRATO:

La **convenzione d'arbitrato** è un accordo con il quale le parti devolvono il giudizio su un'eventuale lite futura o su una lite già sorta a un **arbitro** o a un **collegio arbitrale**, anziché rivolgersi al giudice ordinario.

La convenzione d'arbitrato può assumere la forma di un vero e proprio contratto (**compromesso**) o può essere inserita come clausola di un contratto più ampio affinché siano devoluti agli arbitri le liti che possono insorgere con l'esecuzione di tale contratto (**clausola compromissoria**).

Il procedimento arbitrale termina con un **lodo arbitrale**, che ha valore di una sentenza di primo grado impugnabile solo in determinati casi stabiliti dalla legge.

Limiti all'esercizio del potere giurisdizionale:

- Obbligo della forma scritta per la convenzione arbitrale
- Obbligo di specificare nella convenzione le modalità di nomina degli arbitri e il loro numero (sempre dispari e con capacità d'agire)
- Disponibilità dei diritti della controversia

L'arbitrato si distingue in:

- **Arbitrato rituale:** gli effetti sono gli stessi di quelli della sentenza dell'autorità giudiziaria ed è quindi considerato idoneo sia al giudicato formale sia a quello sostanziale
- **Arbitrato irrituale:** gli effetti sono negoziali

Diverso dall'arbitrato è l'**arbitraggio**, ossia un procedimento volto non a comporre una lite, ma a determinare uno degli elementi essenziali o accidentali del contratto.

L'arbitratore in questo caso non è completamente libero ma le parti possono impugnare innanzi al giudice la determinazione se manifestamente iniqua o erronea.

Dall'arbitrato si distingue anche la **perizia contrattuale**, è quel patto per il quale le parti si rivolgono ad un terzo, scelto in ragione di una sua particolare competenza tecnica, affinché accerti una determinata situazione in fatto.